

جامعة الأزهر الشريف
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه

مقرر الفقه الحنفي

للسنة الثالثة بكليات الشريعة والقانون
والشعب المناظرة

للعام الجامعي 2026/25

إعداد

لجنة من أساتذة كلية الشريعة والقانون

أولاً: الدراسة النصية

من كتاب الهداية شرح بداية المبتدي
المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل
الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان
الدين (المتوفى: 593هـ)

إعداد

د/ أحمد عبد الدايم عبد السلام مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	أ.د/ كمال محمد عواد أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
راجع	
أ.د/ محمد عبدالستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ زكية محمد عبد الرحيم حواس أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

مقدمة

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْبِدَايَةِ وَالْهُدَايَةِ، وَرَعَانَا بِعَيْنِ الْعِنَايَةِ فِي
النَّهَائَةِ عَنِ الْجَهْلِ وَالْغَوَايَةِ، وَجَعَلَنَا مِمَّنْ آمَنَ بِمَا أُنْزِلَ وَاتَّبَعَ
الرُّسُلَ وَوَفَّقَ لِلدِّرَايَةِ، وَخَصَّنَا بِأَهْلِيَّةِ الْأَزْهَرِ، وَرَدَّنَا إِلَى الدَّرِ
المُخْتَارِ، وَبَسَطَ لَنَا مِنَ الْبِدَائِعِ وَالصَّنَائِعِ لِنَحْقُقَ مَرَادَ اللَّهِ فِيْنَا
مِنْ خِلَالِ قَوْلِ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ
بِهِ خَيْرًا، يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ»

وبعد ،،

فهذا كتاب في الفقه الحنفي مقرر على طلاب كليات الشريعة
والقانون والكليات المناظرة لها، يجمع بين الدراسة النصية،
والموضوعية.

راعينا فيه سهولة العبارة من خلال توضيح بعض المصطلحات
الغامضة التي ربما تصعب على الطالب، مع وضع لبعض
نماذج الأسئلة التي قد يُستعان بها لقياس مستوى الطالب في
الفقه الحنفي.

وتشمل الدراسة النصية أبواب: أدب القاضي، والدعوى،
والصلح، والجنايات.

وأما الدراسة الموضوعية: فتشمل أبواب: الشهادات، والإقرار،
والرهن، والإكراه، والحجر.

سائلين الله عزو جل الفقه في الدين، وأن ينفع به الطلاب العلم.
والحمد لله رب العالمين

كِتَابُ (1) أَدَبِ (2) الْقَاضِي (3)

(1) الْكِتَابُ لُغَةً: مُصَدَّرٌ سَمِيَ بِهِ الْمَكْتُوبُ، كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ، يُقَالُ: كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وَكِتَابَةً. وَالْكِتَابُ لُغَةً: مَا يَكْتُبُ فِيهِ. وَالذَّوَاءُ يَكْتُبُ مِنْهَا. وَالضَّمُّ، وَالْجَمْعُ، يُقَالُ: كَتَبَ الْكِتَابَ: إِذَا جَمَعَ حُرُوفَهُ. (جَمَهْرَةُ اللَّغَةِ، 1/255؛ النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ، 4/247؛ الْمُطْلَعُ عَلَى أَلْفَاظِ الْمُقْنَعِ، ص: 14)

وَاصْطِلَاحًا: طَائِفَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ اعْتَبِرَتْ مُسْتَقَلَّةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُسْتَقَلَّةً فِي نَفْسِهَا، كَكِتَابِ اللَّقْطَةِ، أَمْ تَابِعَةً لِمَا بَعْدَهَا، كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، أَوْ مُسْتَتَبَعَةً لِمَا قَبْلَهَا، كَكِتَابِ الصَّلَاةِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهَرِ، 8/9).

(2) الْمُرَادُ بِالْأَدَبِ فِي قَوْلِ الْفُقَهَاءِ: أَدَبُ الْقَاضِي مَعْنَاهُ: التَّزَامُهُ لِمَا نَدَبَ إِلَيْهِ الشَّرْعُ مِنْ بَسْطِ الْعَدْلِ، وَدَفْعِ الظُّلْمِ، وَتَرْكِ الْمِيلِ، وَالْمَحَافَظَةِ عَلَى حُدُودِ الشَّرْعِ، وَالْجَرِيِّ عَلَى سُنَنِ السُّنَّةِ. (الِاخْتِيَارُ لِتَعْلِيلِ الْمُخْتَارِ، 2/82؛ التَّعْرِيفَاتُ الْفَقْهِيَّةُ، ص: 21).

(3) أَيْ هَذَا كِتَابٌ فِي بَيَانِ أَدَبِ الْقَاضِي، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خِلَالِ، أَوْ يَتَنَزَّهُ عَنْهُ. (الْبَيَانَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 9/3). وَالْقَاضِي لُغَةً: الْقَاطِعُ لِلْأُمُورِ، الْمَحْكَمُ لَهَا؛ وَالْجَمْعُ: قَضَاةٌ. (لِسَانُ الْعَرَبِ، 15/186؛ الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، 2/743).

وَاصْطِلَاحًا: مَنْ نَصَّبَهُ وَلِي الْأَمْرِ؛ لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ بَيْنَ النَّاسِ. (مَعْجَمُ لُغَةِ الْفُقَهَاءِ، ص: 354).

وَالْقَضَاءُ لُغَةً: الْحُكْمُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ". أَيْ حُكْمَ. وَالْخَلْقِ، وَالصَّنْعِ، وَالتَّقْدِيرِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ". أَيْ فَخَلَقَهُنَّ، وَعَمَلَهُنَّ، وَصَنَعَهُنَّ. وَالْحَتْمُ (لِسَانُ الْعَرَبِ، 15/186، 187).

= واصطلاحاً: فصل الخصومات، وقطع المنازعات، على وجه خاص.
(رد المحتار على الدر المختار، 5/352).

حكم القضاء: القضاء مشروع دل على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول: أما: الكتاب: فقول الله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق". وجه الدلالة: بين الله تعالى أنه جعل داود عليه السلام، إماماً، وخليفة؛ ليقضي بين الناس بالعدل؛ وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يدل على خلافه؛ فدلّت الآية الكريمة على مشروعية القضاء. وقوله تعالى: (وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ). وقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله).

وأما السنة: فمن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر". (صحيح البخاري، 9/108، حديث رقم: 7352). وجه الدلالة: في الحديث الترغيب في ولاية القضاء، لمن استجمع شروطه، وقوي على أعمال الحق، ووجد له أعواناً؛ لما فيه من الأمر بالمعروف، ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه، وكف يد الظالم، والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات، ولذلك؛ تولاه الأنبياء، ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، 13/121).

وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء، والحكم بين الناس من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. (فتح القدير، 7/252) وأما المعقول: فإن فيه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإظهار الحق، وإنصاف المظلوم من الظالم، وإيصال الحق إلى مستحقه، ودفع التهاجر، وقطع المنازعات، وفصل الخصومات؛

(شُرُوطُ تَوَلَّى الْقَضَاءِ⁽¹⁾)

قَالَ⁽²⁾: (وَلَا تَصِحُّ وَلَايَةُ الْقَاضِي حَتَّى يَجْتَمَعَ فِي الْمَوْلَى⁽³⁾ شُرَاطُ الشَّهَادَةِ⁽⁴⁾، وَيَكُونُ⁽⁵⁾ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِدِ⁽⁶⁾) أَمَّا الْأَوَّلُ⁽⁷⁾: فَلَأَنَّ حُكْمَ الْقَضَاءِ يُسْتَقَى⁽⁸⁾ مِنْ حُكْمِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ

وَلَأَجْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّرَائِعَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ. (الْاِخْتِيَارُ، 82/2؛ الْبَنَاءُ، 4/9).

(1) سواء أكانت هذه الشروط شروط صحة، أم شروط كمال، واستحباب.

(2) أي الإمام القدوري في مختصره. (البنية شرح الهداية، 4/9).

(3) الْمَوْلَى بفتح اللام: اسم مفعول من التولية، وعبر الإمام القدوري (المولى) بلفظ اسم المفعول، ولم يقل (المتولي) بلفظ اسم الفاعل؛ إشارة إلي أنَّ القاضي ينبغي أن يكون قاضياً بتولية غيره، لا بطلبه التولية، وهو الأولي للقاضي (العناية 252/7).

(4) أي شرائط أداء الشهادة: وهي: الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والبصر، والنطق، وكونه غير محدود في قذف، ولا أصم، وأما الأطرش: وهو الذي يسمع القوي من الأصوات، فالأصح، جواز توليته. وعليه: فلا يجوز تقليد ضدهم.

(5) أي المولى بالنصب؛ عطفاً على قوله "حتى يجتمع".

(6) الاجتهاد لغة: بذل الوسع، والمجهود في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد أي هو الطاقة. (مختار الصحاح، ص: 63). واصطلاحاً: بذل الطاقة من الفقيه، في تحصيل حكم، شرعي، ظني. (التقرير والتحبير، 3/291؛ تيسير التحرير، 4/179).

(7) وهو أنه لا بد أن يكون المولى من أهل الشهادة.

(8) أي يستفاد، ويؤخذ، ويستخرج من حكم الشهادة؛ لأن مبنى القضاء

وَأَحَدُ مَنِهْمَا (1) مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ (2) فَكُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلًا
لِلشَّهَادَةِ (3)، يَكُونُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ، وَمَا يُشْتَرَطُ لِأَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ،
يُشْتَرَطُ لِأَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ (4)

(تَوَلِيَّةُ الْفَاسِقِ الْقَضَاءِ)

وَالْفَاسِقُ (5) أَهْلٌ لِلْقَضَاءِ (1) حَتَّى لَوْ قُلِّدَ، يَصِحُّ (2)، إِلَّا أَنَّهُ لَا
يَنْبَغِي (3) أَنْ يُقْلَدَ (4)، كَمَا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ
الْقَاضِي شَهَادَتَهُ، وَلَوْ قَبِلَ (5) جَازَ عِنْدَنَا (6).

على الشهادة. (العناية، 252/7؛ البناية شرح الهداية، 5/9).

(1) أي من القضاء والشهادة. (العناية شرح الهداية، 252/7).

(2) إذ كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى. لأن كل واحد
منهما إلزام: فالشهادة ملزمة على القاضي أن يحكم بها، بعد استيفاء
شرائطها، وتزكية الشهود. والقاضي بحكمه يلزم الخصم. (تبين الحقائق،
175/4، العناية شرح الهداية، 25/7).

(3) تحملاً، وأداء.

(4) بل اشتراطها في القضاء أولى؛ لأن ولاية القضاء أعم، وأكمل من
ولاية الشهادة، فلما اشترط في الشهادة من الصفات، كان اشتراطها في
القضاء أولى. (العناية، 253/7؛ البناية، 6/9).

(5) الفاسق لغة: اسم فاعل من فسق، فسقا، وفسق: العصيان،
والترك لأمر الله - عز وجل - والخروج عن طريق الحق. (اللسان
العرب، 308/10). واصطلاحاً: من فعل كبيرة، أو أصر على صغيرة.
(البحر الرائق، 92/7).

(طُرُوءُ الْفَسْقِ عَلَى وَلَايَةِ الْقَاضِي)

وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا فَفَسَقَ (7) بِأَخْذِ الرِّشْوَةِ (8)، أَوْ غَيْرِهِ (1)، لَمَا يَنْعَزِلُ (2)، وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ (3). وَهَذَا (4) هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ

(1) أي: لتولية القضاء؛ لأهليته للشهادة، وهذا يدل على أن شرط عدالة القاضي، إنما هو شرط أولوية، وكمال، لا شرط جواز، وصحة. (بدائع الصنائع، 3/7 العناية شرح الهداية، 254/7).

(2) أي تقليده، وتوليته. (البنية شرح الهداية، 6/9).

(3) أي: لا يليق. ولفظ لا ينبغي: يستعمل في خلاف الأولى، والمكروه تنزيها.

(4) لَأَنَّهُ لَا يُؤْتَمَنُ فِي أَمْرِ الدِّينِ؛ لِقَلَّةِ مَبَالَاتِهِ فِيهِ. وَلأنَّهُ لِفَسْقِهِ يَسْتَحِقُّ الْإِهَانَةَ، لَا التَّعْظِيمَ بِتَوَلِيهِ الْقَضَاءَ.

(5) أي لو قبل القاضي شهادته مع فسقه. هَذَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صَدَقَهُ، أَمَا إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّ الْقَاضِي صَدَقَهُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ. (درر الحكام 404/2).

(6) بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الْعَدَالَهَ لَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَةِ الشَّهَادَةِ؛ نَظَرًا إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْعَصْرِ الَّذِي شَهِدَ لَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخَيْرِ، وَإِلَى ظَاهِرِ حَالِ الْمُسْلِمِ فِي غَيْرِهِمْ. (العناية، 254/7).

(7) وَجَارٍ. (فتح القدير، 254/7).

(8) الرِّشْوَةُ لُغَةً: بِكَسْرِ الرَّاءِ، وَضَمِّهَا، وَفَتْحُهَا: الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالصَّنَاعَةِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ أَيِ الْحَبْلِ الَّذِي يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ (لسان العرب، 14/322؛ تاج العروس، 38/153).

وَاصْطِلَاحًا: مَا يُعْطَى؛ لِإِبْطَالِ حَقِّ، أَوْ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ. (التعريفات، ص: 111). وَقَدْ خَصَّ الْمَصْنِفُ الرِّشْوَةَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهَا مُعْظَمُ مَا يَفْسُقُ بِهِ

وَعَلَيْهِ مَشَايخُنَا⁽⁵⁾ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:
الْفَاسِقُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ⁽⁶⁾ عِنْدَهُ⁽⁷⁾. وَعَنْ
عَلَمَانَا الثَّلَاثَةِ⁽⁸⁾ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
قَضَاؤُهُ⁽⁹⁾. وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخِ⁽¹⁰⁾ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إِذَا قُلِدَ الْفَاسِقُ

الْفَاضِي، وَإِلَّا فَالْفَسَقُ قَدْ يَكُونُ بَغِيرَهَا، كَشَرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِهِ. (النهر
الفائق، 3/597؛ رد المحتار على الدر المختار، 5/363).

⁽¹⁾ مِنْ أَسْبَابِ الْفُسْقِ، كَالزَّانَا، وَشَرْبِ الْخَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ
الْمَعَاصِي (العناية 7/254).

⁽²⁾ أَيْ بَطَرُوهُ الْفُسْقَ، إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ الْعَزْلَ عِنْدَ التَّقْلِيدِ بِتَعَاظِي
الْمَحْرَمِ (العناية 7/254).

⁽³⁾ أَيْ وَجِبَ عَلَى السُّلْطَانِ عَزْلُهُ؛ لَوْجُودِ سَبَبِ اسْتِحْقَاقِ الْعَزْلِ، وَهُوَ
الْفُسْقُ الطَّارِئُ. (فتح القدير، 7/254؛ درر الحَكَامِ شرح غرر
الأحكام، 2/404).

⁽⁴⁾ قَوْلُهُ: (وَهَذَا) إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعَزْلِ، دُونَ الْعَزْلِ، أَوْ غَيْرِهِ.
(العناية 7/254).

⁽⁵⁾ أَيْ عُلَمَاءُ الْحَنْفِيَّةِ بِبُخَارَى، وَبِسْمَرْقَنْدَ. (البنية شرح الهداية، 9/7).
⁽⁶⁾ بِنَاءٍ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَإِنَّ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيمَانِ عِنْدَهُ،
فَإِذَا فَسَقَ فَقَدْ انْتَقَصَ إِيْمَانُهُ. (العناية شرح الهداية، 7/255).

⁽⁷⁾ أَيْ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. (البيان، 13/20).
⁽⁸⁾ وَهُمْ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. (البنية، 9/7).

⁽⁹⁾ أَيْ قِضَاءُ الْفَاسِقِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ جَمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

⁽¹⁰⁾ كَالْكَرْخِيِّ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَعَلِيِّ الرَّازِيِّ صَاحِبِ أَبِي يُوسُفَ. (العناية
شرح الهداية، 7/254؛ حاشية الشرنبلالي، 2/404).

ابْتَدَاءً يَصِحُّ، وَلَوْ قَدْ وَهُوَ عَدْلٌ، يَنْعَزِلُ بِالْفَسْقِ؛ لِأَنَّ الْمُقْلَدَ اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ، فَلَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِتَقْلِيدِهِ دُونَهَا⁽¹⁾.

(اسْتِفْتَاءُ الْفَاسِقِ)

وَهَلْ يَصْلَحُ الْفَاسِقُ مُفْتِيًا؟ قِيلَ: لَا⁽²⁾؛ لِأَنَّهُ⁽³⁾ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ⁽⁴⁾، وَخَبْرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي الدِّيَانَاتِ⁽⁵⁾ وَقِيلَ: يَصْلَحُ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ⁽⁷⁾ يَجْتَهِدُ كُلَّ الْجَهْدِ فِي إِصَابَةِ الْحَقِّ؛ حَذَارِ النَّسْبَةِ إِلَى الْخَطَا⁽⁸⁾

(أَهْلِيَّةُ الْقَاضِي لِلْاجْتِهَادِ)

وَأَمَّا الثَّانِي⁽⁹⁾: فَالصَّحِيحُ⁽¹⁾ أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْجَاهِلِ، شَرْطُ الْأُولَوِيَّةِ⁽²⁾. الْأُولَوِيَّةِ⁽²⁾. فَمَّا تَقْلِيدُ الْجَاهِلِ⁽³⁾، فَصَحِيحٌ عِنْدَنَا⁽⁴⁾،

(1) يعني أَنَّ عَدَالَتَهُ فِي مَعْنَى الْمَشْرُوعَةِ فِي وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ وِلَاةٍ عَدْلًا، اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ، فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مَقْبُولَةً، وَمَشْرُوعَةٌ بِبَقَاءِ عَدَالَتِهِ، فَتَزُولُ بِزَوَالِهَا، وَالْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَنْتَقِي بِانْتِقَائِهِ. (العناية، 256/7).

(2) أَي لَا يَصْلَحُ لِلْإِفْتَاءِ، وَلَا يَعْتَمَدُ عَلَى فَتَوَاهِ. (البنية، 7/9).

(3) أَي لِأَنَّ الْإِفْتَاءَ. (البنية شرح الهداية، 7/9).

(4) وَقَدْ ظَهَرَتْ خِيَانَتُهُ لِلدِّينِ. (فتح القدير، 255/7، 256).

(5) وَإِنْ قَبِلَ فِي الْمَعَامَلَاتِ. (النهر الفائق، 3/599).

(6) أَي يَعْتَمَدُ عَلَى فَتَوَاهِ، وَيَحِلُّ اسْتِفْتَاؤُهُ. (رد المحتار، 359/5).

(7) أَي لِأَنَّ الْمُفْتِيَّ الْفَاسِقَ. (البنية شرح الهداية، 7/9).

(8) لِأَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَخْطِئَهُ الْفَقْهَاءُ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَيَجِيبُ بِهِ.

(9) أَي الشَّرْطُ الثَّانِي، وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَهْلِيَّةِ الْاجْتِهَادِ فِي الْمُؤَلَّى، أَوْ

الْقَاضِي. (العناية شرح الهداية، 256/7؛ البنية شرح الهداية، 8/9؛)

خَلَفًا لِلشَّافِعِيِّ (5) - رَحِمَهُ اللَّهُ. وَهُوَ (6) يَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ
بِالْقَضَاءِ، يَسْتَدْعِي الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ (7)، وَلَا قُدْرَةَ دُونَ الْعِلْمِ (1). وَلَنَّا:

(1) لَفْظُ الْقُدُورِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةِ وَجُوزِ التَّوْلِيَةِ؛ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي
الْأَصْلِ: أَنَّ الْمُقْلَدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا. لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ أَهْلِيَّةَ
الاجْتِهَادِ شَرْطُ الْأَوَّلِيَّةِ. (العناية، 256/7؛)

وَالاجْتِهَادُ شَرْطُ أَوَّلِيَّةٍ، وَاسْتِحْبَابٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطُ صِحَّةٍ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ
أَقْدَرُ عَلَى الْحُكْمِ بِالْحَقِّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ مُتَعَذِّرُ الْوُجُودِ فِي كُلِّ زَمَنٍ،
وَبَلَدٍ، فَكَانَ شَرْطُ الْأَوَّلِيَّةِ، فَإِذَا وَجَدَ، فَهُوَ الْأَوَّلَى بِالتَّوْلِيَةِ مِنْ غَيْرِهِ.
(تَبْيِينَ الْحَقَائِقِ، 176/4؛ النَّهْرُ الْفَائِقُ، 601/3).

(3) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالْجَاهِلِ: الْمُقْلَدُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي مُقَابَلَةِ
الْمُجْتَهِدِ، وَسَمَّاهُ جَاهِلًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ
بِهِ: مَنْ لَا يَحْفَظُ شَيْئًا مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ. أَوْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى اخْتِ
الْمَسَائِلِ مِنْ كُتُبِ الْفَقْهِ، وَضَبِطِ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ؛ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِسَبَاقِ
الْكَلَامِ؛ لِقَوْلِهِ فِي دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ: (وَلَا قُدْرَةَ دُونَ الْعِلْمِ)، وَلَمْ يَقُلْ بِدُونَ
الاجْتِهَادِ؛ وَالْأَوَّلُ هِيَ الظَّاهِرُ. (العناية، 257/7).

(4) وَيُحْكَمُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ، لِذَا؛ قَالَ الْخِصَّافُ: الْقَاضِيُ يَقْضِي بِاجْتِهَادِهِ
نَفْسَهُ، إِذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ، وَسَأَلَ فُقِيهًا، أَخَذَ بِقَوْلِهِ.
(الْعَنَاءُ، 256/7، 257؛ فَتَحُ الْقَدِيرِ، 256/7).

(5) وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْإِمَامَانِ: مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَقَوْلُهُمْ رَوَايَةٌ عَنْ عِلْمَانِنَا فِي
النُّوَادِرِ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 8/9؛ فَتَحُ الْقَدِيرِ، 256/7).

(6) أَيِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 8/9).

(7) أَيِ عَلَى الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ، وَلَا أَمْرٌ بِلَا قُدْرَةٍ، وَلَا
قُدْرَةَ بِلَا عِلْمٍ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلَ يَخْطُبُ خِطْبَ الْعَشْوِ، وَلَا يُمِيزُ بَيْنَ الْحَقِّ
وَالْبَاطِلِ. (الْبَنَاءُ، 8/9).

أَنَّهُ (2) يُمَكِّنُهُ أَنْ يَقْضِيَ بِفَتْوَى غَيْرِهِ، وَمَقْصُودُ الْقَضَاءِ يَحْصُلُ بِهِ (3)، وَهُوَ إِيصَالُ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحَقِّهِ (4).

(عدم تولية المقلد، عند وجود المجتهد، العدل)

وَيَنْبَغِي (5) لِلْمُقَلِّدِ (6) أَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ الْأَقْدَرُ (1)، وَالْأَوْلَى (2)؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ قَلَدَ إِنْسَانًا عَمَلًا، وَفِي رِعْيَتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَرَسُولَهُ، وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ" (3).

(1) وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ: لَيْسَ مَا يَقْطَعُ بِصَوَابِهِ، بَلْ مَا يَظُنُّهُ الْمَجْتَهِدُ؛ فَإِنَّهُ لَا قِطْعَ فِي مَسَائِلِ الْفَقْهِ. (فتح القدير، 256/7).

(2) أَيِ الْمُقَلِّدِ، أَوْ الْجَاهِلِ. (البنية شرح الهداية، 8/9).

(3) أَيِ بِالْقَضَاءِ بِفَتْوَى غَيْرِهِ.

(4) وَذَلِكَ كَمَا يَحْصُلُ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، يَحْصُلُ مِنَ الْمُقَلِّدِ إِذَا قَضَى بِفَتْوَى غَيْرِهِ. (العناية شرح الهداية، 257/7).

(5) لَفْظُ (يَنْبَغِي): يَسْتَعْمَلُ عِنْدَ مَتَأَخَّرِي الْحَنْفِيَّةِ غَالِبًا فِي الْمُنْدُوبَاتِ، وَعِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ يَسْتَعْمَلُ فِيمَا يَعْمُ الْوَاجِبُ، وَالْمُنْدُوبُ، فَمَعْنَاهُ فِي الْغَالِبِ النَّدْبُ، وَقَدْ يَقْصَدُ بِهِ الْوَجُوبُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: الْوَجُوبُ، أَيِ يَجِبُ عَلَى الْمُقَلِّدِ أَنْ يَخْتَارَ الْأَوْلَى وَالْأَقْدَرُ؛ لِئَلَّا يَكُونَ خَائِنًا لِلَّهِ، وَرَسُولِهِ، وَعَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. (المذهب الحنفي، مراحل وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته، 379/1).

(6) الْمُقَلِّدُ، بِكسر الِلام: هُوَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْلِيدِ. وَالَّذِي لَهُ وِلَايَةُ التَّقْلِيدِ: الْخَلِيفَةُ، وَالسُّلْطَانُ الَّذِي نَصَّبَهُ الْخَلِيفَةُ وَأَطْلَقَ لَهُ التَّصْرِيفَ، وَكَذَا الَّذِي وَلَّاهُ السُّلْطَانُ نَاحِيَةً، وَجَعَلَ لَهُ خَرَاجَهَا، وَأَطْلَقَ لَهُ التَّصْرِيفَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُولِّيَ، وَيَعْزِلَ. (البنية، 8/9).

(حَقِيقَةُ الْجَاهِدِ إِجْمَالًا)

وَفِي حَدِّ (4) الْجَاهِدِ كَلَامٌ عَرِفَ فِي أُصُولِ الْفَقْهِ (5).
وَحَاصِلُهُ (6): أَنْ يَكُونَ (7) صَاحِبَ حَدِيثٍ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفَقْهِ؛
لِيَعْرِفَ مَعَانِيَ الْأَثَارِ (8). أَوْ صَاحِبَ فِقْهِ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ (9)؛

(1) على القضاء. (البنية شرح الهداية، 8/9).

(2) لعلمه، ودينه، وأمانته، وعفته، وقوته، دون غيره؛ لأنه خليفة رسول الله ﷺ في القضاء. ورزقه من بيت المال.. (البنية شرح الهداية، 8/9؛ فتح القدير، 258/7).

(3) رواه الحاكم في المستدرک، بلفظ قريب منه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، 104/4، حديث رقم: 7023. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". وعليه: فلا يقبل المقلد، عند وجود المجتهد العدل. وإنما يكون المقلد آثماً، إذا وثق من يعلم أن غيره أولى منه (العناية شرح الهداية، 259/7).

(4) الحد: هو قول دال على ماهية الشيء. أو حقيقته. أو ما يميز الشيء عما عداه. والمراد بقوله: وحد الاجتهاد: حقيقة الاجتهاد، وماهيته. (التعريفات، ص: 83؛ التوقيف، ص: 137؛).

(5) إشارة إلى معنى الاجتهاد إجمالاً؛ فإن بيانه تفصيلاً موضعه أصول الفقه. (العناية شرح الهداية، 259/7).

(6) أي حاصل ما قيل في حد الاجتهاد. (البنية شرح الهداية، 9/9).

(7) أي الذي يدعي الاجتهاد. (البنية شرح الهداية، 9/9).

(8) والمراد بمعاني الآثار: المعاني التي هي مناطة الأحكام، الدالة عليها ألفاظ الحديث؛ ليتمكن من القياس. (فتح القدير، 259/7).

(9) والفرق بين القولين: أن على الأول، نسبته إلى معرفة الحديث أكثر

لَنَلَّا يَشْتَعَلْ بِالْقِيَاسِ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ⁽¹⁾. وَقِيلَ: أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ⁽²⁾ صَاحِبَ قَرِيحَةٍ⁽³⁾، يَعْرِفُ بِهَا عَادَاتِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا⁽⁴⁾.

(حُكْمُ الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ)

قَالَ: (وَلَا بَأْسَ⁽⁵⁾ بِالْدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ، لَمَنْ يَثِقُ بِنَفْسِهِ⁽⁶⁾ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرَضَهُ⁽¹⁾)؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالْفَقْهِ، وَفِي الثَّانِي، عَكْسُهُ. (فتح القدير، 259/7).
⁽¹⁾ أَي لِيَتَحَرَّزَ، وَلِيَمْتَنِعَ عَنِ الْقِيَاسِ، فِي مَعَارِضَةِ النَّصِّ. (فتح القدير، 259/7).

⁽²⁾ أَي مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ. (العناية شرح الهداية، 259/7).
⁽³⁾ أَي طَبِيعَةً جَيِّدَةً، خَالِصَةً مِنَ الشُّكُوكَاتِ الْمَكْدِرَةِ، يَنْتَقِلُ مِنَ الْمَطَالِبِ إِلَى الْمُبَادِئِ، وَمِنْهَا إِلَى الْمَطَالِبِ بِسُرْعَةٍ. (العناية شرح الهداية، 259/7).

⁽⁴⁾ أَي عَلَى الْعَادَاتِ مَخَالِفًا لِلْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْعَرَفَ قَدْ يَغْلِبُ عَلَى الْقِيَاسِ، كَمَا فِي عَقْدِ الْإِسْتِصْنَاعِ؛ فَإِنَّهُ جُوزَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ. فَمِنْ أَتَقَنَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، فَهُوَ أَهْلٌ لِلْاجْتِهَادِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِاجْتِهَادِهِ، وَلَا يَقْلِدَ أَحَدًا. (العناية، 259/7؛ البناية، 9/9).

⁽⁵⁾ عِبَارَةٌ لَا بِأَسْ: أَكْثَرَ إِسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ فِي الْمُبَاحِ، وَمَا تَرَكَهَ أَوَّلَى. وَقَدْ تَسْتَعْمَلُ فِي الْمُنْدُوبِ أَيْضًا. (فتح القدير، 260/7؛ رد المحتار على الدر المختار، 119/1).

⁽⁶⁾ أَي يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إِذَا تَوَلَّاهُ، قَامَ بِفَرْضِهِ. (العناية شرح الهداية، 260/7).

– تَقْلُدُوهُ⁽²⁾، وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةٌ⁽³⁾. وَلِأَنَّهُ⁽⁴⁾ فَرَضَ كَفَايَةً؛ لَكُونَهُ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ⁽⁵⁾. قَالَ: (وَيُكْرَهُ⁽⁶⁾ الدُّخُولُ فِيهِ⁽¹⁾)، لِمَنْ يَخَافُ

(1) أي فرض القضاء، وهو الحق؛ لأنَّ القضاء بالحق فرض، أمر به الأنبياء؛ قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾. [سورة ص، جزء من الآية: 26]. وَقَالَ لَنَبِيْنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾. [النساء، جزء من الآية: 105]. فَمَنْ وَثِقَ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ يُوَدِّي هَذَا الْفَرَضَ، فَلَا بَأْسَ بِالدُّخُولِ فِيهِ. (العناية، 260/7، البناية شرح الهداية، 10/9).
(2) أي القضاء. أَمَّا إِنْ الصَّحَابَةُ تَقْلُدُوا الْقَضَاءَ، فَحَدِيثٌ مُعَاذٍ مَعْرُوفٍ، وَكَذَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ رَوَى الْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْسِلَنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ". قَالَ: "فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا، أَوْ مَا شَكَّكَتُ فِي قَضَاءِ بَعْدٍ". (أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، 145/3، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 4658، وَقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يَخْرُجَاهُ").

(3) أي كفى بالصحابة أسوة. (البناية شرح الهداية، 10/9).

(4) أي ولأن القضاء. (البناية شرح الهداية، 10/9).

(5) ونهيا عن المنكر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فرض كفاية. (العناية شرح الهداية، 260/7؛ البناية شرح الهداية، 10/9).

(6) والمراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم؛ لأنَّ الغالب الوقوع في محظوره حينئذ. ومحل الكراهة ما إذا لم يتعين عليه، فإن تعين، صار فرض عين

الْعَجْزَ عَنْهُ⁽²⁾، وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفُ⁽³⁾ فِيهِ⁽⁴⁾؛ كَيْ لَا يَصِيرَ⁽⁵⁾ شَرْطًا⁽⁶⁾ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَبِيحِ⁽⁷⁾. وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ⁽⁸⁾ الدُّخُولَ

عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ ضَبْطُ نَفْسِهِ. (فتح القدير، 260/7؛ البحر الرائق، 294/6؛ رد المحتار على الدر المختار، 367/5).

(1) أي في القضاء. (البنية شرح الهداية، 10/9).

(2) أي عن القيام به على الوجه المشروع. (اللباب، 78/4).

(3) أي الظلم، والجور. (العناية شرح الهداية، 261/7؛ اللباب، 78/4).

(4) هَذَا إِذَا خَافَ الْحَيْفَ، أَوْ الْعَجْزَ، أَمَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَجُورُ فِي الْحُكْمِ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ، عَنْ بَرِيدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ. فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فِرْجَلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ". (أخرجه أبو داود في سننه، 299/3، حديث رقم: 3573؛ والحاكم في المستدرك، 101/4، حديث رقم: 7012، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَخْرُجْهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ". (البحر الرائق، 294/6؛ رد المحتار على الدر المختار، 367/5).

(5) أي كي لا يصير الدخول في القضاء. (البنية شرح الهداية، 10/9).

(6) عَبَّرَ بِلَفْظِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ مِنَ الْحَيْفِ، إِثْمًا هُوَ بِالْمِيلِ إِلَى حِطَامِ الدُّنْيَا، بِأَخْذِ الرِّشَاءِ، وَفِي الْغَالِبِ يَكُونُ مُشْرُوطًا بِمَقْدَارٍ مُعَيَّنٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: لِي عَلَى فُلَانٍ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ مُطَالَبَةٌ بِكَذَا، فَإِنْ قَضَيْتَ لِي، فَلَكَ كَذَا. (العناية، 261/7؛ البنية، 10/9).

(7) وَهُوَ الْحَيْفُ فِي الْقَضَاءِ. (العناية، 261/7؛ البنية، 10/9).

(8) كَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِي. (الاختيار لتعليق المختار، 84/2).

فِيهِ مُخْتَارًا⁽¹⁾؛ لَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ"⁽²⁾. وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الدُّخُولَ فِيهِ⁽³⁾ رُخْصَةً⁽⁴⁾؛ طَمَعًا فِي إِقَامَةِ الْعَدْلِ⁽¹⁾. وَالتَّرْكُ عَزِيمَةٌ⁽²⁾؛

(1) كَرِهَ بَعْضُ السَّلَفِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - كَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِي الدُّخُولَ، فِي الْقَضَاءِ مُخْتَارًا، سِوَاءٍ وَثِقُوا بِأَنْفُسِهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِحَقِّهِ، أَوْ خَافُوا عَلَيْهَا، وَفُسِّرَ الْكَرَاهَةُ هَاهُنَا بَعْدَ الْجَوَازِ؛ فَقَالَ الصِّدْرُ الشَّهِيدُ فِي أَدَبِ الْقَاضِي: وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ فِيهِ إِلَّا مَكْرَهَا؛ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَعَى إِلَى الْقَضَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَبَى، حَتَّى = ضَرَبَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثَلَاثِينَ سَوْطًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ قَالَ: حَتَّى أَسْتَشِيرَ أَصْحَابِي، فَاسْتَشَارَ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَوْ تَقَلَّدْتَ لِنَفْعَتِ النَّاسِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ نَظْرَ الْمَغْضَبِ وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبِرَ الْبَحْرَ سَبَاحَةً، أَكُنْتُ أَقْدِرُ عَلَيْهِ؟ وَكَأَنِّي بِكَ قَاضِيًا. وَكَذَا دَعَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِلَى الْقَضَاءِ، فَأَبَى، حَتَّى قِيدَ، وَحَبِسَ، فَاضْطُرَّ، ثُمَّ تَقَلَّدَ. (العناية، 261/7، 262؛ البناية، 10/9، 11).

(2) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سَنَنِ الصَّغْرَى، بَلْفِظِهِ، 124/4، حَدِيثَ رَقْم: 3230؛ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ، بَلْفِظٍ قَرِيبٍ مِنْهُ، 606/3، حَدِيثَ رَقْم: 1325. وَقَالَ: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ". وَجْهٌ تَشْبِيهِ الْقَضَاءِ بِالذَّبْحِ بِغَيْرِ سَكِينٍ: أَنَّ السَّكِينَ تَوَثَّرَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا، وَالدَّبْحُ بِغَيْرِ سَكِينٍ، يَوَثَّرُ فِي الْبَاطِنِ بِإِزْهَاقِ الرُّوحِ، وَلَا يَوَثَّرُ فِي الظَّاهِرِ، وَبِالْقَضَاءِ لَا يَوَثَّرُ فِي الظَّاهِرِ؛ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ جَاهٌ، وَعَظْمَةٌ، لَكِنْ فِي بَاطِنِهِ هَلَاكٌ. (العناية، 262/8؛ البناية، 11/9، 12).

(3) أَيُّ فِي الْقَضَاءِ، عِنْدَ الْأَمْنِ مِنَ الْحَيْفِ، وَعَدَمِ التَّعَيُّنِ.

(4) أَيُّ مَبَاحٍ. رَوَى الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، أَنَّهُ إِذَا قُلِدَ مِنْ

فَلَعَلَّهُ (3) يُخْطِئُ ظَنَّهُ، وَلَا يُوَفِّقُ لَهُ (4)، أَوْ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ (5)،
وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِعَانَةِ (6). إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ (7) دُونَ غَيْرِهِ،
فَحِينَئِذٍ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ (8)؛ صِيَانَةُ لِحَقُوقِ الْعِبَادِ (9)، وَإِخْلَاءُ
لِلْعَالَمِ عَنِ الْفَسَادِ (10).

غَيْرُ مَسْأَلَةٍ، لَا بَأْسَ بِهِ. (العناية، 262/7؛ الدر المختار، ص: 465).
(1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِنَّ الْمَقْسُطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عِزٌّ
وَجَلٌّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْا".
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، 1458/3، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 1827).

(2) مِنَ الْعِزْمِ، وَهُوَ الْجِدُّ وَالصَّبْرُ، فَأَلْوَلَى عَدَمَهُ. (البنية، 13/9).

(3) الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ.

(4) يَعْنِي أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ بِالْحَقِّ فِي الْإِبْتِدَاءِ فِي ظَنِّهِ، ثُمَّ لَا يَقْدِرُ
عَلَيْهِ، أَوْ لَا يُوَفِّقُ لَهُ، فِي الْإِنْتِهَاءِ. (البنية، 13/9).

(5) أَيُّ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ؛ أَنَّهُ رُبَّمَا لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ فِي الْأَمْرِ، إِلَّا
بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّ غَيْرَهُ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ..

(6) أَيُّ عَلَى الْقَضَاءِ، إِنْ كَانَ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ. (العناية، 262/7).

(7) يَعْنِي وَحْدَهُ، وَلَمْ يَوْجَدْ غَيْرَهُ. (البنية شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 13/9).

(8) هَذَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ، إِذَا تَعَيَّنَ وَاحِدٌ لِإِقَامَتِهَا،
يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ. (البنية شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 13/9).

(9) وَدَفْعًا لِظُلْمِ الظَّالِمِينَ. (مَجْمَعُ الْأَنْهَارِ، 155/3).

(10) فِي الْحُدُودِ، وَالْقَصَاصِ. (العناية، 262/7؛ البنية، 13/9).

(طَلَبُ وَلَايَةِ الْقَضَاءِ)

قَالَ: (وَيَنْبَغِي أَنْ لَا (1) يَطْلُبَ الْوَلَايَةَ، وَلَا يَسْأَلَهَا (2)؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ، وَكُلَّ (3) إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ (4)". وَلَئِنْ مَنْ طَلَبَهُ، يَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِهِ (5)، فَيَحْرُمُ (6)، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، يَتَوَكَّلُ

(1) أي يكره كراهة التنزيه.

(2) أي مَنْ صَلَحَ لِلْقَضَاءِ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَطْلُبَ الْوَلَايَةَ بِقَلْبِهِ. وَلَا يَسْأَلَهَا بِلِسَانِهِ. وَقِيلَ: الطَّلَبُ: أَنْ يَقُولَ لِلْإِمَامِ: وَلَنِي. وَالسُّؤَالُ: أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: لَوْ وَلَا نِي الْإِمَامُ قَضَاءَ مَدِينَةٍ كَذَا، لِأَجْبَتِهِ إِلَى ذَلِكَ، وَهُوَ يَطْمَحُ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ، فَيَقْلُدَهُ الْقَضَاءَ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ. (العناية، 262/7؛ الجوهرة النيرة، 241/2؛ البناية، 13/9).

(3) وَكُلَّ: عَلَى صِيغَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ، بِتَخْفِيفِ الْكَافِ: أَيِ فُوضَ أَمْرُهُ إِلَيْهَا، وَلَا يَعَانِ مِنَ اللَّهِ، وَمَنْ فُوضَ أَمْرُهُ إِلَى نَفْسِهِ، لَمْ يَهْتَدِ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. (العناية، 263/7؛ البناية شرح الهداية، 13/9، 14؛ تحفة الأحوذى، 462/4).

(4) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، 103/4، حَدِيثَ رَقْمٍ: 702 وَقَالَ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَخْرُجَاهُ. وَمَعْنَى يُسَدِّدُهُ: أَيِ يُلْهِمُهُ الرُّشْدَ، وَيَحْمِلُهُ عَلَى السَّادِدِ، وَالصَّوَابِ.

(5) أَيِ مِنَ الْوَرَعِ، وَالْعِلْمِ، وَالْفُطْنَةِ، وَالذِّكَاةِ، فَيَصِيرُ مَعْجَبًا بِنَفْسِهِ. (العناية، 263/7)

(6) أَيِ فَيَحْرُمُ التَّوْفِيقَ، وَلَا يُلْهِمُ الرُّشْدَ. (العناية، 263/7؛ البناية شرح الهداية، 14/9).

عَلَى رَبِّهِ (1)، فَيُلْهِمُ (2).

(تَقْلُدُ الْقَضَاءَ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ)

ثُمَّ يَجُوزُ التَّقْلُدُ (3) مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ (4)، كَمَا يَجُوزُ مِنَ الْعَادِلِ (5)؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - تَقْلُدُوهُ (6) مِنْ مُعَاوِيَةَ (7) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ (1) - رَضِيَ

(1) أَيِ مَنْ أَكْرَهَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَدْ اعْتَصِمَ بِجِبِلِّ اللَّهِ، مَكْسُورِ الْقَلْبِ بِالْإِكْرَاهِ عَلَى مَا لَا يَحِبُّهُ، وَيَرْضَاهُ، وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَكَافِيهِ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ. (العناية شرح الهداية، 263/7؛ البناية شرح الهداية، 14/9).

(2) أَيِ الرُّشْدِ، وَالصَّوَابِ، وَالتَّوْفِيقِ. (العناية شرح الهداية، 263/7).

(3) أَيِ تَقْلِيدِ الْقَضَاءِ. وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْقُدُورِيِّ، وَبِهِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ التَّقْلُدِ لِأَهْلِهِ، بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْلِيَّ عَادِلًا، أَوْ جَائِرًا، فَكَمَا جَازَ مِنَ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ، جَازَ مِنَ الْجَائِرِ. (العناية شرح الهداية، 263/7؛ البناية شرح الهداية، 14/9).

(4) أَيِ الظَّالِمِ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اخْتِصَاصِ تَوَلِيَةِ الْقَضَاءِ بِالسُّلْطَانِ، وَنَحْوِهِ كَالْخَلِيفَةِ، حَتَّى لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ بِلَدَةٍ عَلَى تَوَلِيَةِ وَاحِدٍ الْقَضَاءِ، لَمْ يَصَحَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَّوْا سُلْطَانًا بَعْدَ مَوْتِ سُلْطَانِهِمْ. (البحر الرائق، 298/6).

(5) السُّلْطَانُ الْعَادِلُ: الْمُطِيعُ لِأَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ: الْمُرَاعِي لِحُقُوقِ الرُّعْيَةِ. (البحر الرائق، 298/6).

(6) أَيِ الْقَضَاءِ. (البناية شرح الهداية، 14/9).

(7) ابْنُ أَبِي سَفْيَانَ، لَمَّا انْفَرَدَ بِالْإِمْرَةِ، وَخَالَفَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (البناية 14/9).

اللَّهُ عَنْهُ - فِي نَوْبَتِهِ (2). وَالتَّابِعِينَ (3) تَقْلُدُوهُ (4) مِنْ الْحَجَّاجِ (5)،

(1) أي والحال أن الحق. وهذا تصريح بجور معاوية، والميراد في خروجه، لا في أفضيته، ثم إنما يتم إذا ثبت أنه ولي القضاء قبل تسليم الحسن له، وأما بعد تسليمه فلا (البنية، 14/9).

(2) أي في خلافته؛ لأن الخلافة كانت له بعد عثمان رضي الله عنه بالنص (البنية، 14/9؛ فتح القدير، 263/7)، وقيد (بنوبته)؛ احترازاً عن قول الروافض: إنه كان أحق بها في سائر الثوب حتى من أبي بكر - رضي الله عنه، وليس الأمر كما قالوا، بل أجمع الأمة من أهل الحل والعقد، على صحة خلافة الخلفاء قبله. وإنما كان الحق معه في تلك النوبة؛ لصحة بيعته، وانعقادها يدل على ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه، (97/1)، حديث رقم: (447) عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: "ويح عمّار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعوهم إلى النار". وقد قتله أصحاب معاوية. (العناية، 263/7؛ البنية، 14/9؛ فتح القدير، 263/7؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، 910/3).

(3) بالنصب؛ عطفاً على قوله: "لأن الصحابة - رضي الله عنهم". (البنية، 14/9).

(4) أي تقلدوا القضاء من الحجّاج؛ يدل على ذلك ما رواه البخاري في تاريخه الأوسط، قال حدثنا ضمرة قال: "واستقضى الحجّاج أبا بردة بن أبي موسى، وأجلس معه سعيد بن جبير". (البنية، 14/9؛ فتح القدير، 263/7؛ التاريخ الأوسط، للبخاري، 211/1).

(5) ابن يوسف بن الحكم الثقفي: عامل عبد الملك بن مروان على العراق، وخراسان، ولد سنة أربعين، أو إحدى وأربعين، ومات في رمضان، سنة خمسة وتسعين. (سير أعلام النبلاء، 343/4؛ الوافي

وَكَانَ جَائِرًا⁽¹⁾، إِلَّا⁽²⁾ إِذَا كَانَ لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ الْقَضَاءِ بِحَقِّ⁽³⁾؛ لِأَنَّ
الْمَقْصُودَ⁽⁴⁾ لَا يَحْصُلُ بِالنَّقْلِ⁽⁵⁾. بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ⁽⁶⁾ يُمَكِّنُهُ⁽⁷⁾
(أَوَّلُ أَعْمَالِ الْقَاضِي بَعْدَ التَّوْلِيَةِ)
قَالَ: (وَمَنْ قُلِدَ الْقَضَاءُ⁽⁸⁾، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ دِيْوَانُ⁽⁹⁾ الْقَاضِي الَّذِي
كَانَ قَبْلَهُ⁽¹¹⁾): وَهُوَ⁽²⁾ الْخَرَائِطُ⁽³⁾ الَّتِي فِيهَا السَّجَلَاتُ⁽⁴⁾،

بالوفيات، للصفدي، 237/11، 238).

(1) أي ظالماً، شديد الظلم، مشهوراً. قال عنه الذهبي: "وكان ظلوماً،
جباراً، ناصبياً، خبيثاً، سفاكاً للدماء، وكان ذا شجاعة، وإقدام، ومكر،
ودهاء، (15/9؛ سير أعلام النبلاء، للذهبي، 343/4).

(2) استثناء من قوله: "يجوز النقل من السلطان الجائر".

(3) أي إلا إذا كان السلطان الجائر، لا يمكن القاضي من الحكم
بالحق (البنية 15/9).

(4) وهو العمل بالحق. (البنية شرح الهداية، 15/9).

(5) أي من السلطان الجائر، فلا فائدة في التقليد. (العناية، 264/7؛
البنية، 15/9).

(6) أي السلطان الجائر. (البنية شرح الهداية، 15/9).

(7) أي من القضاء بالحق، (البنية، 15/9).

(8) أي من تولى القضاء، بعد عزل آخر. (العناية، 264/7؛ مجمع
الأنهر، 156/2).

(9) الديوان: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء.
والدفاتر التي تدون فيها الحجج ونحوها، وأول من دون الدواوين
عمر (النهاية في غريب الحديث، 150/2؛ معجم لغة الفقهاء،
ص: 212).

وغيرها⁽⁵⁾؛ لأنها⁽⁶⁾ وضعت فيها⁽⁷⁾ لتكون حجة عند الحاجة⁽⁸⁾،
فتجعل في يد من له ولاية القضاء⁽⁹⁾. ثم إن كان البياض⁽¹⁰⁾ من

(1) أي أول ما يبدأ به القاضي من الأعمال، أن يتسلم ديوان القاضي الذي كان قبله. ((العناية، 264/7؛ فتح القدير، 264/7)).

(2) أي الديوان. وهذا تفسير من المصنف لديوان القاضي. (البنية شرح الهداية، 15/9)

(3) الخريطة: وعاء من جلد، أو نحوه؛ يشد على ما فيه من صحف، ونحوها. (المعجم الوسيط، 228/1؛ معجم لغة الفقهاء، ص: 195).

(4) السجلات: جمع سجل بالكسر والتشديد: وهو كتاب الحكم، أو القاضي. أو هو الذي يكتب فيه المحضر، ويكتب معه تنفيذ الحكم، وإمضاؤه. (البنية شرح الهداية، 15/9؛ البحر الرائق، 299/6).

(5) أي وغير السجلات، من المحاضر، والصكوك، وكتاب نصب الأوصياء، وتقدير النفقات للأيتام، وغيرهم، مما اقتضاه الحال. وهذا؛ لأن القاضي يكتب نمختين: أحدهما تكون في يد الخصم، والأخرى في ديوان القاضي؛ إذ ربما يحتاج إليها لمعنى من المعاني. وما في يد الخصم، لا يؤمن عليه من الزيادة والنقصان. (العناية، 264/7؛ فتح القدير، 264/6؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام، 405/2).

(6) أي السجلات، وغيرها من المحاضر، والصكوك.

(7) أي في الخرائط. (العناية، 264/7؛ البنية شرح الهداية، 15/9).

(8) إلى الحجة، ومعرفة الأحوال. (فتح القدير، 264/7).

(9) وهو القاضي المولى؛ لأنه يحتاج إلى معرفة ما فيها، فكان له أخذها. وإلا لا تفيد. (العناية، 264/7؛ البنية شرح الهداية، 15/9).

(10) أي الذي كتب فيه الحادثة، ورقا كان، أو رقاً - وهو الجلد الرقيق الذي يكتب فيه. (العناية، 264/7؛ البنية، 15/9).

بَيَّتَ الْمَالَ، فَظَاهَرَ⁽¹⁾. وَكَذَا⁽²⁾ إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ⁽³⁾ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُمْ وَضَعُوهَا فِي يَدِهِ؛ لِعَمَلِهِ، وَقَدْ انْتَقَلَ إِلَى الْمُؤَلَّى، وَكَذَا⁽⁴⁾ إِذَا كَانَ⁽⁵⁾ مِنْ مَالِ الْقَاضِي، هُوَ الصَّحِيحُ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ⁽⁷⁾ اتَّخَذَهُ تَدِينًا (لَا تَمَوَّلًا)⁽⁸⁾. وَيَبْعَثُ⁽⁹⁾ أَمِينَيْنِ⁽¹⁰⁾؛ لِيَقْبِضَاهَا⁽¹¹⁾

(1) أي يجبر المعزول على دفعه؛ لأن ذلك إنما كان في يده؛ لعمله، وقد صار العمل لغيره، فلا يترك في يده. (البنية، 16/9، 15/9؛ درر الحكام، 405/2).

(2) أي وكذا يجعل البياض، أو الورق الذي كتب عليه القاضي المعزول، في يد من له ولاية القضاء. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(3) لأنه وضع عنده؛ لصيانة حقوق الناس تدنيا، لا تمولا.

(4) أي يجبر القاضي المعزول على الدفع. (البنية، 16/9).

(5) أي البياض. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(6) وَقَوْلُهُ: (فِي الصَّحِيحِ) فِي الصُّورَتَيْنِ، احْتِرَازٌ عَمَّا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَائِخِ: إِنَّ الْبَيَاضَ إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ، أَوْ مَالِ الْقَاضِي، لَا يَجْبِرُ الْمَعْزُولَ عَلَى دَفْعِهِ؛ لِأَنَّهُ مُلْكُهُ، أَوْ وَهَبَ لَهُ، (العناية، 265/7؛ البنية شرح الهداية، 16/9).

(7) أي لأن القاضي المعزول. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(8) أي وضع عندهم بطريق الديانة، والأمانة؛ ليحفظ به أمور الناس، وحاجاتهم وضع عنده من حيث أن يتمول به. (البنية، 16/9).

(9) الْقَاضِي الْجَدِيدُ، لِبَيَانِ لِكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ. (العناية، 265/7).

(10) أي رجلين من ثقاته، وهو أحوط، والواحد يكفي. (العناية شرح الهداية، 265/7).

(11) أي الخرائط التي فيها السجلات، وغيرها. (البنية 16/9)

بِحَضْرَةِ الْمَعْرُوفِ، أَوْ أَمِينِهِ (1)؛ وَيَسْأَلَانِهِ (2) شَيْئًا فَشَيْئًا (3)،
وَيَجْعَلَانِ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا فِي خَرِيطَةٍ (4)؛ كَيْ لَا يَشْتَبَهَ عَلَى
الْمَوْلَى (5)، وَهَذَا السُّؤَالُ (6)؛ لِكَشْفِ الْحَالِ، لَا لِلإِزَامِ (7).
قَالَ (8): (وَيَنْظُرُ (9) فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ (1)؛ لِأَنَّهُ (2) نُسِبَ

(1) أي الأمين من جهة القاضي المعزول. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(2) أي يسألان القاضي المعزول. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(3) يعني واحدا بعد واحد. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(4) فما كان فيها من نسخ السجلات يجمع في خريطة منفردة، وما كان
من نصيب الأوصياء يجعل في خريطة، وما كان من نسخ الأوقاف
يجمع في خريطة، وما كان من الصكوك يجعل في خريطة؛ ليكون
أسهل للتناول؛ لأنَّ السجلات، إن تركت مجتمعة، تشبه على المولى،
فلا يصل إلى المقصود وقت الحاجة، أو يتعسر عليه ذلك. (العناية
265/7؛ البنية 16/9؛ فتح القدير، 265/7).

(5) شيء من هذه السجلات وغيرها. (البنية شرح الهداية، 16/9).

(6) أي سؤال القاضي المعزول عن أحوال الديوان، والمحبوسين، وسبب
الحبس. (العناية 265/7؛ البنية شرح الهداية، 16/9).

(7) لا يلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي المعزول؛ لأن قول
القاضي المعزول ليس بحجة؛ لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا، فلا
يكون قوله حجة. ومتى قبضا ذلك، يختمان ذلك؛ احترازاً عن الزيادة
والنقصان، وهذا ينبغي أن يكون في حق كل قاض. (العناية 265/7؛
البنية شرح الهداية، 16/9؛ فتح القدير، 265/7).

(8) أي القدوري - رحمه الله - في مختصره.

(9) أي ينظر القاضي الجديد. (تبيين الحقائق، 177/4).

نَاطِرًا⁽³⁾. (فَمَنْ اعْتَرَفَ⁽⁴⁾ بِحَقِّ، أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ⁽⁵⁾)؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُلْزِمٌ⁽⁶⁾. (وَمَنْ أَنْكَرَ⁽⁷⁾)، لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ الْمَعْزُولِ عَلَيْهِ⁽⁸⁾ إِلَّا بَيِّنَةٌ⁽⁹⁾ لَأَنَّهُ⁽¹⁾ بِالْعَزْلِ التَّحَقُّ بِالرَّعَايَا⁽²⁾، وَشَهَادَةُ الْفَرْدِ لَيْسَتْ

(1) وَالْمُرَادُ: الْمَحْبُوسُ فِي سَجْنِ الْقَاضِي. وَأَمَّا الْمَحْبُوسُ فِي سَجْنِ الْوَالِي، فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ النَّظَرُ فِي أَحْوَالِهِمْ. وَكَيْفِيَّةُ النَّظَرِ فِي أَحْوَالِهِمْ: أَنْ يَبْعَثَ الْقَاضِي ثِقَةً يَحْصِيهِمْ فِي السَّجْنِ، وَيَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَجْدَادِهِمْ، وَأَخْبَارَهُمْ، وَسَبَبَ حَبْسِهِمْ، وَتَارِيخَ حَبْسِهِمْ، وَمَنْ حَبْسَهُمْ. (العناية، 266/7؛ فتح القدير، 266/7؛ 300).

(2) أَي لَأَنَّ الْقَاضِي الْجَدِيدَ. (البنية شرح الهداية، 17/9).

(3) أَي لَأَنَّ الْقَاضِي نَاطِرٌ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَهَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ، مُحْبُوسُونَ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَهُ سَبَبٌ يَوْجِبُ حَبْسَهُمْ، وَثَبُوتُهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ، لَيْسَ حُجَّةً يَعْتَمِدُهَا الثَّانِي فِي حَبْسِ هَؤُلَاءِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَوَّلِ لَمْ يَبْقَ حُجَّةً بَعْدَ عَزْلِهِ. (العناية، 266/7؛ فتح القدير، 266/7).

(4) أَي مَنْ أَقْرَبَ مِنَ الْمَحْبُوسِينَ. (الدر المختار، ص: 465).

(5) أَي أَلْزَمَهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَقْرَبَ بِهِ. أَوْ أَلْزَمَهُ الْحَبْسَ - وَهُوَ الظَّاهِرُ - وَرَدَّهُ إِلَى السَّجْنِ، إِذَا طَلَبَ الْخَصْمُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ الْمَقْدَارَ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ السَّجْنِ عِنْدَهُ، إِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَالٌ. (العناية شرح الهداية، 266/7؛ فتح القدير، 266/7؛ البحر الرائق، 301/6).

(6) أَي حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ لِلْمَقْرَرِ.

(7) مَا يَوْجِبُ الْحَبْسَ. (العناية شرح الهداية، 266/7).

(8) كَمَا لَوْ قَالَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ: حَبَسْتَهُ بِحَقِّ عَلَيْهِ، أَوْ قَالَ: كُنْتُ حَكَمْتُ عَلَيْهِ لِفُلَانٍ بِكَذَا. (البحر الرائق، 301/6).

(9) سِوَاءَ شَهَدَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَصْلِ الْحَقِّ، أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي عَلَيْهِ. فَإِنْ قَامَتْ

لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ (3)، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ (4) عَلَى فِعْلٍ نَفْسِهِ. (فَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ (5)، لَمْ يُعَجَّلْ (6) بِتَخْلِيَّتِهِ (7)، حَتَّى يَنَادِيَ عَلَيْهِ (8)، وَيَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ؛ لَأَنَّ فِعْلَ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ حَقٌّ ظَاهِرٌ (9)، فَلَا يُعَجَّلُ (1)؛ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى إِبْطَالِ

الْبَيِّنَةِ بِالْحَقِّ، وَالْقَاضِي يَعْرِفُ عَدَالَةَ الشُّهُودِ، رَدُّهُمْ إِلَى الْحَبْسِ؛ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَالَتَهُمْ، أَخَذَ مِنْهُمْ كَفِيلًا، وَأَطْلَقَهُمْ، حَتَّى يَنْظُرَ فِي حَالِهِمْ، فَإِنْ ظَهَرَتْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ رَدُّهُمْ إِلَى السِّجْنِ، إِذَا طَلَبَ الْخَصْمُ ذَلِكَ. (البحر الرائق، 301/6).

(1) أي لأن القاضي المعزول. (البنية شرح الهداية، 17/9).

(2) أي بواحد من الرعايا. (فتح القدير، 266/7).

(3) موجبة للعمل. (فتح القدير، 266/7).

(4) أي شهادة الفرد على تأويل الأخبار. (البنية 17/9).

(5) أي بما وجب حبسه، ولم يقر على نفسه، أو لم يحضر خصم، وأدعى المحبوس أن لا خصم له، وهو محبوس بغير حق. (تبيين الحقائق، 177/4).

(6) أي القاضي. (البنية شرح الهداية، 17/9).

(7) وإطلاق سراحه. (فتح القدير، 266/7).

(8) بأن يأمر القاضي كل يوم إذا جلس مناديا ينادي في محلته: من كان يطلب فلان بن فلان، المحبوس بحق، فليأت إلى القاضي. يفعل ذلك أياما، فإذا حضر وأدعى، وهو على جواده، ابتداء الحكم بينهما، وإن لم يحضر، أخذ منه كفيلا بنفسه، وأطلقه. (تبيين الحقائق، 177/4).

(9) إذ لعنه محبوس بحق لغائب، وأمارته أنه في حبس قاض، والظاهر أنه حبس بحق.

حَقَّ الْغَيْرِ⁽²⁾. (وَيَنْظُرُ⁽³⁾ فِي الْوَدَائِعِ⁽⁴⁾، وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ⁽⁵⁾)؛
فَيَعْمَلُ فِيهِ⁽⁶⁾ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ يَعْتَرِفُ بِهِ مَنْ هُوَ فِي
يَدِهِ⁽⁷⁾؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ⁽⁸⁾ حُجَّةٌ. (وَلَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْمَعزُولِ⁽⁹⁾)؛ لِمَا
بَيَّنَّا⁽¹⁰⁾. (إِلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، أَنْ⁽¹⁾ الْمَعزُولِ

(1) أي بإطلاق سراحه.

(2) لجواز أن يكون له خصم غائب يدعي عليه إذا حضر. (العناية
266/7).

(3) أي من جملة عمل القاضي الجديد، أن ينظر.

(4) أي: ودائع اليتامى.

(5) أي غلات الوقوف الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي؛ لأنه نصب ناظراً
في أمور الناس. والذي في ديارنا من هذا: أَنَّ أَمْوَالَ الْأَوْقَافِ تَحْتَ أَيْدِي
جَمَاعَةٍ يُولِيهِمُ الْقَاضِي النَّظَرَ، أَوْ الْمِبَاشَرَةَ فِيهَا، وَوَدَائِعُ الْيَتَامَى تَحْتَ يَدِ
الَّذِي يَسَمَّى أَمِينِ الْحُكْمِ. وَقَدْ انْقَطَعَ هَذَا فِي زَمَانِنَا؛ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
تَحْتَ يَدِ الْأَوْصِيَاءِ، وَلَمْ يُولَ فِي زَمَانِنَا أَمِينِ الْحُكْمِ. (البحر
الرائق، 302/6)

(6) أي في المذكور. (العناية شرح الهداية، 267/7).

(7) لأنه لا بد لعمله من حجة. (العناية شرح الهداية، 267/7)..

(8) أي كل واحد من قيام البينة، واعتراف من هو في يده. (البنية
18/9).

(9) عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ، إِذَا أَنْكَرَ، إِلَّا بَيِّنَةٌ. يَعْنِي لَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ
الْمَالُ: الْمَالُ لِي، وَقَالَ الْمَعزُولُ: إِنَّهُ مَالٌ وَقَفَ، أَوْ يَتِيمٌ، لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَ
الْمَعزُولِ إِلَّا بَيِّنَةٌ. (البحر الرائق، 302/6)

(10) إشارة إلى قوله: "لأنه بالعزل التحق بالرعايا، وشهادة الفرد ليست

سَلَّمَهَا (2) إِلَيْهِ، فَيَقْبَلُ قَوْلَهُ (3) فِيهَا (4)؛ لَأَنَّهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ (5)، أَنَّ الْيَدَ كَانَتْ لِلْقَاضِي (6)، فَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْقَاضِي (7)، كَأَنَّهُ فِي يَدِهِ فِي الْحَالِ (8). إِلَّا إِذَا بَدَأَ (9) بِالْإِقْرَارِ لغيرِهِ، ثُمَّ أَقْرَأَ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِي (10)، فَيُسَلِّمُ مَا فِي يَدِهِ إِلَى الْمُقَرَّرِ لَهُ الْأَوَّلِ (1)؛ لِسَبْقِ حَقِّهِ،

بِحُجَّةٍ. بخلاف القاضي؛ لأنه هو المخصوص بأن يكفي بقوله في الإلزام، حتى إن الخليفة الذي قلد = القاضي، لو أخبر القاضي أنه شهد عنده الشهود بكذا، لا يقضي به، حتى يشهد عنده الخليفة مع آخر، والواحد لا يقبل قوله. (البنية، 18/9؛ فتح القدير، 267/7).

(1) القاضي. (فتح القدير، 267/7).

(2) أي الدوائع، أو الغلات. (اللباب في شرح الكتاب، 80/4).

(3) أي القاضي المعزول. (اللباب في شرح الكتاب، 80/4).

(4) أي في الدوائع، وارتفاع الأوقاف. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(5) أي بإقرار ذي اليد. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(6) المعزول. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(7) المعزول به. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(8) ولو كان بيده عياناً، صحَّ إقراره به، فكذا إذا كان بيد مودعه؛ لأنَّ يد المودع، كيد المودع. (العناية شرح الهداية، 267/7؛ البنية شرح الهداية، 18/9).

(9) استثناء من قوله: "فيقبل". أي إلا إذا بدأ به ذوي اليد. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(10) بأن قال ذو اليد: هذا المال لفلان ابن فلان، غير الذي أقر له القاضي المعزول، ودفعه إليَّ القاضي. (العناية شرح الهداية، 268/7؛ فتح القدير، 268/7).

حَقَّهُ، وَيَضْمَنُ (2) قِيَمَتَهُ (3) لِلْقَاضِي (4) بِإِقْرَارِهِ الثَّانِي، وَيَسْلَمُ إِلَى الْمُقَرَّرِ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي (5).

(مَكَانُ جُلُوسِ الْقَاضِي لِلْقَضَاءِ)

قَالَ: (وَيَجْلِسُ (6) لِلْحُكْمِ (7) جُلُوسًا ظَاهِرًا (8)، فِي الْمَسْجِدِ (9)؛ كَيْ لَا يَشْتَبَهَ مَكَانُهُ عَلَى الْغُرَبَاءِ (10)، وَبَعْضُ

(1) وهو الذي أقر له ذو اليد. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(2) أي ذو اليد. (البنية شرح الهداية، 18/9).

(3) إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا. (فتح القدير، 268/7).

(4) المعزول.

(5) وهذا؛ لأنه لما بدأ بالإقرار، صح إقراره، ولزم؛ ووجب تسليم المال إلى المقر له. فإذا قال بعد ذلك: دفعه إلي القاضي، وهو يقول: لفلان آخر، فقد أقر أن اليد كانت للقاضي، وإقراره لغير من أقر له القاضي، أتلّف المال على من أقر له القاضي، فكان ضامنا للمثل. أو القيمة. (العناية شرح الهداية، 268/7؛).

(6) أي القاضي. (البنية شرح الهداية، 19/9).

(7) وكذلك السلطان يجلس للحكم في المسجد، والمفتي، والفقيه.

(8) ويندب له أن يستدير القبلة في جلوسه، كخطيب، ومدرس. ولا يتعب نفسه في طول الجلوس، ولكن يجلس في طرفي التّهار. (فتح القدير، 269/7).

(9) وأطلق المسجد، فشمل غير الجامع، لكن المسجد الجامع أولى؛ لأنه أشهر.

(10) الغرباء: جمع غريب. وهو البعيد عن وطنه. (البنية، 19/9).

المُقيمِينَ⁽¹⁾، وَالْمَسْجِدَ الْجَامِعَ أَوْلَى⁽²⁾؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ⁽³⁾. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّهُ⁽⁵⁾ يَحْضُرُهُ الْمُشْرِكُ⁽⁶⁾، وَهُوَ نَجَسٌ بِالنَّصِّ⁽⁷⁾، وَالْحَائِضُ⁽⁸⁾، وَهِيَ⁽⁹⁾ مَمْنُوعَةٌ عَنْ دُخُولِهِ⁽¹⁰⁾. وَلَنَا⁽¹⁾ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

- (1) الذين ليس لهم اختلاط بالقضاء. (البنية شرح الهداية، 19/9).
- (2) لأنه أشهر، وأرقى بالناس، ثم الذي تقام فيه الجماعات، وإن لم تصل فيه الجمعة. قال فخر الإسلام البيهقي: هذا إذا كان الجامع في وسط البلد، أما إذا كان في طرف منها، فلا لزيادة المشقة على أهل الشقة المقابلة له، فالأولى أن يختار مسجدا في وسط البلد. ويجوز أن يحكم في بيته، إلا أن الأولى ما ذكرنا. (فتح القدير، 269/7).
- (3) أي أشهر المواضع. (البنية شرح الهداية، 19/9).
- (4) وهذا على الأصح من مذهب الشافعية. وفي رواية: لا يكره، لكن الأولى تركه (روضة الطالبين، 138/11).
- (5) أي القضاء. (فتح القدير، 269/7).
- (6) للدعوى.
- (7) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾. سورة التوبة، من الآية الكريمة: 28. (تبيين الحقائق، 178/4).
- (8) أي ويحضره الحائض. (البنية شرح الهداية، 19/9).
- (9) أي الحائض. (البنية شرح الهداية، 19/9).
- (10) أي دخول المسجد. ولأن المساجد بنيت للصلاة، والذكر، والخصومات تقترب بالمعاصي كثيرا من اليمين الغموس، والكذب في الدعوى. (البنية، 19/9).

وَالسَّلَامُ: "إِنَّمَا بُنِيَ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْحُكْمِ"⁽²⁾.
 "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْصِلُ الْخُصُومَةَ
 فِي مُعْتَكِفِهِ"⁽³⁾. وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، كَانُوا يَجْلِسُونَ فِي
 الْمَسَاجِدِ؛ لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ، فَيَجُوزُ
 إِقَامَتُهَا فِي الْمَسْجِدِ، كَالصَّلَاةِ. وَنَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ فِي اعْتِقَادِهِ، لَا
 فِي ظَاهِرِهِ⁽⁴⁾، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ⁽⁵⁾. وَالْحَائِضُ تَخْبِرُ بِحَالِهَا؛

(1) أي ودليلنا على ما ذهبنا إليه.

(2) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: لَمْ أَجِدْ هَكَذَا، وَإِنَّمَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، فِي
 قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا
 تَصْلَحُ لَشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -
 وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ". أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ
 الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَتَّهَ عَلَيْهِ. (الدَّرَايَةُ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ
 الْهَدَايَةِ، 2/168؛ صَحِيحُ مُسْلِمٍ، 1/236، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 285).

(3) فِيهِ أَحَادِيثٌ، مِنْهَا: مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
 "أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيْقَلْتَهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ".
 وَلَا بَدَّ مِنْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا كَاذِبًا، حَانِثًا فِي يَمِينِ غَمُوسٍ. (فَتْحُ
 الْقَدِيرِ، 7/269؛ صَحِيحُ الْبَخَارِيِّ، 1/92، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 423).

(4) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ. وَتَقْرِيرُهُ: نَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ فِي إِعْتِقَادِهِ، لَا فِي
 ظَاهِرِهِ؛ فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ الْوُفُودَ فِي الْمَسْجِدِ. (الْعِنَايَةُ،
 7/270؛ الْبَنَاءُ 9/20).

(5) إِذْ لَا يُصِيبُ الْأَرْضَ مِنْهُ شَيْءٌ. (الْعِنَايَةُ، 7/270؛ الْبَنَاءُ شَرْحُ
 الْهَدَايَةِ، 9/20).

فَيَخْرُجُ الْقَاضِي إِلَيْهَا، أَوْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، أَوْ يَبْعَثُ⁽¹⁾ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهَا⁽²⁾ وَبَيْنَ خَصْمَهَا،⁽³⁾ كَمَا إِذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ فِي الدَّابَّةِ⁽⁴⁾. وَلَوْ جَلَسَ⁽⁵⁾ فِي دَارِهِ، لَمْ بَأْسَ بِهِ⁽⁶⁾، وَيَأْذَنُ لِلنَّاسِ⁽⁷⁾ بِالْدُخُولِ فِيهَا⁽⁸⁾، وَيَجْلِسُ مَعَهُ⁽⁹⁾ مَنْ كَانَ يَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ⁽¹⁰⁾؛

(1) أي القاضي. (البناية شرح الهداية، 20/9).

(2) أي بين الحائض. (البناية شرح الهداية، 20/9).

(3) فَإِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحَائِضُ غَيْرَ مُسَلِّمَةٍ، لَا تَعْتَقِدُ حُرْمَةَ الدُّخُولِ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُخْبِرُ عَنْ حَالِهَا. قُلْنَا: الْكُفَّارُ لَيْسُوا بِمُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرَائِعِ، فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهَا. (العناية، 270/7؛ .).

(4) فَيُوقِفُ الدَّابَّةَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَيُخْرِجُ الْقَاضِي، أَوْ يُرْسِلُ نَائِبَهُ؛ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ.

(5) أي القاضي. (البناية شرح الهداية، 20/9).

(6) ذَكَرَ هَذَا تَقْرِيعًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ شَمْسُ الْأُئِمَّةِ السَّرْحَسِيُّ: وَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَجْلِسَ فِي دَارِهِ، فَلَهُ ذَلِكَ، بِشَرَطِ أَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ. (البناية 20/9).

(7) عَلَى الْعَمُومِ، وَلَا يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ حَقًّا فِي مَجْلِسِهِ. (فتح القدير، 270/7).

(8) أَي فِي دَارِهِ. وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَسْجِدِ، أَنَّ الْأَوَّلَى أَنْ تَكُونَ دَارُهُ فِي وَسْطِ الْبَلَدِ. (البناية شرح الهداية، 20/9، 21؛ فتح القدير، 270/7، 271).

(9) أَي وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْلِسَ مَعَهُ. (فتح القدير، 271/7).

(10) كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ؛ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مِنَ الثُّمَةِ. (العناية، 271/7).

لَأَنَّ فِي جُلُوسِهِ وَحْدَهُ تَهْمَةٌ⁽¹⁾

(حُكْمُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي)

قَالَ: (وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً⁽²⁾ إِلَّا مَنْ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ⁽³⁾)، أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَلََةُ الرَّحِمِ.

- (1) أي تهمة الظلم، وأخذ الرشوة. (العناية، 271/7؛ البناءة، 21/9).
- (2) من أحد والهدية: ما يعطى بلا شرط إعانة. بخلاف الرشوة. فهي ما يعطى بشرط الإعانة، والتكثير في قوله: "هدية"؛ للتقليل، أي ويرد أي هدية، حتى ولو كانت قليلة. وذكر الهدية ليس احترازاً؛ إذ يحرم عليه الاستقراض، والاستعارة ممن يحرم عليه قبول هديته. ومقتضاه أنه يحرم عليه قبول سائر التبرعات، (البحر الرائق، 305/6).
- (3) هذا القيد لا بد منه؛ ليخرج ابن العم. (البحر الرائق، 305/6).
- (4) أي قبل أن يصير المهدي إليه قاضياً. (البناءة شرح الهداية، 21/9).
- وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدَى لِي، قَالَ: "فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يَهْدِي لَهُ، أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا، لَهُ رِغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً، لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعِرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ إِبْطِيهِ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَغَيْتَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَغَيْتَ". ثَلَاثًا. وَتَعْلِيلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي سَبَبُهَا الْوَلَايَةُ. (العناية شرح الهداية، 271/7، 272؛ فتح القدير، 271/7، 272).

وَالثَّانِي لَيْسَ لِلْقَضَاءِ، بَلْ جَرَى عَلَى الْعَادَةِ. وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ (1)
يَصِيرُ أَكْلًا بِقَضَائِهِ (2)، حَتَّى لَوْ كَانَتْ لِلْقَرِيبِ خُصُومَةٌ، لَا يَقْبَلُ
هَدِيَّتَهُ، وَكَذَا (3) إِذَا زَادَ الْمُهْدِي عَلَى الْمُعْتَادِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ
خُصُومَةٌ (4)؛ لِأَنَّهُ لِأَجْلِ الْقَضَاءِ، فَيَتَحَامَاهُ (5)

(حُكْمُ إِجَابَةِ الْقَاضِي الدَّعْوَةَ)

(وَلَا يَحْضُرُ (6) دَعْوَةَ (7) إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً (1) (2)؛ لِأَنَّ

(1) أي فيما وراء الأول، والثاني. (البنية شرح الهداية، 21/9).

(2) والأكل بالقضاء، حرام، وسحت. (البنية شرح الهداية، 21/9).

(3) لا يقبل القاضي الهدية.

(4) فَإِنْ قَبِلَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْخُصُومَةِ، جَازٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تَنْتَاهِي
خُصُومَاتِهِ، كَنَظَارِ الْأَوْقَافِ، وَمُبَاشَرِيهَا. (رد المحتار على الدر
المختار، 374/5).

(5) أي يحترز عنه، ولا يأخذه. (البنية شرح الهداية، 21/9).

❁ ثُمَّ إِذَا أَخَذَ الْهَدِيَّةَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَبَاحُ أَخْذُهَا، مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ
مِنْهُ. قِيلَ: يَضَعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ: عَلَى
أَنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَى أَرْيَابِهَا، إِنْ عَرَفَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفَهُمْ، أَوْ كَانُوا بَعِيدًا حَتَّى
تَعَثَّرَ الرَّدُّ، فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، وَيَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الْقِطْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ الْمَالِكُ
يَوْمًا، يَعْطَاهَا. وَإِنَّمَا يَضَعُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ لِعَمَلِهِ،
وَهُوَ فِي هَذَا الْعَمَلِ نَائِبٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَتْ الْهَدَايَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
لَهُمْ. (العناية شرح الهداية، 272/7، 273؛ البنية، 22/9؛ فتح
القدير، 272/7)..

(6) أي القاضي. (البنية شرح الهداية، 22/9).

(7) الدَّعْوَةُ إِلَى الطَّعَامِ يَفْتَحُ الدَّالُّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعَرَبِ، وَبَعْضُهُمْ يَكْسِرُهَا. (رد

الْخَاصَّةُ (3) لِأَجْلِ الْقَضَاءِ، فَيَتَّهَمُ بِالْإِجَابَةِ، بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (4)،
وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ (5) قَرِيبُهُ (6)،
وَهُوَ قَوْلُهُمَا (7). وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُجِيبُهُ، وَإِنْ
كَانَتْ خَاصَّةً (8)، كَالْهَدِيَّةِ (9). وَالْخَاصَّةُ (1): مَا لَوْ عَلِمَ الْمُضِيفُ

المختار على الدر المختار، 374/5).

(1) يَشْرُطُ أَنْ لَا يَكُونَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الْعَامَّةِ خُصُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ
خُصُومَةٌ، فَلَا يَجِيبُ الْقَاضِي دَعْوَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى
إِيذَاءِ الْخَصْمِ الْآخَرِ، أَوْ إِلَى التُّهْمَةِ. (العناية شرح الهداية، 273/7).
(2) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَلَامُ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ. (مختصر القدوري،
ص: 207).

(3) أَيِ الدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ. (البنية شرح الهداية، 22/9).
(4) لِأَنَّهُ لَا تَهْمَةَ فِيهَا، وَالْإِجَابَةُ سَنَّةٌ. (الاختيار لتعليل المختار، 86/2).
(5) أَيِ إِطْلَاقِ قَوْلِ الْقُدُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - "وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةُ خَاصَّةٍ".
(6) أَيِ قَرِيبِ الْقَاضِي، فَلَا يَجِيبُ دَعْوَتَهُ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَامَّةً، وَلَا خُصُومَةَ
لَهُ.

(7) أَيِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
(8) أَيِ يَجِيبُ الْقَاضِي دَعْوَةَ الْقَرِيبِ، وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً.
(9) أَيِ كَمَا فِي الْهَدِيَّةِ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا مِنْ قَرِيبِهِ. هَكَذَا حَكَى
الْخَلَّافُ الطَّحَاوِيُّ. وَقَالَ الْخُصَّافُ: يَجِيبُ الْخَاصَّةَ لِقَرِيبِهِ، بَلَا خِلَافٍ
لِصَلَةِ الرَّحْمِ. وَعَلَى تَقْدِيرِ الْخِلَافِ، قِيلَ فِي الْفَرْقِ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ
- رَحِمَهُمَا اللَّهُ - بَيْنَ الضِّيَافَةِ وَالْهَدِيَّةِ، حَيْثُ جُوزَ قَبُولُ هَدِيَّةِ ذِي الرَّحْمِ
الْمَحْرَمِ، وَلَمْ يَجُزْ حُضُورُ دَعْوَتِهِ، وَمَا ذَكَرُوا فِي الْهَدِيَّةِ، مَحْمُولٌ عَلَى مَا
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَهَادَاةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ، صِلَةُ لِلرَّحْمِ. (العناية شرح الهداية،

أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا، لَا يَتَّخِذُهَا⁽²⁾

(شُهُودُ الْقَاضِي الْجَنَائِزِ)

قَالَ: (وَيَشْهَدُ⁽³⁾ الْجَنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ⁽⁴⁾)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ⁽⁵⁾. قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ"⁽⁶⁾. وَعَدَّ مِنْهَا⁽⁷⁾ هَذَيْنِ⁽⁸⁾.

273/7؛ البناية شرح الهداية، 22/9؛ فتح القدير، 273/7.

(1) أي تعريف الدعوة الخاصة.

(2) الدعوة العامة: هي التي يتخذها حضرها القاضي، أو لا.

(3) أي القاضي. (البناية شرح الهداية، 23/9).

(4) شريطة أن لا يكون للمريض خصومة مع أحد، فإن كانت له خصومة، فلا يعود. فإن لم يكن له خصومة، وعادة، فلا يطيل مكثه عنده. (تبيين الحقائق، 179/4).

(5) لأنه أمر مندوب إليه، وليس فيه تهمة ولا يمتنع عليه القيام بحقوق الناس بسبب تقلده القضاء (المبسوط، للسرخسي، 81/16).

(6) أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ". قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ، فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَصْحَكَ، فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمْدُ اللَّهِ، فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرَضَ، فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ، فَاتَّبِعْهُ". (صحيح مسلم، 4/1705، حديث رقم: 2162).

(7) أي من الست. (البناية شرح الهداية، 23/9).

(8) وهما شهادة الجنابة، وعيادة المريض. (البناية شرح الهداية، 23/9).

(حكم ضيافة القاضي للخصوم)

(وَلَا يُضَيَّفُ (1) أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ، دُونَ خَصْمِهِ (2)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَلِكَ (3). وَلِأَنَّ فِيهِ تَهْمَةً (4).)

(تَسْوِيَةُ الْقَاضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ)

قَالَ: (وَإِذَا حَضَرَ (5)، سَوَى (6) بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ (7)، وَالْإِقْبَالِ (8)؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ

(1) يقل: أضاف فلانا: أغاثه، وأجاره، وأنزله ضيفا عنده. (المعجم الوسيط، 547/1).

(2) لأن ذلك يكسر قلب الخصم الآخر، ويلحق به تهمة الميل. وفي التقييد بأحد الخصمين، إشارة إلى أنه لا بأس بأن يضيفهما جميعا؛ لأن تهمة الميل تنتفي عنه، إذا سوى بينهما. (اللباب في شرح الكتاب، 81/4).

(3) أخرجه الطبراني في الأوسط، عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي ﷺ أن يضيف أحد الخصمين، دون الآخر".

(4) أي تهمة الميل. (البنية، 24/9؛ فتح القدير، 274/7).

(5) أي الخصمان. (البنية شرح الهداية، 24/9).

(6) أي يجب على القاضي التسوية بين الخصمين.

(7) بين يديه. (اللباب في شرح الكتاب، 81/4).

(8) أراد بالإقبال: تسوية النظر من الجانبين. وكتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى - رضي الله عنه - أس بين الناس في مجلسك، ووجهك، وكذلك. (العناية، 274/7).

بِالْقَضَاءِ، فَلْيَسُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ، وَالْإِشَارَةَ، وَالنَّظَرَ⁽¹⁾. (وَلَا يُسَارُّ أَحَدُهُمَا⁽²⁾، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ⁽³⁾، وَلَا يُلْقِنُهُ حُجَّةً)؛ لِلتُّهْمَةِ⁽⁴⁾. وَلَئِنْ فِيهِ مَكْسَرَةٌ⁽⁵⁾ لِقَلْبِ الْآخَرِ، فَيَتْرَكَ حَقَّهُ⁽⁶⁾. (وَلَا يَضْحَكُ فِي وَجْهِ أَحَدِهِمَا⁽⁷⁾)؛ لِأَنَّهُ يَجْتَرِئُ عَلَى خَصْمِهِ⁽⁸⁾. (وَلَا يَمَازِحُهُمْ، وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمْ⁽⁹⁾)؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِمَهَابَةِ الْقَضَاءِ.

(1) أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فِي مَسْنَدِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَقْضِ وَهُوَ غَضَبَانِ، وَلَيْسُوا بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ، وَالْمَجْلِسِ، وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْقَ الْآخَرِ". (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ، 4/197، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 7021).

(2) أَيُّ لَا يَكْلُمُ الْقَاضِيَ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ سِرًّا، وَلَا بِلِسَانٍ لَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ، وَلَا يَخْلُو بِأَحَدٍ فِي مَنْزِلِهِ. (بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ، 7/9؛ الْعِنَايَةُ، 7/275؛).

(3) لَا بِيَدِهِ، وَلَا بِرَأْسِهِ، وَلَا بِعَيْنِهِ، وَلَا بِحَاجِبِيهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْهِي شَرْعًا. (الْعِنَايَةُ، 7/275؛ الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 9/24؛ مَجْمَعُ الْأَنْهَرِ، 2/159).

(4) أَيُّ تَهْمَةُ الْمِيلِ، وَلَئِنْ فِيهِ إِعَانَةٌ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، وَكَسَرَ قَلْبَ الْآخَرِ.

(5) الْمَكْسَرَةُ: بَفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ مِيمِي، بِمَعْنَى الْكُسْرِ. (الْبَنَاءُ، 9/24).

(6) لِأَنَّهُ يَتَجَنَّبُ عَنْ طَلَبِ حَقِّهِ، فَيَتْرَكَ حَقَّهُ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 9/24).

(7) أَيُّ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ. وَكَذَا الْقِيَامُ لَهُ بِالْأَوَّلَى. (الْبَنَاءُ، 9/25).

(8) بِسَبَبِ ضَحْكِ الْقَاضِي فِي وَجْهِهِ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 9/25).

(9) أَيُّ يَنْبَغِي عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَجْتَنِبَ الْمَزَاحَ مُطْلَقًا: مَعَهُمَا، أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا، أَوْ مَعَ غَيْرِهِمَا فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَفِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْمَهَابَةِ

(تَلْقِينُ الْقَاضِي الشَّاهِدَ)

قَالَ (1): (وَيَكْرَهُ تَلْقِينُ الشَّاهِدِ (2)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَقُولَ لَهُ: أَتَشْهَدُ بِكَذَا وَكَذَا، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، يَكْرَهُ (3)، كَتَلْقَيْنِ الْخَصْمَ (4)).

وَاسْتَحْسَنَهُ (5) أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ التُّهْمَةِ (6)؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يُحْصَرُ (7)؛ لِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ، فَكَانَ تَلْقِينُهُ (1) إِحْيَاءً لِلْحَقِّ (2)، بِمَنْزِلَةِ الْإِشْخَاصِ (3)، وَالتَّكْفِيلِ (4).

(1) أَيِ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي "الْجَامِعِ الصَّغِيرِ". (الْبَنَاءُ، 252/9)

(2) تَلْقِينُ الشَّاهِدِ: هُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَاضِي مَا يَسْتَفِيدُ بِهِ الشَّاهِدَ عِلْمًا، بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ. قَيَّدَ بِالشَّاهِدِ؛ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَلْقَنُ الْمُدَّعِي بِالْأُولَى. (الْعَنَاءُ، 276/7).

(3) لِأَنَّ الْقَاضِي مَنُهِىٌّ عَنْ اكْتِسَابِ مَا يَجْرُؤُ عَلَيْهِ تَهْمَةُ الْمِيلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ إِعَانَةٌ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، إِمَّا صَوْرَةً، أَوْ مَعْنَى، وَتَلْقِينُ الشَّاهِدِ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ.

(4) حَيْثُ يَكْرَهُ. وَكَرَاهَةُ تَلْقِينِ الْقَاضِي الشَّاهِدَ، هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْعَزِيمَةُ، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَاسْتَحْسَنَ التَّلْقِينَ؛ رَخْصَةً فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ. (الْعَنَاءُ شَرْحَ الْهَدَايَةِ، 276/7؛ الْبَنَاءُ شَرْحَ الْهَدَايَةِ، 25/9).

(5) أَيِ تَقْلِينِ الْقَاضِي الشَّاهِدَ. (الْبَنَاءُ شَرْحَ الْهَدَايَةِ، 25/9).

(6) وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ: "فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التُّهْمَةِ"؛ لِأَنَّ فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ، لَا يَجُوزُ ذَلِكَ التَّلْقِينُ بِالِاتِّفَاقِ. (الْعَنَاءُ شَرْحَ الْهَدَايَةِ، 276/7؛ الْبَنَاءُ شَرْحَ الْهَدَايَةِ، 25/9).

(7) أَيِ يَضِيقُ صَدْرَهُ، وَيَنْحَبِسُ لِسَانُهُ، عَنِ الْبَيَانِ. (الْبَنَاءُ، 25/9).

نماذج أسئلة:

- ما شروط صحة ولاية القاضي؟
- ما مدى أهلية الفاسق للقضاء؟
- حكم طروء الفسق على ولاية القاضي؟
- ما مدى صلاحية الفاسق للإفتاء؟
- ما مدى أهلية القاضي للاجتهاد؟، وهل يجوز تقليد الجاهل القضاء؟
- أهلية القاضي للاجتهاد، هل هو شرط صحة، وجواز، أم شرط أولوية، وندب، واستحباب؟
- حكم الدخول في القضاء
- هل يجوز للقاضي أن يقضي بين الخصوم في المسجد؟
- هل يقبل القاضي الهدية؟
- ما حكم إجابة القاضي الدعوة؟
- ما المقصود بتلقين القاضي الشاهد؟ ، وما حكمه؟ معالاستدلال

(1) أي الشاهد.

(2) لأن القضاء مشروع؛ لإحياء حقوق الناس، (العناية، 276/7).

(3) الأشخاص: هو إرسال شخص ليأتي بخصمه. (العناية 276/7).

(4) التكفيل: هو أخذ الكفيل؛ لأحد الخصمين. وكل من الأشخاص،

والتكفيل، مشروع؛ لأنه ليس فيه إغانة أحد الخصمين. تأخير قول أبي

يوسف، وتسميته بالاستحسان، دليل على أنه مختار المصنف. والفتوى

على قول أبي يوسف، فيما يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تجربته. (البنية شرح

الهداية، 25/9؛ البحر الرائق، 307/6).

(فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ⁽¹⁾)

(1) الْحَبْسُ لغة: المنع، وهو مصدر حبسته، من باب ضرب، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْبَسُ فِيهِ. وَيُجْمَعُ: عَلَى حُبُوسٍ، مِثْلُ: فَلَسٍ، وَفُلُوسٍ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "فَصْلٌ فِي الْحَبْسِ". أَي هَذَا فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْحَبْسِ. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فَصْلَ الْحَبْسِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ، وَالْحَبْسُ يَصْلَحُ لِلْعُقُوبَةِ، لَذَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ، وَجَعَلَهُ مِنْ جُمْلَتِهِ. وَأَفْرَدَهُ فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ؛ لِإِخْتِصَاصِهِ بِأَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ. (المصباح المنير، 118/1؛ العناية 277/7).

❁ وَالْحَبْسُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ، وَالسُّبَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْمَعْقُولِ: فَأَمَّا الْكِتَابُ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي قِطَاعِ الطَّرِيقِ: «أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ». [المائدة: 33]. وَالْمُرَادُ بِالنَّفْيِ فِي آيَةِ الْحَبْسِ. قَالَ الْجِصَّاصُ: وَاخْتَلَفَ فِي النَّفْيِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ حَبْسُهُ حَيْثُ يَرَى الْإِمَامُ. (أحكام القرآن، للجصاص، 4/58؛ تبين الحقائق، 4/179).

وَأَمَّا السُّبَّةُ: فَمَنْ يَهْزِ بِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَى عَنْهُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ، 4/28، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 1417. وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ"). وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ: فَلَأَنَّ الصَّحَابَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعِثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - لَمْ يَكُنْ سَجَنٌ، وَكَانَ يُحْبَسُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بَنِيَ السَّجْنَ وَكَانَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ بَنَاهُ فِي الْإِسْلَامِ وَسَمَّى السَّجْنَ نَافِعًا وَلَمْ يَكُنْ حَصِينًا فَانْقَلَتِ النَّاسُ مِنْهُ وَبَنَى سَجْنًا آخَرَ وَسَمَّاهُ مَخْيَسًا. (تبيين الحقائق، 4/179، 180؛ العناية شرح الهداية، 277/7). وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَلَأَنَّ الْقَاضِي نَصِبَ؛ لِإِصْلَاحِ الْحَقُوقِ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَإِنْ أَمْتَنَعَ الْمَطْلُوبُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الطَّالِبِ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي بَدٌّ مِنْ أَنْ يَجْبِرَهُ

(حَبْسُ الْغَرِيمِ بِسَبَبِ مُمَاطَلَتِهِ)

قَالَ: (وَإِذَا (1) ثَبَتَ الْحَقُّ (2) عِنْدَ الْقَاضِي (3)، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ (4)، لَمْ يُعَجَّلْ بِحَبْسِهِ (5)، وَأَمْرُهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ (6)، فَلَا بَدَّ مِنْ ظُهُورِهَا (7). وَهَذَا (8) إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كَوْنَهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ

عَلَى الْإِدَاءِ، وَلَا خِلَافَ أَنْ لَا جَبْرَ بِالضَّرْبِ، فَيَكُونُ بِالْحَبْسِ أَوْلَى.
(العناية شرح الهداية، 277/7، 278).

(1) تمت الدعوى. (اللباب في شرح الكتاب، 82/4).

(2) أَطْلَقَ الْحَقَّ، فَشَمَلَ الْقَلِيلَ وَالكَثِيرَ، وَلَوْ دَانِقًا، وَهُوَ سَدَسُ دِرْهَمٍ.
(العناية شرح الهداية، 278/7، 279/6، 309/6).

(3) تَقْيِيدُهُ بِالْقَاضِي؛ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّ الْمَحْكَمَ لَا يَحْبِسُ. (البحر
الرائق، 308/6).

(4) وَهُوَ قَبْدٌ لَزِمٌ. (رد المحتار على الدر المختار، 379/5).

(5) لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ ظُلْمُهُ. (الاختيار لتعليل المختار، 89/2).

(6) لِقَوْلِهِ ﷺ: "لِي الْوَاجِدُ، يَحِلُّ عَرْضُهُ، وَعَقُوبَتُهُ". قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَحِلُّ عَرْضُهُ؛ يَغْلُظُ لَهُ. وَعَقُوبَتُهُ: يَحْبِسُ لَهُ. (الحديث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سَنَنِهِ، 313/3، حَدِيثٌ رَقْمٌ: 3628. قَالَ الْحَاكِمُ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَخْرُجْهُ").

(7) أَيْ ظُهُورُ الْمُمَاطَلَةِ، وَلَمْ تَظْهَرْ بِمَجْرَدِ ثُبُوتِ الْحَقِّ بِالْإِقْرَارِ (البنية
، 26/9).

(8) أَيْ تَرَكَ الْقَاضِي عَجَلَتَهُ بِحَبْسِ الْغَرِيمِ. (البنية شرح الهداية، 27/9).

الْوَهْلَةُ⁽¹⁾، فَلَعَلَّهُ طَمَعَ فِي الْإِمْهَالِ، فَلَمْ يَسْتَصْحِبِ الْمَالَ⁽²⁾. فَإِذَا
امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، حَبَسَهُ؛ لظُهُورِ مَطْلِهِ. أَمَّا إِذَا ثَبَتَ⁽³⁾ بِالْبَيِّنَةِ⁽⁴⁾،
حَبَسَهُ⁽⁵⁾ كَمَا ثَبَتَ⁽⁶⁾؛ لظُهُورِ الْمَطْلِ بِإِنْكَارِهِ⁽⁷⁾.

(1) يُقَالُ: لَقِيْتُهُ أَوَّلَ وَهْلَةٍ: أَيِ أَوَّلِ كُلِّ شَيْءٍ. (البنائية شرح
الهداية، 27/9).

(2) وَإِنَّمَا يَظْهَرُ، إِذَا أَمَرَهُ بَعْدَ إِقْرَارِهِ، فَاْمْتَنَعَ. (فتح القدير، 278/7).

(3) أَيِ الْحَقِّ الَّذِي ادَّعَاهُ وَلَوْ دَانَقًا. (مجمع الأنهر، 160/2).

(4) أَوْ بِالْأَكُولِ. (البحر الرائق، 6/308؛ رد المحتار، 5/379).

(5) إِلَّا إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ فِيمَا يَقْبَلُ فِيهِ دَعْوَاهُ، وَلَوْ قَالَ: أَمَهْلَنِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛
لأَدْفَعُهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ يَمَهْلُ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْقَوْلِ مَمْتَنِعًا مِنَ الْأَدَاءِ، وَلَا
يَحْبِسُ (رد المحتار، 5/379، 380).

(6) أَيِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْإِقْرَارِ، إِنْ طَلَبَ الْخَصْمُ حَبْسَهُ. (مجمع
الأنهر، 160/2).

(7) وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا. وَعَنْ شَمْسِ الْأُئِمَّةِ السَّرْحَسِيِّ عَكْسُ هَذَا: وَهُوَ
أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْبَيِّنَةِ، لَا يَحْبِسُهُ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَذِرُ بِأَنِّي مَا كُنْتُ
أَعْلَمُ لَهُ دِينًا عَلَيَّ، فَإِذَا عَلِمْتُ الْآنَ، لَا أَتَوَانِي فِي قَضَائِهِ. بِخِلَافِهِ
بِالإِقْرَارِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالذَّيْنِ، وَلَمْ يَقْضِهِ، حَتَّى أَحُوجَّهُ إِلَى شِكْوَاهُ.
(العناية شرح الهداية، 278/7).

(حَبَسُ الْمَدِينِ بِكُلِّ دَيْنٍ بَدَلَ مَالٍ، أَوْ التَّزَمَهُ بِعَقْدٍ، وَإِنْ ادَّعَى الْفَقْرَ) قَالَ: (فَإِنْ اِمْتَنَعَ⁽¹⁾، حَبَسَهُ⁽²⁾) فِي كُلِّ دَيْنٍ⁽³⁾ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ، كَثَمَنِ الْمَبِيعِ⁽⁴⁾، أَوْ التَّزَمَهُ بِعَقْدٍ، كَالْمَهْرِ⁽⁵⁾، وَالْكَفَالَةِ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ⁽⁷⁾، ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ⁽⁸⁾،

(1) أي الغريم، بعد أمره بقضائه (البنية، 27/9؛ فتح القدير، 279/7).

(2) حبسه القاضي، وإنما يحبسه إذا كان موسرا، أما إذا كان معسرا لا يحبسه.

(3) هذا قيد؛ ليخرج ما لم يكن ديناً مطلقاً، كالنفقة، وغيرها. (العناية، 279/7،

(4) وبَدَلَ الْقَرْضِ، وَالْمَغْصُوبِ، وَالْأَجْرَةِ الْوَاجِبَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْمَنَافِعِ. وَمَا عَلَى الْمُشْتَرِيِّ، وَمَا عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فسخِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا، بِإِقَالَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَرَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ. (الجوهر النيرة، 242/2، 243؛ البحر الرائق، 309/6.)

(5) وبَدَلَ الْخُلْعِ. (دُرَرُ الْحُكَامِ شرح غرر الأحكام، 407/2).

(6) إِذَا طَلَبَ الْخَصْمُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ (العناية، 278/7؛ البنية، 27/9)

(7) أي المال الذي هو ثمن المبيع، ونحوه، من أي جهة كان. (البنية، 27/9،

(8) وزَوَالُهُ عَنْ الْمَلِكِ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّابِتُ لَا يَتْرَكَ بِالْمُحْتَمَلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ الْفَقْرُ، وَالْغِنَى حَادِثٌ، فَوَجِبَ اسْتِصْحَابُ الْمَالِ، حَتَّى يَعْلَمَ حَدُوثَ مَا يَخَالِفُهُ. وَمَا كَانَ بَدَلًا عَنْ مَالٍ، فَقَدْ عُلِمَ حُصُولُ الْغِنَى بِهِ، فَسَقَطَ حُكْمُ الْأَصْلِ. وَوَجِبَ اسْتِصْحَابُ الْغِنَى، حَتَّى يَعْلَمَ زَوَالَهُ، فَهَذَا لَمْ يَصْدُقْ فِي الْاِعْتِبَارِ، وَصَارَ امْتِنَاعُهُ ظُلْمًا، فَحَبَسَ لِأَجْلِهِ. (العناية، 279/7؛ البنية، 28/9).

وإِقْدَامُهُ عَلَى التَّزَامِهِ⁽¹⁾ بِاخْتِيَارِهِ، دَلِيلُ يَسَارِهِ؛ إِذْ هُوَ⁽²⁾ لَا يَلْتَزِمُ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى آدَائِهِ⁽³⁾. وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ: مَعْجَلُهُ⁽⁴⁾، دُونَ مُوَجَّلِهِ⁽⁵⁾

(لَا يُحْبَسُ الْمَدِينُ فِي غَيْرِ دَيْنٍ بَدَلَ مَالٍ، أَوْ التَّزَامَهُ بِعَقْدٍ، إِذَا ادَّعَى الْفَقْرَ)

قَالَ: (وَلَا يُحْبَسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ⁽⁶⁾) إِذَا قَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ، إِلَّا أَنْ يُثَبَّتَ غَرِيمُهُ⁽⁷⁾ أَنْ لَهُ مَالًا، فَيُحْبَسُهُ⁽⁸⁾؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَوْجَدْ دَلَالَةُ الْيَسَارِ⁽⁹⁾، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَعَلَى الْمُدَّعِي

(1) بعقد كالمهر، والكفالة. (البنية شرح الهداية، 28/9).

(2) أي لأنه. (البنية شرح الهداية، 28/9).

(3) فإذا ادعى الإعسار، يريد إسقاطها عن نفسه، فلا يقبل قوله، ويحبس.

(4) قيد بالمعجل؛ لأنه لا يحبس في المؤجل، ويصدق في الإعسار، وعليه الفتوى. (مجمع الأنهر، 161/2).

(5) لأن العادة جرت بتسليم المعجل، فكان إقدامه على النكاح، دليلاً على قدرته. فلا يقبل قوله: إنه معسر. (العناية، 279/7؛ البنية، 29/9).

(6) أي لا يحبسه في غير ما ذكرنا من الديون، وذلك مثل: أروش الجنيات، ونفقة الأقارب، والزوجات وإعتاق العبد المشترك، وضمان المتلفات؛ لأن ذلك مما ليس ببذل مال، ولا ملتزم بعقد. (الاختيار لتعليق المختار، 90/2؛ البنية شرح الهداية، 29/9).

(7) أي المدعي.

(8) حينئذ. (فتح القدير، 279/7).

(9) أي قدرته على الدين المدعى به. (فتح القدير، 280/7).

إثباتُ غناه. ويروى⁽¹⁾ أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدِّينُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ⁽²⁾؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعُسْرَةُ.⁽³⁾ ويروى⁽⁴⁾ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ⁽⁵⁾، إِلَّا فِيمَا بَدَلَهُ مَالٌ⁽⁶⁾. وفي النفقة⁽⁷⁾، القول قول الزوج: إنه

(1) عَنِ الْخَصَافِ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ. (تبيين الحقائق، 4/180؛).

(2) أَي فِيمَا كَانَ بَدَل مَالٍ، أَوْ لَزِمَهُ بَعْدُ، أَوْ حَكَمًا لِفَعْلِهِ، لَا لَعَدِّهِ، كَالِاتِّلَافِ، وَضَمَانِ الْغَضَبِ. (العناية شرح الهداية، 7/279، 280؛ فتح القدير، 7/280).

(3) فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ؛ إِذِ الْأَصْلُ أَنَّ الْإِئْمَى يُؤَدُّ فَقِيرًا، لَا مَالَ لَهُ، وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا، وَالْقَوْلُ قَوْلٌ مِنْ تَمَسُّكِ بِالْأَصْلِ، حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَدْيُونِ مَعَ يَمِينِهِ. (تبيين الحقائق، 4/180؛ العناية شرح الهداية، 7/279، 280؛).

(4) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَاخْتَارَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَلْجِيُّ. (تبيين الحقائق، 4/180؛ العناية شرح الهداية، 7/280؛ فتح القدير، 7/280).

(5) أَيِ لِلْمَدْيُونِ. (فتح القدير، 7/280).

(6) كِبْدَلِ الْقَرْضِ، وَثَمَنِ الْمَبِيعِ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ عَرِفَ دُخُولَ شَيْءٍ فِي مَلِكِهِ، وَزَوَالَهُ مُحْتَمَلٌ. وَمَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُهُ مَالًا، كَالْمَهْرِ، وَبَدَلِ الْخَلْعِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَلِكِهِ شَيْءٌ، وَلَمْ يَعْرِفْ قُدْرَتَهُ عَلَى الْقَضَاءِ، فَبَقِيَ مَتَمَسِّكًا بِالْأَصْلِ، وَهُوَ الْعُسْرَةُ (العناية، 7/280؛ فتح القدير، 7/280).

(7) بَيَانٌ لِمَا هُوَ الْمُحْفَظُ مِنَ الرِّوَايَةِ، نَصًّا عَنْ أَصْحَابِنَا بِلَا خِلَافٍ. (العناية شرح الهداية، 7/280؛ فتح القدير، 7/280).

مُعَسَّرٌ⁽¹⁾. وَفِي إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ، الْقَوْلُ لِلْمُعْتَقِ⁽²⁾.
وَالْمَسْأَلَتَانِ⁽³⁾ تَوْدِيَانِ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ⁽⁴⁾، وَالتَّخْرِيجُ عَلَى مَا قَالَ
فِي الْكِتَابِ⁽⁵⁾، أَنَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مُطْلَقٍ، بَلْ هُوَ صِلَةٌ، حَتَّى تَسْقُطَ

(1) يَعْنِي إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، أَنَّهُ مُوسِرٌ؛ لَتَأْخُذَ نَفَقَةَ الْيَسَارِ،
وَقَالَ: إِنَّهُ مُعَسَّرٌ؛ لِيُعْطِيَ نَفَقَةَ الْإِعْسَارِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ. (العناية شرح
الهداية، 281/7؛ البناية شرح الهداية، 30/9؛ فتح القدير، 280/7).

(2) يَعْنِي أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا أَعْتَقَ إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ
مُعَسَّرٌ، فَلَا يَضْمَنُ لِلْسَّائِكَةِ شَيْئًا، وَلَكِنْ يَسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَقَالَ شَرِيكُهُ: بَلْ
مُوسِرٌ؛ لِيَضْمَنَهُ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُعْتَقِ. (تبيين الحقائق، 181/4؛ العناية
شرح الهداية، 281/7).

(3) وَهُمَا مَسْأَلَةُ النِّفَقَةِ، إِعْتَاقُ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ. (البناية شرح
الهداية، 30/9).

(4) أَيِ تَوْدِيَانِ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، يَعْنِي قَوْلَ الْقَائِلِ: الْقَوْلُ لِمَنْ عَلَيْهِ فِي
جَمِيعِ ذَلِكَ. وَقَوْلَ الْقَائِلِ: الْقَوْلُ لِمَنْ عَلَيْهِ إِلَّا فِيمَا بَدَلَهُ مَالٌ. أَمَّا تَأْيِيدُهُمَا
الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَوْلَ قَوْلَ الزَّوْجِ، وَالْمُعْتَقِ، فَلَوْ كَانَ الصَّحِيحُ مَا ذَكَرَ
أَوَّلًا، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ، وَالشَّرِيكِ السَّائِكَةِ فِي دَعْوَى الْيَسَارِ. وَأَمَّا
تَأْيِيدُهُمَا الثَّانِي؛ فَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الْمَهْرِ، وَبَدَلُ الْعَتَقِ مَالًا، جَعَلَ
الْقَوْلَ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ، فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْقَوْلَانِ الْأَخِيرَانِ. (العناية
شرح الهداية، 281/7؛ فتح القدير، 281/7).

(5) أَيِ تَخْرِيجِ مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ، وَالْإِعْتَاقِ، عَلَى وَجْهِ لَا يَرُدُّ نَقْضًا عَلَى مَا
قَالَ الْقُدُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي "مِخْتَصَرِهِ" حَيْثُ قَالَ: "حَبْسُهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ
لِزِمِهِ، بِدَلَالَةٍ عَنْ مَالٍ، أَوْ التَّزَمُّ بِعَقْدٍ؛ لِأَنَّ الْمَرَادَ بِالذَّيْنِ، هُوَ الْمَطْلُوقُ مِنْهُ؛
إِذَا بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْتِدْلَالُ عَلَى الْقُدْرَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْخُلَاصُ

النَّفَقَةُ⁽¹⁾ بِالْمَوْتِ عَلَى التَّفَاقُقِ⁽²⁾ وَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ضَمَانُ الْإِعْتِاقِ⁽³⁾ ثُمَّ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدْعَى: إِنْ لَهُ مَالًا، أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ⁽⁴⁾ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ، يَحْبِسُهُ⁽⁵⁾ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً⁽⁶⁾، ثُمَّ يَسْأَلُ⁽⁷⁾ عَنْهُ⁽⁸⁾ . فَالْحَبْسُ؛

منه في حياته، ومماته من جهته إلا بالإيفاء، وأقدم عليه، دلَّ على أنه قادر عليه. (العناية، 281/7؛ البناية شرح الهداية، 30/9).

(1) أي نفقة الأيام الماضية. (تبيين الحقائق، 182/4).

(2) فلو كان ديناً صحيحاً، مطلقاً، لم يسقط إلا بالأداء، أو بالإبراء، لأن الدين الصحيح، هو ما لا يسقط إلا بإبراء من له، أو بإيفاء من عليه. (العناية، 282/7).

(3) فإن المريض إذا أعتق في مرض موته عبداً مشتركاً، لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلما كان كذلك، لم ترد هاتان المسألتان نقضاً للقول الأول، وهو قوله: "حبسه في كل دين ... إلى آخره"؛ لأن المراد بالدين: هو المطلق منه؛ إذ به يحصل الاستدلال على القدرة. (البناية شرح الهداية، 30/9).

(4) أو بنكول المدعى عليه، أو بإقراره. (تبيين الحقائق، 181/4).

(5) أي الحاكم. (العناية، 282/7؛ البناية شرح الهداية، 30/9).

(6) وهو رواية محمد، عن أبي حنيفة، في كتاب الحوالة، والكفالة. (البناية، 30/9).

(7) جيرانه، وأهل خبرته. (العناية شرح الهداية، 282/7).

(8) عن يمينه، وإعساره، بعد ما حبسه قدر ما يراه، فإن سأل عنه، فقامت بيينة على عسرتة، أخرجه القاضي من الحبس، وإن شهد شاهدان عنده، أنه قادر على قضاء الدين، أبد حبسه. ولا يحتاج في البيينة إلى لفظة

لظهور ظلمه في الحال⁽¹⁾. وإنما يحبسهُ مدة؛ ليظهر ماله⁽²⁾ لو كان يخفيه، فلا بد من أن تمتد المدة؛ ليفيد هذه الفائدة⁽³⁾، فقدره⁽⁴⁾ بما ذكره⁽⁵⁾. ويروى غير ذلك⁽⁶⁾ من التقدير بشهر⁽⁷⁾، أو أربعة، إلى ستة أشهر⁽⁸⁾. والصحيح: أن التقدير⁽⁹⁾ مفوض إلى رأي القاضي⁽¹⁰⁾؛ لاختلاف أحوال الأشخاص فيه⁽¹⁾. قال:

الشهادة، والعدد، بل إذا أخبر بذلك ثقة عمل بقوله، والاثنان أجوط، إذا لم يكن حال منازعة. وهذا السؤال من القاضي عن حال المدين بعد ما حبسه، احتياط، وليس بواجب. (العناية، 282/7، 283)

(1) بالمطل في الحال. (العناية شرح الهداية، 282/7).

(2) فيؤدي ما عليه. (فتح القدير، 282/7).

(3) أي ظهور ماله لو كان يخفيه. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(4) أي محمد بن الحسن - رحمه الله. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(5) وهو شهران، أو ثلاثة. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(6) أي غير الشهرين، أو الثلاثة. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(7) وهو إختيار الطحاوي؛ لأن ما زاد على الشهر في حكم الأجل، وما دون الشهر في حكم العاجل، فصار أدنى الأجل شهرا، والأقصى لا غاية له، فيقدر بشهر. قال شمس الأئمة الحلواني: وهو أرفق الأقاويل في هذا الباب. (العناية، 282/7)

(8) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. (العناية، 282/7).

(9) في مدة الحبس. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(10) ذكر هشام عن محمد نحوه، وكذا الصدر الشهيد، فالتقدير في هذا غير معتبر، بل هو مفوض إلى رأي القاضي. (فتح القدير، 282/7).

(فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ⁽²⁾، خَلَّى سَبِيلَهُ⁽³⁾)، يَعْنِي بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ⁽⁴⁾؛ لَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ النَّظْرَةَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ⁽⁵⁾، فَيَكُونُ حَبْسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُلْمًا. وَلَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِفْلَاسِهِ قَبْلَ الْمُدَّةِ⁽⁶⁾، تُقْبَلُ⁽⁷⁾ فِي

(1) أَيِ فِي احْتِمَالِ الْحَبْسِ؛ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَضْجُرُ فِي السِّجْنِ فِي مَدَّةٍ قَلِيلَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَضْجُرُ كَثِيرَ ضَجْرٍ بِمِقْدَارِ تِلْكَ الْمُدَّةِ الَّتِي ضَجَرَ الْآخِرُ؛ فَقَوِّضْ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْحَاكِمِ. (العناية شرح الهداية، 282/7).

(2) أَيِ لَمْ يَظْهَرْ لِلْمَحْبُوسِ، أَوْ لِلْغَرِيمِ مَالٌ. (العناية شرح الهداية، 283/7).

(3) وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرَمَائِهِ. (البنية شرح الهداية، 31/9).

(4) أَيِ الَّتِي رَأَاهَا الْقَاضِي بِرَأْيِهِ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي اخْتَارَهَا بَعْضُ الْمَشَايِخِ، كَشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (العناية شرح الهداية، 283/7).

(5) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ». [البقرة: 280]. (تبيين الحقائق، 181/4؛ العناية شرح الهداية، 283/7).

(6) بِأَنْ أَخْبَرَ وَاحِدٌ ثَقَّةً، أَوْ اثْنَانِ، أَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ، أَنَّهُ مَقْلُوبٌ، مُعْجَمٌ، لَا نَعْلَمُ لَهُ مَا لَا سِوَى كَسَوْتِهِ الَّتِي عَلَيْهِ، وَثِيَابَ لَيْلِهِ، وَقَدْ اخْتَبَرْنَا أَمْرَهُ، سِرًّا وَعَلَانِيَةً (العناية 283/7).

(7) أَيِ الْبَيِّنَةِ. (البنية شرح الهداية، 32/9).

رواية. ولَا تُقْبَلُ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ عَامَّةُ الْمَشَايخ (1) -
رَحِمَهُمُ اللَّهُ (2).

قَالَ فِي الْكِتَابِ: (خُلِيَ سَبِيلُهُ، وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرْمَائِهِ (3)،
وَهَذَا كَلَامٌ (4) فِي الْمُلَازِمَةِ (5)، وَسَنَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجَرِ (6) إِنْ
شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَجُلٌ أَقْرَأَ عِنْدَ الْقَاضِي

(1) وقال الصدر الشهيد - رحمه الله: "هو الصحيح". (البنية شرح
الهداية، 32/9).

(2) وَإِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى إِعْسَارِهِ قَبْلَ الْحَبْسِ؛ فَعِنَ مُحَمَّدٍ فِيهِ رَوَايَتَانِ: فِي
رِوَايَةٍ تَقْبَلُ، يَحْبِسُهُ، وَبِهِ كَانَ يَفْتِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
الْفَضْلِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَمَادٍ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَفِي
أُخْرَى، وَعَلَيْهَا عَامَّةُ مَشَايِخ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ، أَنَّهُ يَحْبِسُهُ، وَلَا يَلْتَقِثُ إِلَى هَذِهِ
الْبَيِّنَةِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْإِعْسَارِ، بَيِّنَةٌ عَلَى النَّفْيِ، فَلَا تَقْبَلُ حَتَّى تَتَأَيَّدَ بِمُؤَيِّدٍ،
وَبَعْدَ مَضِيِّ الْمُدَّةِ تَأَيَّدَتْ؛ إِذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ، لَمْ يَتَحَمَّلْ ضَيْقَ
السَّجْنِ، وَمِرَارَتِهِ. (العناية، 283/7؛ البنية، 32/9؛ .).

(3) أَيِ لَا يَمْنَعُهُمْ عَنِ مِلَازِمَتِهِ، بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ. فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ
لِرَجُلٍ عَلَى امْرَأَةٍ، لَا يُلَازِمُهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُلُوةِ بِهَا، وَلَكِنْ يَبْعَثُ امْرَأَةً
أَمِينَةً تُلَازِمُهَا. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ،
وَمُحَمَّدٌ، وَزُفَرٌ: يَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَظَرٌ بِإِنْظَارِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْمَيْسَرَةِ.
(تبيين الحقائق، 181/4؛ الجوهرة النيرة، 243/2).

(4) يَعْنِي الْمَنْعَ عَنِ مِلَازِمَةِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ.

(5) هَلْ لِلطَّالِبِ ذَلِكَ، أَوْ لَا. (العناية، 283/7؛ البنية، 32/9).

(6) فِي بَابِ الْحَجَرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ. (العناية شرح الهداية، 284، 283/7).

بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يُحْبِسُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَبَدَ حَبْسَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا خَلَّى سَبِيلَهُ⁽¹⁾.

ومُراده: إذا أقرَّ عند غير القاضي، أو عنده مرة، وظهرت مماطلته⁽²⁾. والحبس أولاً، ومدته، قد بيناه، فلا نعيده⁽³⁾.

(1) إنما ذكر رواية الجامع الصغير ههنا؛ لأن رواية لجامع من حيث الظاهر، تخالف ما جاء في أول الفصل - من كلام القدوري - أن الحق إذا ثبت بالإقرار، لا يحبس، أول وهلة. ورواية "الجامع الصغير" تدل على جواز الحبس متصلاً بالإقرار، فثبت التناقض بين الروایتين، فذكر رواية الجامع الصغير، كما هي، ثم ذكر تأويلها، بقوله: "ومراده إذا أقر...؛ إزالة للتناقض الثابت من حيث الظاهر. (العناية، 284/7).

(2) يعني مراد محمد - رحمه الله - فيما إذا ثبت الحق بالإقرار، ثم ثبتت المماطلة، فترافعا إلى القاضي، فحينئذ يحبس لا بمجرد الإقرار. قال فخر الإسلام: معني المسألة: إذا كان جاحداً فأقرَّ عند القاضي، وظهر للقاضي جحوده عند غيره، ومماطلته، أو ظهر له مماطلته بعد، ما أقرَّ عند غيره، فحينئذ يحبس؛ لما مر. فأما إذا أقر مرة، فلا يحبس. (تبيين الحقائق، 181/4، 182؛ البناية شرح الهداية، 33/9).

(3) يعني أن المذكور في الجامع الصغير من الحبس أولاً، ومدته، على ما بينا، ليس فيه مخالفة لما بيناه، فيحتاج إلى ذكره لها، فلا نعيده. (العناية شرح الهداية، 284/7).

❁ خلاصة المسألة: لا يحبس القاضي المدين في غير دين بدل مال، أو التزمه بعقد، كأروش الجنایات، ونفقة الأقارب، والزوجات، إذا ادعى المدين الفقر، إلا أن يثبت المدعي أن له مالاً، أو يثبت ذلك ببيته، أو بنكول المدعى عليه، أو بإقراره، فيحبسه القاضي شهراً، أو شهرين، أو

(مَا يُحْبَسُ الرَّجُلُ بِسَبَبِهِ مِنَ النَّفَقَاتِ، وَمَا لَنَا يُحْبَسُ)
 قَالَ: (وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ)؛ لَأَنَّهُ ظَالِمٌ
 بِالْامْتِنَاعِ⁽¹⁾. (وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ⁽²⁾)⁽³⁾؛ لَأَنَّهُ⁽⁴⁾ نَوْعُ
 عُقُوبَةٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ، كَالْحُدُودِ، وَالْقَصَاصِ⁽⁵⁾.

ثَلَاثَةً، أَوْ أَرْبَعَةً، أَوْ سِتَّةً، ثُمَّ يَسْأَلُ جِيرَانَهُ، وَأَهْلَ خَبَرَتِهِ، عَنْ يَسَارِهِ،
 وَإِعْسَارِهِ، فَإِنْ قَامَتِ بَيْنَهُ عَلَى عَسْرَتِهِ، أَخْرَجَهُ الْقَاضِي مِنَ الْحَبْسِ، وَإِنْ
 شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَهُ، أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى قِضَاءِ الدَّيْنِ، أَبَدَ حَبْسَهُ. وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ
 لِلغَرِيمِ مَالٌ، بَعْدَ مِضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي رَأَاهَا الْقَاضِي بِرَأْيِهِ، أَوْ بَعْدَ مِضِيِّ الْمُدَّةِ
 الَّتِي اخْتَارَهَا بَعْضُ الْمَشَايِخِ، كَشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، خَلِيَ سَبِيلَهُ، وَلَا يَحُولُ
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرْمَانِهِ، بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ.

(1) إِذَا فَرَضَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ، أَوْ اصْطَلَحَا عَلَى مِقْدَارٍ،
 وَلَمْ يَنْفِقْ عَلَيْهَا، وَرَفَعَتْ إِلَى الْحَاكِمِ حَبْسَهُ؛ لِيُظْهَرَ ظُلْمُهُ بِالْامْتِنَاعِ. فَأَمَّا
 بِمَجَرَّدِ فَرْضِهَا، لَوْ طَلَبَتْ حَبْسَهُ، لَمْ يُحْبَسْ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ تَسْتَحِقُّ بِالظُّلْمِ،
 وَالظُّلْمُ بِالْمَنْعِ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَلَمْ يَنْتَحِقِ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَفْرِضْ
 لَهَا، وَلَمْ يَنْفِقِ الرُّوجَ عَلَيْهَا فِي يَوْمٍ، يَنْبَغِي إِذَا قَدَّمَتْهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَنْ
 يَأْمُرَهُ بِالْإِنْفَاقِ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَمْ يَنْفِقِ، أَوْجَعَهُ عُقُوبَةً، وَإِنْ كَانَتْ التَّفَقُّةُ سَقَطَتْ
 بَعْدَ الْوُجُوبِ، فَهُوَ ظَالِمٌ لَهَا. (الْعُنَايَةُ، 284/7؛ فَتْحُ الْقَدِيرِ، 284/7).

(2) وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَالْجَدَّاتُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَصَاحِبَةٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ أُمِرَ بِهَا.

(3) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ مِنْ كَلَامِ الْقُدُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

(4) أَيِ لِأَنَّ الْحَبْسَ. (الْبَيَانَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 33/9).

(5) وَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَالِدُ عُقُوبَةَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الشَّافِيَّ لَمَّا حَرَّمَ؛ لِقَوْلِهِ

تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾. [الْإِسْرَاءُ:

23]. كَانَ الْحَبْسُ حَرَامًا؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ. وَكَذَا لَا يَحُدُّ لَهُ إِذَا قَذَفَهُ، وَلَا يَقْتَصُّ

(إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ⁽¹⁾؛ لِأَنَّ فِيهِ⁽²⁾ إِحْيَاءَ لَوْلَدِهِ⁽³⁾).
وَلِأَنَّهُ لَا يَتَذَرُكَ لِسُقُوطِهَا⁽⁴⁾ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ⁽⁵⁾.

نماذج أسئلة:

- إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ، فَهَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَهُ؟ مَعْلَلًا لِمَا تَذَكَّرَ
- مَا الدِّيونُ الَّتِي يَحْبِسُ فِيهَا الْمَدِينُ؟

- منه إِذَا قَتَلَهُ. (العناية شرح الهداية، 284/7)
- (1) فَإِنَّهُ يَحْبِسُ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ التَّقَّةُ، فَأَبَى عَنِ الْإِنْفَاقِ، أَمَا كَانَ، أَوْ أُمًّا، أَوْ جَدًّا. (فتح القدير، 285/7).
- (2) أَيِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ. (البنية شرح الهداية، 34/9).
- (3) وَفِي تَرْكِهِ الْإِنْفَاقِ سَعْيٍ فِي هَلَاكِهِ، فَيَحْبِسُ؛ لِدَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِقَتْلِهِ إِذَا شَهِرَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، وَلَمْ يُمْكِنَ دَفْعُهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ. (تبيين الحقائق، 182/4).
- (4) أَيِ لِسُقُوطِ التَّقَّةِ عَلَى الْوَلَدِ. (فتح القدير، 285/7).
- (5) وَلِأَنَّ دِينَ التَّقَّةِ يَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، فَلَوْ لَمْ يَحْبَسْ عَلَيْهَا، تَقَوَّتْ، بِخِلَافِ سَائِرِ الدِّيُونِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، فَلَا يَخَافُ فِيهَا الْفَوَاتُ، فَافْتَرَقَا فِي هَذَا الْحَاكِمِ، فَيَفْتَرِقَانِ فِي حَقِّ الْحَبْسِ. (تبيين الحقائق، 182/4).

❁ خلاصة المسألة: يَحْبِسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ، إِذَا فَرَضَ الْقَاضِي عَلَيْهِ النَفَقَةَ، أَوْ إِصْطَلَحَا عَلَى مَقْدَارٍ، وَلَمْ يَنْفَقْ عَلَيْهَا، وَرَفَعَتْ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ. وَلَا يَحْبِسُ وَالِدٌ - وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَالْجَدَّاتُ - فِي دَيْنِ وَلَدِهِ، إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَحْبِسُ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ التَّقَّةُ، فَأَبَى عَنِ الْإِنْفَاقِ، أَمَا كَانَ، أَوْ أُمًّا، أَوْ جَدًّا.

- مَا يُحْبَسُ الرَّجُلُ بِسَبَبِهِ مِنَ النَّفَقَاتِ، وَمَا لَا يُحْبَسُ
- هل يحبس القاضي المدين في غير دين بدل مال، أو التزمه بعقد، كأروش الجنایات، ونفقة الأقارب، والزوجات، إذا ادعى المدين الفقر؟
- هل يحبس الرجل في نفقة زوجته؟

الفصل الثالث

(بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي⁽¹⁾)

(كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحُقُوقِ الَّتِي تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ) قَالَ: (وَيَقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي⁽²⁾ فِي الْحُقُوقِ⁽³⁾)، إِذَا شُهِدَ⁽⁴⁾ بِهِ⁽⁵⁾ عِنْدَهُ⁽⁶⁾؛

(1) أي هذا باب في بيان حكم كتاب القاضي إلى القاضي. وأورد هذا الباب بعد فصل الحبس؛ لأنَّ هذا من عمل القضاء أيضاً، إلا أنَّ السجن يتم بقاض واحد، وهذا باثنين، والواحد قبل الاثنين. (العناية، 285/7؛ البناء شرح الهداية، 35/9).

(2) وإنما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، إذا كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام، فصاعداً، أمَّا إذا كان أقلَّ من ذلك، لا يقبل. (الجوهرية النيرة، 243/2).

(3) أي التي تثبت مع الشُّبُهَاتِ، بخلاف الحدود والقصاص؛ وذلك؛ لأنَّ كتاب القاضي إلى القاضي، بمنزلة الشهادة على الشهادة؛ لأنَّ كتابه ينقل شهادة الأصول، كما أنَّ الفروع ينقلون بشهادتهم شهادة الأصول، ثمَّ الشهادة على الشهادة، لا تجوز في الحدود والقصاص؛ فكذلك كتاب القاضي فيه؛ لأنَّ فيه شبهة البدلية، والحدود والقصاص يسقط بالشُّبُهَاتِ. (العناية، 285/7؛ البناء شرح الهداية، 35/9؛ فتح القدير، 285/7).

(4) بضم الشين، بالبناء بالمجهول. (العناية، 285/7).

(5) أي بالكتاب. (البناء شرح الهداية، 35/9؛ فتح القدير، 285/7).

(6) أي عند القاضي المكتوب إليه أنه كتاب فلان القاضي، وختمه (العناية، 285/7).

لِلْحَاجَةِ (1) عَلَى مَا نُبَيِّنُ (2). (فَإِنْ شَهِدُوا (3) عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ (4)، حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ (5) لَوْجُودِ الْحُجَّةِ (6). (وَكُتِبَ بِحُكْمِهِ (7) وَهُوَ الْمَدْعُوُّ سَجِلًا (8). (وَإِنْ شَهِدُوا بِهِ بِغَيْرِ حَضَرَةِ الْخَصْمِ، لَمْ

(1) أي حاجة الناس إليه. (البنية شرح الهداية، 35/9).

(2) إشارة إلى قوله بعد هذا: "لمساس الحاجة ... إلى آخره". (البنية 35/9).

(3) عند القاضي الكاتب. (اللباب في شرح الكتاب، 84/4).

(4) المراد بالخَصْمِ الْحَاضِرِ: مَنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ، أَوْ مَسْخَرًا: وَهُوَ مَنْ يَنْصِبُهُ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنِ الْغَائِبِ؛ لِيَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَإِلَّا لَوْ أَرَادَ بِالْخَصْمِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ، لَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ إِلَى الْكِتَابِ إِلَى الْقَاضِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ حَاضِرَ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ. (البنية 35/9، 36؛ فتح القدير، 285/7، 286).

(5) على قواعد مذهبه. (اللباب في شرح الكتاب، 84/4).

(6) وَلِحُضُورِ الْخَصْمِ. (تبيين الحقائق، 184/4).

(7) إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّتِي فِيهَا الْمَوْكَلُ؛ لِيَقْتَضِيَ مِنْهُ الْحَقَّ. وَصُورَتُهُ: رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً، أَوْ أَقَرَّ بِذَلِكَ، فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، يَكْتُبُ هَذَا الْقَاضِي كِتَابًا إِلَى ذَلِكَ الْقَاضِي؛ مَخَافَةَ أَنْ يَنْكَرَهُ، فَيَأْخُذَهُ بِالْكِتَابِ. (الجوهرة النيرة، 244/2؛ فتح القدير، 286/7).

(8) أَيْ كِتَابِ الْحُكْمِ يُسَمَّى سَجِلًا فِي عَرَفِهِمْ؛ لِأَنَّ السَّجِلَ لَا يَكُونُ إِلَّا عِنْدَ الْحُكْمِ. وَإِنَّمَا يَكْتُبُ حَتَّى لَا تَنْسَى الْوَاقِعَةَ عَلَى طَوْلِ الزَّمَانِ وَلِيَكُونَ الْكِتَابُ مَذْكَرًا لَهَا. (تبيين الحقائق، 184/4).

يَحْكُمُ (1) ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ، (وَكُتِبَ
بِالشَّهَادَةِ (2)؛ لِيَحْكُمَ بِهَا (3) الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ (4) وَهَذَا هُوَ الْكِتَابُ
الْحُكْمِيُّ (5)، وَهُوَ نَقْلُ الشَّهَادَةِ فِي الْحَقِيقَةِ (6).

(1) أي بتلك الشهادة؛ لأنه حينئذ قضاء على غائب.

(2) أي كتب القاضي بما يسمعه من الشهادة إلى القاضي.

(3) أي بهذه الشهادة، لكن إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي الكاتب، فهو بمنزلة نقل الشهادة.

(4) أي ليحكم بها القاضي المكتوب إليه، على قواعد مذهبه. (اللباب
، 85/4).

(5) أي وهذا الكتاب إلى القاضي، يسمى الكتاب الحكمي في عرفهم؛ لأنه
يكتب؛ ليحكم به القاضي المكتوب إليه. (البنية شرح الهداية، 36/9؛ فتح
القدير، 286/7).

(6) لِأَنَّ الْحَاكِمَ الْكَاتِبَ لَمْ يَحْكَمْ بِالشَّهَادَةِ، وَإِنَّمَا نَقَلَهَا؛ لِيَحْكُمَ بِهَا الْمَكْتُوبُ
إِلَيْهِ؛ وَلِهَذَا يَحْكُمُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِرَأْيِهِ، وَإِنْ خَالَفَ رَأْيَهُ رَأْيَ الْكَاتِبِ. بخلاف
السجل، فإنه ليس له أن يخالفه، وينقض حكمه. ومن هنا يتبين أن كتاب
القاضي إلى القاضي نوعان: النوع الأول: نقل حكم، وهو المسمى سجلاً.
والنوع الثاني: نقل شهادة، وهو المسمى الكتاب الحكمي. والفرق بينهما:
أَنَّ الْأَوَّلَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا التَّنْفِذُ، وَافَقَ رَأْيَهُ، أَوْ
خَالَفَهُ؛ لِاتِّصَالِ الْحُكْمِ بِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي، فَإِنْ وَافَقَهُ، نَقَذَهُ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِعَدَمِ
اتِّصَالِ الْحُكْمِ بِهِ.

❦ وكذلك يتضح أن لا فرق بين كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة
على الشهادة، إلا من حيث إن شهود الفرع، يشهدون على شهادة
الأصول، والتأقلون لكتاب القاضي، يشهدون على أن الكتاب من القاضي.

وَيَخْتَصُّ⁽¹⁾ بِشَرَائِطَ⁽²⁾ نَذَرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَجَوَازُهُ⁽³⁾،
لِمَسَاسِ الْحَاجَةِ⁽⁴⁾؛ لِأَنَّ الْمُدْعَى قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ
شُهُودِهِ، وَخَصَمِهِ، فَأَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ⁽⁵⁾. وَقَوْلُهُ: "فِي

وَأَنَّ الْقَاضِيَ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْدِيلِ الشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا فِي
الْحَادِثَةِ، وَفِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، لَا بَدْءَ مِنْ تَعْدِيلِهِمْ.

(1) أَيَّ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 36/9).

(2) مِنْهَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْعُلُومُ الْخَمْسَةُ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْلُومٍ، إِلَى
مَعْلُومٍ، فِي مَعْلُومٍ، لِمَعْلُومٍ، عَلَى مَعْلُومٍ. (الْعَنَاءُ، 287/7؛ الْبَنَاءُ شَرْحُ
الْهَدَايَةِ، 36/9).

(3) أَيُّ جَوَازِ كِتَابِ النَّاسِ إِلَى الْقَاضِي، هُوَ الْمَوْعُودُ بِقَوْلِهِ: "عَلَى مَا
نَبِينُ" ..

(4) أَيُّ لُشْدَةِ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ. وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسُ بِأَيِّ جَوَازِ الْعَمَلِ
بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ عِبَارَتِهِ، وَلَوْ جُضِرَ بِنَفْسِهِ مَجْلِسَ الْمَكْتُوبِ
إِلَيْهِ، وَعَبَّرَ بِلِسَانِهِ عَمَّا فِي الْكِتَابِ، لَمْ يَعْمَلْ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ إِبْخَارَ
الْقَاضِي، لَا يَثْبُتُ حُجَّةً فِي غَيْرِ مَجْلٍ وَلَا يَتَّهَ، فَكِتَابُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ.
وَفِيهِ شَبْهَةُ التَّرْوِيرِ؛ إِذِ الْخَطُّ يَشْبَهُ الْخَطَّ، وَالْخَاتَمُ الْخَاتَمُ، إِلَّا أَنَّهُ جَوَازٌ؛
لِحَاجَةِ النَّاسِ؛ لَمَّا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَوَّزَهُ، كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ.

(5) يُشِيرُ إِلَى أَنَّ جَوَازَهُ ثَابِتٌ بِمِثَابَهَتِهِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ لِاتِّحَادِ
الْمَنَاطِ، وَهُوَ تَعَذُّرُ الْجَمْعِ بَيْنَ الشُّهُودِ، وَالْخَصَمِ، فَكَمَا جَوَّزَ الشَّهَادَةَ عَلَى
الشَّهَادَةِ؛ لِإِحْيَاءِ حَقُوقِ الْعِبَادِ، فَكَذَا جَوَّزَ الْكِتَابَ لِذَلِكَ. وَلَا يَرَادُ بِالْمِثَابَةِ
الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْقِيَاسِ، فَيَرَادُ بِهِ الْإِتِّحَادُ فِي مَنَاطِ الْإِسْتِحْسَانِ.
(الْعَنَاءُ، 287/7؛ الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 36/9).

الْحُقُوقُ" يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ: الدِّينُ⁽¹⁾، وَالنِّكَاحُ⁽²⁾، وَالنَّسَبُ⁽³⁾،
وَالْمَغْصُوبُ⁽⁴⁾، وَالْأَمَانَةُ الْمَجْهُودَةُ⁽⁵⁾، وَالْمُضَارَبَةُ الْمَجْهُودَةُ⁽⁶⁾؛
لَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ⁽⁷⁾
بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ⁽⁸⁾، وَهُوَ⁽⁹⁾ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ⁽¹⁰⁾، لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى
الْإِشَارَةِ⁽¹⁾.

(1) فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِالْقَدْرِ، وَالْوَصْفِ، وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْإِشَارَةِ. (مجمع
الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 2/165).

(2) بَأَن ادْعَى رَجُلًا نَكَاحًا عَلَى امْرَأَةٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ. وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ، إِذَا
ادْعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا طَلَاقًا. (تبيين الحقائق، 4/183).

(3) بَأَن ادَّعَى نَسَبًا مِنْ حَيٍّ، أَوْ مَيِّتٍ؛ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِذِكْرِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ،
وَالْقَبِيلَةِ.

(4) بَأَن ادَّعَى غَضَبًا عَلَى رَجُلٍ. (البنية شرح الهداية، 9/37).

(5) أَيِ الْوَدِيعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا الْمُوَدَّعُ. (البنية شرح الهداية، 9/37).

(6) الَّتِي جَعَلَهَا الْمُضَارِبُ. وَإِنَّمَا قِيدَ بِالْجَدِّ فِي الْأَمَانَةِ، وَالْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ
الْمُوَدَّعَ، وَالْمُضَارِبَ، لَوْ كَانَا مُقَرَّرَيْنِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى كِتَابِ الْقَاضِي.
(البنية، 9/37).

(7) أَيِ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. (البنية شرح الهداية، 9/37).

(8) وَالَّذِينَ يَجُوزُ فِيهِ الْكِتَابُ، فَكَذَا يَجُوزُ فِيهَا كَانُ فِي مَنْزِلَتِهِ. (العناية
شرح الهداية، 7/287؛ البنية شرح الهداية، 9/37).

(9) أَيِ الدِّينِ. (العناية شرح الهداية، 7/287؛ البنية شرح الهداية، 9/37).

(10) يُشِيرُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: إِلَى أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا يَجُوزُ فِيهِ الْكِتَابُ؛ لِأَنَّهُ
يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ، لَا يُحْتَاجُ إِلَى الْإِشَارَةِ. وَإِلَى أَنَّ مَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى

(كِتَابُ الْقَاضِي فِي الْعَقَارِ، وَالْمَنْقُولِ)

وَيُقْبَلُ فِي الْعَقَارِ أَيْضًا⁽²⁾؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ فِيهِ⁽³⁾ بِالتَّحْدِيدِ⁽⁴⁾. وَلَا يُقْبَلُ⁽⁵⁾ فِي الْأَعْيَانِ الْمَنْقُولَةِ⁽¹⁾؛ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِشَارَةِ⁽²⁾. وَعَنْ أَبِي

الْإِشَارَةِ، لَا يَجُوزُ فِيهِ الْكِتَابُ. وَإِلَى أَنَّ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ، بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ فِي أَنَّهَا تَعْرِيفٌ بِالْوَصْفِ، لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشَارَةِ.

(1) وَاعْتَرَضَ بَأَنَّ فِي دَعْوَى النِّكَاحِ، لَا بَدْءَ مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى الرَّجُلِ وَإِلَى الْمَرْأَةِ، وَكَذَا فِي الْأَمَانَةِ، وَالْمَغْصُوبِ، فَكَانَتْ هَذِهِ بِمَنْزِلَةِ الْأَعْيَانِ الْمَدْعَى بِهَا، وَكِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي لَا يَجُوزُ فِيهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَاجِبٌ بَأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الْخَصْمِ - وَهُوَ الرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ شَرْطٌ فِيهَا ذِكْرُ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَدْعَى بِهِ، إِنَّمَا الْمَدْعَى بِهِ، هُوَ نَفْسُ النِّكَاحِ، وَالْأَمَانَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا هُوَ مِنَ الْأَفْعَالِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الدَّائِنِ، وَالْمَدْيُونِ، لَا بَدْءَ مِنْهَا عِنْدَ دَعْوَى الدِّينِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَنْعٍ بِالْإِجْمَاعِ (العناية، 287/7).

❁ خلاصة المسألة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، في الحقوق التي تثبت مع الشبهات - كالدين، والنكاح، والنسب - بخلاف الحدود والقصاص، استحساناً؛ لحاجة الناس إليه. والقياس يأبى جوازه. وكتاب القاضي إلى القاضي نوعان: الأول: نقل حكم، وهو المسمى سجلاً. والثاني: نقل شهادة، وهو المسمى الكتاب الحكمي.

(2) أي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في دعوى العقار أيضاً. (العناية شرح الهداية، 287/7؛ البناية شرح الهداية، 37/9).

(3) أي في دعوى العقار. (البناية شرح الهداية، 37/9).

(4) أي ببيان حدوده الأربعة، وذلك لا يحتاج إلى إحضاره إلى مجلس الحاكم، ولا إلى الإشارة، فصار كالدين. (تبيين الحقائق، 183/4).

(5) أي كتاب القاضي إلى القاضي. (البناية شرح الهداية، 37/9).

يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ⁽³⁾ يُقْبَلُ فِي الْعَبْدِ، دُونَ الْأَمَةِ⁽⁴⁾؛
لِغَلَبَةِ الْإِبَاقِ فِيهِ، دُونَهَا⁽⁵⁾. وَعَنْهُ⁽⁶⁾ أَنَّهُ يُقْبَلُ⁽⁷⁾ فِيهِمَا⁽⁸⁾، بِشَرَايِطَ
تُعَرَفُ فِي مَوْضِعِهَا⁽⁹⁾. وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ⁽¹⁰⁾ يُقْبَلُ
فِي جَمِيعِ مَا يُنْقَلُ، وَيَحُولُ⁽¹¹⁾، وَعَلَيْهِ⁽¹²⁾ الْمَتَأَخَّرُونَ⁽¹³⁾.

-
- (1) كَالْحِمَارِ، وَالسَّيَّارَةِ، وَالثَّوْبِ. (فتح القدير، 288/7).
- (2) عِنْدَ الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَةِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. (تَبْيِينَ الْحَقَائِقِ، 183/4؛ الْعِنَايَةُ، 288/7).
- (3) أَيِ أَنْ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 37/9).
- (4) وَغَيْرِهَا مِنَ الْمِنْقُولَاتِ. (تَبْيِينَ الْحَقَائِقِ، 183/4).
- (5) فَإِنَّ الْعَبْدَ يَخْدُمُ خَارِجَ الْبَيْتِ غَالِبًا، فَيَقْدَرُ عَلَى الْإِبَاقِ، فَتَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى الْكِتَابِ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ، فَإِنَّهَا تَخْدُمُ دَاخِلَ الْبَيْتِ غَالِبًا، فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهَا الْإِبَاقُ (الْعِنَايَةُ، 288/7).
- (6) أَيِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَوَاهَا عَنْهُ بَشَرُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ..
- (7) كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 38/9).
- (8) أَيِ فِي الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 38/9).
- (9) يَعْنِي الْكُتُبَ الْمُبْسُوطَةَ: كَالْمُبْسُوطِ، وَشُرُوحِ أَدَبِ الْقَاضِي.
- (10) أَيِ أَنْ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 38/9).
- (11) مِنَ الدُّوَابِّ، وَالنِّيَابِ، وَالْإِمَاءِ. (فتح القدير، 288/7).
- (12) أَيِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 38/9).
- (13) وَنَصَّ الْإِسْبِجَابِيُّ عَلَى أَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ؛ لِلضَّرُورَةِ. (تَبْيِينَ الْحَقَائِقِ، 183/4).

(لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَةٍ)
 قَالَ: (وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ⁽¹⁾)؛
 لِأَنَّ الْكِتَابَ يُشَبِّهُ الْكِتَابَ، فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَةٍ⁽²⁾.
 وَهَذَا⁽³⁾ لِأَنَّهُ⁽⁴⁾ مُلْزَمٌ⁽⁵⁾، فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُجَّةِ. بِخِلَافِ كِتَابِ
 الْإِسْتِثْمَانِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزَمٍ⁽¹⁾. وَبِخِلَافِ
 رَسُولِ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّي⁽²⁾، وَرَسُولِهِ⁽³⁾

(1) يعني لا يقبل القاضي المكتوب إليه، كتاب القاضي إليه، إلا بحجة تامة، وهي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، على أنه كتاب القاضي فلان الكاتب، وأنه ختمه، وإن فيه كذا وكذا. أما اشتراط الحجة؛ فلأنه ملزم، ولا إلزام بدونها. وأما قبول رجل وامرأتين؛ فلأنه حق لا يسقط بالشبهات، وهو مما يطلع عليه، فيقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، كما في سائر الحقوق. ولا بد من إسلامهما: فلا تقبل شهادة الذميين على كتاب القاضي المسلم، ولو كان الكتاب لزمي علي نمي؛ لأنهم يشهدون على فعل المسلم، وهذا لأن قبول شهادة بعضهم على بعض، كان للحاجة والضرورة؛ إذ قلما يحضر المسلمون معاملاتهم، خصوصاً الأنكحة، والوصايا، وهذا لا يتحقق في كتاب القاضي، وختمه. (العناية 290/7، 291؛ البناية شرح الهداية، 39/9).

(2) وهي البينة. (فتح القدير، 291/7).

(3) أي اشتراط الحجة. (البناية شرح الهداية، 39/9).

(4) أي لأن كتاب القاضي إلى القاضي. (البناية شرح الهداية، 39/9).

(5) إذ يجب على القاضي المكتوب إليه، أن ينظر فيه، ويعمل به.

(6) هذا جواب من المصنف - رحمه الله تعالى - عن قول القائلين:

بجواز كتاب القاضي إلى القاضي بغير بينة؛ قياساً على كتاب الاستئمان.

إِلَى الْقَاضِي (4)؛ لَأَنَّ الْإِلْزَامَ بِالشَّهَادَةِ، لَا بِالْتَّزْكِيَةِ (5).

فَقَالَ: "بِخِلَافِ كِتَابِ الْإِسْتِمَانِ". يَعْنِي إِذَا جَاءَ مِنْ مَلِكٍ أَهْلُ الْحَرْبِ، فِي طَلَبِ الْأَمَانِ، فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، حَتَّىٰ لَوْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ صَحَّ. (1) فَإِنَّ الْإِمَامَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى الْأَمَانَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْطِهِ، فَلَا يَشْتَرَطُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ.

(2) وَإِنَّمَا قِيدَ بِقَوْلِهِ: "إِلَى الْمَزْكِيِّ"؛ لِأَنَّ رَسُولَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، غَيْرُ مَعْتَبَرٍ أَصْلًا فِي حَقِّ لُزُومِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ، بِبَيِّنَةٍ، وَبِغَيْرِهَا. وَالْفَرْقُ بَيْنَ رَسُولِ الْقَاضِي، وَبَيْنَ كِتَابِهِ، حَيْثُ يَقْبَلُ كِتَابَهُ، وَلَا يَقْبَلُ رَسُولَهُ؛ فَلِأَنَّ غَايَةَ رَسُولِهِ أَنْ يَكُونَ كَنَفْسِهِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ مَا فِي كِتَابِهِ، لِذَلِكَ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ، لَا يَقْبَلُهُ. وَكَانَ الْقِيَاسُ فِي كِتَابِهِ كَذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ أُجِيزَ بِإِجْمَاعِ الْقَائِعِينَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. (فتح القدير، 291/7).

(3) أَيِ وَرَسُولِ الْمَزْكِيِّ. (البنية شرح الهداية، 40/9).

(4) فَإِنَّهُ يَقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. (العناية شرح الهداية، 291/7).

(5) أَيِ لِأَنَّ الْإِلْزَامَ عَلَى الْحَاكِمِ لَيْسَ بِالْتَّزْكِيَةِ، بَلْ هُوَ بِالشَّهَادَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قُضِيَ بِالشَّهَادَةِ بِلَا تَزْكِيَةٍ، صَحَّ، وَإِنَّمَا التَّزْكِيَةُ لِنَوْعِ رَجْحَانِ الصَّدَقِ. (العناية شرح الهداية، 291/7؛ البنية شرح الهداية، 40/9).

❁ خلاصة المسألة: لَا يَقْبَلُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ، كِتَابَ الْقَاضِي إِلَيْهِ، إِلَّا بِحُجَّةٍ تَامَةٍ، وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، عَلَى أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي فَلَانَ الْكَاتِبِ، وَأَنَّهُ خَتَمَهُ، وَأَنَّ فِيهِ كَذًا وَكَذًا. أَمَّا إِشْتِرَاطُ الْحُجَّةِ؛ فَلِأَنَّهُ مُلْزَمٌ، وَلَا إِلْزَامَ بِدُونِهَا. وَأَمَّا قَبُولُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؛ فَلِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ، وَهُوَ مِمَّا يَطْلُعُ عَلَيْهِ، فَيَقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، كَمَا فِي سَائِرِ الْحَقُوقِ.

(شَرَّاطُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي)

قَالَ: (وَيَجِبُ⁽¹⁾ أَنْ يَقْرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ⁽²⁾؛ لِيَعْرِفُوا مَا فِيهِ⁽³⁾، أَوْ يُعَلِّمَهُمْ بِهِ⁽⁴⁾)؛ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ⁽⁵⁾.
(ثُمَّ يَخْتَمُهُ⁽⁶⁾ بِحَضْرَتِهِمْ، وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ)؛ كَيْ لَا يَتَوَهَّمِ التَّغْيِيرُ⁽⁷⁾، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ عِلْمَ مَا فِي الْكِتَابِ، وَالْخَتْمَ بِحَضْرَتِهِمْ شَرْطٌ، وَكَذَا⁽⁸⁾ حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا⁽⁹⁾،

(1) على القاضي الكاتب. (الباب في شرح الكتاب، 4/85).

(2) أي على الشهود. (البنية شرح الهداية، 9/40).

(3) أي ما في الكتاب؛ إذ لا شهادة بدون العلم. (تبيين الحقائق، 4/184).

(4) أي أو يعلم القاضي الشهود بما في الكتاب؛ لأن المعرفة تحصل به، وهو المقصود. (تبيين الحقائق، 4/184؛ البنية شرح الهداية، 9/40).

(5) لأنهم إن لم يعلموا ما فيه، كانت شهادتهم بلا علم، وهي باطلة؛ قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾. [الزخرف: 86].

(6) أي الكتاب. (البنية شرح الهداية، 9/40).

(7) إذا كان بغير ختم، أو بيد الخصم. (العناية شرح الهداية، 7/292).

(8) أي وكذا يشرط. (البنية شرح الهداية، 9/41).

(9) أي عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله..

وَلِهَذَا (1)؛ يُدْفَعُ (2) إِلَيْهِمْ (3) كِتَابٌ آخَرُ، غَيْرُ مَخْتُومٍ؛ لِيَكُونَ مَعَهُمْ مُعَاوَنَةً عَلَى حِفْظِهِمْ (4).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - آخِرًا (5): شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (6) لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالشَّرْطُ (7) أَنْ يُشْهَدَهُمْ أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ، وَخَتَمُهُ (8). وَعَنْ

(1) أي ولكون اشتراط حفظ ما في الكتاب. (البناية شرح الهداية، 41/9).

(2) القاضي الكاتب.

(3) أي إلى الشهود. (البناية شرح الهداية، 41/9).

(4) فَإِنْ فَاتَ شَيْءٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، لَا يَقْبَلُ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْحَاصِلُ: إِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، فَلَا يَدْ حِينَئِذٍ مِنْ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَعْلَمَهُمْ مَا فِيهِ. وَاشْتِرَاطُ عِلْمِهِمْ بِمَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي، وَحِفْظُهُمْ لِمَا فِيهِ، وَأَنْ يُشْهَدُوا أَنَّهُ خَتَمَهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْتَمَهُ بِحَضْرَتِهِمْ، وَيَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ الْكِتَابُ مَعْنُونًا، قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَلِهَذَا قِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ نَسْخَةٌ أُخْرَى مَفْتُوحَةٌ؛ لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى حِفْظِ مَا فِي الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْ مِنْ التَّنْكِيرِ مِنْ وَقْتِ الشَّهَادَةِ، إِلَى وَقْتِ الْأَدَاءِ.

(5) أي فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ، وَإِنَّمَا قَالَ: "آخِرًا"؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ، مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ. (العناية، 293/7؛ فتح القدير، 292/7).

(6) هَذَا مَقُولُ الْقَوْلِ، وَلَفْظُ شَيْءٍ مُبْتَدَأٌ، وَإِنْ كَانَ نَكْرَةً؛ لِأَنَّهُ تَخْصِصٌ بِقَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ كَائِنٍ مِنْ ذَلِكَ، أَيْ عِلْمٍ مَا فِي الْكِتَابِ، وَحِفْظِهِ، وَالْخَتْمُ بِحَضْرَتِهِمْ. (البناية شرح الهداية، 41/9).

(7) أي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ. (البناية شرح الهداية، 41/9).

(8) قُلُوا أَشْهَدُهُمُ الْقَاضِي أَنَّ هَذَا كِتَابُهُ، وَخَتَمَهُ، فَشَهِدُوا عَلَى الْكِتَابِ، وَالْخَتْمُ، عِنْدَ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، كَانَ كَافِيًا.

أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْخَتَمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ أَيْضًا، فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ؛ لَمَّا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ⁽¹⁾. وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأُئِمَّةِ السَّرْحَسِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ⁽²⁾.

(شُرُوطُ قَبُولِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي)

قَالَ: (وَإِذَا وَصَلَ⁽³⁾ إِلَى الْقَاضِي⁽⁴⁾)، لَمْ يَقْبَلْهُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ⁽⁵⁾؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ آدَاءِ الشَّهَادَةِ⁽⁶⁾، فَلَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ⁽⁷⁾.

(1) لِأَنَّ الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ، وَالْكَذِبَ، وَلَيْسَ فِي الْمُعَايَنَةِ احْتِمَالٌ.

(2) تَيْسِيرًا عَلَى النَّاسِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ، (الْعُنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 293/7).

(3) أَيِ كِتَابِ الْقَاضِي. (الْبَابُ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ، 86/4).

(4) لَمَّا فَرَّغَ مِنْ بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجَانِبِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِجَانِبِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ..

(5) وَالْمُرَادُ: أَنَّهُ لَا يَقْرَأُهُ إِلَّا بِحُضُورِهِ، لَا مُجَرَّدَ قَبُولِهِ، فَإِذَا وَصَلَ الْمُدَّعِي إِلَى الْقَاضِي، جَمَعَ بَيْنَهُ، وَبَيَّنَّ خَصْمَهُ، فَإِنْ اعْتَرَفَ، اسْتَعْنَى عَنِ الْكِتَابِ، وَإِنْ أَنْكَرَ، قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ حُجَّةٌ، فَإِنْ قَالَ: مَعِيَ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَيْكَ، طَالِبُهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، فَإِذَا حُضِرُوا، أَحْضَرَ خَصْمَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، فَيُشْهِدُونُ بِحَضْرَتِهِ: أَنَّهُ كِتَابُ الْقَاضِي، سَلَّمَهُ إِلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا (فَتْحُ الْقَدِيرِ، 293/7).

(6) أَيِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَّ يَنْقُلُ أَلْفَظَ الشُّهُودِ بِكِتَابِهِ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ شَاهِدَ الْفَرْعِ يَنْقُلُ شَهَادَةَ شَاهِدِ الْأَصْلِ بِعِبَارَتِهِ. (فَتْحُ الْقَدِيرِ، 293/7).

(7) أَيِ حُضُورِ الْخَصْمِ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ حُضُورِ الْمَشْهُودِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ، وَالشَّهَادَةُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِمُدَّعٍ، وَخَصْمٍ..

بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ⁽¹⁾؛ لِأَنَّهُ لِلنَّقْلِ، لَا لِلْحُكْمِ⁽²⁾. قَالَ:
(فَإِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُودُ إِلَيْهِ⁽³⁾)، نَظَرَ إِلَى خَتَمِهِ⁽⁴⁾، فَإِذَا شَهِدُوا: أَنَّهُ
كِتَابُ فُلَانِ الْقَاضِي، سَلَّمَهُ إِلَيْنَا فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ⁽⁵⁾، وَقَرَأَهُ
عَلَيْنَا، وَخَتَمَهُ، فَتَحَهُ الْقَاضِي⁽⁶⁾، وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ، وَالزَّمَهُ مَا
فِيهِ⁽⁷⁾. وَهَذَا⁽⁸⁾ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

(1) فَإِنَّهُ يُسَمَّعُ مِنَ الْأُصُولِ الشَّهَادَةِ، وَإِنْ كَانَ الْخَصْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ غَائِبًا.
(الْبِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 42/9؛ فَتْحُ الْقَدِيرِ، 293/7).

(2) فَكَانَ سَمَاعُهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْمِيلِ الْفَرْعِ لِشَهَادَةِ الْأَصْلِ، وَفِي التَّحْمِيلِ لَا
يُشْتَرِطُ حُضُورُ الْخَصْمِ، كَذَا هَذَا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ أَبُو
يُوسُفَ: يَقْبَلُهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْخَصْمِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ يَخْتَصُّ بِالْمَكْتُوبِ
إِلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ، وَالْحُكْمُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ بِمَا عَلِمَهُ مِنَ الْكِتَابِ، فَاعْتَبِرَ
حُضُورَ الْخَصْمِ عِنْدَ الْحُكْمِ بِهِ. (الْعَنَايَةُ، 294/7).

(3) إِيَّاهُ إِذَا سَلَّمَ الشُّهُودُ الْكِتَابَ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ.

(4) أَوَّلًا؛ لِيَتَعَرَّفَهُ. (الْبَابُ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ، 86/4).

(5) أَيَّ فِي مَجْلِسٍ يَصِحُّ حُكْمُهُ فِيهِ، حَتَّى لَوْ سَلَّمَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ،
لَا يَصِحُّ.

(6) الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ. (الْبِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 43/9).

(7) أَيَّ مَا فِي الْكِتَابِ، إِذَا ثَبَتَتْ عِدَالَتُهُمْ: بِأَنْ كَانَ يَعْرِفُهُمْ بِهَا، أَوْ وَجَدَ فِي
الْكِتَابِ عِدَالَتَهُمْ، أَوْ سَأَلَ مِنْ يَعْرِفُهُمْ مِنَ الثَّقَاتِ فَرَكُوا. وَأَمَّا قَبْلَ ظُهُورِ
عِدَالَتِهِمْ، فَلَا يَحْكُمُ بِهِ، وَلَا يُلْزِمُ الْخَصْمَ. (الْبِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 43/9).

(8) أَيَّ الْمَذْكُورِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا شَهِدُوا: أَنَّهُ كَتَبَهُ، وَخَاتَمَهُ، قَبْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ⁽¹⁾. وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْكِتَابِ⁽²⁾ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ⁽³⁾ لِلْفَتْحِ⁽⁴⁾. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْضُ الْكِتَابَ⁽⁵⁾ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْخَصَافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّهُ⁽⁶⁾ رُبَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى زِيَادَةِ الشُّهُودِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُهُمْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ بَعْدَ قِيَامِ الْخْتَمِ⁽⁷⁾.

(1) أشار إلى ما قال قبل هذا: "وقال أبو يوسف - رحمه الله - آخرًا: شيء من ذلك ليس بشرط، والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه، وختمه". (البنية شرح الهداية، 43/9).

(2) أي في مختصر القدوري.

(3) في شهود الكتاب.

(4) أي فتح الكتاب؛ لأنه قال: فإذا شهدوا: أنه كتاب فلان القاضي، سلمه إلينا، في مجلس حكمه، وقرأه علينا، وختمه، فتحه القاضي، ولم يقل: فإذا شهدوا، وعدلوا، فعلم أنه لم يشترط العدالة. (العناية شرح الهداية، 294/7؛ البنية شرح الهداية، 43/9).

(5) أي يفتحه.

(6) أي المدعي. (البنية شرح الهداية، 43/9).

(7) أي لأنه إذا لم تظهر العدالة، رُبَّمَا احتاج المدعي إلى أن يزيد في شهوده، وإنما يمكنهم أداء الشهادة حال قيام الختم؛ ليشهدوا أن هذا كتاب فلان القاضي، وختمه، فأما إذا فك الختم، فلا يمكنهم ذلك. (العناية، 294/7؛ فتح القدير، 294/7).

(حَيَاة الْقَاضِي، وَأَهْلِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ، شَرْطٌ لِقَبُولِ كِتَابِهِ، وَالْعَمَلُ

بِهِ)

وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ⁽¹⁾، إِذَا كَانَ الْكَاتِبُ عَلَى الْقَضَاءِ⁽²⁾،
حَتَّى لَوْ مَاتَ، أَوْ عَزَلَ⁽³⁾، أَوْ لَمْ يَبْقَ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ⁽⁴⁾ قَبْلَ وُصُولِ
الْكِتَابِ⁽⁵⁾، لَمْ يَقْبَلْهُ⁽⁶⁾؛ لِأَنَّهُ⁽⁷⁾ التَّحَقَّ بِوَاحِدٍ مِنَ الرِّعَايَا⁽⁸⁾،

(1) أي وإنما يقبل الكتاب القاضي المكتوب إليه. (البنية شرح الهداية، 43/9).

(2) هَذَا شَرْطٌ آخَرُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الْكَاتِبَ عَلَى قَضَائِهِ، إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَمْرُ الْكِتَابِ. (فَتْحُ الْقَدِيرِ، 294/7).

(3) أَيِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ، قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْكِتَابُ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ.

(4) بِأَنْ جَنَّ الْكَاتِبَ، أَوْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ ارْتَدَّ، أَوْ قَذَفَ فَحْدًا، أَوْ عَمِيَ، أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوْ فَسَقَ بَعْدَ أَنْ تَوَلَّى الْقَضَاءَ.

(5) أَوْ بَعْدَ وَصُولِهِ، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَيْهِمْ..

(6) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأُمَالِي: يَقْبَلُهُ، وَيَعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّ كِتَابَ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَكْتُابُهُ يَنْقُلُ شَهَادَةَ الَّذِينَ شَهِدُوا عِنْدَهُ بِالْحَقِّ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَالتَّقْلُّ قَدْ تَمَّ بِالْكِتَابِ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ شَهَوْدِ الْفُرُوعِ إِذَا مَاتُوا بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْقَضَاءَ. (تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ، 1865/4)

(7) أَيِ لِأَنَّ الْقَاضِي الْكَاتِبَ، بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ.

(8) يَعْنِي قَبْلَ تَمَامِ الْقَضَاءِ، فَلَا يَنْفِذُ الْحُكْمَ بِكِتَابِهِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا عَزَلَ، أَمَّا فِي الْمَوْتِ، أَوْ فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْأَهْلِيَّةِ، فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ، وَالْمَجْنُونِ، لَا يَلْتَحِقَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الرِّعَايَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: يَعْلَمُ

ولهذا⁽¹⁾؛ لا يقبل إخباره قاضياً آخر في غير عمله⁽²⁾، أو في غير عملهما⁽³⁾. وكذا لو مات المكتوب إليه⁽⁴⁾، إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان، قاضي بلدة كذا، وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين⁽⁵⁾؛ لأن غيره⁽⁶⁾ صار تبعاً له، وهو معرف⁽⁷⁾. بخلاف ما إذا كتب ابتداء⁽⁸⁾ إلى كل من يصل إليه⁽¹⁾، على ما عليه مشايخنا - رحمهم الله -؛ لأنه غير معرف⁽²⁾.

ذلك بالأولي، وذلك؛ لأنه إذا كان حياً، وعلى أهلية القضاء لم يبق كلامه حجة، فلان لا يبقى بعد الموت، أو الخروج عن الأهلية أولى.
(1) أي ولكونه ملحقاً بواحد من الرعايا. (البنية شرح الهداية، 44/9).

(2) يعني إذا أخبر القاضي قاضياً آخر، في غير عمل المخبر، لا يقبل كتابه، فلان لا يقبل كتابه إذا عزل، أو مات بالطريق الأولى.
(3) كما لو التقى قاضيان في مصر ليس من عملهما، فقال أحدهما للآخر: ثبت عندي لفلان كذا، فاعمل بما يحق لك، لم يقبل منه، ولم ينفذه؛ لأن السماع وجد من غير القاضي، حيث لم يكن في مكان ولايته.
(البنية شرح الهداية، 44/9).

(4) أو عزل، وولي غيره، لا يعمل الذي قام مقامه عندنا؛ لأن الكاتب لما خصه، فقد اعتمد عدالته، وأمانته، والقضاة متفاوتون في ذلك، فصحّ التعيين. (العناية، 296/7).

(5) فحينئذ يقبل الكتاب، بعد موت قاضي تلك البلدة المكتوب إليه.

(6) أي غير المكتوب إليه. (البنية شرح الهداية، 44/9).

(7) لأنه أتى بما هو شرط، وهو أن يكون من معلوم، إلى معلوم.

(8) من فلان بن فلان، قاضي بلد كذا.

وَلَوْ كَانَ مَاتَ الْخَصْمُ⁽³⁾، يَنْفُذُ الْكِتَابُ عَلَى وَارَثِهِ⁽⁴⁾؛ لِقِيَامِهِ⁽⁵⁾ مَقَامَهُ⁽⁶⁾.

(1) مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَحُكَّامِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَصُحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَعَهُ. وَأَجَازَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ، حِينَ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ، تَسْهِيلًا لِلْأَمْرِ عَلَى النَّاسِ. وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ إِعْلَامَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا، فَبِالْعُمُومِ يَعْلَمُ كَمَا يَعْلَمُ بِالْخُصُوصِ، وَلَيْسَ الْعُمُومُ مِنْ قِبَلِ الْإِجْمَالِ، وَالتَّجْهِيلِ، فَصَارَ قَصْدِيَّتَهُ، وَتَبَعِيَّتَهُ. سِوَاءِ (تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ، 187/4؛ الْعِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 296/7)

(2) لِأَنَّهُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَجْهُولٍ، وَالْعِلْمُ فِيهِ شَرْطٌ كَمَا مَرَّ. وَحَاصِلُ الْكَلَامِ: أَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى: صَرَحَ الْكِتَابُ بِاعْتِمَادِهِ عَلَى الْكُلِّ، بَعْدَ تَعْرِيفِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَأَتَى بِمَا هُوَ شَرْطٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَعْلُومٍ، ثُمَّ صِيرَ غَيْرَهُ تَبَعًا لَهُ. وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ: مِنْ مَعْلُومٍ إِلَى مَجْهُولٍ، وَالْعِلْمُ فِيهِ شَرْطٌ. (الْعِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 296/7)

(3) أَطْلُقَ لَفْظَ "الْخَصْمِ" فَشَمِلَ الْمُدَّعِيَّ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (الْبَحْرُ الرَّائِقُ، 5/7).

(4) أَيْ وَرَثَةُ الْخَصْمِ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 45/9).

(5) أَيْ لِقِيَامِ الْوَرِثَةِ. (الْبَنَاءُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ، 45/9).

(6) أَيْ مَقَامِ الْخَصْمِ، سِوَاءِ كَانَ تَارِيخُ الْكِتَابِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَطْلُوبِ، أَوْ بَعْدَهُ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ.

(حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، والقصاص)
 (ولما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود،
 والقصاص⁽¹⁾)؛ لأن فيه شبهة البدلية⁽²⁾، فصار كالشهادة على
 الشهادة⁽³⁾. ولأن مبناهما⁽⁴⁾ على الإسقاط، وفي قبوله⁽⁵⁾ سعي⁽⁶⁾
 في إثباتهما⁽⁷⁾.

(1) لأنهما يسقطان بالشبهة، وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأن
 الخط يشبه الخط، فيمكن أنه لم يكن من القاضي، والحدود تدراً بالشبهات.
 (الجوهرة النيرة، 2/245).

(2) لأن للمكتوب إليه صار بدلاً عن الكاتب؛ لأنه لم يشاهد الشهادة.
 (البنية شرح الهداية، 45/9).

(3) وهي غير مقبولة فيهما؛ لأن مبنى الحدود والقصاص على الإسقاط
 بالشبهات. (العناية شرح الهداية، 296/7؛ البنية شرح الهداية، 45/9؛ فتح
 القدير، 296/7).

(4) أي مبنى الحدود، والقصاص. (البنية شرح الهداية، 45/9).

(5) أي وفي قبول كتاب القاضي إلى القاضي فيهما.

(6) واحتياط. (فتح القدير، 296/7).

(7) فلا يجوز. (البنية شرح الهداية، 45/9).

✽ خلاصة المسألة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود،
 والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة، وفي كتاب القاضي إلى القاضي
 شبهة البدلية.

نماذج أسئلة:

- ما هي الحقوق التي يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي؟ وما شروط ذلك؟

- ما الفرق بين "نقل حكم"، و"نقل شهادة" في كتاب القاضي إلى القاضي؟

- ما الفرق بين كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة؟

- هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، في الحقوق التي تثبت مع

الشبهات - كالدين، والنكاح، والنسب، وهل يختلف الأمر بالنسبة

للحدود والقصاص؟

- شروط قبول كتاب القاضي إلى القاضي

- هل يقبل كتاب القاضي في دعوى العقار؟

- هل يقبل كتاب القاضي في الأعيان المنقولة - كالسيارة؟

- شرائط كتاب القاضي إلى القاضي

- شروط قبول كتاب القاضي إلى القاضي

كِتَابُ الدَّعْوَى (1)

تعريف الدعوى (2)، وشروطها

(تعريف المدعى ، والمدعى عليه)

(1) أي هذا كتاب في بيان الأحكام المتعلقة بالدعوى

(2) الدعوى لغة: اسم لادعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالا، وفتح الواو لا غير، كفتوى وفتاوى، وهى: قول يقصد به إيجاب حق على الغير. والدعوى اصطلاحاً: إضافة الشيء إلى نفسه في حالة المنازعة، ولها ركن وشرط وحكم وسبب، أما ركنها فإضافة الشيء إلى نفسه، لأن ركن الشيء ما يقوم به الشيء، والدعوى إنما تقوم بإضافة المدعى إلى نفسه فكان ركننا، وأما شرطها مجلس القضاء لأن الدعوى لا تصح في غير مجلس القاضي حتى لا يجب على المدعى عليه جواب المدعى، وأما حكمها: فوجوب الجواب على الخصم إما بنعم أو بلا، وأما سببها: تعلق البقاء المقدّر بتعاطي المعاملات، لأنّ المدعى به إما أن يكون راجعاً إلى النوع أو الشخص

وهي مشروعة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، أما الكتاب: قوله تعالى في قصة داود - عليه السلام - : ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ (سورة ص: الآية 20) وفسر علي - رضي الله عنه - بقوله: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» .

وأما السنة: فما رواه عمرو بن شعيب - رضي الله عنه - عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» ، وأما الإجماع: فقيل: انعقد إجماع الأمة عليها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. البناية شرح الهداية، 313/9، العناية على الهداية، 153/8.

قَالَ (الْمُدَّعِي مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ) (1)

(الفرق بين المدعى والمدعى عليه)

وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا (2) مِنْ أَهَمِّ مَا يَبْتَغَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايخ (3) - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيهِ، فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ (4) وَهُوَ حَدٌّ عَامٌّ صَحِيحٌ (5)، وَقِيلَ الْمُدَّعَى: مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ (6)، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ :

(1) الدَّعْوَى لَا تَحْصِلُ إِلَّا مِنْ مَدَّعٍ عَلَى مَدَّعٍ عَلَيْهِ؛ فَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَا يَبْتَغَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى، فَإِنَّ الثَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» فَلَا بَدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمَا. وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايخ فِيهِ. فَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْقُدُورِيُّ: الْمُدَّعَى مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ، وَهُوَ حَدٌّ عَامٌّ صَحِيحٌ.

(2) أي بين المدعى والمدعى عليه.

(3) المشايخ : يطلق على من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه . مقدمة عمدة الرعاية ، للكنوي ص 15.

(4) وهو مختصر القدوري . البناية 314/9.

(5) أما عمومها فلأنه يتناول كل حد من الحدود التي ذكرت في المدعى والمدعى عليه، وأما صحته فلأنه جامع مانع على ما لا يخفى، فلذلك اختاره المصنف - رحمه الله تعالى - .

(6) الذي يدعي عيناً في يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجة، يعني البينة أو الإقرار .

مَنْ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَذِي الْيَدِ (1)، وَقَبْلَ
الْمُدَّعِي مَنْ يَتَمَسَّكُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ (2) وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ
بِالظَّاهِرِ (3)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ (4):
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكَرُ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي
مَعْرِفَتِهِ (5)، وَالتَّرْجِيحُ بِالْفَقْهِ (6) عِنْدَ الْحَذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا -
رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلْمَعْنَى دُونَ الصُّورِ، فَإِنَّ الْمُوْدَعِ :
إِذَا قَالَ رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا
لِلرَّدِّ صُورَةً ، لِأَنَّهُ يَنْكُرُ الضَّمَانَ مَعْنَى (7).

(1) أي كصاحب اليد فإنه لا يحتاج إلى بينته واستحقاقه بقوله هذا ملكي
وأنا واضع اليد

(2) إذ الظاهر أن الأملاك في يد المالك وبراءة الذمة.

(3) لأنه يدعي قرار يده وملكه على ظاهره، وهذا منقوض بالمودع فإنه
مدعى عليه، وليس بتمسك بالظاهر، لأن رد الوديعة ليس بظاهر، لأن
الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال

(4) الأصل ويسمى المبسوط ، صنّفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ،
أحد كتب ظاهر الرواية ، وسمى بالأصل ، لأنه صنّفه قبل سائر كتبه
المعروفة . عقود رسم المفتى ، لابن عابدين ص 56.

(5) أي في معرفة المنكر .

(6) عني باعتبار المعنى دون الصورة

(7) فلو أقام على ذلك بينة قبلت، لأنه متمسك بالأصل إذ الأصل في
الذمم البراءة، ويحلف القاضي أنه لا يلزمه رد ولا ضمان، ولا يحلفه على
أنه رده لأن اليمين أبداً يكون على النفي، فلو أقام على بينة قبلت والقول
قوله مع يمينه أيضاً فكان مدعى عليه، فإذا أقام البينة اعتبر الصورة، وإذا

(شروط قبول الدعوى)

قَالَ: (وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكَرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جَنْسِهِ وَقَدْرِهِ)، لَأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ (1).

(فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدْعَى عَلَيْهِ، كُفِّ إِحْضَارُهَا لِإِشِيرِئِهَا بِالدَّعْوَى، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِحْطَافِ (1)، لَأَنَّ الْإِعْلَامَ

عجز عنها اعتبر معناها فإنه ينكر الضمان والقول قول المنكر مع يمينه، فإن قيل: المودع بدعوى الرد يتمسك بما ليس بثابت وهو الرد، إذ الرد لم يكن ثابتاً، والمودع متمسك بما هو ثابت، وهو عدم الرد، فإن كان ثابتاً فينبغي أن يكون الأمر على العكس.

(1) لا يلتفت القاضي إذا ادعى شيئاً مجهولاً، ولا يكلف المدعى عليه الجواب، لأنه إن أنكر لا يصح إقامة البينة عليها مع الجهالة، وإن نكل عن اليمين لا يمكن القضاء بالمجهول فسقطت الدعوى، فإذا كان كذلك اعتبرت الدعوى الصحيحة، وهي بأن يكون المدعي معلوماً في جنسه كالدرهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل كذا وكذا درهماً أو ديناراً، أو كرا وينكر مع ذلك صفتها، كالحنطة البيضاء أو الحمراء، وينكر أنها جيدة أو رديئة .

وإذا كان المدعي مجهولاً في نفسه لا تسمع ولا نعلم فيه خلافاً إلا في الوصية؛ فإن الأئمة الثلاث يجوزون دعوى المجهول في الوصية بأن ادعى حقاً من وصية أو إقراراً فإنهما يصحان بالمجهول، وتصح دعوى الإبراء بالمجهول بلا خلاف، ولا يشترط لسماع الدعوى المخالطة والمعاملة، ولا فرق فيه بين طبقات الناس، وعن مالك - رحمه الله - : لا يسمع دعوى الذمي الزاني على الشريف إذا لم يعرف بينهما نسب.

بِأَقْصَى مَا يُمَكِّنُ شَرْطٌ ، وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمَنْقُولِ ، لِأَنَّ النُّقْلَ
 مُمَكِّنٌ ، وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِالِدَّعْوَى وَجُوبُ
 الْحُضُورِ (2) ، وَعَلَى هَذَا الْقَضَاءِ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِّ عَصْرِ (3) ،
 وَوَجُوبُ الْجَوَابِ إِذَا حَضَرَ لِيُفِيدَ حُضُورَهُ ، وَلِزُومِ إِحْضَارِ
 الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ (4) لَمَّا قُلْنَا وَالْيَمِينِ إِذَا أَنْكَرَهُ (5) ، وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً (6) ذَكَرَ قِيَمَتَهَا لِيَصِيرَ
 الْمُدَّعَى مَعْلُومًا) ، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعْرَفُ بِالْوَصْفِ ، وَالْقِيَمَةُ تُعْرَفُ
 بِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ (7) . وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ (8) :
 يُشْتَرَطُ مَعَ بَيَانِ الْقِيَمَةِ ذِكْرُ الذَّكُورَةِ وَالْأُنْثَى .

(1) يعني إذا استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها .

(2) يعني يتعلق بالدعوى الصحيحة الحضور

(3) أي من كل زمان من أزمان الفقهاء والمجتهدين

(4) ويتعلق بالدعوى أيضا وجوب إحضار العين المدعاة مجلس القاضي
 على المدعى عليه إذا كانت منقولة قائمة في يده .

(5) البناية 316/9

(6) أي العين المدعاة

(7) لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك ،
 إذ هي المقصود غالبا ، ويذكر في القيمة شيئا معينا في قدره ووصفه
 وجنسه نفيا للجهالة لما بينا ، وإن كان حيوانا يذكر الذكورة أو الأنوثة .
 البناية 317/9 .

(8) أبو الليث : نصر بن محمد بن إبراهيم ، الإمام الفقيه الحنفي ، أبو
 الليث السمرقندي ، صاحب كتاب الفتاوى توفي سنة خمس وسبعين
 وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة هجرية . الفوائد البهية ،

(شروط المدعى به)

أَقَالَ (وَإِنْ ادَّعى عَقَارًا حَدَدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لَأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ لَتَعَذُّرِ النَّقْلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّحْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعْرَفُ بِهِ، وَيَذَكُرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ، وَيَذَكُرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابَهُمْ، وَلَا بَدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ، لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْرِيفِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِذِكْرِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ يَكْتَفِي بِهَا عِنْدَنَا، خِلَافًا لَزُفَرٍ لَوْجُودِ الْأَكْثَرِ⁽¹⁾، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَلَطَ فِي الرَّابِعَةِ، لَأَنَّهُ يَخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعى وَلَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا، وَكَمَا يَشْتَرُطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّعْوَى يَشْتَرُطُ فِي الشَّهَادَةِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَا بَدَّ مِنْهُ، لَأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَسِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَفِي الْعَقَارِ لَا يَكْتَفِي بِذِكْرِ الْمُدَّعى وَتَصَدِّقِ الْمُدَّعى عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، بَلْ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِيهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي، هُوَ الصَّحِيحُ⁽²⁾ نَفْيًا لَتَهْمَةِ الْمَوَاضَعَةِ، إِذِ الْعَقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ،

للكنوي ص 412، الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ) 54/27.

(1) لأن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . البناءة 318/9.

(2) الصحيح : هو لفظ يستعمل للترجيح بين الأقوال . الكواشف الجليلة عن مصطلحات الحنفية عبد الإله بن محمد الملا ص 203.

لأنَّ الأيد فيه مُشَاهِدَةٌ، وَقَوْلُهُ⁽¹⁾ : وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمُطَالِبَةَ حَقُّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ⁽²⁾، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرَهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوسًا بِالنَّهْنِ فِي يَدِهِ، وَبِالْمُطَالِبَةِ يَزُولُ هَذَا الْاِحْتِمَالُ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ : يَجِبُ أَنْ يَقُولَ : فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

قَالَ (وَأِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لَمَّا قُلْنَا⁽³⁾، وَهَذَا لِأَنَّ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدْ حَضَرَ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالِبَةُ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ بِهِ .

(سؤال المدعى عليه عن الشيء المدعى به وإقراره بذلك)

قَالَ (وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا)، لِيُنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ⁽⁴⁾، (فَإِنْ اعْتَرَفَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا)، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ ، فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ⁽⁵⁾ .

(مطالبة المدعى بالبينة عند إنكار المدعى عليه)

(وَأِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعَى الْبَيِّنَةَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ لَا، فَقَالَ: "لَكَ يَمِينُهُ" ⁽¹⁾ " سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى فَقَدِ الْبَيِّنَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِحْطَافُ⁽²⁾

(1) أي قول القدوري - رحمه الله -.

(2) أي: لأن المطالبة حق المدعي، فلا بد من طلبه حتى تجب على القاضي إعانته. البناية 319/9.

(3) إشارة إلى قوله: إن المطالبة حقه فلا بد من طلبه . البناية 320/9.

(4) لأن الأشياء التي تنقطع بها المنازعة الإقرار والبينة واليمين.

(5) لأن الإقرار موجب بنفسه، فلا يتوقف على القضاء، وإذا كان كذلك فيأمره بالخروج عنه، لأن ذلك موجب لإقراره.

. قَالَ (فَإِنْ أَحْضَرَهَا قُضِيَ بِهَا)، لَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا ، (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ) اسْتَحْلَفَهُ (عَلَيْهَا) ، لَمَّا رَوَيْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ(3).

نماذج أسئلة:

-عرف المدعى والمدعى عليه، والفرق بينهما.

-ما شروط قبول الدعوى؟

-بين شروط المدعى به.

(1)الإيمان لابن منده ، رقم 580.

(2)أي: فيمكن القاضي طلب اليمين من المدعى عليه. البناية 321/9.

(3)قوله .لَمَّا رَوَيْنَا ، يريد به قوله ﷺ «لَكَ يَمِينُهُ» ، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ الاستحلاف ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ ، قِيلَ : إِنَّمَا جَعَلَ يَمِينَ الْمُنْكَرِ حَقَّ الْمُدَّعِي ، لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ خَصْمَهُ أَتَى - أَهْلَكَ - حَقَّهُ بِإِنْكَارِهِ، فَالْشَّرْعُ جَعَلَ لَهُ حَقَّ اسْتِحْلَافِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ فَالْيَمِينَ الْغُمُوسُ مَهْلَكَةٌ لَخَصْمِهِ ، فَيَكُونُ إِتَوَاءٌ بِمُقَابَلَةِ إِتَوَاءٍ ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ كَالْقَصَاصِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا زَعَمَ ، فَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ يَنَالُ الثَّوَابَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى صَادِقًا، ثُمَّ إِنَّمَا رَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَيِّنَةِ لَا عَلَى الْعَكْسِ ، لِأَنَّ نَفْسَ الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِمُوجِبَةٍ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لِمَا ادَّعَاهُ، لِأَنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِالْآخِرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَوُجِبَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي لِإثْبَاتِ اسْتِحْقَاقِهِ بِهَا فَيُطَالِبُهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّنْكِيرِ لَهُ، الْعَنَاءَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ 169/8.

هل يطالب المدعي بالبينة عند إنكار المدعى عليه؟ وهل يقضى له بها؟

(بَابُ الْيَمِينِ) (1)

(طلب اليمين من المدعى عليه مع وجود البينة)

قال: (وَإِذَا قَالَ الْمُدْعَى لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عِنْدَ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، مَعْنَاهُ : حَاضِرَةٌ فِي الْمَصْرِ (2)، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُسْتَحْلَفُ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ مَرْتَبٌ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، لِمَا رَوَيْنَا ، فَلَا يَكُونُ حَقُّهُ دُونَهُ، كَمَا إِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ

(1) اليمين لغة: اليد اليمنى ، أو هو خلاف اليسار، وإنما سمي القسم يمينا ، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، وقيل اليمين لغة : القوة والقدرة ، وشرعا: عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى ، أو بصفة من صفاته على وجه مخصوص ، أو تعليق الجزاء على الشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط . " المغرب في ترتيب المغرب، للمطرزى ص 512، البناية 9/323.

(2) احترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم ، فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع، وإن طلب الخصم ، واحترز به أيضا عما إذا كانت البينة غائبة عن المصر، فحينئذ يستحلف بالاتفاق. البناية 9/323.

حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ ، وَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَصَافُ⁽¹⁾، وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ.

(رد اليمين على المدعى)

قَالَ (وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"⁽²⁾ قَسَمَ ، وَالْقِسْمَةُ تَنَافِي الشَّرَكَةِ، وَجَعَلَ جِنْسَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُنْكَرِينَ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ⁽³⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(التعارض بين بيعة صااحب اليد وبيعة الخارج في الملك)

(المطلق)

قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيْعَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمَلِكِ الْمَطْلُوقِ)⁽⁴⁾، وَبَيْعَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى⁽¹⁾ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِبَيْعَةِ ذِي الْيَدِ ،

(1)الخصاف: لقب أحمد بن عمرو الشيباني الإمام أبو بكر مؤلف الشروط ت 261 هـ . الجواهر المضية في طبقات الحنفية 400/1، معجم المؤلفين 35/2.

(2)السنن الصغرى ، للبيهقي ، رقم3103، سنن الدار قطنى رقم 4508.
(3)حيث قال: برد اليمين إلى المدعى، وهو مذهب مالك وكافة أصحابه ، وصوبه أحمد ، لقوله تعالى: (أَوْ يَخَافُوا أَنْ تَرَكَ إِيْمَانُ بَعْدَ أَمَانِهِمْ..سورة المائدة:108، ولآية واضحة الدلالة في رد اليمين على المدعى عند عزز المدعى عليه عن إقامة البيعة.

(4)وَقَيْدَ بِالْمَلِكِ الْمَطْلُوقِ ، إِحْتِرَازًا عَنِ الْمُقَيَّدِ بِدَعْوَى النَّتَاجِ، وَعَنِ الْمُقَيَّدِ بِمَا إِذَا ادَّعَى تَلْقَى الْمَلِكِ مِنْ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا قَابِضٌ، وَبِمَا إِذَا ادَّعَى الشَّرَاءَ

لَا عِتْصَادَهَا بِالْيَدِ ، فَيَنْتَقَوِي الظُّهُورُ ، وَصَارَ كَالنَّتَاجِ وَالنَّكَاحِ ،
وَدَعَوَى الْمَلِكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ (2) وَلَنَا : أَنْ بَيِّنَةَ
الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِثْبَاتًا أَوْ إِظْهَارًا ، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُ لَا يَثْبُتُهُ
بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ ، إِذْ الْيَدُ دَلِيلُ مُطْلَقِ الْمَلِكِ ، بِخِلَافِ النَّتَاجِ ، لِأَنَّ الْيَدَ
لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأُخْتِيهِ ، وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بِهَا
(3)

(القضاة بالنكول على المدعى عليه)

قَالَ (وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ،
وَالزَّمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَقْضَى بِهِ بَلْ يَرُدُّ
الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضَى بِهِ ، لِأَنَّ النُّكُولَ يَحْتَمِلُ
التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ، وَالتَّرَفُّعَ عَنِ الصَّادِقَةِ ، وَاشْتِبَاهَ
الْحَالِ ، فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةٌ مَعَ الْإِحْتِمَالِ ، وَيَمِينُ الْمُدَّعِي دَلِيلُ
الظُّهُورِ ، فَيُصَارُ إِلَيْهِ ؛ وَلَنَا : أَنَّ النُّكُولَ دَلٌّ عَلَى كَوْنِهِ بَازِلًا أَوْ

مِنْ اثْنَيْنِ ، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصُّورِ تَقْبُلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ
بِالْإِجْمَاعِ. الْعُنَايَةُ عَلَى الْهَدَايَةِ 173/8.

(1) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْمَفْتُى بِهِ ، وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
الْمَجْشُونِ ، وَرَوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ ، وَاسْتَدَلُّوا
بِحَدِيثِ : "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى" ، وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ بِهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ ، فَتَقْدُمُ ،
كَتَقْدِيمِ مَنْ مِنْ شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ وَرَثَتُهُ عَنْ
أَبِيهِ. الْمَبْسُوطُ 65/15 ،

(2) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُونُسَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ نَهَايَةَ الْمَحْتَاجِ 362/8 .

(3) وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. كِفَايَةُ النَّبِيِّ فِي شَرْحِ التَّبْيِيهِ 529/18.

مَقْرَأً، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ إِقَامَةً لِلْوَجِبِ، وَنَفَعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَتَرَجَّحَ هَذَا الْجَانِبُ، وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي لِمَا قَدَّمَاهُ⁽¹⁾.

(إنذار المدعي عليه بالقضاء بالنكول عند الإنكار)

«قَالَ (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْكَ الْيَمِينِ ثَلَاثًا، فَإِنْ حَلَفْتَ ، وَإِلَّا قُضِيَتْ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ) ، وَهَذَا الْإِنْذَارُ ، لِإِعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ. قَالَ (فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ) وَهَذَا التَّكْرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَزِيَادَةِ الْاِحْتِيَاظِ ، وَالْمَبَالِغَةِ فِي إِبْلَاءِ الْعُذْرِ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ قُضِيَ بِالنُّكُولِ بَعْدَ الْعَرَضِ مَرَّةً جَازَ ، لِمَا قَدَّمَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى⁽²⁾ .

(1) راجع في هذا مسألة رد اليمين على المدعي .

(2) قوله : " لما قدمناه " : إشارة إلى ما ذكر، إذ النكول دل على كونه باذلاً أو مقراً، كذا قاله الأترزي، والكاكي، والأكمل - رحمهم الله - وقال تاج الشريعة: قوله: "لما قدمناه" : يعني أنه لولا كونه كاذباً لأقدم على اليمين إقامته للجواب ، وقوله: "هو الصحيح" ، قال الأترزي - رحمه الله - : احتراز عن قول الخصاف ، فإنه يشترط التكرار، وقال الأكمل: احتراز عما قيل - لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ ، وهذا هو الأوجه، وقوله : "والأول أولى" ، أي ما تكره الخصاف أولى، كما في الإمهال للمرتد، فإن قتل بلا إمهال جاز. البناية 329/9.

(كيفية النكول)

ثُمَّ النُّكُولُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقًا كَقَوْلِهِ لَا أَحْلَفُ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمًا بِأَنْ يَسْكُتَ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا آفَةَ بِهِ مِنْ طَرَشٍ أَوْ خَرَسٍ هُوَ الصَّحِيحُ (1) .

(الدعاوى التى لا يستحلف فيها المنكر)

قَالَ (وَأِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفَ الْمُنْكَرُ) (2) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَالرَّجْعَةِ (3) ، وَالْفَيْءِ فِي الْإِبْلَاءِ (4) ، وَالرِّقِّ، وَالِاسْتِيلَادِ (5)،

(1) أشار به إلى اختلاف الروايات فيما إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ولم يقل - لا أحلف، فقال بعض أصحابنا: إذا سكت المدعى عليه سأل القاضي: هل به خرس أو طرش؟ فإذا قالوا: لا، جعله ناكلا، وقضى عليه، ومنهم من قال: يحبس حتى يجيب، والأول هو الصحيح. البناية 329/9.

(2) ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة وبالعكس، فلا استحلاف فيه عنده.

(3) أي ولا يستحلف أيضا في الرجعة، بأن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه كان راجعا في العدة، وهي تجدد أو ادعت هي كذلك وهو يجحد.

(4) أي ولا يستحلف في الفَيْء في الإيلاء أيضا، بأن ادعى بعد مضي هذه الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وهي تجدد، أو ادعت المرأة كذلك وهو يجحد.

(5) بأن ادعت الأمة على مولاهما أنها ولدت منه وأنكر المولى، ولا يتصور العكس من قبله عليها، لأن الاستيلاء يثبت بإقراره.

وَالنَّسَبِ (1) وَالْوَلَاءِ (2) وَالْحُدُودِ وَاللَّعَانِ (3). وَقَالَا: يَسْتَحْلِفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَاللَّعَانِ.

(استحلاف السارق)

قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ السَّارِقُ⁽⁴⁾) ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَقْطَعْ لَأَنَّ الْمَنُوطَ بِفَعْلِهِ شَيْئَانِ: الضَّمَانُ وَيَعْمَلُ فِيهِ النُّكُولُ ، وَالْقَطْعُ ، وَلَمَّا يَثْبُتْ بِهِ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ⁽⁵⁾

(استحلاف الزوج في دعوى الطلاق قبل الدخول والنسب)

(1) ولا يستحلف في الولاء بأن ادعى على معروف النسب أنه معتقه.
(2) ولا يستحلف في النسب، بأن ادعى الوالد على الولد وأنكر الآخر.
(3) أي ولا يستحلف أيضا فيهما. أما الدعوى في الحد بأن قال رجل لآخر: لي عليك حد قذف وهو ينكر لا يستحلف بالإجماع، لأنه يندرا بالشبهات، إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبد بالزنا، وقال: إن زنيته فأنت حر، وادعى العبد: أنني زنيته، ولا بينة له عليه يستحلف المولى حتى إذا نكل ثبت العتق.

(4) يريد به أنه إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع يستحلف السارق بالله ما له عليك هذا المال لأنه يثبت بالشبهات؛ ألا يرى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة، فجاز أن يثبت بالنكول الذي هو بذل أو إقرار فيه شبهة، والحدود لا تقام بحجة فيها شبهة فكذا لا تقام بالنكول، فتح القدير: 187/8.

(5) قوله: "ولا يثبت به أي ولا يثبت القطع بالنكول" ، لأنه لا يجري البذل بالنكول في الحدود، ولا يثبت بما فيه شبهة الإقرار فيثبت المال ولا يثبت القطع. البناية 334/9.

قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتَحْلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا)، لِأَنَّ الاسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ، لَا سِيمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ⁽¹⁾، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَ⁽²⁾، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَالِ، ثُمَّ يَثْبُتُ الْمَالُ بِنُكُولِهِ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ، وَكَذَا فِي النَّسَبِ⁽³⁾، إِذَا ادَّعَى حَقًّا، كَالْإِرْثِ⁽⁴⁾ وَالْحَجْرِ فِي اللَّقِيطِ⁽⁵⁾.

(1) وفائدة تعيين صورة المسألة في الطلاق قبل الدخول هي تعليم أن دعوى المهر لا تتفاوت بين أن تكون الدعوى في كل المهر أو نصفه. فتح القدير: 188/8.

(2) أي وكذا يستحلف الزوج بالإجماع فيما إذا ادعت المرأة مع النكاح الصداق، لأن ذلك دعوى المال، أي المقصود من ذلك دعوى المال، ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح، يعني يثبت المال بنكوله في قولهم جميعا لأن المال يجري فيه الإقرار والبذل، ولا يثبت النكاح في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن النكاح لا يجري فيه البذل. فتح القدير: 188/8.

(3) أي وكذا يستحلف في النسب بالإجماع. فتح القدير: 188/8.
(4) بأن ادعى رجل على رجل أنه أخ المدعى عليه مات أبوهما وترك مالا في يد المدعى عليه فإنه يستحلف بالإجماع، فإن حلف برئ، وإن نكل يقضى بالمال دون النسب. فتح القدير: 188/8.

(5) بأن ادعت امرأة حرة الأصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد رجل النقطة أنه أخوها وأنها أولى بحضانتها فإنه يستحلف بالإجماع، فإن نكل ثبت لها حق نقل الصبي إلى حجرها دون النسب. فتح القدير: 188/8.

وَالنَّفَقَةُ⁽¹⁾ وَامْتِنَاعُ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ⁽²⁾، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هَذِهِ
الْحَقُوقَ⁽³⁾، وَإِنَّمَا يَسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمَجْرَدِ⁽⁴⁾ عِنْدَهُمَا⁽⁵⁾، إِذَا
كَانَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ⁽⁶⁾، كَالْأَبِ وَالْأَبْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ⁽⁷⁾، وَالْأَبِ

(1) بأن ادعى زمن على موسى أنه أخوه وأن نفقته عليه فأنكر المدعى
عليه الأخوة يستحلف بالإجماع، فإن نكل يقضى بالنفقة دون النسب. فتح
القدير: 189/8.

(2) بأن أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنت أخي يريد
بذلك إبطال حق الرجوع فإنه يستحلف بالإجماع، فإن نكل ثبت امتناع
الرجوع دون النسب. فتح القدير: 189/8.

(3) يعني أن المقصود بالدعوى في المسائل المذكورة هذه الحقوق: أي
دون النسب المجرد. فتح القدير: 189/8.

(4) قيد به احترازاً عما هو مقرون بدعوى حق آخر. فتح القدير: 190/8.

(5) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. فتح القدير: 190/8.

(6) أي إذا كان يثبت النسب بمجرد إقرار المدعى عليه فإن النكول
عندهما إقرار فكل نسب لو أقر به المدعى عليه ثبت يثبت بالنكول أيضاً.
فتح القدير: 190/8.

(7) إذا أقر بالأب والابن يصح إقراره ويثبت نسب المقر له منه بمجرد
إقراره. فتح القدير: 190/8.

فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ⁽¹⁾، لَأَنَّ فِي دَعْوَاهَا الْبَابَ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِّهِمَا.⁽²⁾

(استحلاف المدعى عليه بالقصاص)

قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَدَّهُ اسْتَحْلَفَ⁽³⁾) ،
بِالْإِجْمَاعِ⁽⁴⁾، (ثُمَّ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، يَلْزِمُهُ
الْقِصَاصُ، وَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفْسِ ، حُبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَقْرَ)
وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَقَالَا: لَزِمَهُ الْأَرَشُ
فِيهِمَا⁽⁵⁾، لَأَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ
الْقِصَاصُ ، وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ
لِمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ مِنْ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا أَقْرَّ بِالْخَطَا وَالْوَلِيُّ يَدَّعِي
الْعَمْدَ⁽⁶⁾. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأَطْرَافَ يَسْلُكُ بِهَا

(1) إذا أقرت بالأب يصح إقرارها ويثبت نسب المقر له منها بمجرد إقرارها، وأما لو أقرت بالابن فلا يصح إقرارها ولا يثبت نسبه منها. فتح القدير: 190/8.

(2) لأن في ادعائها الابن: أي في إقرارها به، تحميل النسب على الغير، وهو لا يجوز، والمولى: أي وكالولي: يعني السيد، والزوج في حقهما: أي في حق الرجل والمرأة، وهذا القيد: فتح القدير: 190/8.

(3) المدعى عليه.

(4) سواء كانت الدعوى في النفس بها أو فيما دونها

(5) أي يلزمه المال في النفس والطرف جميعا

(6) ولأنه لم يصح بالإقرار فأشبه الخطأ، وأما إذا كان الامتناع من جانب من له ، كما إذا أقام مدعي القصاص رجلا وامرأتين أو الشهادة على

مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ ، فَيَجْرِي فِيهَا الْبَدْلُ ، بخِلَافِ الْآنْفُسِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : اقْطَعْ يَدِي ، فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَهَذَا إِعْمَالٌ لِلْبَدْلِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا بِيَّاحَ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَهَذَا الْبَدْلُ مُفِيدٌ لَانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ ، فَصَارَ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكْلَةِ ، وَقَلَعَ السِّنَّ لِلْوَجَعِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقَصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَالْيَمِينِ حَقَّ مُسْتَحَقٍّ يَحْبَسُ بِهِ (1) ، كَمَا فِي الْقَسَامَةِ (2)

(الكفالة بالنفس عن المدعى عليه للحضور أمام القضاء)

قَالَ : (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي : لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ، قِيلَ لَخَصْمَةِ : أَعْطَهُ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كَى لَا يَغِيبُ نَفْسَهُ ، فَيَضِيعَ حَقُّهُ ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَأَخَذَ

الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ لَا يَقْضَى بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ بِالْقَصَاصِ لَكِنْ تَعَثَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَمْ يَشِبْهُ الْخَطَأُ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَلَا تَفَاوَتْ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا . العناية 191/8.

(1) لِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الْأَطْرَافَ يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ وَقَايَةً لِلنَّفْسِ ، كَالْأَمْوَالِ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَدْلُ ، فَلَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِعْمَالُ الْبَدْلِ ، بخِلَافِ الْآنْفُسِ فَلَا يَجْرِي فِيهَا الْبَدْلُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ يُؤْخَذُ بِالْقَصَاصِ فِي رِوَايَةٍ وَبِالْيَدِيَةِ فِي أُخْرَى . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ الْأَطْرَافُ يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ لَجَازَ قَطْعُ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ إِذَا قَالَ اقْطَعْ يَدِي . أَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنَّهُ لَا بِيَّاحَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَطْعُ مُفِيدًا كَالْقَطْعِ لِلْأَكْلَةِ وَقَلَعَ السِّنَّ لِلْوَجَعِ لَمْ يَأْتُمْ بِفِعْلِهِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْبَدْلِ : أَيُّ الَّذِي بِالْتَّكْوُلِ مُفِيدٌ ، لَانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَيَكُونُ مَبَاحًا . العناية 191/8 ، 192.

(2) فَإِنَّهُمْ إِذَا نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ يَحْبَسُونَ ، حَتَّى يَقْرَأُوا أَوْ يَحْلِفُوا . قِرَّةٌ عَيُونَ الْأَخْيَارِ لَتَكْمَلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ 59/8.

الْكفيل بِمَجَرَّدِ الدَّعْوَى اسْتِحْسَانٌ عِنْدَنَا، لَأَنَّ فِيهِ نَظْرًا لِلْمُدَّعِي ،
وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرٌ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا لَأَنَّ الْحُضُورَ
مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِمَجَرَّدِ الدَّعْوَى حَتَّى يَعْدَى عَلَيْهِ وَيَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
أَشْغَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِإِحْضَارِهِ (1)، وَالتَّقْدِيرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرُورٍ
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا فَرْقَ فِي
الظَّاهِرِ بَيْنَ الْخَامِلِ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَطِيرِ ، ثُمَّ لَا
بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لِلتَّكْفِيلِ وَمَعْنَاهُ فِي الْمَصْرِ ، حَتَّى لَوْ
قَالَ الْمُدَّعَى لَا بَيِّنَةٌ لِي أَوْ شُهُودِي غَيْبٌ لَا يَكْفُلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ .
قَالَ (فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلَازِمَتِهِ) ، كَيْ لَا يَذْهَبَ حَقُّهُ ، (إِلَّا أَنْ
يَكُونَ غَرِيبًا فَيُلَازِمُ مِقْدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِي) ، وَكَذَا لَا يَكْفُلُ إِلَّا
إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مَنْصَرَفٌ إِلَيْهِمَا ، لَأَنَّ فِي أَخْذِ
الْكفيلِ وَالْمُلَازِمَةِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهِ بِمَنْعِهِ عَنِ السَّفَرِ ،
وَلَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْمَقْدَارِ ظَاهِرًا ، وَكَيْفِيَّةُ الْمُلَازِمَةِ نَذَرُهَا فِي
كِتَابِ الْحَجَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (2)

(1) أَمَّا جَوَازُ التَّكْفِيلِ فَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ، وَالْقِيَاسُ بِأَبَاهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ ،
وَوُجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ الْحُضُورَ بِمَجَرَّدِ الدَّعْوَى مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ
يَعْدَى عَلَيْهِ ، وَيَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ فَيَصَحُّ التَّكْفِيلُ بِإِحْضَارِهِ نَظْرًا
لِلْمُدَّعَى وَضَرَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ يَسِيرُ فَيَتَحَمَّلُ كَالِإِعْدَاءِ وَالْحِيلُولَةِ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ . الْعِنَايَةُ عَلَى الْهَدَايَةِ 193/8 .

(2) الْمُلَازِمَةُ : أَنْ يَدُورَ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ ، وَيَبْعَثُ أَمِينًا حَتَّى يَدُورَ مَعَهُ أَيْنَمَا
دَارَ ، وَلَا يَحْبِسُهُ فِي مَوْضِعٍ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الدَّعْوَى ، وَلَا

نماذج أسئلة:

- هل يجوز طلب اليمين من المدعى عليه مع وجود البينة؟
- هل تُردُّ اليمينُ على المدَّعي؟
- حكم التعارض بين بينة صاحب اليد وبينة الخارج في الملك المطلق.
- هل يقضي القاضي بالنكول على المدعى عليه؟
- بين حقيقة النكول، وكيفيته.
- ما الدعاوى التي لا يستحلف فيها المنكر؟
- هل يستحلف في دعوى النكاح؟
- هل يستحلف السارق؟، وما الحكم عند نكوله؟
- ما الأثر المترتب على استحطاف الزوج في دعوى الطلاق قبل الدخول والنسب؟
- هل يستحلف المدعى عليه بالقصاص؟، وما الأثر المترتب على نكوله؟

يشغله عن التصرف، والمدعي يدور معه ، ولا يمنعه من الدخول إلى أهله ، ويجلس على باب داره . البناية 340/9.

(فصلٌ في كيفية اليمين والاستحلاف)

(بم يكون الحلف للمسلم)

قَالَ (وَالْيَمِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرَ⁽¹⁾ ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ"⁽²⁾ .

(كيفية تغليظ اليمين على المسلم)

(وَقَدْ تَوَكَّدَ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ) وَهُوَ التَّغْلِيظُ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: قُلْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ، مَا لِفُلَانٍ هَذَا عَلَيْكَ ، وَلَا قَبْلَكَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى هَذَا ، وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاطُ فِيهِ كَيْ لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَمِينٍ وَاحِدَةً، وَالْقَاضِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَلَطَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَغْلُظْ فَيَقُولُ: قُلْ بِاللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: لَا يَغْلُظُ عَلَى الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ ، وَيَغْلُظُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقِيلَ: يَغْلُظُ فِي الْخَطِيرِ مِنَ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ .

(1) متفق عليه بين الشيخين: البخاري رقم 2679 مسلم رقم 1646.

(2) رواه ابن حبان في صحيحه، ولأن المسلم الورع يعتقد تعظيم اسم الله تعالى، فصلح ذكره . صحيح ابن حبان، 4358.

(الاستحلاف بالطلاق)

قَالَ (وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْعَتَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ سَاغَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ نَفْلَةً الْمُبَالَاةِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةَ الْأَمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ⁽¹⁾

(استحلاف غير المسلم)

قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَالنَّصْرَانِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَابِنِ صُورِيَّا الْأَعُورِ "أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَنْ حُكِمَ الزَّيْنَا فِي كِتَابِكُمْ هَذَا (2)" ، وَلِأَنَّ الْيَهُودِيَّ يَعْتَقِدُ نُبُوَّةَ مُوسَى وَالنَّصْرَانِيَّ نُبُوَّةَ عِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَيُغْلَظُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذِكْرِ الْمَنْزَلِ عَلَى نَبِيِّهِ، (و) يَسْتَحْلِفُ (الْمَجُوسِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ)⁽³⁾

(1) وهذا قول عامة المتأخرين من الحنفية، واستدلوا: بأن عبد الله بن عمرو بن العاص حلف بالطلاق عند النبي ﷺ ولم ينكر عليه، ولأنه لما ضعف الوازع الديني عند بعض الناس، مست الحاجة إلى الوثيقة بالطلاق، وما أشبه. تبين الحقائق 419/3.

(2) رواه مسلم في صحيحه رقم 1700/28، شرح مشكل الآثار للطحاوي رقم 4539.

(3) لأن المجوسي يعتقد الحرمة في النار، فيمتنع عن اليمين الكاذبة ، فيحصل المقصود. تكملة فتح القدير 206/8، 207.

وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ⁽¹⁾، يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي النُّوَادِرِ⁽²⁾: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ أَحَدًا إِلَّا بِاللَّهِ خَالِصًا، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ غَيْرَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا ، لِأَنَّهُ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْظَمَ⁽³⁾، بِخِلَافِ الْكُتَّابِينَ، لِأَنَّهُ كُتِبَ اللَّهُ مُعْظَمَةً (وَالْوُثْقَى لَا يَحِلُّ إِلَّا بِاللَّهِ)، لِأَنَّ الْكُفْرَةَ بِأَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُونَ اللَّهُ تَعَالَى⁽⁴⁾، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. } [لقمان: 25] .

(1) كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، وهو من كتب ظاهر الرواية ، والتي تتضمن أيضا السير الصغير والكبير ، والجامع الصغير والكبير ، والزيادات ، وسمى بالأصل ، لأن الشيباني صنفه قبل سائر كتبه المعروفة . مفتاح السعادة 263/2.

(2) تطلق على المسائل التي رويت عن أئمة المذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في غير كتب ظاهر الرواية كـ " الرقيات ، والهارونيات ، والكيسانيات والجرجانيات ، أو كتب غيره من أصحاب أبي حنيفة ، كالأمالي ، لأبي يوسف والمجرد للحسن بن زياد ، أو تكون بروايات مفردة ، كروايات ابن سماعة ، والمعلّى بن منصور وغيرهم . رد المحتار 50/1 ، 69.

(3) روى عن أبي حنيفة ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.

(4) تكملة فتح القدير 207/8 ، الذخيرة 73/11 ، الحاوي 117/17 ، المغنى 228/9.

(حكم تغليظ اليمين على المسلم)

قَالَ (وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ)، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمَ الْمَقْسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِيْجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي حَيْثُ يَكْلِفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدْفُوعٌ.

(افتداء اليمين)

قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرٍ مَالًا ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ ، أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشْرَةٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ) وَهُوَ مَاثُورٌ عَنْ عُثْمَانَ (1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ أَبَدًا)، لِأَنَّهُ اسْقَطَ حَقَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نماذج أسئلة:

- بم يكون الحلف للمسلم، وغير المسلم؟
- كيفية تغليظ اليمين على المسلم.
- مدى جواز الاستحلاف بالطلاق؟
- حكم تغليظ اليمين على المسلم.
- حكم افتداء اليمين.

(1) عن الشعبي، أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم ، فلما تقاضاه، قال: " إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم ، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف ، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف فقال عمر رضي الله عنه: " أنصفك " فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك " قال: البيهقي : هذا إسناد صحيح إلا أنه منقطع. السنن الكبرى للبيهقي رقم 20740.

(بَابُ التَّحَالُفِ)

(حكم يمين المتبايعين)

قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرِ مِنَ الْمَبِيعِ ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا) ، لِأَنَّ فِي الْجَانِبِ الْآخِرِ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْهَا (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ لِلنَّائِبَاتِ وَلَمْ تَعَارِضْ فِي الزِّيَادَةِ ، (وَلَوْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا ، فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الثَّمَنِ ، وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ) نَظَرًا إِلَى زِيَادَةِ النَّائِبَاتِ ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، وَقِيلَ لِلْبَائِعِ : إِمَّا أَنْ تَسْلِمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ ، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ) ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعَ الْمُنَازَعَةِ ، وَهَذِهِ جِهَةٌ فِيهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرْضِيَانِ بِالْفَسْخِ ، فَإِذَا عَلِمَا بِهِ يَتَرَاضِيَانِ بِهِ ، (فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضِيَا ، اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ) ، وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَنْكُرُهُ ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي وَجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا نَقَدَ ، وَالْبَائِعُ يَنْكُرُهُ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكَرٌ فَيَحْلِفُ ؛ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ، فَمُخَالَفٌ لِلْقِيَاسِ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِي شَيْئًا ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَالِمٌ لَهُ ، فَبَقِيَ دَعْوَى الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يَنْكُرُهَا فَيَكْتَفِي بِحَلْفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ

بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ ، وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ بَعِينَهَا ، تَحَالَفَا وَتَرَادَا"(1)

(البدء بيمين المشتري عند الاختلاف)

قال: (وَيَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي) ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا إِنْكَارًا ، لِأَنَّهُ يُطَالَبُ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ النُّكُولِ ، وَهُوَ الْإِزَامُ الثَّمَنِ ، وَلَوْ بَدَأَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى زَمَانِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ أَوَّلًا: يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ"(2) ، خَصَّهُ بِالذِّكْرِ ، وَأَقْلُ فَائِدَتَهُ النَّقْدِيمِ.

(البدء بيمين أحد المتبايعين في المقايضة والصرف)

(وَإِنْ كَانَ بَيْعٌ عَيْنٍ بَعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِثَمَنٍ بَدَأَ الْقَاضِي بِيَمِينِ أَحَدِهِمَا شَاءَ) لَاسْتَوَائِهِمَا.

(1) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم 786 ، شرح مشكل

الآثار رقم 2389.

(2) المسند: للشاشي ، رقم 302 ، الآثار ، لأبي يوسف رقم 830.

(صفة اليمين عند اختلاف المتبايعين)

(وصفة اليمين : أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف ، ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين) ، وقال في الزيادات⁽¹⁾ :
 يحلف بالله ما باعه بألف ، ولقد باعه بألفين ، يحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف ، يضمن الإثبات إلى النفي تأكيداً ، والأصح الاقتصار على النفي ، لأن الأيمان على ذلك وضعت ، دل عليه حديث القسامة بالله ما قتلتم ولا علمتم له قاتلاً⁽²⁾ قال (فإن حلفاً ، فسخ القاضي البيع بينهما) ، وهذا يدل على أنه لا يفسخ بنفس التحالف ، لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما ، فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي ، قطعاً للنمنازعة ، أو يقال : إذا لم يثبت البذل يبقى بيعاً بلا بدل ، وهو فاسد ، ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد⁽³⁾

(1) كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، شرحه قاضي خان ت 592 ، مطبوع . مفتاح السعادة ، كبرى زادة 2 / 263.

(2) السنن الكبرى: للبيهقي، رقم 16451، عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه)

(3) ولأن الاختلاف في البذل يوجب الاختلاف في العقد، لأن كل واحد منهما ادعى عقداً غير الذي ادعاه الآخر فكان البيع مجهولاً لجهالة البذل. البناية 9/356.

(نكول أحد المتبايعين)

قَالَ: (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ) لَأَنَّهُ جُعِلَ بَازِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعْوَاهُ مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْآخَرِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِنُبُوَّتِهِ⁽¹⁾ .

(اختلاف المتبايعين في الأجل وما أشبهه)

قَالَ (وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ، أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ، أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ ، فَلَا تَحَالَفَ بَيْنَهُمَا)، لَأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالْمَعْقُودِ بِهِ، فَأَشْبَهَ الْاِخْتِلَافَ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ، وَهَذَا لِأَنَّ بَانْعِدَامَهُ لَا يَخْتَلُ مَا بِهِ قَوَامُ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ الْاِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جَرِيَانِ التَّحَالَفِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الثَّمَنِ، فَإِنَّ الثَّمَنَ دِينَ، وَهُوَ يَعْرِفُ بِالْوَصْفِ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَجَلُ، لَأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْفٍ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيِّهِ. قَالَ: (وَالْقَوْلُ قَوْلٌ مَنْ يَنْكُرُ الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُمَا يَثْبُتَانِ بِعَارِضِ الشَّرْطِ وَالْقَوْلِ لِمَنْكُرِ الْعَوَارِضِ.

(اختلاف المتبايعين عند هلاك المبيع)

قَالَ: (فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اِخْتَلَفَا ، لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيَمَةِ الْهَالِكِ)،

(1) لعدم المعارض. البناءة 356/9.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (1) - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِالْعَيْبِ. لَهُمَا : أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدْعِي غَيْرَ الْعَقْدِ الَّذِي يَدْعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ ، وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ؛ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَّلْعَةِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : أَنَّ التَّحَالَفَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، لِأَنَّهُ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي مَا يَدْعِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِ السَّلْعَةِ، وَالتَّحَالَفُ فِيهِ يُفْضِي إِلَى الْفَسْخِ، وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهَا ، لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالِاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حَصُولِ الْمَقْصُودِ، وَإِنَّمَا يِرَاعَى مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوْجِبُهُ الْعَقْدُ، وَفَائِدَةُ دَفْعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لَيْسَتْ مِنْ مُوْجِبَاتِهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ قَائِمٌ فَتَوْفَرُ فَائِدَةُ الْفَسْخِ، ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلُ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ (2)

(1) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/378.

(2) أي: يرد قيمته إن لم يكن له مثل، كما إذا تبايعا حيوانا بحيوان .

البنية 9/360.

(السِّلْمُ واختلاف المتبايعين في الثمن)

قَالَ (وَمَنْ أَسْلَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرٍّ حَنْطَةٍ (1) ثُمَّ تَقَايَلَا (2) ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ السِّلْمُ (3)) ، لَأَنَّ الْقَائِلَةَ فِي بَابِ السِّلْمِ لَا تَحْتَمِلُ النِّقْضَ ، لَأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَلَا يَعُودُ السِّلْمُ ، بخلاف الْقَائِلَةَ فِي الْبَيْعِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَأْسَ مَالِ السِّلْمِ لَوْ كَانَ عَرْضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى رَبِّ السِّلْمِ لَا يَعُودُ السِّلْمُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .

(اختلاف الزوجين في المهر)

قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادْعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتْ تَزَوَّجَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةُ تَقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) ، لَأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ .

(1) يضم الكاف وتشديد الراء، وهو مكيال لأهل العراق معروف، وقال الأزهري: الكر ستون ققيزا والققيز ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف صاع وهو ثلاث كيلجات، قال: وهو من الحساب اثنا عشر وسقا، والوسق ستون صاعا.

(2) أي : السِّلْمُ .

(3) وهو في اللغة: التقديم والتسليم وكذلك السلف، وهو في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي الثمن آجلا، وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن . الاختيار لتعليل المختار 33/2، المعرب صـ

(وَأَنَّ أَقَامَا الْبَيِّنَةِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ) ، لَأَنَّهَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةَ ،
 مَعْنَاهُ : إِذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ ، (وَأِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
 بَيِّنَةٌ تَحَالُفًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَمْ يَفْسَخِ النِّكَاحُ) ، لِأَنَّ أَثَرَ
 التَّحَالُفِ فِي انْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يَخُلُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، لِأَنَّ
 الْمَهْرَ تَابِعٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ يَفْسُدُهُ عَلَى مَا
 مَرَّ فَيَفْسَخُ ، (وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ مَا اعْتَرَفَ
 بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ ، قَضَى بِمَا قَالَ الزَّوْجُ) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ
 لَهُ ، (وَأِنْ كَانَ مِثْلُ مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قَضَى بِمَا ادَّعَتْهُ
 الْمَرْأَةُ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ وَأَقَلَّ
 مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ ، قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَحَالَفَا ،
 لَمْ تَثْبُتِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَمْ يَحْطُ عَنْهُ . قَالَ - رَحِمَهُ
 اللَّهُ - : ذَكَرَ التَّحَالُفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَرْخِيِّ (1) -
 رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ ،
 وَسَقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالُفِ وَلِهَذَا يَقْدَمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا ، وَيَبْدَأُ
 بِبَيِّنِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعَجُّيلًا لِفَائِدَةِ النُّكُولِ كَمَا فِي

(1) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخي ، كرخ
 حدان ، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد
 البردعي ، وانتشرت أصحابه ، وعنه أخذ أبو بكر الرازي ، وأبو عبد الله
 الدامغاني ، وأبو علي الشاشي ، وأبو القاسم علي بن محمد التتوخي ،
 وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة . (الجواهر المضية
 في طبقات الحنفية ، لمحيي الدين الحنفي (المتوفى: 775 هـ) 337/1).

المُشْتَرِي، وَتَخْرِيجُ الرَّازِي بِخُلَافِهِ وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَاهُ فِي النِّكَاحِ
وَذَكَرْنَا خُلَافَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا نَعِيدُهُ⁽¹⁾

(اختلاف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه)

(وَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، تَحَالَفَا
وَتَرَادَا) ، مَعْنَاهُ : اِخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوْ فِي الْمُبْدَلِ ، لِأَنَّ التَّحَالَفَ
فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَالْإِجَارَةُ
قَبْلَ الْقَبْضِ ، الْمَنْفَعَةُ نَظِيرُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَكَلَامُنَا قَبْلَ
اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، (فَإِنْ وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ يَبْدَأُ بِيَمِينِ
الْمُسْتَأْجِرِ) ، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَوْجُوبِ الْأَجْرَةِ ، (وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفَعَةِ
يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُؤَجَّرِ ، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، وَأَيُّهُمَا
أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ ، وَلَوْ أَقَامَاهَا ، فَبَيِّنَةُ الْمُؤَجَّرِ أَوْلَى إِنْ كَانَ
الْاِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنَافِعِ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ
أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ، قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدْعِيهِ
مَنْ الْفَضْلُ) نَحْوُ أَنْ يَدْعِيَ هَذَا شَهْرًا بَعَثَرَةً ، وَالْمُسْتَأْجِرُ
شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ يَقْضِي بِشَهْرَيْنِ بَعَثَرَةً.

(1) وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْجِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ ، إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَكْرٍ : يَعْنِي فِي بَابِ الْمَهْرِ فَلَا نَعِيدُهُ . العناية 231/8.

(اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء جميع المعقود عليه)
 قَالَ (وَإِنْ اِخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ، لَمْ يَتَحَالَفَا، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ
 الْمُسْتَأْجِرِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ هَٰذَا
 الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالَفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ
 الْهَلَكَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ عِنْدَهُ فِي الْمَبِيعِ لِمَا أَنَّ لَهُ قِيَمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ
 فَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهَا، وَلَوْ جَرَى التَّحَالَفُ هَاهُنَا وَفُسَخَ الْعَقْدُ، فَلَا قِيَمَةَ
 ، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقُومُ بِنَفْسِهَا، بَلْ بِالْعَقْدِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عَقْدَ، وَإِذَا
 امْتَنَعَ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَيْهِ (1)

(اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء بعض المعقود عليه)

(

(وَإِنْ اِخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسَخَ
 الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ ، وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ)، لِأَنَّ
 الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ كَأَنَّ
 ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا
 تَعَذَّرَ فِي الْبَعْضِ تَعَذَّرَ فِي الْكُلِّ (2)

(اختلاف الزوجين في متاع البيت)

(1) ومضى وقع الخلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه مع
 يمينه . البناية 9/371.

(2) أى: فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك، تعذر في الكل ضرورة، فظهر
 الفرق .

قَالَ (وَإِذَا اِخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلَحُ لِلرَّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، كَالْعِمَامَةِ) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَمَا يَصْلَحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ، كَالْوَقَايَةِ) ، لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا (وَمَا يَصْلَحُ لهُمَا ، كَالْأَنِيَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ) ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ ، وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا ، لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَمْ يَفَرْقْ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْاِخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ.

(بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ) (1)

(الحكم إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ببينتهما)

قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى اثْنَانِ عَيْنًا فِي يَدِ آخَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا) (2)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: تَهَاتَرَتَا (3)، وَفِي قَوْلٍ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا (4)؛ لِأَنَّ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ كَاذِبَةٌ بَيِّنٌ ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمَلِكَيْنِ فِي الْكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ

(1) أي هذا باب في بيان ما يدعيه الرجلان، ولما فرغ من بيان حكم الواحد شرع في بيان حكم الاثنين؛ لأنه بعد الواحد.

(2) واستدلوا بحيث الناقة ، ولأن البينة أقوى من اليد ، وقد ثبت أنهما إذا تساويا في اليد جعل بينهما ، فكذاك إذا تساويا في البينة من باب أولى .
الفتاوى التاتارخانية 5/502.

(3) واستدلوا : بأن البينة حجة في الشرع ، والبينتان حجتان تعارضتا دون مرجح ، فسقطتا ، كالخبرين إذا تعارضا. الحاوي 17/319.

(4) وهو قول عند الشافعية . البيان في مذهب الشافعي 7/169.

، وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَيَتَهَاتَرَانِ أَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرْعَةِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَقْرَعَ فِيهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكَمُ
بَيْنَهُمَا⁽¹⁾ ، وَلَنَا حَدِيثُ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ: " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ⁽²⁾ .

وَحَدِيثُ الْقُرْعَةِ كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُسِخَ ، وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ لِلشَّهَادَةِ
فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمَلُ الْوُجُودِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ أَحَدُهُمَا
سَبَبُ الْمَلِكِ ، وَالْآخِرُ الْيَدَ ، فَصَحَّتِ الشَّهَادَتَانِ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ
بِهِمَا مَا أَمَكَنَ ، وَقَدْ أَمَكَنَ بِالتَّنْصِيفِ ، إِذِ الْمَحِلُّ يَقْبَلُهُ ، وَإِنَّمَا
يُنْصَفُ لِاسْتَوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ⁽³⁾ .

(إذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا)

(وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَا
بَيِّنَةً فَالرَّهْنُ أَوْلَىٰ) ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَفِي الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أَوْلَىٰ
لِأَنَّهَا تُثَبَّتُ الْمَلِكُ وَالرَّهْنُ لَا يُثَبَّتُ. وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ: أَنَّ
الْمَقْبُوضَ بِحُكْمِ الرَّهْنِ مَضْمُونٌ ، وَبِحُكْمِ الْهِبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ،
وَعَقْدُ الضَّمَانِ أَقْوَىٰ ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِشَرَطِ الْعَوَضِ ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ

(1) رواه الطبراني في الأوسط 98/3، 99، وقال : تفرد به أبو مصعب ،
أبو داود في مراسيله رقم 424.

(2) رواه أبو داود ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم
يخرجاه . السنن رقم 1613، المستدرک 95/4.

(3) البحر الرائق 397/7، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،
للسبكي 492/3.

انْتِهَاءَ وَالْبَيْعُ أَوْلَىٰ مِنَ الرِّهْنِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ ضَمَانٌ يُثَبِّتُ الْمَلِكُ صُورَةً وَمَعْنَى، وَالرِّهْنُ لَا يَثْبُتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْهَلَاكِ مَعْنَى لَا صُورَةً ، فَكَذَا الْهَبَةُ بِشَرْطِ الْعَوَضِ.

(إذا أقام الخارجان بينة مقيدة على الملك وتاريخ أحدهما أقدم

(

وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ ، فصاحب التاريخ الأقدم أولى) ، لأنه أثبت أنه أول المالكين ، فلا يتلقى الملك إلا من جهته ، ولم يتلق الآخر منه⁽¹⁾ .

(الحكم إذا ادعى الشراء من غير صاحب اليد وتاريخ أحدهما

أقدم)

قَالَ: (وَلَوْ ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى)، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَقْتٍ لَا مُنَازَعَ لَهُ فِيهِ .

(إذا ادعى كل منهما الشراء من آخر ببينة مؤرخة)

"(وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من آخر ، وذكرنا تاريخاً) ، فهما سواء ، لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما ،

(1) ولأن الملك ثبت للبينة الأقدم، فمن القواعد الفقهية "إبقاء ما كان على ما كان" وما أثبتته البينة الأخرى محتمل، لمعارضة هذه البينة له، فتساقطتا فيما تعارضتا فيه، فبقى استصحاب الحال للأقدم. البحر الرائق 397/7، خزنة الأكملة، للرجاني 761/3.

فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا، ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ . ادعى كل منهما الشراء من آخر وإحدى البيئتين مؤرخة دون الأخرى : "(وَلَوْ وَقَّتْ إِحْدَى الْبَيْتَيْنِ وَقَّتَا ، وَلَمْ تَوْقَّتْ الْأُخْرَى ، قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) ، لَأَنَّ تَوْقِيتَ إِحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمَلِكِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقَدَمَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا ، لَأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَلِكَ لَا يَنْتَقِي إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، فَإِذَا أُثْبِتَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يَحْكُمُ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ شِرَاءً غَيْرَهُ (1) .

(إذا أقام كل من الخارج وصاحب اليد بينة على نتاج الدابة
أنها له)

قَالَ (وَأِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا ، وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ ، فَيَقْضِي لَهُ ، وَهَذَا

(1) لِأَنَّ الْبَائِعَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ التَّعَاقُبُ ضَرُورِيًّا ، وَقَدْ ثَبِتَ لِأَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ مِلْكٌ فِي وَقْتٍ ، وَمِلْكٌ غَيْرُهُ مَشْكُوكٌ إِنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ مِلْكٌ فَتَعَارَضَا فَيَرْجَحُ بِالْوَقْتِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا ، فَكَمَا جَازَ أَنْ يَقْعَا مُتَعَاقِبَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَقْعَا مَعًا ، وَفِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ أَيْضًا ، فَضَعُفَ قُوَّةُ الْوَقْتِ عَنِ التَّرْجِيحِ لِتَضَاعُفِ التَّعَارُضِ . العناية 261، 262/8.

هُوَ الصَّحِيحُ ، خَلَا فَا لَمَّا يَقُولُهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ (1) إِنَّهُ تَتَهَاتَرُ
 الْبَيْنَتَانِ ، وَيَتْرَكَ فِي يَدِهِ ، لَمْ عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ ، وَلَوْ تَلَقَّى كُلُّ
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَلِكَ مِنْ رَجُلٍ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّتَاجِ عِنْدَهُ فَهُوَ
 بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى النَّتَاجِ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ
 عَلَى الْمَلِكِ ، وَالْآخَرُ عَلَى النَّتَاجِ : "(وَلَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى
 الْمَلِكِ ، وَالْآخَرُ عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ النَّتَاجِ أَوْلَى أَيُّهُمَا كَانَ)
 ، لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ قَامَتْ عَلَى أَوْلِيَّةِ الْمَلِكِ ، فَلَا يَثْبُتُ لِلْآخَرِ إِلَّا بِالتَّلَقِّي
 مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيِّنَةُ النَّتَاجِ
 أَوْلَى لَمَّا ذَكَرْنَا (وَلَوْ قَضَى بِالنَّتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ ثَالِثُ
 الْبَيِّنَةِ عَلَى النَّتَاجِ يَقْضِي لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا ذُو الْيَدِ) لِأَنَّ الثَّالِثَ
 لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ ، وَكَذَا الْمُقْضِي عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ
 الْمُطْلَقِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّتَاجِ تَقَبُّلٌ وَيَنْقُضُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ
 بِمَنْزِلَةِ النَّصْرِ. وَالْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الْجَاهِدِ. قَالَ (وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي
 الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً) كَغَزَلِ الْفُطْنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ
 فِي الْمَلِكِ لَا يَتَكَرَّرُ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّتَاجِ ، كَحَلْبِ اللَّبَنِ ،
 وَاتِّخَاذِ الْجُبْنِ وَاللَّبْدِ ، وَالْمَرْعَزَى (2) وَجَزِ الصُّوفِ ، وَإِنْ كَانَ

(1) عيسى بن أبان بن صدقة، ولي القضاء بالبصرة، في شهر ربيع الأول
 سنة إحدى عشر ومائتين. تفقه على محمد بن الحسن قيل إنه لزمه ستة
 أشهر. (الجواهر المضوية في طبقات الحنفية 1/401).

(2) المرعزى: بكسر الميم والعين، فإذا شدت الزاي قصرت، وإذا خففت
 مدت، وقد يقال:، وهي كالصوف تحت شعر الغنم، أو الزغب الذي تحت
 شعر العنز. البناية 9/396، البحر الرائق 1/192.

يَتَكَرَّرُ قُضِي بِهِ لِلخَارِجِ، بِمَنْزِلَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ، وَهُوَ مِثْلُ الْخَزْرِ
وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ، فَإِنْ أَشْكَلَ يَرْجِعُ
إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ، لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِهِ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قُضِي بِهِ
لِلخَارِجِ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بَيِّنَتُهُ هُوَ الْأَصْلُ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ بِخَبَرِ
النِّتَاجِ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ

(الحكم إذا أقام أحد المدعين شاهدين والآخر أربعة)

قَالَ: (وَأِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا
سَوَاءٌ) لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ الشَّاهِدِينَ عِلَّةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ،
وَالْتَرَجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّةِ فِيهَا عَلَى مَا عُرِفَ.

(الحكم إذا ادعى أحدهما ببيئته على أن له جميع الدار)

وَادْعَى الْآخَرُ ببيئته أن له نصفها والدار في يد ثالث لئلا يملكها

(

قَالَ (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ ، أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا
، وَالْآخَرُ نَصْفَهَا ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، فَلصاحب الجميع ثلثاثة
أرباعها ، ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة)، اعتبارا
بطريق المنازعة، فَإِنْ صَاحِبُ النِّصْفِ لَا يَنَازِعُ الْآخَرَ فِي
النِّصْفِ ، فَسَلَّمَ لَهُ بِلَا مَنَازَعٍ ، وَاسْتَوَتْ مَنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ
الْآخَرِ ، فَيُنْصَفُ بَيْنَهُمَا ، (وَقَالَا: هِيَ بَيْنَهُمَا اثْنَانِ) فَاعْتَبَرَا
طَرِيقَ الْعَوْلِ ، وَالْمُضَارَبَةِ، فَصَاحِبُ الْجَمِيعِ يَضْرِبُ بِكُلِّ حَقِّهِ
سَهْمَيْنِ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَتَقْسَمُ اثْنَانِ، وَلِهَذَا الْمَسْأَلَةُ
نَظَائِرُ وَأَصْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي
الزِّيَادَاتِ.

(كِتَابُ الصُّلْحِ)

(أنواع الصلح وحكمه)

قَالَ (الصُّلْحُ⁽¹⁾) عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إِقْرَارٍ، وَصُلْحٌ مَعَ سَكُوتٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يُقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكَرَ ، وَصُلْحٌ مَعَ إِنْكَارٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ) ، لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : "كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"⁽²⁾ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مَعَ إِنْكَارٍ أَوْ سَكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ فَيَنْقَلِبُ الْأَمْرُ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَهَذَا رِشْوَةٌ⁽³⁾، وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا

(1) الصلح لغة: اسم للمصالحة ، واصطلاحاً: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة .نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لقاضى زادة أفندى، وهى تكملة فتح القدير 403/8 ، المعرب فى ترتيب المغرب ، لأبى الفتح المطرزي ص 270.

(2) أخرجه الحاكم فى المستدرک ، ، برقم7059.

(3) ولقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188] والصلح على الإنكار من أكل المال بالباطل ، ولأنه لم يثبت له حق يجوز أن يعاوض عليه.، والصلح على الإنكار محرم للحلال ومحل للحرام ،لأنه يحل المعاوضة على غير حق ثابت وذلك حرام ، ويحرم على المدعي باقي حقه وذلك حلال ، ولأنه صلح على مجرد الدعوى فوجب أن يكون باطلا ، كما لو ادعى قتل عمه فصولح عليه مع الإنكار،

، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ "أَحَلَّ حَرَامًا" لِعَيْنِهِ ، كَالْخَمْرِ " أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" لِعَيْنِهِ ، كَالصَّلَاحِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الضَّرَّةَ ، وَلِأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَيَقْضَى بِجَوَازِهِ ، لِأَنَّ الْمُدْعَى يَأْخُذُهُ عَوْضًا عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ ، وَالْمُدْعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضًا ، إِذَا الْمَالُ وَقَايَةَ النَّفْسِ ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ (1)

(المعتبر في الصلح عن إقرار)

قَالَ (فَإِنْ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ أُعْتَبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ) ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدِينَ بِتَرْضَائِهِمَا (فَنَجْرِي فِيهِ الشَّفَعَةُ (2) إِذَا كَانَ عَقَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، وَيُثَبَّتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطُ، وَيُفْسَدُهُ جِهَالَةُ الْبَدَلِ) ، لِأَنَّهَا هِيَ الْمَفْضِيَّةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُونَ جِهَالَةِ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَيَشْتَرِطُ الْقُدْرَةُ

ولأنه اعتاض عن حق لم يثبت له ، فوجب أن لا يملك عوضه ، ولأنه صالح من لم يعلم صدقه فوجب أن لا يصح ، كما لو علم كذبه ، ولأنه نوع معاوضة لا يصح مع الجهالة فوجب أن لا يصح مع الإنكار كالبيع ، ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول العين. الحاوي للماوردي 369/6، 370، 293/7.

(1) دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع . العناية 408/8.

(2) الشفعة لغة: الشفع ، الضم ، وأصطلاحاً : تملك العقار جبرا على

المشتري بما قام عليه . البحر الرائق 143/8.

عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَل⁽¹⁾ الْمَعْتَبَرِ فِي الصَّلْحِ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ (وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ ، يُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ) لَوْجُودِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ تَمْلِكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ ، وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا ، فَيَشْتَرِطُ التَّوَقُّيْتُ فِيهَا وَيَبْطُلُ ، الصَّلْحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ.

(الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى والمدعى عليه
لإفتداء اليمين)

(1) وهذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، وهو أن الصلح باعتبار البدلية على أربعة أوجه: إما أن يكون معلوماً على معلوم، وهو جائز لا مجاله، وإما أن يكون عن مجهول على مجهول، فإن لم يحتج فيه إلى التسليم والتسليم مثل أن يدعي حقاً في دار رجل وادعى المدعى عليه حقاً في أرض بيد المدعى واصطلاحاً على ترك الدعوى جاز، وإن احتج إليه وقد اصطلاحاً على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبينه على أن يترك الآخر دعواه أو على أن يسلم إليه ما ادعاه لم يجز، وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتج فيه إلى التسليم، كما لو ادعى حقاً في دار في يد رجل ولم يسمه فاصطلاحاً على أن يعطيه المدعى مالا معلوماً ليسلم المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه وهو لا يجوز، وإن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلاحاً في هذه الصورة على أن يترك المدعى دعواه جاز، وإما أن يكون عن معلوم على مجهول وقد احتج فيه إلى التسليم لا يجوز، وإن لم يحتج إليه جاز. والأصل في ذلك كله: أن الجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة عن التسليم والتسليم هي المفسدة، فما لا يجب فيه التسليم والتسليم جاز، وما وجب فيه لم يجز مع الجهالة، لأن القدرة على تسليم البدل شرط لكونه في معنى البيع (العناية 409/8).

قال: (وَالصَّلَحُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدْعَى عَلَيْهِ ،
لِافْتِدَاءِ الْيَمِينِ، وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَفِي حَقِّ الْمُدْعَى بِمَعْنَى
الْمُعَاوَضَةِ) لَمَّا بَيَّنَّا (1) . (وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلَفَ حُكْمُ الْعَقْدِ فِي
حَقِّهِمَا كَمَا يَخْتَلَفُ حُكْمُ الْإِقَالَةِ (2) فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَغَيْرِهِمَا)
وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ
وَالْجُحُودَ فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ عَوَضًا فِي حَقِّهِ بِالشَّكِّ.

(أثر الصلح عن دار في وجوب الشفعة)

قَالَ (وَإِذَا صَلَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ
عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سَكُوتٍ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَيُدْفَعُ
الْمَالُ دَفْعًا لِخُصُومَةِ الْمُدْعَى ، وَزَعَمُ الْمُدْعَى لَا يُلْزِمُهُ (3) .

(أثر الصلح على دار في وجوب الشفعة)

بِخِلَافِ مَا إِذَا صَلَحَ عَلَى دَارٍ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّ
الْمُدْعَى يَأْخُذُهَا عَوَضًا عَنِ الْمَالِ ، فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ ،

(1) يشير بهذا إلى قوله: "لأن المدعى يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه".

(2) الإقالة : فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث ، عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: بيع جديد في حق الكل . الاختيار لتعليل المختار 11/2.

(3) أي أن المدعى عليه يأخذها ، ليستبقى الدار على ملكه، لا أنه يشتريها، ويدفع المال، لدفع الخصومة على زعمه، والإنسان يأخذ بما في زعمه ، ولا يلزمه زعم غيره. العناية على الهداية 410/8.

فَتَلْزَمُهُ الشَّفَعَةُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ يَكْذِبُهُ (1) .

(أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن إقرار)
 قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ ، وَاسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، رَجَعَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَضِ) ،
 لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ كَالْبَيْعِ ، وَحُكْمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَذَا (2)
 (أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن سكوت أو إنكار)

(وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سَكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ رَجْعَ الْمُدْعَى بِالْخُصُومَةِ، وَرَدَّ الْعَوَضِ) لِأَنَّ الْمُدْعَى عَلَيْهِ مَا بَدَلَ الْعَوَضِ إِلَّا لِيُدْفَعَ خُصُومَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَهَا خُصُومَةً لَهُ، فَيَبْقَى الْعَوَضُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، لِأَنَّهُ خَلَا الْعَوَضُ فِي هَذَا الْقَدَرِ عَنْ الْغَرَضِ (3)

(أثر استحقاق المصالح عليه في دعوى الحق غير الثابت)
 قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يَبَيِّنْهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعَوَضِ ، لِأَنَّ دَعْوَاهُ

(1) فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر، فتجب فيها الشفعة. البناية 7/10.

(2) أي الرجوع بالحصة من العوض . البناية 7/10.

(3) أي عن غرض المدعى عليه . البناية 8/10.

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَقِيَّةٌ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ يَعْرِى الْعَوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابَلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيَّوعِ .

(المصالحة على جزء من المدعى به)

وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا ، لَمْ يَصِحَّ الصَّلْحُ ، لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ ، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَزِيدَ دَرَاهِمًا فِي بَدَلِ الصَّلْحِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ عَوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِيهَا بَقِيَّةً ، أَوْ يُلْحَقَ بِهِ ذِكْرُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي (1) .

(فصل في الصَّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ)

(حكم الصَّلْحِ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ)

قَالَ: (وَالصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ (2)

(الصَّلْحُ فِي دَعْوَى الْمَنَافِعِ)

قَالَ (وَالْمَنَافِعُ ، لِأَنَّهَا تَمْلِكُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ ، فَكَذَا بِالصَّلْحِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ: أَنَّ الصَّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْعُقُودِ إِلَيْهِ

(1) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بَرِئْتُ مِنْ دَعْوَايَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمِصَادِفَةِ الْبَرَاءَةِ الدَّعْوَى وَهُوَ صَحِيحٌ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَجَاءَ بَيِّنَةٌ لَمْ تَقْبَلْ. الْعَنَافَةُ 412/8.

(2) فَمَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ الصَّلْحُ عَنْهُ . الْبَنَاءُ 10/10.

وَأَشْبَهَهَا بِهِ احْتِيَالًا لِتَصْحِيحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمَكَنَ (1)

(الصلح عن جناية العمد والخطأ)

قَالَ (وَيَصِحُّ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ) أَمَّا الْأَوَّلُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178] الْآيَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ (2)، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ، حَتَّى أَنْ مَا صَلَحَ مُسَمًّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادِلَةٌ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ فُسَادِ التَّسْمِيَةِ هُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ، لِأَنَّهَا مُوجِبُ الدَّمِ (3)

(1) أي بقدر الإمكان، فإن كان عن مال بمال اعتبر بالشبهات، وإن كان على منافع اعتبر بالإجازات. البناية 10/10.

(2) تفسير ابن كثير 490/1.

(3) قَالَ الْبَاهِرِيُّ: "الصَّلْحُ عَنِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشِيرَةٍ - دِرَاهِمٍ - صَبِيحٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلَحْ صِدَاقًا ، وَأَتَتْهُ إِذَا صَالَحَ عَلَى أَنْ يَعْفُوَ مِنْ عَلَيْهِ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ عَلَى آخَرٍ جَازٍ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلَحْ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ صِدَاقًا ، لِأَنَّ كَوْنَ الصَّدَاقِ مَا لَا مَنْصُوصَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] وَيَدُلُّ الصَّلْحُ فِي الْقِصَاصِ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَيَكْتَفِي بِكَوْنِ الْعَوَضِ فِيهِ مَتَقَوْمًا ، وَالْقِصَاصِ مَتَقَوْمٍ حَتَّى يَصْلَحَ الْمَالُ عَوَضًا عَنْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَوَضًا عَنْ قِصَاصٍ آخَرَ، وَقَوْلُهُ: "إِلَّا أَنْ عِنْدَ فُسَادِ التَّسْمِيَةِ" اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ: "إِنْ مَا صَلَحَ مُسَمًّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا" : أَيُّ لَكِنْ إِذَا فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ بِجَهَالَةٍ فَاحْشَةُ أَوْ بِتَّسْمِيَةٍ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مَتَقَوْمٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. العناية 415/8.

(الصلح على خمر)

وَلَوْ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ، لَا يَجِبُ شَيْءٌ⁽¹⁾، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفْوِ. الصلح في النكاح على خمر أو مال مجهول: "وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين"⁽²⁾، لأنه الموجب الأصلي، ويجب مع السكوت عنه حكماً، ويدخل في إطلاق جواب الكتاب الجنائية في النفس وما دونها.

(الصلح على مال في حق الشفعة)

وَهَذَا بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال ، حيث لا يصح ، لأنه حق التملك، ولأحق في المحل قبل التملك⁽³⁾

(الصلح على مال في القصاص)

وَأَمَّا الْقصاصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفَعْلِ ، فَيَصِحُّ الْاِعتِيَاضُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصَّلْحُ تَبَطَّلَ الشُّفْعَةُ، لِأَنَّهَا تَبَطَّلُ بِالْاِعْرَاضِ وَالسُّكُوتِ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الشُّفْعَةِ،

(1) لأنه لما لم يسم مالا متقوما، صار ذكره والسكوت عنه شيئا، ولو سكت بعد العفو مطلقا وفيه لا يجب شيء فكذا في ذكر الخمر. البناية 11/10.

(2) أى في فصل تسمية المال المجهول، وفصل الخمر، لأن المهر هو الموجب الأصلي في النكاح، ويجب حكما مع السكوت عنه، لأن المهر من ضرورات النكاح ، فإنه ما شرع إلا بالمال، فإذا لم يكن المسمى صالحا صار كما لو لم يسم مهرا. العناية 416/8.

(3) وأخذ البذل هنا أخذ مال في مقابلة ما ليس بشيء ثابت في المحل ، وذلك رشوة حرام. البناية 12/10.

حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصِّلَحِ عَنْهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي بَطْلَانِ الْكَفَالَةِ رَوَايَتَيْنِ⁽¹⁾ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

(الصلح على مال في جناية الخطأ والقصاص)

وَأَمَّا الثَّانِي: وَهُوَ جَنَايَةُ الْخَطَأِ ، فَلَأَنَّ مُوجِبَهَا الْمَالُ ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَصَحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لَأَنَّهُ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، فَلَا يَجُوزُ إِطَالُهُ فَتَرَدُّ الزِّيَادَةُ ، بِخِلَافِ الصِّلَحِ عَنِ الْقَصَاصِ ، حَيْثُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّ الْقَصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَإِنَّمَا يَتَّقَوْمُ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا إِذَا صَالَحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ ، أَمَّا إِذَا صَالَحَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ ، لَأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ بِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ ، كَيْ لَا يَكُونَ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بَدِيلٍ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جَنْسٍ آخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ ، لَأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ ، فَكَانَ مُبَادَلَةً ، بِخِلَافِ الصِّلَحِ ابْتِدَاءً ، لِأَنَّ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ⁽²⁾

(الصلح عن دعوى حد أو حق عام)

(1) فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ تَبْطُلُ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ ، وَبِهِ يَفْتِي لِأَنَّ السَّقُوطَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَوْضِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ لَا تَعُودُ وَفِي الصِّلَحِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلِيمَانَ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ وَقَدْ تَكُونُ مُوصِلَةً إِلَى الْمَالِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْعِنَايَةِ 416/8.

(2) فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجْزِ. الْعِنَايَةِ 417/8.

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ) ، لَأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاظُ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاظُ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا ، لَأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقَّهَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصِّلَحُ عَمَّا أَشْرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ ، لَأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنْهُ؛ وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذْفِ، لِأَنَّ الْمَغْلَبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ⁽¹⁾

(مصالحة المرأة رجلا في دعوى النكاح)

قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجِدُّ ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتْهُ حَتَّى يَتْرَكَ الدَّعْوَى جَارَ ، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ) ، لَأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحَهُ خُلْعًا فِي جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ ، وَفِي جَانِبِهَا بَدَلًا لِلْمَالِ ، لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ. قَالُوا: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبْطَلًا فِي دَعْوَاهُ⁽²⁾

(1) وَلَقَائِلُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمَغْلَبُ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ ، لَوَجِبَ أَنْ لَا يَحْدَّ الْمُسْتَأْمَنُ إِذَا قَذَفَ ، كَمَا لَوْ زَنَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَحْدُّ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ. وَالْجَوَابُ : أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقِيقِينَ لَا مُحَالَةَ ، فَيَعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ، وَمَا يَلِيقُ بِالْحَرَبِيِّ أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْعَبْدِ ، لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ ، وَمَا يَلِيقُ بِالْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، لَأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْعِنَايَةُ 277/5.

(2) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى التَّرْوِيجِ بَيْنَهُ بَعْدَ الصِّلَحِ ، لَمْ يَقْبَلْ لِأَنَّ مَا جَرَى كَانَ خُلْعًا فِي زَعْمِهِ ، وَلَا فَائِدَةَ فِي إِقَامَتِهَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُبْطَلًا فِي دَعْوَاهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصِّلَحِ ،

(مصالحة الرجل امرأة في دعوى النكاح)

قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَصَالِحَهَا عَلَى مَالٍ
بَذَلَهُ لَهَا جَازٍ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هَكَذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ
نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ (1)، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: لَمْ يَجْزُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ :
أَنْ يُجْعَلَ زِيَادَةٌ فِي مَهْرِهَا، وَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ بَذَلَ لَهَا الْمَالَ
لِتَتْرَكَ الدَّعْوَى ، فَإِنْ جُعِلَ تَرَكَ الدَّعْوَى مِنْهَا فِرْقَةٌ فَالزَّوْجُ لَا
يُعْطَى الْعَوَضَ فِي الْفِرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ
عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّعْوَى ، فَلَا شَيْءَ يَقَابِلُهُ الْعَوَضُ فَلَمْ يَصِحَّ (2)

إِلَّا أَنْ يَسْلَمَهُ بِطَيْبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا عَلَى طَرِيقِ الْهَبَةِ . العناية
419/8

- (1) أى مختصر القدورى، أحمد بن محمد بن جعفر القدورى ت 428 هـ .
(2) لأنَّ الفِرْقَةَ لِمَا لَمْ تَوْجِدْ كَانَتْ دَعْوَاهَا عَلَى حَالِهَا لِبَقَاءِ النِّكَاحِ فِي
زَعْمِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَيْءٍ يَقَابِلُهُ الْعَوَضُ ، فَكَانَ رِشْوَةً . العناية 419/8.

(بَابُ التَّبَرُّعِ بِالصَّلَاحِ وَالتَّوَكُّلِ بِهِ)

(التوكيل بالصالح عن دم العمد أو بعض ما يدعيه من

(الدين)

(وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصَّلَاحِ عَنْهُ فَصَالِحٌ ، لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلُ مَا صَالِحَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوكَّلِ) وتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ ، أَوْ كَانَ الصَّلَاحُ عَنْ بَعْضِ مَا يَدْعِيهِ مِنَ الدِّينِ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ مَحْضٍ ، فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَمُعَبَّرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُوَ مُوَآخِذٌ بِعَقْدِ الضَّمَانِ لَا بِعَقْدِ الصَّلَاحِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَتَرْجِعُ الْحَقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ ، فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكَّلِ (1)

(صلح الفضولي (2))

قَالَ (وَإِنْ صَالَحَ رَجُلٌ عَنْهُ بَغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ

(1) قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّهُ لَا يَدُّ لَتَأْوِيلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ قِيْدِ آخِرٍ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمِصَالِحُ فِي الْمَعَاوِضَاتِ عَلَى الْإِنْكَارِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا لِأَنَّ الصَّلَاحَ عَلَى الْإِنْكَارِ مِعَاوِضَةٌ بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ بِجَعْلِ ذَلِكَ جَائِزًا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ جَوَازَهُ مَعَ الْخَصْمِ 423/8 ، 424.

(2) الْفُضُولِيُّ: "جَمَعَ فَضْلًا ، غَلَبَ فِي الْإِشْتَغَالِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَمَا لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ . الْبَحْرُ الرَّائِقُ 3/147.

أَوْجُهُ(1): إِنْ صَلَّحَ بِمَالٍ وَضَمَّنَهُ ، تَمَّ الصَّلْحُ ، لِأَنَّ الْحَاصِلَ
لِلْمَدْعَى عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الْبَرَاءَةُ ، وَفِي حَقِّهَا هُوَ وَالْأَجَنْبِيُّ سَوَاءٌ
، فَصَلْحٌ أَصِيلًا فِيهِ إِذَا ضَمَّنَهُ ، كَالْفُضُولِيِّ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمَّنَ
الْبَدَلَ ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ
بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِهَذَا
الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمَدْعَى ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ
تَصْحِيحَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ
مُقْرًا أَوْ مُنْكَرًا (2) .

(1) ووجه ذلك : أن الفضولي عند الصلح على مال ، إما أن قرن بذكر
المال ضمان نفسه ، أو لا ، فالأول : هو الوجه الأول ، والثاني : أما إن
أضاف المال إلى نفسه ، أو لا ، فالأول : هو الوجه الثاني ، والثاني :
= إما أن يسلم المال المذكور أم لا ، فالأول : هو الوجه الثالث ، والثاني
هو الرابع . حاشية سعدى أفندى على تكملة فتح القدير 424/8.

(2) أما إذا كان منكرا فظاهر ، لأنه في زعم المدعى عليه أنه لا شيء
عليه ، فيكون متبرعا في إسقاط الخصومة منه ، وزعم المدعي لم ينفذ
إليه ، وأما إذا كان مقرا بالدين وبالصلح ، ينبغي أن يصير مشتريا ما في
ذمته بما أدى ، إلا أن شراء الدين من غير المذكور لا يصح ، لأن فيه
تمليك الدين من غير من عليه الدين ، وإذا لا يجوز ، بخلاف ما لو كان
المدعى به عينا ، والمدعى عليه مقرا ، فإنه يصير مشتريا لنفسه إذا كان
بغير أمره ، لأن شراء الشيء من مالكه صحيح وإن كان في يد
غيره. البناية 22/10.

بَابُ الصُّلْحِ فِي الدَّيْنِ

(الصلح على المستحق بعقد المدائنة)

(وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمَدَائِنَةِ (1)
لَمْ يَحْمَلْ عَلَى الْمَعَاوِضَةِ، وَإِنَّمَا يَحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى
بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَهُ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخِرِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ
فَصَالِحُهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخِرِ أَلْفٍ جِيَادٌ،
فَصَالِحُهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ زِيُوفٍ جَازٍ ، وَكَأَنَّهُ أَبْرَاهُ عَنْ بَعْضِ
حَقِّهِ) ، وَهَذَا لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ يَتَحَرَّى تَصْحِيحَهُ مَا أُمِنَ ،
وَلَا وَجَهَ لِتَصْحِيحِهِ مُعَاوِضَةً لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرَّبِّاءِ، فَجُعِلَ إِسْقَاطًا
لِلْبَعْضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَلِلْبَعْضِ وَالصِّفَةِ فِي الثَّانِيَةِ (2)

(الصلح عن جميع الدين المؤجل)

(وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ جَازٍ ، وَكَأَنَّهُ أَجَلَ نَفْسِ الْحَقِّ) ،
لَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ مُعَاوِضَةً ، لِأَنَّ بَيْعَ الدَّرَاهِمِ بِمِثْلِهَا نَسِئَةٌ لَا
يَجُوزُ ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ ، (وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرٍ إِلَى
شَهْرٍ لَمْ يَجْزِ) ، لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمَدَائِنَةِ ، فَلَا
يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَلَا وَجَهَ لَهُ سِوَى الْمَعَاوِضَةِ، وَبِيعَ

(1) أي من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بعقد المدائنة
البنائية 25/10.

(2) (فجعل إسقاطا لبعض الدين في مسألة مسامحة الألف بخمسمائة
وإسقاطا للصفة في المسألة الثانية وهي مصالحه الجياد بالزئوف.
البنائية 26/10.

الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَّ الصَّلْحُ⁽¹⁾

(الصلح عن بعض الدين المؤجل)

قال: (ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) ، لأنَّ المعجل خير من المؤجل ، وهو غير مستحق بالعقد ، فيكون بإزاء ما حطه عنه ، وذلك اعتياض عن الأجل ، وهو حرام⁽²⁾

(الصلح عن الدين المؤجل مع زيادة في الوصف أو الجودة)

(

وإن كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز) لأنَّ البيض غير مستحقَّ بعقد المداينة ، وهي زائدة وصفاً ، فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف وهو رباً ، بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود ، حيث يجوز ، لأنه إسقاط كله قدراً ووصفاً ، وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود ، لأنه معاوضة المثل بالمثل ، ولما معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس⁽³⁾

(1) لأنه يؤدي إلى الربا . البنائة 26/10.

(2) روي أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما فنهاه عن ذلك ، ثم سأله فقال: إنَّ هذا يريد أن أطعمه الربا ، وهذا لأنَّ حرمة ربا النساء ليست إلا لشبهة مبادلة المال بالأجل ، فحقيقة ذلك أولى . البنائة 26/10 ، العناية 472/8.

(3) لأنه صرف.

(الصلح في الدين على بعضه مقابل إسقاط باقيه)

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخِرِ أَلْفٍ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَدِّ إِلَيَّ غَدًا مِنْهَا خُمُسَمَائَةَ عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ فَفَعَلَ ، فَهُوَ بَرِيءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ الْخُمُسَمَائَةَ غَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) لَأَنَّهُ إِبرَاءٌ مُطْلَقٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ آدَاءَ الْخُمُسَمَائَةِ عَوْضًا حَيْثُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةٍ عَلَى وَهْيِ لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَالْآدَاءُ لَا يَصِحُّ عَوْضًا ، لِكُونِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ فَجَرَى وَجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ ، فَبَقِيَ الْإِبْرَاءُ مُطْلَقًا ، فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَأَ بِالْإِبْرَاءِ ، وَلَهُمَا: أَنْ هَذَا إِبرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ ، فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهِ ، لَأَنَّهُ بَدَأَ بِآدَاءِ الْخُمُسَمَائَةِ فِي الْغَدِ ، وَأَنَّهُ يَصْلَحُ غَرَضًا حَذَارَ إِفْلَاسِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَى تِجَارَةِ أَرْبَحٍ مِنْهُ ، وَكَلِمَةُ "عَلَى" إِنْ كَانَتْ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهِيَ مُحْتَمَلَةٌ لِلشَّرْطِ ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْمَقَابَلَةِ فِيهِ ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ تَصَحُّيحًا لِنَصْرِفِهِ ، أَوْ لَأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ ، وَالْإِبْرَاءُ مِمَّا يَتَّقَدُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَّعَلَقُ بِهِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ ، وَسَتَخْرُجُ الْبِدَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

(الصلح عن الباقى)

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِأَخْرَ: لَا أَقْرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّي ، أَوْ تَحُطَّ عَنِّي ، فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ⁽¹⁾) ، لَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ ، وَمَعْنَى

(1) أي هذا التصرف وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطالبته في الحال ولا مطالبة ما حط عنه.

المسألة : إذا قال ذلك سراً ، أما إذا قال علانية يؤخذ به (1) .

(فصل في الدين المشترك)

(صلح أحد الشريكين في الدين في جميع نصيبه)

قال (وإذا كان الدين بين شريكين ، فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب ، فشريكه بالخيار ، إن شاء اتبع الذي عليه الدين بصفة ، وإن شاء أخذ نصف الثوب ، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين) ، وأصل هذا : أن الدين المشترك (2) بين اثنين ، إذا قبض أحدهما شيئاً منه ، فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض ، لأنه ازداد بالقبض ، إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض ، وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق ، فتصير كزيادة الولد والثمره ، وله حق المشاركة ، ولكنه قبل المشاركة باق على مالك القابض ، لأن العين غير الدين حقيقة ، وقد قبضه بدلاً عن حقه فيملكه حتى ينفذ تصرفه فيه ، ويضمن لشريكه حصته ، والدين المشترك يكون واجباً بسبب متحد ، كثن المبيع إذا كان صفقة واحدة ، وثن المال المشترك

(1) أي يؤخذ المقر بجميع المال في الحال بلا خلاف ، لأنه إقرار منه بالحق .

(2) عرف الدين المشترك : بأنه الذي يكون واجباً بسبب متحد ، كثن مبيع صفقة واحدة ، بأن كان لكل منهما عين على حدة ، فباعا صفقة واحدة ، وثن مال مشترك ، وموروث مشترك بقيمة مستهلك مشترك .
العناية 8 / 433 .

وَالْمُورُوثَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيَمَةَ الْمُسْتَهْلَكِ الْمَشْتَرَكِ . إِذَا عَرَفْنَا هَذَا
فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ (1) : لَهُ أَنْ يَتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، لِأَنَّ
نَصِيْبَهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبْضَ نَصِيْبِهِ ، لَكِنْ لَهُ حَقُّ
الْمُشَارَكَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نَصْفَ الثَّوْبِ ، لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ
إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيْكُهُ رُبْعَ الدِّينِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ (2)

(صلح أحد الشريكين في الدين في نصف نصيبه)

قَالَ (وَلَوْ اسْتَوْفَى نَصْفَ نَصِيْبِهِ مِنَ الدِّينِ كَانَ لَشَرِيْكِهِ أَنْ
يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبْضَ) ، لَمَّا قُلْنَا (ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ
بِالْبَاقِي) ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى
الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَةِ.

(صلح أحد الشريكين عن نصيبه بسلعة)

قَالَ (وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهِ مِنَ الدِّينِ سِلْعَةً ، كَانَ

(1) أي مختصر القدوري .

(2) لما فرغ المصنف - رحمه الله - من بيان الأصل قال: إذا عرفنا
(هذا) : وترك عليه (فنقول في مسألة الكتاب) أي مختصر القدوري (له)
أن يتبع الذي عليه الأصل) : أي للساكت أن يتبع المديون (لأن نصيبه
باق في ذمته) : ولم يستوفه (لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق
المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب) ونصف الثوب قدر ربع الدين ، لأن
الثوب صولح عليه بنصف الدين ، فيكون الثوب قدر نصف الدين ،
ونصف النصف ربع لا محالة لأن له حق المشاركة إلا أن يضمن له
شريكه ربع الدين ، لأن حقه في ذلك) أي لأن حقه كان في الدين . البناية

لشريكه أَنْ يَضْمَنَهُ رُبْعَ الدِّينِ) ، لَأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ
بِالْمُقَاصَّةِ كَامِلًا ، لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ عَلَى الْمَمَّاكِسَةِ⁽¹⁾ ، بخلاف
الصلح ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطَةِ ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ دَفْعَ
رُبْعِ الدِّينِ يَتَضَرَّرُ بِهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا سَبِيلَ
لِلشَّرِيكِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْبَيْعِ ، لَأَنَّهُ مَلَكُهُ بِعَقْدِهِ ، وَالْإِسْتِيفَاءُ
بِالْمُقَاصَّةِ بَيْنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدِّينِ . وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَّبَعَ الْغَرِيمَ فِي
جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى
نَصِيبَهُ حَقِيقَةً ، لَكِنْ لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ ، فَلَهُ أَنْ لَا يَشَارِكَهُ ، فَلَوْ
سَلَّمَ لَهُ مَا قَبِضَ ، ثُمَّ تَوَى⁽²⁾ مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنْ يَشَارِكَ
الْقَابِضَ ، لَأَنَّهُ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لِيُسَلَّمَ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ ،
وَلَمْ يُسَلِّمْ ، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُقَاصَّةُ⁽³⁾ بَدِينٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ، لَمْ

(1) المماكسة : من المكس في البيع ، وهو استقصاص الثمن من باب

ضرب . البناءة 5/ 171 ، المغرب في ترتيب المغرب ص 431 ، 432 .

(2) التوى : الهلاك ، مقصور يكتب بالياء ، لأنهم يقولون : توى ما له

يتوى توى ، إذا هلك . المقصور والممدود ، لابن ولاد أبو العباس أحمد

بن محمد بن الوليد التميمي المصري (المتوفى: 332هـ) 22/1 .

(3) أصل المقاصة : المماثلة ، من قولهم : قص الخبر : إذا حكاه ، فأداه على

مثل ما سمع ، والقصاص في الجراح : أن يستوفى مثل جرحه ، وكذلك

سميت المقاصة في الدين ؛ لأن على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما

لآخر . التَّظْمُ المستعذب ، لابن بطال 2/ 114 .

يَرْجِعُ عَلَيْهِ الشَّرِيكَ⁽¹⁾، لَأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيْبِهِ لَا مَقْتَضٍ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ نَصِيْبِهِ ، فَكَذَلِكَ لَأَنَّهُ إِتْلَافٌ وَلَيْسَ بِقَبْضٍ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتْ قِسْمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ السَّهَامِ، وَلَوْ أُخِّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيْبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، اِعْتِبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمَطْلُوقِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا ، لَأَنَّهُ يُوْدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدِّينِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا مِنْهُ أَوْ اشْتَرَاهَا شَرَاءً فَاسِدًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَهُوَ قَبْضٌ ، وَالْإِسْتِجَارُ بِنَصِيْبِهِ قَبْضٌ، وَكَذَا الْإِحْرَاقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ⁽²⁾ -

(1) وَإِذَا تَزَوَّجَ بِنَصِيْبِهِ مِنَ الدِّينِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ حَصَّتِهِ شَيْئًا مَضْمُونًا يَقْبَلُ الشَّرِيكَ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الْبَيْعَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مَتَقَوْمٍ وَلَا مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ ، فَكَانَ كَالْجَنَاحِ ، وَرَوَى بِشَرِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ ، لِأَنَّ التَّزْوِجَ وَإِنْ كَانَ بِالنَّصِيبِ لَفِظًا ، فَهُوَ بِمِثْلِهِ مَعْنَى ، فَيَكُونُ دَيْنُ الْمَهْرِ الْوَاجِبِ لِلْمَرْأَةِ آخِرَ الدِّينَيْنِ ، فَيَصِيرُ قَضَاءً لِلأَوَّلِ فَيَتَحَقَّقُ الْقَضَاءُ وَالْإِقْتِضَاءُ، وَالصُّلْحُ عَلَى نَصِيْبِهِ بِجَنَاحٍ الْعَمْدِ إِتْلَافٌ كَالْتَّزْوِجِ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا قَابِلًا لِلشَّرِيكَ بَلْ أَتْلَفَ نَصِيْبَهُ . الْعِنَايَةُ 437/8.

(2) وَصُورَةُ الْإِحْرَاقِ : مَا إِذَا رُمِيَ النَّارُ عَلَى ثَوْبِ الْمَدْيُونِ فَأَحْرَقَهُ وَهُوَ يَسَاوِي نَصِيبَ الْمَحْرُوقِ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الثَّوْبَ ثُمَّ أَحْرَقَهُ فَإِنَّ الشَّرِيكَ السَّابِكُ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَحْرُوقَ بِالْإِجْمَاعِ ، لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْإِحْرَاقَ إِتْلَافٌ لِمَالٍ مَضْمُونٍ فَكَانَ كَالْغَصَبِ، وَالْمَدْيُونُ صَارَ قَاضِيًا لِنَصِيْبِهِ بِطَرِيقِ الْمَقَاضَةِ ، فَيَجْعَلُ الْمَحْرُوقَ مَقْتَضِيًا، وَلِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مَتْلَفَ نَصِيْبِهِ بِمَا صَنَعَ لَا قَابِضٌ، لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ إِتْلَافٌ فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ الْجَنَاحِ، فَإِنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى نَفْسِ الْمَدْيُونِ حَتَّى سَقَطَ نَصِيْبُهُ مِنَ الدِّينِ لَمْ

رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالتَّزْوُجُ بِهِ إِتْلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁽¹⁾، وَكَذَا الصَّلْحُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ⁽²⁾ .

(صلح أحد الشريكين في السلم على رأس المال)

قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلْمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، لَمْ يَجْزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ الصَّلْحُ) ، اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدِّيُونِ ، وَبِمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيْبِهِ . وَلَهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ فِي نَصِيْبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ ، وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيْبِهِمَا لَأَبْدَى مِنْ إِجَازَةِ

يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَكَذَا إِذَا جَنَى بِالْإِحْرَاقِ . الْعَنَايَةُ 437/8.

(1) ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ : وَهِيَ مَسَائِلُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، وَيَلْحَقُ بِهِمْ زُفَرٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ أَخَذَ عَنِ الْإِمَامِ ، لَكِنَّ الْغَالِبَ الشَّائِعُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ أَنَّ يَكُونُ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ ، وَكُتِبَ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ ، كُتِبَ مُحَمَّدُ الْبُسْتِيُّ الْمَبْسُوطُ وَالزِّيَادَاتُ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالسِّيَرُ الصَّغِيرُ وَالْجَامِعُ الْكَبِيرُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرَوَايَاتِ الثَّقَاتِ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ إِمَّا مُتَوَاتِرَةً أَوْ مَشْهُورَةً عَنْهُ .. رَدُ الْمُحْتَارِ 69/1 ، رِسْمُ الْمِفْتَاحِ ص 16.

(2) قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَمْدًا لِأَنَّهُ فِي الْخَطِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَأُطْلِقَ فِي الْإِيضَاحِ فَقَالَ : وَلَوْ شَجَّهِ مُوضِحَةً فَصَالَحَهُ عَلَى حِصَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْ الشَّرِيكَ شَيْءٌ لِأَنَّ الصَّلْحَ عَنِ الْمَوْضِحَةِ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ ، وَقَيَّدَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فَلَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا لَشَيْءٍ . الْعَنَايَةُ 437/8.

الْآخِرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ، وَالْعَقْدُ قَامَ بِهِمَا فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِرَفْعِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لِمُشَارَكِهِ فِي الْمَقْبُوضِ، فَإِذَا شَارَكَهُ فِيهِ رَجَعَ الْمَصَالِحُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُؤَدِّي إِلَى عَوْدِ السَّلَامِ بَعْدَ سَقُوطِهِ. قَالُوا: هَذَا إِذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ (1).

(1) قوله (فعلى الوجه الأول) أراد به النكتة الأولى، وهي لزوم قسمة الدين في الذمة (هو على الخلاف) المذكور (وعلى الوجه الثاني) : أراد به النكتة الثانية (هو) : قوله : "ولأنه لو جاز لمشاركه ... إلى آخره " (على الاتفاق) : أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله ، لأن رأس المال إذا لم يكن مخلوطا، وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه، لأنه لا حق له فيه لأنه مال الغير. البناية 37/10.

كِتَابُ الْجَنَايَاتِ (1) (2)

(أنواع القتل الموجبة للضمان، وحكمها (3))

قَالَ: (الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ (4): عَمْدٌ، وَشَبَهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ، وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ) وَالْمُرَادُ بَيَانُ قَتْلِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ (5).

(1) حققه وعلق عليه: أ.د/ كمال محمد عواد، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

(2) الْكِتَابُ لُغَةً: مُصَدَّرٌ سَمِيَ بِهِ الْمَكْتُوبُ، كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ، يُقَالُ: كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وَكِتَابَةً. وَالْكِتَابُ لُغَةً: مَا يَكْتُبُ فِيهِ. وَالذَّوَاءُ يَكْتُبُ مِنْهَا. وَالْفَرَضُ. وَالْحَكْمُ. وَالْقَدْرُ. وَالضَّمُّ، وَالْجَمْعُ، يُقَالُ: كَتَبَ الْكِتَابَ: إِذَا جَمَعَ حُرُوفَهُ. (جُمُهرَةُ اللُّغَةِ، 1/255).

وَاصْطِلَاحًا: طَائِفَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ اعْتَبِرَتْ مُسْتَقِلَّةً، سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْتَقِلَّةً فِي نَفْسِهَا، كَكِتَابِ اللَّقْطَةِ، أَوْ تَابِعَةً لِمَا بَعْدَهَا، كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، أَوْ مُسْتَتَبَعَةً لِمَا قَبْلَهَا، كَكِتَابِ الصَّلَاةِ. (مَجْمَعُ الْأَنْهَرِ فِي شَرْحِ مِلْثَمِي الْأَبْحَرِ، 1/8).
وَالْجَنَايَاتُ جَمْعُ جُنَايَةٍ وَهِيَ لُغَةً: اسْمٌ لِمَا يَكْتَسِبُ مِنَ الشَّرِّ تَسْمِيَةً بِالمَصْدَرِ مِنْ جَنَى عَلَيْهِ شَرًّا، وَهُوَ عَامٌّ. (لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ، مَادَّةُ (جَنَى)، 14/154)

وَالْجُنَايَةُ شَرْعًا: كُلُّ اعْتِدَاءٍ مُجْرِمٍ شَرْعًا حَلٌّ بِالنَّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ، فَإِنْ حُلَّ بِالنَّفْسِ: يَسْمَى قَتْلًا : وَهُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ، وَزَوَالُ الْحَيَاةِ بِدُونِ قَتْلِ الْعِبَادِ يَسْمَى مَوْتًا. وَإِنْ حُلَّ بِالْأَطْرَافِ: يَسْمَى قَطْعًا وَجَرَحًا).
العناية شرح الهداية للبابرتي، 10/203

(3) العنوان والتقسيم من وضع المعد.

(4) قيد به لأن أنواع القتل أكثر من خمسة، من رجم وقصاص، وقتل حربي، وقتل لقطع الطريق، وقتل المرتد. (البنابة، 13/62)

(5) والمراد بالقتل هنا: القتل الذي يتعلّق به حكم من قصاصٍ وديةٍ وكفارةٍ

(القتل العمد وموجبه)

(حقيقة القتل العمد)

قَالَ (فَالْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبُهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ⁽¹⁾ كَالْمَحْدَدِ مِنَ الْخَشَبِ وَلَيْطَةِ الْقَصَبِ⁽²⁾ وَالْمَرَّةِ الْمُحَدَّدةِ⁽³⁾ وَالنَّارِ) ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ، وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلِهِ⁽⁴⁾ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ آلَةِ الْقَاتِلَةِ فَكَانَ مُتَعَمِّدًا فِيهِ⁽⁵⁾ عِنْدَ ذَلِكَ⁽⁶⁾.

(موجب القتل العمد)

(وَمُوجِبٌ⁽⁷⁾ ذَلِكَ الْمَأْتَمُ⁽⁸⁾) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا

وَجِرْمَانِ إِرْثَ خِمْسَةِ أَوْجِهٍ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، فَإِنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ بِهِ قَصْدُ الْقَتْلِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ الْعَمْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْخَطَأُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ مَعَهُ قَصْدُ التَّأْدِيبِ وَالضَّرْبِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ جَارِيًا مَجْرَى الْخَطَأِ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْقَتْلُ بِالسَّبَبِ. (الْبَيَانَةُ 62/13).

(1) يعني في تفريق الأجزاء كالمحْدَد من الخشب وليطة القصب.

(2) الليطة بكسر اللام قشر القصب.

(3) المروة المحددة: وهي القطعة من الحجر الصوان، يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.

(4) أي دليل العمد: وهو استعمال الآلة القاتلة فكان متعمدا فيه.

(5) أي في عمدته باستعمال الآلة القاتلة.

(6) أي عند وجود العمد باستعمال الآلة القاتلة.

(7) أي مقتضى العمد الموصوف بتلك الأوصاف.

(8) أي حصول الإثم العظيم. وروي عنه ﷺ: {لزوال الدنيا أهون على الله

مَتَّعِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الْآيَةُ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ
وَاحِدٍ مِنَ السَّنَةِ⁽¹⁾، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ⁽²⁾. قَالَ: وَالْقَوْدُ⁽³⁾
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: 178]
إِلَّا أَنَّهُ تَقِيدُ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:
«الْعَمْدُ قَوْدٌ»، أَيُّ مُوجِبُهُ، وَلِأَنَّ الْجَنَايَةَ بِهَا تَتَكَامَلُ وَحِكْمَةُ
الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ، وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ⁽⁴⁾ لَا شَرَعَ لَهَا دُونَ
ذَلِكَ⁽⁵⁾.

من قتل رجل مسلم، أخرجه الترمذي في سننه، وصححه برقم 1395.

(1) أي السنة فيه أكثر من أن يحصى، وأظهر من أن يخفى منها ما رواه
البخاري - رحمه الله - في صحيحه برقم 6862 عن ابن عمر - رضي
الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: {لن يزال المؤمن في فسحة
من دينه، ما لم يصب دماً حراماً}. ومنها: ما رواه ابن ماجه برقم 2620
من حديث سعيد بن المسيب - رحمه الله - عن أبي هريرة - رضي الله
تعالى عنه - قال: قال رسول الله ﷺ من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر
كلمة، لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.

(2) أي وعلى التحريم إجماع أمة النبي ﷺ على الوجه المنكور.

(3) يعني القصاص معطوف على قوله المأثم: أي موجب القتل العمد الإثم

في الآخرة والقصاص في الدنيا

(4) القود عقوبة متناهية والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون العمدية.

(5) أي لا شرعية للعقوبة المتناهية بدون العمدية. وتقرير حجته أن
العمدية تتكامل بها الجناية، وكل ما تتكامل به الجناية كانت حكمة الزجر
عليها أكمل.

قَالَ (إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ يُصَالِحُوا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ثُمَّ هُوَ (1) وَاجِبٌ عَيْنًا، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنْ لَهُ حَقَّ الْعُدُولِ إِلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ (2) فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ، وَفِي قَوْلِ الْوَاجِبِ أَحَدُهُمَا لَا بَعَيْنَهُ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شُرْعًا جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نَوْعٌ جَبَرٌ فَيُتَخَيَّرُ وَلَنَا مَا تَلَوْنَا مِنَ الْكِتَابِ (3) وَرَوَيْنَا مِنَ السُّنَنِ (4)، وَلَنَا (5)، الْمَالُ لَا يَصْلَحُ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْمُمَاتَلَةِ، وَالْقِصَاصُ يَصْلَحُ لِلتَّمَاتَلِ، وَفِيهِ

(1) يَعْنِي الْقَوْدَ.

(2) يَعْنِي لِأَنَّ الْقَاتِلَ فِي الْاِمْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ بَعْدَمَا اسْتَحَقَّتْ نَفْسُهُ قِصَاصًا بِسَقِّهِ وَيَلْقَى نَفْسَهُ فِي التَّهْلُكَةِ فَيَجْبَرُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُ عَنْهُ شُرْعًا.

(3) مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: 178] وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْخِطَا الدِّيَةَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْقِصَاصُ الْمَذْكُورُ فِيهِ فِيمَا هُوَ ضِدُّ الْخِطَا وَهُوَ الْعَمْدُ، وَلَمَّا تَعَيَّنَ بِالْعَمْدِ لَا يَعْدِلُ عَنْهُ لَوْلَا تَلَزُّمُ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ بِالرَّأْيِ.

(4) وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَنِ أَنَّ الْأَلْفَ وَاللَّامَ فِي قَوْلِهِ الْعَمْدُ قَوْدٌ لِلْجِنْسِ، إِذْ لَا مَعْهُودَ بِنَصْرِفِ إِلَيْهِ، فَفِيهِ تَنْصِيبٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جِنْسِ الْعَمْدِ ذَلِكَ، فَمِنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ زَادَ عَلَى النَّصِّ أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ: الْعَمْدُ قَوْدٌ لَا مَالَ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.

(5) وَجْهُ الْمَعْقُولِ أَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلَحُ مُوجِبًا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُمَاتَلَةِ، لِأَنَّ الْأَدْمِيَّ مَالِكٌ مُبْتَدَلٌ وَالْمَالُ مَمْلُوكٌ مُبْتَدَلٌ فَأُلْئِي بِتِمَاتَلَانِ، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَصْلَحُ مُوجِبًا لِلتَّمَاتَلِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ حِكْمَةٍ وَهِيَ مَصْلِحَةُ الْإِحْيَاءِ زَجْرًا لِلْغَيْرِ عَنْ وَقُوعِهِ فِيهِ وَجَبْرًا لِلْوَرْتَةِ فَيَتَعَيَّنُ، فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ

مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ زَجْرًا وَجَبْرًا فَيَتَعَيَّنُ، وَفِي الْخَطَا وَجُوبِ
الْمَالِ ضَرُورَةُ صَوْنِ الدِّمِّ عَنِ الْإِهْدَارِ، وَلَا يَتَيَقَّنُ بَعْدَ قَصْدِ
الْوَلِيِّ بَعْدَ اخْتِزَالِ الْمَالِ (1) فَلَا يَتَعَيَّنُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ،

(حكم وجوب الكفارة في القتل العمد؟)

وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ عِنْدَنَا (2): وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ؛
لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمْسُ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَا
فَكَانَ أَدْعَى إِلَى إِجَابَتِهَا

صَلَحَ مُوجِبًا فِي الْخَطَا وَالْفَائِتِ فِيهِ مِثْلُ الْفَائِتِ فِي الْعَمْدِ أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَفِي
الْخَطَا وَجُوبِ الْمَالِ ضَرُورَةُ صَوْنِ الدِّمِّ عَنِ الْإِهْدَارِ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ
الِاقْتِصَاصُ فِيهِ هَدْرِ الدِّمِّ لَوْ لَمْ يَجِبِ الْمَالُ وَالْأَدْمِيُّ مَكْرُمٌ لَا يَجِبُ إِهْدَارُ
دِمِّهِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَالْعَمْدُ لَيْسَ فِي
مَعْنَاهُ حَتَّى يُلْحَقَ بِهِ.

(1) جَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ وَذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَلِيُّ
الْمَالَ مِنَ الْقَاتِلِ بِدُونِ رِضَاةٍ ثُمَّ يَقْتُلَهُ. قِيلَ هَذَا الْوَهْمُ مُوجُودٌ فِيمَا إِذَا أَخَذَ
الْمَالَ صَلَاحًا وَقَدْ جَازَ. أَجِيبُ بِأَنَّ فِي الصُّلْحِ الْمَرَاضَاةِ وَالْقَتْلِ بَعْدَهُ ظَاهِرُ
الْعَمْدِ.

(2) أَيُّ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ سِوَاءٍ وَجِبَ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ لَمْ يَجِبْ كَالْأَبِ إِذَا
قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى
التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمْسُ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَا لِأَنَّهَا لَسَتْ تَسْتَرِ الذَّنْبَ وَالذَّنْبُ فِي
الْعَمْدِ أَكْثَرُ.

وَلَنَا (1) أَنَّهُ كَبِيرَةٌ مُحْضَةٌ (2)، وَفِي الْكَفَّارَةِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَلَا تَنَاطُ بِمِثْلِهَا، وَلَئِنْ الْكَفَّارَةُ (3) مِنْ الْمَقَادِيرِ، وَتَعَيَّنَتْ فِي الشَّرْعِ لِدَفْعِ الْأَدْنَى لَا يَعْينُهَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى (4)

- (1) استدلال الحنفية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد.
 (2) وما هو كذلك لا يكون سببا لما فيه معنى العبادة والكفارة فيها ذلك.
 (3) جواب عن قياس الشافعي .
 (4) الخلاصة: ما حكم جواز العفو والمصالحة عن القصاص؟، يجوز العفو والمصالحة عن القصاص.

ومن له الحق في ذلك؟ الحق في ذلك لأولياء الدم
 وهل القصاص واجب على التعيين أم التخيير بينه وبين الدية؟ القصاص واجب عينا عند الحنفية . وهل يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل؟. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: ومذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل، إلا أن للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه. واستدلوا على أنه لا يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب، فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرِّ بِالْحَرِّ} [البقرة: 178] الآية ووجه التمسك به أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْخَطِّ الدِّيةَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْقَصَاصُ الْمَذْكُورُ فِيهِ لِلْعَمْدِ، وَلَمَّا تَعَيَّنَ بِالْعَمْدِ لَا يَعدَلُ عَنْهُ لئَلَّا تُلْزَمَ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ بِالرَّأْيِ.

وأما السنة فقوله ﷺ: {العمد قود} ووجه التمسك بالسنة أَنَّ الْأَلْفَ وَالْإِلَامَ فِي قَوْلِهِ الْعَمْدُ قُودٌ لِلْجِنْسِ، إِذْ لَا مَعْهُودَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، فَفِيهِ تَنْصِيفٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جِنْسِ الْعَمْدِ ذَلِكَ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ زَادَ عَلَى النَّصِّ .

وَمِنْ حُكْمِهِ حَرَمَانُ الْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
«لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ»

(القتل شبه العمد وموجبه)

(حقيقة القتل شبه العمد)

قَالَ (وَشَبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبُ بِمَا لَيْسَ
بِسَلَّاحٍ وَلَا مَا أُجْرِي مَجْرَى السَّلَّاحِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيمٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ
فَهُوَ عَمْدٌ، وَشَبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرِبُهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ بِهِ غَالِبًا؛
لأنَّهُ يَتَقَاصَرُ مَعْنَى الْعَمْدِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يَقْتُلُ بِهَا
غَالِبًا لَمَّا أَنَّهُ يَقْصَدُ بِهَا غَيْرَهُ كَالْتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ شَبْهُ الْعَمْدِ،
وَلَا يَتَقَاصَرُ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا تَلْبِثُ؛ لأنَّهُ لَا يَقْصَدُ بِهِ إِلَّا الْقَتْلَ
كَالسَّيْفِ فَكَانَ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقَوْدِ (1)

وَوَجْهُ الْمَعْقُولِ أَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلَحُ مُوجِبًا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ،
لأنَّ الْأَدْمِيَّ مَالِكٍ مُبْتَدِلٍ وَالْمَالِ مَمْلُوكٌ مُبْتَدَلٌ فَكَيْفَ يَتَمَاثَلَانِ، بِخِلَافِ
الْقَصَبِاصِ فَإِنَّهُ يَصْلَحُ مُوجِبًا لِلتَّمَاثُلِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ حِكْمَةٍ وَهِيَ مُصْلَحَةُ
الْإِحْيَاءِ زَجْرًا لِلْغَيْرِ عَنْ وَقُوعِهِ فِيهِ وَجَبْرًا لِلْوَرِثَةِ فَيَتَعَيَّنُ.

(1) اِخْتَلَفَ فَقَهَاءُ الْحَنْفِيَّةِ فِي تَفْسِيرِ الْقَتْلِ شَبْهُ الْعَمْدِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْأَوَّلُ:
لأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ شَبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبُ بِمَا لَيْسَ
بِسَلَّاحٍ وَلَا أُجْرِي مَجْرَاهُ سِوَاءِ كَانِ الْهَلَاكُ بِهِ غَالِبًا كَالْحَجَرِ وَالْعَصَا
الْكَبِيرَيْنِ وَمِدْقَةِ الْقَصَارِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ. الْقَوْلُ الثَّانِي:
لِلصَّاحِبِينَ: هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبُ بِمَا لَا يَحْصُلُ الْهَلَاكُ بِهِ غَالِبًا كَالْعَصَا
الصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يُوَالِ فِي الضَّرْبَاتِ. فَأَمَّا إِذَا وَالَى فِيهَا فَقِيلَ شَبْهُ عَمْدٍ

وَلَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْبَابِلِ»، (1)، وَلِأَنَّ (2) الْآلَةَ (3) غَيْرَ مَوْضُوعَةٍ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى غَرَّةٍ (4) مِنْ الْمَقْصُودِ قَتْلَهُ، وَبِهِ (5) يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا فَقَصُرَتِ الْعَمْدِيَّةُ نَظْرًا إِلَى الْآلَةِ (6)، فَكَانَ شَبَهُ الْعَمْدِ كَالْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ.

عِنْدَهُمَا وَقِيلَ عَمْدٌ مُحْضٌ، قَالَا: سَمِيَ هَذَا النَّوعُ شَبَهُ الْعَمْدِ لِأَقْتِصَارِ مَعْنَى الْعَمْدِ فِيهِ وَإِلَّا لَكَانَ عَمْدًا، وَأَقْتِصَارُهُ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ فِي اسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا يَقْتُلُ بِهَا غَالِبًا كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ يَقْصُدُ بِاسْتِعْمَالِهَا غَيْرَ الْقَتْلِ كَالْتَأْدِيبِ وَنَحْوِهِ.

(1) وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ ^{بِجَعْلِ} قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مُطْلَقًا شَبَهُ عَمْدٍ فَتَخْصِيصُهُ بِهِ بِالصَّغِيرَةِ إِبْطَالٌ لِلْإِطْلَاقِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَلِأَنَّ الْعَصَا الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ تَسَاوَيَا فِي كَوْنِهِمَا غَيْرَ مَوْضُوعَتَيْنِ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَتَيْنِ لَهُ، إِذْ لَا يُمْكِنُ الاسْتِعْمَالُ عَلَى غَرَّةٍ مِنَ الْمَقْصُودِ قَتْلَهُ، وَبِالْاسْتِعْمَالِ عَلَى غَرَّةٍ يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا، وَإِذَا تَسَاوَيَا وَالْقَتْلُ بِالْعَصَا

(2) اسْتِدْلَالُ أَبِي حَنِيفَةَ بِالمَعْقُولِ.

(3) سِوَاءُ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً.

(4) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ عَلَى غَفْلَةٍ.

(5) أَيْ وَبِالْاسْتِعْمَالِ عَلَى غَرَّةٍ.

(6) يَعْنِي الْقَصْدَ إِلَى الْقَتْلِ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، فَأَقَامَ الشَّرْعُ الضَّرْبَ بِآلَةٍ وَضَعْتَ لِلْقَتْلِ مَقَامَ الْقَصْدِ إِلَى الْقَتْلِ، وَأَقَامَ الضَّرْبَ بِآلَةٍ وَضَعْتَ لِلتَأْدِيبِ مَقَامَ عَدَمِ الْقَصْدِ، فَسَقَطَ اعْتِبَارُ حَقِيقَةِ الْقَصْدِ، وَاعْتَبِرَ السَّبَبُ الْقَائِمُ مَقَامَهُ.

(موجب القتل شبه العمد)

قال (وموجب ذلك⁽¹⁾ على القولين الإثم) لأنه قتل وهو قاصد في الضرب (والكفارة) لشبهه بالخطأ (والدية مغلظة على العاقلة) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة⁽²⁾ اعتباراً بالخطأ، وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه⁽³⁾ - وتجب مغلظة، وسننين صفة التغليظ من بعد إن شاء الله تعالى. (ويتعلق به⁽⁴⁾ حرمان الميراث) لأنه جزاء القتل، والشبهة تؤثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث⁽⁵⁾،

-
- (1) أي موجب شبه العمد على القولين: يعني قول أبي حنيفة وقولهما.
 (2) احتراز بقوله لا بمعنى يحدث من بعد عما تصالحوا فيه على الدية وعن قتل الوالد ولده عمدا وعن إقرار القاتل بالقتل خطأ وقد كان قتله عمدا فإن في هذه الصورة تجب الدية على القاتل في ماله.
 (3) يعني ما روي عنه أنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، والمروي عنه كالمروي عن رسول الله ﷺ لأنه مما لا يعرف بالرأي.
 (4) أي شبه العمد
 (5) لأن الحرمان جزاء القتل بالنص وهو قوله - عليه السلام - : «لا ميراث للقاتل» .

ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - وإن أنكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما أسلفناه⁽¹⁾.

(القتل الخطأ وموجبه)

(حقيقة القتل الخطأ وموجبه)

قال : (والخطأ على نوعين⁽²⁾: خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم. وخطأ في الفعل، وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا. وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (النساء: الآية 92)، وهي على عاقلته في ثلاث سنين لما بيناه⁽³⁾. قال: (ولما إثم فيه) يعني في الوجهين⁽⁴⁾، قَالُوا: الْمُرَادُ إِثْمُ الْقَتْلِ، فَأَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَعْرِى عَنِ الْإِثْمِ مَنْ حَيْثُ تَرَكَ الْعَزِيمَةَ وَالْمَبَالِغَةَ فِي التَّثَبُّتِ فِي حَالِ الرَّمْيِ، إِذْ شَرَعَ الْكَفَّارَةَ يُؤْذِنُ بِاعْتِبَارِ هَذَا

(1) قيل أراد قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِلَّا إِنْ قَتَلَ خَطَأً الْعَمْدَ قَتَلَ السُّوْطَ وَالْعَصَا» الْحَدِيثَ، وَلَكِنَّ الْمَعْهُودَ مِنَ الْمَصْنُفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مِثْلِهِ أَنْ يَقُولَ مَا رَوَيْنَا وَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا قَالَ أَسْلَفْنَا نَظْرًا إِلَى الْحَدِيثِ وَالْمَعْنَى الْمَعْقُولُ.

(2) إِنَّمَا انْحَصَرَ الْخَطَأُ فِي نَوْعَيْنِ، لِأَنَّ الرَّمْيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلًا مُشْتَمِلٌ عَلَى فِعْلِ الْقَلْبِ وَهُوَ الْقَصْدُ وَالْجَارِحَةُ وَهُوَ الرَّمْيُ، فَإِنْ اتَّصَلَ الْخَطَأُ بِالْأَوَّلِ فَهُوَ الْأَوَّلُ، وَإِنْ اتَّصَلَ بِالثَّانِي فَهُوَ الثَّانِي

(3) إِشْبَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ وَتَجِبُ فِي ثَلَاثِ سَنِينَ لِقَضِيَّةِ عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(4) أَيِ النَّوَاعِينِ لِقَوْلِهِ ﷺ «رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ» الْحَدِيثَ.

الْمَعْنَى (وَيَحْرَمُ عَنِ الْمِيرَاثِ)؛ لِأَنَّ فِيهِ إِثْمًا (1) فَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْحَرَمَانِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَمَّدَ (2) الضَّرْبُ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهِ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ فَمَاتَ حَيْثُ يَجِبُ الْقَصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ وَجَدَ بِالْقَصْدِ إِلَى بَعْضِ بَدَنِهِ، وَجَمِيعِ الْبَدَنِ كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ

(ما أجرى مجرى الخطأ في القتل وموجبه)
 قَالَ (وَمَا أَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأِ فِي الشَّرْعِ، (3))

(1) بِدَلِيلِ وَجوبِ الْكَفَّارَةِ، وَالْحَرَمَانِ يَجِبُ بِأَنْوَاعِ الْقَتْلِ فِيمَا هُوَ جُنَايَةٌ، قِيلَ عَلَى الْمَوْرِثِ تَضَمَّنَتْ تَهْمَةُ الاسْتِعْجَالِ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَهَذَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصْدُهُ، إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرَ الْخَطَأَ مِنْ نَفْسِهِ.

(2) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَمَوْجِبُ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ وَالْدِيَّةُ. وَصُورَةُ ذَلِكَ رَجُلٌ تَعَمَّدَ أَنْ يَضْرِبَ يَدَ رَجُلٍ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ عُنُقَهُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ عَمِدٌ فِيهِ الْقَوْدُ. وَلَوْ أَرَادَ يَدَ رَجُلٍ فَأَصَابَ عُنُقَ غَيْرِهِ وَأَبَانَهُ فَهُوَ خَطَأٌ، وَمَا أَجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ لِأَنَّ النَّائِمَ لَا يُوَصَّفُ فَعَلُهُ بِالْعَمْدِ وَلَا بِالْخَطَأِ، إِلَّا أَنَّهُ كَالْخَطَأِ فِي الْأَحْكَامِ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ مَاتَ بِثَقْلِهِ فَكَأَنَّهُ مَاتَ بِفَعْلِهِ.

(3) لَكِنَّهُ دُونَ الْخَطَأِ حَقِيقَةً، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْدِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا وَجِبَتْ الْكَفَّارَةُ لِتَحْرِيزِ عَنِ نَوْمِهِ، فِي مَوْضِعٍ يَتَوَهَّمُ أَنْ يَصِيرَ قَاتِلًا، وَالْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ إِنَّمَا تَجِبُ لِتَرْكِ التَّحْرِكِ أَيْضًا. وَإِنَّمَا جَعَلَ مُحْرَمًا عَنِ الْمِيرَاثِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ تَقَاوُمٌ وَلَمْ يَكُنْ قَائِمًا حَقِيقَةً. وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي حَقِّ الْحَرَمَانِ. وَفِي الْأَوْضَحِ: لَوْ وَقَعَ مِنْ سَطْحٍ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، أَوْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ إِنْسَانًا فَمَاتَ، أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَبَنَةٌ أَوْ خَشَبَةٌ فَسَقَطَتْ

(القتل بسبب وموجبه)

(وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبُئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مُلْكِهِ، وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلَفَ فِيهِ أَدَمِي الدِّيَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ) ؛ لَأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدِّ فِيهِ فَأَنْزَلَ مَوْقِعًا (1) دَافِعًا (2) فَوَجِبَتْ الدِّيَّةُ (وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَرَمَانُ الْمِيرَاثِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُلْحَقُ بِالْخَطَا فِي أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا (3) وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةٌ (4) فَالْحَقُّ بِهِ (5) فِي حَقِّ الضَّمَانِ (6) فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ (7) عَلَى الْأَصْلِ (8)، وَهُوَ إِنْ كَانَ

على إنسان فقتله، فهذا مثل النائم ينقلب لكونه قتلا معصوما فأجرى مجرى الخطأ.

(1) يعني في البئر .

(2) يعني في الحجر .

(3) يعني في الضمان فكان كالمباشرة فعندهم المسبب كالمباشر .

(4) لأنه ليس بمباشر للقتل حقيقة لأن مباشرة القتل إيصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوجد

(5) أي بالمباشر .

(6) صيانة للدم عن الهدر على خلاف الأصل .

(7) (فبقي في حق غيره) وهو حق الكفارة وحرمان الميراث .

(8) (على الأصل) وهو عدم القتل، وهو إن كان يأثم، هذا جواب عما يقال: الحافر في غير ملكه يأثم، وما فيه إثم من الفعل يصح تعليق الحرمان به.

يَأْتُمُّ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِ مَلَكِهِ لَا يَأْتُمُّ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوا (1) ،
 وَهَذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ الْقَتْلِ وَكَذَا الْحَرَمَانُ بِسَبَبِهِ .
 (وَمَا يَكُونُ شَبْهَ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا) (2) ؛
 لِأَنَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ آلَةِ (3) ، وَمَا دُونَهَا (4) لَا
 يَخْتَصُّ إِتْلَافُهُ بِآلَةٍ دُونَ آلَةٍ (5) وَاللَّهُ أَعْلَمُ . (6)

(1) أي المشايخ

(2) يعني ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ .

(3) فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح وما يجري مجراه

(4) أي ما دون النفس

(5) ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين، يقصد بالسوط والعصا الصغيرة .

(6) نخلص مما سبق بأن 1- المقصود بالقتل بسبب: أن يتسبب إنسان بحفر بئر أو وضع حجر في غير ملكه فيقتل شخصاً . 2- موجب القتل بسبب: الدية على العاقلة، ؛ لأنه سبب التلّف وهو متعد فيه فأنزل موقعاً دافعا فوجبت الدية . 3- ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب بالقتل بسبب الكفارة أو الحرمان من الميراث، واستدلوا على أن القتل بسبب لا يوجب كفارة أو الحرمان من الميراث، لأن الكفارة تجب بالقتل وهو معدوم منه حقيقة لعدم اتصال فعله به، وإنما ألحق به في حق الضمان على خلاف القياس صيانة للدماء عن الهدر فيبقى في حق غيره على الأصل . فإن قيل: الحافر في غير ملكه يأثم وما فيه إثم من القتل يصح تعليق الحرمان به كما ذكرتم في الخطأ .

(باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه)

(القصاص في النفس)

(باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه)

قال : (القصاص واجب بقتل كل محقون الدم⁽¹⁾ على التأبيد⁽²⁾ إذا قتل عمدا) أما العمدية فلما بيناه. ⁽³⁾ وأما حقن الدم على التأبيد⁽⁴⁾ فلتنفني شبهة الإباحة وتتحقق المساواة⁽⁵⁾.

(حكم قتل المسلم بالذمي)

قَالَ (وَيُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لَهُ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»⁽⁶⁾ وَلِأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا وَقَتَ الْجَنَايَةِ، وَكَذَا الْكُفْرُ مَبِيحٌ فَيُورِثُ الشُّبُهَةَ

(1) من حقن دمه: إذا منعه أن يسفك من وجه دخل على التأبيد احترز به عن المستأمن، ولا يشكل بقتل الأب ابنه، فإنه قتل مسلم لمسلم محقون الدم، مع أنه لا يجب القصاص لأن ذلك من العوارض فلا يدخل تحت القواعد والكلام في الأصول.

(2) قيد به لأنه إذا قتل خطأ لا يجب القصاص.

(3) في أوائل كتاب الجنایات من قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : «العمد قود» ، وأن الجنایة شامل بها.

(4) احترز به عن المستأمن؛ لأن فيه شبهة الإباحة، والعود إلى دار الحرب .

(5) بين القاتل والمقتول.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ، برقم 111.

وَلَنَا مَا رَوَى «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّي» (1) وَلَئِنْ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعَصْمَةِ ثَابِتَةً نَظَرًا إِلَى التَّكْلِيفِ وَالِدَارِ وَالْمَبِيحِ كَفَرِ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِمِ، وَالْقَتْلُ بِمِثْلِهِ يُؤْذَنُ بَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْحَرْبِيُّ لِسِيَاقِهِ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» (2) وَالْعَطْفُ لِلْمُغَايِرَةِ (3)

(حَكْمُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِابْنِهِ)

قَالَ (وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يَقَادُ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ» (4) وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَا لَكَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ يَقَادُ إِذَا ذَبَحَهُ ذَبْحًا (5)، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْيَائِهِ، فَمِنْ الْمَحَالِ أَنْ يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْأَعْدَاءِ مُقَاتِلًا أَوْ زَانِيًا وَهُوَ مُحَصَّنٌ، وَالْقَصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ، وَالْجَدُّ مِنْ قَبْلِ الرِّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ، وَإِنْ عَلَا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَكَذَا

(1) أخرجه الدراقطني في سننه ، برقم 3259.

(2) بيانه: ما ذكره الطحاوي - رحمه الله - في " شرح الآثار " : أن الذي حكاه أبو جحيفة عن علي - رضي الله تعالى عنه - لم يكن مفردا، ولو كان مفردا لاحتمل ما قالوا، ولكن موصلا بغيره، وهو قوله: (ولا ذو عهد في عهده " . ووجه ذلك: أنه عطف هذا على الأول.

(3) لأن المعطوف غير المعطوف عليه.

(4) أخرجه الدراقطني في سننه، برقم 3277.

(5) يعني إذا قصد قتله. أما لو رماه بالسيف أو السكين ولم يرد قتله، فلا قصاص.

الْوَالِدَةُ وَالْجَدَّةُ مِنْ قَبْلِ اللَّابِ أَوْ الْأُمُّ قَرِيبَتْ أَوْ بَعُدَتْ لِمَا بَيْنَا، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعَدَمِ الْمُسْقُطِ.

(حكم من ورث قصاصا على أبيه)

قَالَ (وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ لِحُرْمَةِ الْأَبَوَةِ

(أداة استيفاء القصاص)

قَالَ (وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ إِنْ كَانَ فَعَلًا مَشْرُوعًا، فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا تَحَزَّ رَقَبَتُهُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قُوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»⁽¹⁾ وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَاحُ، وَلِأَنَّ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الزِّيَادَةِ لَوْ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَيَحْزُ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ ١.

(الحكم إذا كان في أولياء الدم صغار)

قَالَ (وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صَغَارٌ وَكِبَارٌ فَلِلْكَبَارِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَدْرِكَ الصَّغَارُ)؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ لِعَدَمِ التَّجْزِي، وَفِي اسْتِيفَائِهِمُ الْكُلَّ إِبْطَالُ حَقِّ الصَّغَارِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى إِدْرَاكِهِمْ كَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَأَحَدِهِمَا غَائِبٌ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمُؤَلَّيْنِ

وَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَأُ لِثَبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ، وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ مِنَ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 2667.

كَمَا فِي وَلَايَةِ الْإِنكَاكِحِ، بِخَافِ الْكَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ ثَابِتٌ وَمَسْأَلَةُ الْمَوْلِيِّينَ مَمْنُوعَةٌ⁽¹⁾.

(حكم من ضرب رجل بمر (2) - فأس - فقتله)

قَالَ (وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِمِرٍّ فَقَتَلَهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ⁽³⁾ قُتِلَ بِهِ⁽⁴⁾ وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ⁽⁵⁾ فَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ)⁽⁶⁾ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وَهَذَا⁽⁷⁾ إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيدِ لَوْ جُودَ الْجُرْحُ فَكَمُلَ⁽⁸⁾ السَّبَبُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بظَهْرِ الْحَدِيدِ فَعِنْدَهُمَا⁽⁹⁾ يَجِبُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اعْتِبَارًا مِنْهُ لِلآلَةِ، وَهُوَ الْحَدِيدُ:

(1) (ومسألة الموليين ممنوعة) هذا جواب عن قوله: أو كان بين الموليين قالوا: إنه لا ولاية في هذا فيمنع. ونقول: لا نسلم أن لا ينفرد أحدهما للاستيفاء، ولئن سلمنا فنقول: إن أحد الموليين إنما لم ينفرد بالاستيفاء لأن السبب لم يكمل في حقه لأن بعض الملك، وبعض الولاء ليس بسبب أصلا، فصارا جميعا كشخص واحد، فثبت ملك قصاص واحد لشخص واحد، بخلاف السعاية، فإنها سبب كامل لاستحقاق كل القصاص.

(2) (مر): بفتح الميم وتشديد الراء: هو الذي يعمل به في الطين. ينظر: المغرب للمطرزي ص 439.

(3) أي بالحديد الذي في أحد طرفي المر.

(4) (قتل به) بلا خلاف لوجود القتل على وجه الكمال.

(5) الذي هو أحد طرفي المر

(6) أي بالحديد الذي في أحد طرفي المر.

(7) أي وجوب القصاص

(8) أي الجرح

(9) أي عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -

وَعَنْهُ⁽¹⁾ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا جَرَحَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا نَبَّيْنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَلَى هَذَا⁽²⁾ الضَّرْبُ بِسِنَجَاتِ الْمِيزَانِ؛ وَأَمَّا إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعُودِ فَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيةُ لَوْجُودِ قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ وَامْتِنَاعِ الْقَصَاصِ حَتَّى لَا يَهْدَرَ الدَّمُ، ثُمَّ قِيلَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَا الْكَبِيرَةِ فَيَكُونُ قَتْلًا بِالْمَقْتُلِ، وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا نَبَّيْنَهُ⁽³⁾، وَقِيلَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّوْطِ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَوَالَةِ⁽⁴⁾ لَهُ⁽⁵⁾ أَنَّ الْمَوَالَةَ فِي الضَّرَبَاتِ إِلَى أَنْ مَاتَ دَلِيلُ الْعَمْدِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ الْمَوْجِبُ وَلَنَا: مَا رَوَيْنَا «أَلَا إِنْ قَتَلَ خَطَا الْعَمْدِ» وَيُرْوَى " شَبَّهَ الْعَمْدُ " الْحَدِيثَ وَلِأَنَّ فِيهِ شَبْهَةً عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَوَالَةَ قَدْ تَسْتَعْمَلُ لِلتَّأْدِيبِ أَوْ لَعَلَّه اعْتَرَاهُ الْقَصْدُ فِي خِلَالِ الضَّرَبَاتِ فَيَعْرِى أَوَّلُ الْفِعْلِ عَنْهُ وَعَسَاهُ أَصَابَ الْمَقْتُلَ، وَالشَّبْهَةُ دَارِئَةٌ لِلْقَوْدِ فَوَجِبَ الدِّيةُ.

(1) أي وعن أبي حنيفة - رحمه الله -

(2) أي وعلى هذا الاختلاف

(3) فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين؛ لأنه عمد. وعندهما: يجب

القصاص لأنه قتل عمد. وبه قالت الأئمة الثلاثة - رحمهم الله -

(4) يعني في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير، إذا والى

الضربات، لا يجب القصاص به. .

(5) للإمام الشافعي - رحمه الله -

(حكم من غرق صبيا أو بالغاً في البحر)

قَالَ (وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: يَقْتَضِ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، غَيْرَ أَنْ عِنْدَهُمَا يَسْتَوْفَى حَزَا وَعِنْدَهُ يَغْرَقُ كَمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلِ لَهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ غَرَّقَ غَرَقْنَاهُ» وَلِأَنَّ النَّالَةَ قَاتِلَةٌ فَاسْتَعْمَلَهَا أَمَارَةُ الْعَمْدِيَّةِ، وَلَمْ يَرَأَ فِي الْعَصْمَةِ وَلَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطِيءِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَا»⁽¹⁾ وَفِيهِ «وَفِي كُلِّ خَطِيءٍ أَرْشٌ»⁽²⁾؛ لِأَنَّ النَّالَةَ غَيْرُ مَعْدَةٍ لِلْقَتْلِ، وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ فَتَمَكَّنَتْ شُبْهَةُ عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَنْبِئُ عَنِ الْمِثَالَةِ، وَمِنْهُ يُقَالُ: اقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَمِنْهُ الْقِصَّةُ لِلْجُلَمِيِّينَ⁽³⁾، وَلَمْ تَمَازِلْ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالْدَقِّ لِقُصُورِ الثَّانِي عَنْ تَخْرِيبِ الظَّاهِرِ، وَكَذَا لَمْ يَتِمَّازِلَا فِي حِكْمَةِ الزَّجْرِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسِّلَاحِ غَالِبٌ وَبِالْمَقْتَلِ نَادِرٌ، وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْ هُوَ مُحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَقَدْ أُوْمِتَ إِلَيْهِ إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ

(1) أخرجه الدارقطني في سننه، برقم 3168.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه، برقم 3176.

(3) الجلم: الذي يجز به الشعر والصوف، والجلمان شفرتاه، كالمقص والمقصين. والجلم: مصدر إذا أخذ ما على عظامها من اللحم. لسان العرب 102/12.

وَجَبَتْ الدِّيَّةُ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاخْتَلَفَ
الرَّوَايَتَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ

(حَكَمَ مَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ)

(

(قَالَ) (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى
مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) لَوْجُودِ السَّبَبِ (1) وَعَدَمِ مَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ
فِي الظَّاهِرِ فَأُضِيفَ إِلَيْهِ.

(تعدد أسباب الجريمة)

قَالَ (وَمَنْ شَجَّ نَفْسَهُ وَشَجَّهَ رَجُلٌ وَعَقَرَهُ أَسَدٌ وَأَصَابَتْهُ حَيَّةٌ
فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُ الدِّيَّةِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْأَسَدِ
وَالْحَيَّةِ جَنْسٌ وَاحِدٌ لِكُونِهِ هَدْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَفِعْلُهُ
بِنَفْسِهِ هَدْرٌ فِي الدُّنْيَا مَعْتَبَرٌ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى يَأْتِمَ عَلَيْهِ، وَفِي
النُّوَادِرِ (2) أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَغْسَلُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ، وَفِي
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَغْسَلُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَفِي شَرْحِ السَّيْرِ

(1) وهو سفك دم محقون على التأبيد عمدا.

(2) النوادر، وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت كتب
ظاهر الرواية، ولم تزو إلا بطريق الأحاد بين صحيح وضعيف،
كالزَّقِيَّاتِ "و"، الكيسانِيَّاتِ "و"، الجزجَانِيَّاتِ "و"، الهَارُونِيَّاتِ "من تصانيف
محمد التي رواها عنه الأحاد، ولم تبلغ حد التواتر، ولا الشهرة عنه.

الكبير⁽¹⁾ ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايخِ⁽²⁾ عَلَى مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ فَلَمْ يَكُنْ هَدْرًا مُطْلَقًا وَكَانَ جِنْسًا آخَرَ، وَفِعْلُ الْأَجْنَبِيِّ مُعْتَبَرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَصَارَتْ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ فَكَانَ النَّفْسُ تَلَفَتْ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِفِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(حكم من شهر على المسلمين سيفاً)

قَالَ (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَمَ دَمَهُ» وَلِأَنَّهُ بَاغٍ فَتَسْقُطُ عَصَمَتُهُ بِبَغْيِهِ، وَلِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ، وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَحَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ إِشَارَةً إِلَى الْوُجُوبِ، وَالْمَعْنَى وَجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ

(الحكم إن أشهر المجنون على غيره سلاحاً فقتله المشهور

عليه)

قَالَ (وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالِدَابَةُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ

(1) كتاب "شرح السير الكبير" لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ).

(2) المراد بالمشايخ: من لم يدرك الإمام. وذلك بعد وفاة حسن بن زياد اللؤلؤي قرابة 204هـ.

يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الدَّابَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ،
لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيَعْتَبَرُ بِالْبَالِغِ الشَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ
يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفَعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمَكْرَهَ
وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا
يُوجِبُ الضَّمَانُ، أَمَّا فَعْلُهُمَا فَمُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَّقْنَاهُ
يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَكَذَا عَصَمَتُهُمَا لِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ
لِحَقِّ مَالِكِهَا فَكَانَ فَعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَّةِ، وَلَنَا
أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ
وَفِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فَعْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ
عَصَمَتُهُمَا حَقًّا لِعَدَمِ اخْتِيَارِ صَحِيحٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ
بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بَخَافِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا
صَحِيحًا، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ
فَتَجِبُ الدِّيَّةُ

(حکم من أشهر على غيره سلاحاً في المصر)

قَالَ (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فِي الْمَصْرِ فَضْرِبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ
الْآخِرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ) مَعْنَاهُ: إِذَا ضْرِبَهُ فَانْصَرَفَ (1)؛
لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَارِبًا بِالْانْصِرَافِ فَعَادَتْ عِصْمَتُهُ.
(حکم من دخل عليه غيره ليلاً وأخرج السرقة فاتبعه وقتله)

(

(1) يعني أشهر سيفه وضربه، ثم انصرف وترك الضرب ثم قتله المشهور
عليه، فعليه القصاص ولا قصاص على الشاهر.

قَالَ (وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتَّلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ» وَلِأَنَّهُ يَبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ دَفْعًا فِي الْبَتْدَاءِ فَكَذَا اسْتِرْدَادًا فِي الْانْتِهَاءِ، وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ لَا يَتِمَكَّنُ مِنَ الْاسْتِرْدَادِ إِلَّا بِالْقَتْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

القصاص فيما دون النفس

(قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنْ الْمِفْصَلِ)

قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنْ الْمِفْصَلِ قُطِعَتْ يَدُهُ، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنْ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] وَهُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَازَلَةِ، فَكُلُّ مَا أُمِكنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا، وَقَدْ أُمِكنَ فِي الْقَطْعِ مِنَ الْمِفْصَلِ فَاعْتَبِرَ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكِبَرِ الْيَدِ وَصِغَرِهَا لِأَنَّ مَنَفْعَةَ الْيَدِ لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ لِإِمْكَانِ رِعَايَةِ الْمُمَازَلَةِ.

(حَكَمَ مَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا)

قَالَ: (وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ) لِامْتِنَاعِ الْمُمَازَلَةِ فِي الْقَلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْءُهَا فَعَلِيهِ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَازَلَةِ عَلَى مَا قَالُ فِي الْكِتَابِ (1): تُحْمَى لَهُ الْمِرَّةُ وَيَجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ وَتَقَابِلُ عَيْنُهُ بِالْمِرَّةِ

(1) يَعْنِي الْقُدُورِيَّ.

فَيَذْهَبُ ضَوْءُهُمَا، وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (1)

(القصاص في السن)

قَالَ: (وَفِي السِّنِّ الْقَصَاصُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] (وَإِنْ كَانَ سِنٌّ مِنْ يَقْتَصُّ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنْ سِنِّ الْآخِرِ) لَأَنَّ مَنْفَعَةَ السِّنِّ لَا تَتَفَاوَتُ بِالصَّغَرِ وَالْكَبَرِ. قَالَ: (وَفِي كُلِّ شَجَةٍ تَتَحَقَّقُ فِيهَا الْمُمَاتِلَةُ الْقَصَاصُ) لَمَّا تَلَوْنَا (2).
قَالَ (وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ) (3) وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ» (4)

(1) رَوَى أَنَّ هَذَا حَدَّثَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَأَلَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمْ يَكُنْ عَنْدهُمْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى بِذَلِكَ وَعَمِلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

(2) (إشارة إلى قوله تعالى {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

(3) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 2/269 رقم 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السِّنِّ وَالرَّأْسَ"

(4) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 2/269 رقم 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ

وَالْمَرَادُ غَيْرُ السِّنِّ، وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُمَاتِلَةِ فِي غَيْرِ السِّنِّ مُتَعَذِّرٌ
لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، بِخِلَافِ السِّنِّ لِأَنَّهُ يَبْرُدُ بِالْمَبْرَدِ،
وَلَوْ قُلِعَ مِنْ أَصْلِهِ يَقْلَعُ الثَّانِي فَيَتِمَّ اثْنَانِ.

(لَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ)

قَالَ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ
خَطَأٌ) لِأَنَّ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعُودُ إِلَى الْآلَةِ، وَالْقَتْلُ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ
بِاخْتِلَافِهَا دُونَ مَا دُونَ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إِتْلَافُهُ بِاخْتِلَافِ
الْآلَةِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ.

(الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (1))

(وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ
الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ
إِلَّا فِي الْحُرِّ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ. وَيُعْتَبَرُ الْأَطْرَافُ بِالنَّفْسِ
لِكُونِهَا تَابِعَةً لَهَا. وَلَنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يَسْلُكُ بِهَا مَسْلَكُ الْأَمْوَالِ

إِلَّا فِي السِّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ

الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السِّنِّ وَالرَّأْسِ

(1) اختلف الفقهاء في القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس على

قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة.

القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جريان القصاص بين الرجل والمرأة

باعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس فكما يجري القصاص بين

الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف. واستدل الحنفية على

أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة، لأنَّ الأطراف يسلك بها مسلك الأموال

فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع.

فَيَنْعَدُمُ التَّمَاثُلُ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْقِيَمَةِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا بِتَقْوِيمِ الشَّرْعِ فَأَمَكَّنَ اعْتِبَارَهُ. بِخِلَافِ التَّفَاوُتِ فِي الْبُطْشِ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لَهُ فَاعْتَبِرَ أَصْلَهُ، وَبِخِلَافِ الْأَنْفُسِ لِأَنَّ الْمُتَلَفَ إِزْهَاقُ الرُّوحِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ.

(الْقَصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ)

(وَيَجِبُ الْقَصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ) لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَرْشِ. (1)

(قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا) قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً) (2) فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَا قَصَاصَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاطَّةِ فِيهِ، إِذِ الْأَوَّلُ كَسَرُ الْعَظْمِ وَلَا ضَابِطَ فِيهِ، وَكَذَا الْبَرَاءُ نَادِرٌ فَيُفَضِّلُ الثَّانِي إِلَى الْهَلَاكِ ظَاهِرًا.

(قطع اليد الشلاء أو ناقصة الأصابع بالصحيحة)

(1) يطلق الأرش عند الفقهاء على المال الواجب فيما دون النفس بالجناية عليه .

(2) الجائفة: لغة الجراحة التي وصلت الجوف .المغرب للمطري: 96/1. ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف ، كبطن ، وصدر ، وثغرة نحر ، وجنبين ، وخاصرة ، ومثانة ، وجفان ، وكذا لو أدخل من الشرج شيئاً فخرق به حاجزاً في البطن . ولو نفذت الطعنة أو الجرح في البطن وخرجت من محل آخر فجائفتان .

قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَاحِبَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَاءً أَوْ نَاقِصَةً الْأَصَابِعِ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمَعْيِبَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ كَامِلًا) لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ كَامِلًا مُتَعَذِّرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِدُونِ حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يَعْدَلَ إِلَى الْعَوَضِ (1) كَالْمِثْلِيِّ (2) إِذَا انْصَرَمَ (3) عَنْ أَيْدِي النَّاسِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ (4) ثُمَّ إِذَا اسْتَوْفَاهَا نَاقِصًا فَقَدْ رَضِيَ بِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا إِذَا رَضِيَ بِالرَّدِيِّ مَكَانَ الْجَيِّدِ (وَلَوْ سَقَطَتِ الْمُؤَوَّفَةُ (5) قَبْلَ اخْتِيَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ قُطِعَتْ ظُلْمًا فَلَا شَيْءَ لَهُ) عِنْدَنَا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيَّنٌ فِي الْقِصَاصِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَالِ بِاخْتِيَارِهِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ، بخلاف ما إذا قُطِعَتْ بِحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ سَرَقَةٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فَصَارَتْ سَالِمَةً لَهُ مَعْنَى.

(1) أرش

(2) كالمثلي: يعني لم يبق منه إلا ناقص الصفة فالمالك بالخيار، إن شاء أخذه ناقصا، وإن شاء عدل إلى القيمة، كذا هنا، فيسقط حقه، .

(3) انقطع.

(4) أي أتلّف المثلّي ثم انصرم هو.

(5) أي المعيبة الشلاء.

(شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعِبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا

تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ)

قَالَ: (وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعِبَتِ الشَّجَّةُ (1) مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ فَالْمَشْجُوجُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ بِمِقْدَارِ شَجَّتِهِ يَبْتَدِئُ مِنْ أَيْ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ (الرَّش) لِأَنَّ الشَّجَّةَ مُوجِبَةٌ لَكُونِهَا مَشِينَةً فَقَطُّ فَيَزِدُّ الشَّيْنُ بَزِيَادَتِهَا، وَفِي اسْتِيفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ، وَلَا يَلْحَقُهُ مِنَ الشَّيْنِ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْرُ حَقِّهِ مَا يَلْحَقُ الْمَشْجُوجَ فَيَنْتَقِصُ فَيُخَيَّرُ كَمَا فِي الشَّلَاءِ وَالصَّحِيحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ يُخَيَّرُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِيفَاءُ كَامِلًا لِلتَّعَدِّي إِلَى غَيْرِهِ. حَقُّهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الشَّجَّةُ فِي طَوْلِ الرَّأْسِ وَهِيَ تَأْخُذُ مِنْ جِبْهَتِهِ إِلَى قَفَاهُ وَلَا تَبْلُغُ إِلَى قَفَا الشَّاجِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلَفُ.

(الْقِصَاصُ فِي اللِّسَانِ وَفِي الذِّكْرِ)

قَالَ: (وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذِّكْرِ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ يَجِبُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ. وَلَنَا أَنَّهُ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ (إِلَّا أَنْ تَقُطَعَ الْحَشْفَةُ) لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقُطْعِ مَعْلُومٌ كَالْمَفْصِلِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْحَشْفَةِ أَوْ بَعْضُ الذِّكْرِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارَهُ، بِخِلَافِ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ

(1) للصغر رأسه.

لأنه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة، والشفة إذا استقصاها بالقطع يجب القصاص للمكان اعتبار المساواة، بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها.

(الحكم إذا اصططح القاتل وأولياء القتيل على مال)

قال: (وإذا اصططح القاتل (1) وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال (2) قليلا كان أو كثيرا (3)) لقوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] الآية على ما قيل نزلت الآية في الصلح. وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «من قتل له قتيل» (4) الحديث، والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه، ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي. والقليل والكثير فيه سواء لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره، وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والتمن، بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد.

(1) عن القصاص.

(2) المسمى.

(3) أزيد على مقدار الدية.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 5/9 رقم 6880.

(عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدِّمِّ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى عَوْضٍ)
(وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدِّمِّ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى
عَوْضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِيْنَ عَنِ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيْبُهُمْ
مِنَ الدِّيَةِ). وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ جَمِيعُ الْوَرِثَةِ، وَكَذَا
الدِّيَةُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الزَّوْجَيْنِ. لِهَذَا أَنَّ الْوَرِثَةَ
خِلَافَةٌ وَهِيَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ، وَلَنَا «أَنَّهُ
- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِتَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشِيمِ الضَّبَابِيِّ
مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشِيمِ» (1)، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، حَتَّى
أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ كَانَ الْقِصَاصُ
بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَابْنِ الْإِبْنِ فَيُثَبَّتُ لِسَائِرِ الْوَرِثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى
بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ أَوْ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَدًّا
إِلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْجَرْحُ، وَإِذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيعِ فَكُلٌّ مِنْهُمْ يَتِمَكَّنُ مِنْ
الِاسْتِيفَاءِ وَالْإِسْقَاطِ عَفْوًا وَصَلَحًا وَمِنْ ضَرُورَةِ سَقُوطِ حَقِّ
الْبَعْضِ فِي الْقِصَاصِ سَقُوطُ حَقِّ الْبَاقِيْنَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ،
بِخِلَافِ مَا إِذَا قُتِلَ رَجُلَيْنِ وَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيِّينَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ
قِصَاصَانِ مِنْ غَيْرِ شَبْهَةٍ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ وَالْمَقْتُولِ وَهَاهُنَا وَاحِدٌ
لِاتِّحَادِهِمَا، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيْبُ الْبَاقِيْنَ مَالًا لِأَنَّهُ
امْتَنَعَ لِمَعْنَى رَاجِعٍ إِلَى الْقَاتِلِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ
لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِفَعْلِهِ وَرِضَاةٍ، ثُمَّ يَجِبُ مَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ فِي
ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ زَفَرٌ: يَجِبُ فِي سَنَتَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ

(1) أخرجه الدارقطني في سننه 135/5 رقم 4089.

الشَّرِيكَيْنِ وَعَفَا أَحَدَهُمَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ نَصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً. وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الدَّمِ وَكُلُّهُ مُؤَجَّلٌ إِلَى ثَلَاثِ سَنِينَ فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْيَدِ كُلِّ بَدَلِ الطَّرَفِ وَهُوَ فِي سَنَتَيْنِ فِي الشَّرْعِ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ عَمْدٌ.

(قَتْلُ جَمَاعَةٍ وَاحِدًا عَمْدًا)

قَالَ : (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ، وَالْقِصَاصُ مَزْجَرَةٌ لِلْسَفَهَاءِ فَيَجِبُ تَحْقِيقًا لِحِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ (1).

(قَتْلُ وَاحِدٍ جَمَاعَةً)

(1) إِذَا تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ لَانْتِفَاءُ الْمِثْلَةِ، لَكِنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ بِمَا رَوَى أَنَّ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتَهُمْ. وَالتَّمَالُؤُ النَّعَاوُنُ، وَصَنْعَاءُ الْيَمَنُ: قِصْبَتُهَا. وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَتَلَ ثَلَاثَةَ بَوَاحِدٍ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَتَلَ جَمَاعَةً بِوَاحِدٍ، وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فِجْلَ مُحَلِّ الْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَتَحَقَّقُ غَالِبًا إِلَّا بِالْإِجْتِمَاعِ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ يَقَاوِمُ الْوَاحِدَ، وَمَا غَلَبَ وَقَوَعَهُ مِنَ الْفَسَادِ يُوجِبُ مَزْجَرَةً فَيَجِبُ الْقِصَاصُ تَحْقِيقًا لِحِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَمَا عَجَزَ الْمَفْسِدُ عَنْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ أَمْثَالُهُ وَيَقْتُلَ لَعَلَّمَهُ أَنْ لَا قِصَاصَ فَيُؤَدِّي إِلَى سُدِّ بَابِ الْقِصَاصِ.

(وَإِذَا قُتِلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قُتِلَ لْجَمَاعَتِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْتُلُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمْ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الْمَالُ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَوَّلُ قُتِلَ لَهُمْ وَقِسِمَتِ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيَقْتُلُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. لَهُ أَنْ الْمَوْجُودُ مِنَ الْوَاحِدِ قَتَلَتْ وَالَّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قُتِلَ وَاحِدٌ فَلَا تَمَاطُلَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ. وَلَنَا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بَوْصَفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاتُلُ أَصْلُهُ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا وَجِبَ الْقَصَاصُ، وَلِأَنَّهُ وَجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَرَحٌ صَالِحٌ لِلْإِزْهَاقِ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمْ إِذْ هُوَ لَا يَنْجِزُ، وَلِأَنَّ الْقَصَاصَ شَرَعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحْقِيقِ الْإِحْيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ بِقَتْلِهِ فَانْتَفَى بِهِ.

(سقوط القصاص بالموت)

قَالَ : (وَمَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ الْقَصَاصُ إِذَا مَاتَ سَقَطَ الْقَصَاصُ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الِاسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ مَوْتَ الْعَبْدِ الْجَانِي، وَيَتَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ إِذَا الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ.

(قطع رجلان يد رجل واحد)

قَالَ : (وَإِذَا قُطِعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قَصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نَصْفُ الدِّيَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَطَّعُ يَدَاهُمَا، وَالْمَفْرُضُ إِذَا أَخَذَ سَكِينًا وَأَمَرَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتْ لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالنَّفْسِ، وَالْيَدَيِ تَابِعَةٌ لَهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، أَوْ يَجْمَعُ

بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الزَّجَرِ. وَلَنَا أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاطِعُ بَعْضِ
الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِيهِمَا وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّئٌ فَيُضَافُ
إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَعْضُ فَلَا مُمَازَّةَ، بِخِلَافِ النَّفْسِ لِأَنَّ
الْإِنْزِهَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ الْجَمَاعَةِ غَالِبٌ حَذَارُ
الْغَوْتِ، وَالْجَمَاعَةُ عَلَى قِطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمَفْصَلِ فِي حِيزِ النَّدْرَةِ
لِإِفْتِقَارِهِ إِلَى مُقَدِّمَاتٍ بَطْنِيَّةٍ فَيُلْحَقُهُ الْغَوْتُ. قَالَ (وَعَلَيْهِمَا
نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّهُ دِيَّةُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَهُمَا قَطَعَاهَا.

(قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ (1))

(وَأِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي (2) رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا
يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا
مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعَاقُبِ يَقْطَعُ

(1) اختلف الفقهاء في قِطْعِ وَاحِدٍ يَمِينِي رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ
الْأَوَّلُ: قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: لَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْسِمَانِهِ
نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَاسْتَدْلُوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِأَنََّّهُمَا
اسْتَوِيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِمَا كَالْغَرِيمَيْنِ فِي الثَّرَكَةِ،
وَالْقَصَاصِ مَلِكِ الْفِعْلِ يَثْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِسْتِيفَاءِ.
أَمَّا الْمَحَلُّ فَخَلَوُ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الثَّانِي، بِخِلَافِ الرِّهْنِ لِأَنَّ الْحَقَّ
ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ.

(2) قَيَّدَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَمِينُ أَحَدِهِمَا وَبَسَّارَ الْآخَرِ قُطِعَتْ يَدَاهُ. لَا
يُقَالُ: تَنْتَفِي الْمِمَازَّةِ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ مَا قُوتَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسُ
الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ قُوتَاهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمَعْتَبَرَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَلَيْسَ
فِي ذَلِكَ تَقْوِيَتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا زِيَادَةُ عَلَى حَقِّهِ.

بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُقَرَعُ لَأَنَّ الْيَدَ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَثْبُتُ
الِاسْتِحْقَاقُ فِيهَا لِلثَّانِي كَالرَّهْنِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ
الْوَّاحِدَةُ لَا تَقِي بِالْحَقِّينِ فَتَرْجَحُ بِالْقَرَعَةِ. وَلَنَا أَنَّهُمَا اسْتَوِيَا فِي
سَبَبِ الْاسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَّرَكَةِ،
وَالْقَصَاصِ مِلْكُ الْفِعْلِ يَثْبُتُ مَعَ الْمَنَافِي فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا فِي حَقِّ
الِاسْتِيفَاءِ.

أَمَّا الْمَحَلُّ فَخَلَوْا عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتَ الثَّانِي، بِخِلَافِ الرَّهْنِ لَأَنَّ
الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ. فَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدَ يَمِينَهُمَا عَلَى
التَّعَاقُبِ فَتَسْتَحِقُّ رَقَبَتَهُ لِهَمَا، وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ
فَلَا أُخِرَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لَأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لثُبُوتِ حَقِّهِ
وَيَتَرَدَّدُ حَقُّ الْغَائِبِ، وَإِذَا اسْتَوْفِيَ لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الْاسْتِيفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ
حَقُّ الْآخَرِ فِي الدِّيَةِ لَأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا.

(رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمَ مِنْهُ إِلَى آخِرِ فَمَاتَا)

(وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمَ مِنْهُ إِلَى آخِرِ فَمَاتَا فَعَلِيهِ
الْقَصَاصُ لِلأَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ) لَأَنَّ الْأَوَّلَ عَمْدٌ
وَالثَّانِي أَحَدُ نَوْعِي الْخَطَا، كَأَنَّهُ رَمَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا
وَالْفِعْلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّ الْأَثَرِ.

(قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَاً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا)

قَالَ : (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَاً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ يَدُهُ
أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَاً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ خَطَاً فَبَرِئَتْ يَدُهُ
ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَاً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَبَرَأَتْ ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا فَإِنَّهُ
يُؤْخَذُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَرَاحَاتِ

وَأَجِبَ مَا أَمَكْنَ تَتَمِيمًا لِلأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الأَعْمِ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعاقِبَةٍ، وَفِي اعتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرْجِ، إِلَّا أَنْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فِي هَذِهِ الفُصُولِ فِي الأولَيْنِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الفَعْلَيْنِ، وَفِي الْآخَرَيْنِ لِتَخَلُّلِ البرِّءِ وَهُوَ قَاطِعٌ لِلسَّرَايَةِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَجْمَعُ بِالإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتَفَى بَدِيَّةً وَاحِدَةً (وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ يَدَهُ، فَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ قَالَ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ اقْتُلُوهُ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: اقْتُلُوهُ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَقْتُلُ وَلَا تَقْطَعُ يَدَهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمْكِنٌ لِتَجَانُسِ الفَعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ البرِّءِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَلَهُ أَنْ الْجَمْعُ مُتَعَذَّرٌ، إِمَّا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنِ الفَعْلَيْنِ هَذَيْنِ لِأَنَّ المَوْجِبَ الْقَوْدَ وَهُوَ يَعْتَمِدُ المُسَاوَاةَ فِي الفِعْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْحَزَّ يَقْطَعُ إِضَافَةَ السَّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ، حَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ شَخْصَيْنِ يَجِبُ الْقَوْدُ عَلَى الْحَازِ فَصَارَ كَتَخَلُّلِ البرِّءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ الفِعْلَ وَاحِدًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَأَيْنِ لِأَنَّ المَوْجِبَ الدِّيَّةَ وَهِيَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ اعتِبَارِ المُسَاوَاةِ، وَلِأَنَّ أَرْشَ اليَدِ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ أَثَرِ الفِعْلِ وَذَلِكَ بِالْحَزِّ الْقَاطِعِ لِلسَّرَايَةِ فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الكُلِّ وَضَمَانُ الْجُزْءِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجْتَمِعَانِ. أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ قِصَاصًا يَجْتَمِعَانِ (1).

(1) الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ إِذَا حَصَلَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَانَا عَلَى وَجْهِ: أَنْ يَكُونَ

(الحكم إذا قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك (1))

خَطَّائِنَ أَوْ عَمْدَيْنِ، أَوْ يَكُونُ الْقَتْلُ خَطَأً وَالْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَذَلِكَ بِالنَّسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَرْبَعَةً. ثُمَّ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبَرِّ أَوْ بَعْدَهُ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْجِهًا، وَكُلُّ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ شَخْصَيْنِ فَذَلِكَ سِتَّةٌ عَشَرَ وَجْهًا، فَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصَيْنِ يَفْعَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبَ فَعْلِهِ مِنَ الْقَصَبِ وَأَخَذَ الْأَرِشَ مُطْلَقًا، لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إِمَّا يَكُونُ عِنْدَ اتِّجَادِ الْمَحَلِّ لَا غَيْرَ، وَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَيُجَابِ مُوجِبُ الْفَعْلَيْنِ أَوْ إِهْدَارُ أَحَدِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلِ ذِكْرِهِ الْمَصْنُفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ (وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ).

(1) اختلف الفقهاء في حكم سرية القطع والشجعة والجراحة على النفس بعد العفو، فهل يسري العفو إلى ذلك على قولين: القول الأول: ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ وَالشَّجْعَةِ وَالْجِرَاحَةِ لَيْسَ بِعَفْوٍ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ، فَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَعُفِيَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ عَنْهُ ثُمَّ سَرَى وَمَاتَ فَعَلِيَ الْجَانِي الدِّيةَ فِي مَالِهِ عِنْدَهُ. القول الثاني: ذهب صاحبان إلى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ وَالشَّجْعَةِ وَالْجِرَاحَةِ عَفْوٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ، وَإِلَّا شَيْءٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنِ مُوجِبِهِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى فَلَا يَتَصَوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنِ مُوجِبِهِ وَمُوجِبِهِ إِمَّا الْقَطْعُ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا اقْتَصَرَ أَوْ سَرَى فَكَانَ الْعَفْوُ عَنْهُمَا، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَّ وَالْمَقْتَصِرَ فَإِنَّ الْإِذْنَ بِالْقَطْعِ إِذْنٌ بِهِ وَبِمَا حَدَّثَ مِنْهُ. حَتَّى إِذَا قَالَ شَخْصٌ آخَرَ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ لَمْ يَضْمَنْ وَالْعَفْوُ إِذْنٌ

قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ (1) يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا الْمَقْطُوعَةَ يَدَهُ عَنِ الْقَطْعِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ (2) فَعَلَى الْقَاطِعِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ (3) وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ (4) خَطَأً فَهُوَ مِنَ الثَّلَاثِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِذَا عَفَا عَنِ الْقَطْعِ فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ أَيْضًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا عَفَا عَنِ الشَّجَةِ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ، لَهُمَا أَنْ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنِ مُوجِبِهِ، وَمُوجِبُهُ الْقَطْعُ لَوْ اِقْتَصَرَ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا سَرَى، فَكَانَ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ أَحَدٍ مُوجِبِيهِمَا أَيهما كَانَ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ يَتَنَوَّلُ السَّارِيَّ وَالْمَقْتَصِرَ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنِ قَطْعِ عَفْوًا عَنْ نَوْعِيهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْجَنَائِيَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَوَّلُ الْجَنَائِيَةَ السَّارِيَّةَ وَالْمَقْتَصِرَةَ. كَذَا هَذَا. وَلَهُ أَنْ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَتْلُ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ مُتَقَوِّمَةٌ وَالْعَفْوُ لَمْ يَتَنَوَّلْهُ بِصَرِيحِهِ لِأَنَّهُ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ وَهُوَ غَيْرُ الْقَتْلِ، وَبِالسَّرَاطِيَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاقِعَ قَتْلٌ وَحَقُّهُ فِيهِ وَنَحْنُ نَوْجِبُ ضَمَانَهُ. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقَصَاصُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْجِبُ لِلْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ فِي

انتِهَاءٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِذْنِ ابْتِدَاءً، فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْجَنَائِيَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَوَّلُ السَّارِيَّةَ وَالْمَقْتَصِرَةَ، فَكَذَا هَذَا.

(1) عمداً أو خطأً

(2) القطع.

(3) المقطوعة يده.

(4) قطع.

الاستحسان تجب الدية، لأن صورة العفو أورشئت شبهة وهي دائرة للقود. ولما نسلّم أن الساري نوع من القطع، وأن السراية صفة له، بل الساري قتل من الابتداء، وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعاً فلا يتناولُه العفو، بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنس، وبخلاف العفو عن الشجة وما يحدث منها لأنه صريح في العفو عن السراية والقتل، ولو كان القطع خطأ فقد أجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقاً وخلافاً، أذن بذلك إطلاقه، إلا أنه إن كان خطأ فهو من الثلث، وإن كان عمداً فهو من جميع المال، لأن موجب العمد القود ولم يتعلق به حق الورثة لما أنه ليس بمال فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه. أما الخطأ فموجب للمال، وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث.

مقرر الفقه الحنفي
للسنة الثالثة، بكليات الشريعة والقانون،
والشعب المناظرة
الدراسة الموضوعية
إعداد

أ.د/ أحمد قياتي محمد شلقامي أستاذ الفقه المساعد، بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	أ.د/ محمد سعيد الرملاوي أستاذ الفقه، بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
د/ إبراهيم عاشور السيد مدرس الفقه، بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة	د/ أحمد عبد الدايم عبد السلام مدرس الفقه، بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة
راجع	
أ.م زكية محمد حواس أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ	أ.د/ محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ، بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

العام الجامعي 2025 / 2026م

القسم الثاني

الدراسة الموضوعية

تشتمل الدراسة الموضوعية على الأبواب

الآتية:

الباب الأول: الشهادات.

الباب الثاني: الإقرار.

الباب الثالث: الرهن.

الباب الرابع: الإكراه.

الباب الخامس: الحجر.

الباب الأول: الشهادات.

الفصل الأول

تعريف الشهادات، ومشروعيتها، وحجيتها، وحكمها،
وركنها

المبحث الأول: تعريف الشهادات، وسبب تسميتها،
والألفاظ ذات الصلة

المطلب الأول: تعريف الشهادات، وسبب تسميتها
أولاً: تعريف الشهادة:

الشهادة لغة: مصدر شَهِدَ، يَشْهَدُ، شَهَادَةً، فهو شَاهِدٌ، وتجمع
على شَهِادَاتٍ⁽¹⁾. وتطلق في اللغة على عدة معانٍ، منها:
الخبر القاطع: يقال: شَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا شَهَادَةً: أي أخبر به
خبراً قاطعاً⁽²⁾.

المعينة، والاطلاع على الشيء: ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا
الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا إِنَّا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾⁽³⁾. أي

(1) المطلاع على ألفاظ المقنع، لمحمد بن أبي الفتح البجلي، ص: 496،
الناشر: مكتبة السوادي، الطبعة الأولى 1423هـ.

(2) لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، ابن منظور الأنصاري،
239/3، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ؛ المعجم
الوسيط، الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 497/1، الناشر: دار
الدعوة، بدون طبعة.

(3) سورة الزخرف، جزء من الآية رقم: 19.

مشاهدة البصر⁽¹⁾.

الشهادة اصطلاحاً: عرفها الكمّال بن الهمام بقوله: "إخبارٌ صدقٌ؛ لاثباتِ حقٍّ، بلفظِ الشّهادة، في مجلسِ القضاء"⁽²⁾.
 شرح التعريف: "إخبارٌ" الإخبار بالإعلام بما يحتمل الصدق، والكذب و(والإخبار) جنس في التعريف، يشمل كل إخبار: فإن كان إخباراً بحق للإنسان على غيره في مجلس قضاء القاضي، فهو (دعوى). وإن كان إخباراً بحق للغير على المخبر نفسه فهو (إقرار). وإن كان إخباراً بحق للغير على الغير، بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء، فهو (شهادة). وإن كان إخباراً بثبوت حق للغير على الغير من القاضي على سبيل الإلزام فهو (قضاء). وإن كان إخباراً عن قول، أو فعل، أو صفة، أو تقرير، منسوب إلى رسول الله - ﷺ - فهو " (حديث، أو أثر، أو سنة). وإن كان إخباراً عن مساوئ الشخص فهو (غيبة). وإن كان إخباراً عن كلام الصديق لصديقه الآخر على وجه الإفساد بينهما، فهو (نميمة). وإن كان إخباراً عن سرٍّ، فهو (إفشاء). وإن كان إخباراً عما يضرُّ

(1) المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف، بالراغب الأصفهاني، ص: 465، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، بدون طبعة.

(2) فتح القدير، لابن الهمام، 364/7، .

بِالْمُسْلِمِينَ فَهُوَ (خِيَانَةٌ). فالإخبار يشمل هذا كله⁽¹⁾.
 (والإخبار) قيد؛ ليخرج الإنشاء: وَهُوَ الْكَلَامُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ
 الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ لِذَاتِهِ، كَأَنَّ اللَّهَ⁽²⁾، والصدق مطابقة الكلام
 للواقع، بحسب اعتقاد المتكلم. (والصدق) قيد ثان في
 التعريف؛ ليخرج الإخبار بالكذب، كشهادة الزور⁽³⁾.
 قوله: "الْإِثْبَاتُ" الْإِثْبَاتُ: هو إقامة الدليل على صحة الادعاء،
 أمام القاضي.
 (والإثبات) جنس في التعريف، يشمل كل إثبات، سواء أكان
 إثباتاً لصدق وحق، كإثبات التوحيد، وصدق النبوة، أو إثباتاً
 لكذب، وباطل، كمن يثبت مع الله إلهاً آخر⁽⁴⁾. (والإثبات) قيد
 ثالث في التعريف؛ ليخرج النفي.

-
- (1) العناية: للبارتي، 364/7، ؛ التوقيف على مهمات التعاريف،
 للمناوي، القاهري، ص: 209، ؛ معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس
 قلعجي، وحامد صادق قنيبي، ص: 49، 48.
 (2) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، لعبد النبي بن عبد الرسول
 الأحمد نكري، 39/1، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص.
 (3) العناية شرح الهداية، 364/7؛ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقى،
 ليوسف بن حسن بن عبد الهادي، المعروف بـ «ابن المبرد»، 686/3، .
 القاموس الفقهي، لغة واصطلاحاً، د/سعدي أبو حبيب، ص: 209، .
 معجم لغة الفقهاء، ص: 272.
 (4) التوقيف على مهمات التعاريف، ص: 38؛ معجم لغة الفقهاء، ص:
 41.

"حَقٌّ" الحق هو: الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب؛ باعتبار اشتغالها على ذلك. ويقابله الباطل. (والحق) جنس في التعريف، يشمل كل حق، سواء أكان حقاً لله تعالى، أم للعبد، أم مشتركاً بين الله تعالى، والعبد، وقوله: "لإثبات حق" قيد رابع؛ ليخرج الباطل، ويخرج قول القائل في مجلس القضاء: أشهد بكذا، لبعض العرفيات⁽¹⁾⁽²⁾. "بلفظ الشهادة": صوت يخرج من الفم، مشتمل على بعض الحروف⁽³⁾. أو هو ما نطق به اللسان من الكلام⁽⁴⁾. وقوله: "بلفظ الشهادة" قيد خامس؛ ليخرج ما يجري على القلب من المعاني. ويخرج أداء الشهادة بغير لفظ، كالكتابة، أو الإشارة المفهمة. أو بلفظ غير لفظ الشهادة، كقول الشاهد: أخبر، أو أعلم، أو أوقن، فلا تصح الشهادة. وكذلك يُخرج شهادة الزور؛ فإنها ليست بشهادة، وإن سميت شهادة

(1) كقول الشاهد: أشهد أن الشمس مشرقة، وأن المصباح مضيء، وأمثال ذلك من الأمور العادية. (الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، لعلي قراعة، ص: 144.

(2) درر الحكام لملا خسرو 370/2، ؛ قرّة عين الأخيار، ، لمحمد بن محمد أمين، المعروف بابن عابدين، 474/7 .

(3) الحدود الأنينة والتعريفات الدقيقة، لذكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي، ص: 78، .الكليات، لأيوب بن موسى، أبي البقاء الحنفي، ص: 795، .

(4) معجم لغة الفقهاء، ص: 393.

مجازاً⁽¹⁾. "فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ" قيد سادس؛ ليخرج أداء الشهادة في غير مجلس القضاء، فلا تقبل⁽²⁾.
 ثانياً: سبب تسميتها: سميت الشهادة بذلك؛ لأنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة؛ لأن الشاهد يخبر عما يشاهده. وقيل: لأن الشاهد بإخباره، جعل الحاكم كالشاهد للمشهود به.
 وتسمى أيضاً بيّنة؛ لأنها تبين ما التبس، وتكشف الحق فيما اختلف فيه⁽³⁾.

المطلب الثاني

الألفاظ ذات الصلة بالشهادة

من الألفاظ ذات الصلة بالشهادة: الإقرار، والدعوى، .
 أولاً: تعريف الدعوى، والإقرار:

تعريف الدعوى: الدعوى لغة: اسم من الدّعاء، والدّعاء مصدر ادّعى، يدّعي، ادّعاء ودعوى، فهو مدّع، والعين، أو الدين الذي يدّعيه فهو مدّعي، ولا يقال مدّعي فيه أو به، وإن كان يتكلم به المتفقهة، وذلك الرجل الآخر مدّعي عليه، وهما متدّعيان، كما يقال في البيع هما متبايعان. وتجمع الدعوى

(1) المبسوط: للسرخسي، 16/1414، 130هـ؛ فتح القدير، 7/364.

(2) قرّة عين الأخير، 7/474.

(3) تبين الحقائق، 4/207، ؛ الجوهرة النيرة، للعبادي، 2/224، .

عَلَى دَعَاوَى بِكَسْرٍ، الْوَاوِ وَفَتْحِهَا⁽¹⁾.

واصطلاحاً: "إخبار بحق له على غيره عند الحاكم"⁽²⁾. أو هي "إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة"⁽³⁾.

2-تعريف الإقرار:

الإقرار لغة: ضد الجحود، مشتق من القرار. والإقرار: الاعتراف، يقال: أقر بالشيء، يقر، إقراراً: إذا اعترف به، فهو مقر، والشيء مقر به. والإقرار: إثبات ما كان مترزلاً⁽⁴⁾.

واصطلاحاً: اعتراف صادر من المقر، يظهر به حق ثابت،

(1) الكلبيات، ص: 67؛ طلبية الطلبة، لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبي حفص النسفي، ص: 134، الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، ببغداد، بدون طبعة، 1311هـ؛ المصباح المنير، 1/194.
(2) الباب في شرح الكتاب، لعبد الغني بن طالب بن حمادة، الغنيمي، الميداني، الحنفي، 4/26، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

(3) كنز الدقائق، لعبد الله بن أحمد بن محمود، النسفي، ص: 494؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان، 2/249.

(4) معجم مقاييس اللغة، للقزويني الرازي، 5/8، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقى، لابن المبرد، 3/15، الناشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة أنيس الفقهاء، لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي، ص: 91؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر، وآخرون، 3/1795.

فَيَسْكُنُ قَلْبَ الْمُقَرَّرِّ لَهُ إِلَى ذَلِكَ⁽¹⁾. أو هو إخبارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ، لِلْغَيْرِ عَنْ نَفْسِهِ⁽²⁾.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:

- الشهادة اصطلاحاً: إخبارٌ صدق؛ لإثباتِ حقٍّ للغير على النفس في مجلس القضاء. (...).

- الشهادة لغة تطلق على الإقرار، ومنه قوله تعالى: "شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ". (...).

- الشهادة حجة قاصرة على الشاهد، لا يتعدى أثرها إلى غيره. (...).

السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- الشهادة لغة تطلق على: (1-الخبر القاطع. 2-الدعاء. 3-النماء).

- سميت الشهادة شهادة؛ لأنها: (1-تبين ما التَّبَسَّ، وتكشف الحق فيما اُخْتَلَفَ فيه. 2-تنشئ الحق المشهود به. 3-لأنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة).

- الإخبار في الدعوى يرجع بنفع على: (1-المخبر نفسه، أو المدعي. 2-المدعى عليه. 3-الشاه

(1) الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي، 127/2، .

(2) البناية شرح الهداية، للعيني، 428/9، ؛ فتح القدير، 318/8.

المبحث الثاني

مشروعية الشهادات، وحجيتها، وحكمها، وصفتها،
وركنها

يشمل هذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول: مشروعية الشهادات، وحجيتها

الشهادة حجة شرعية، ثبتت مشروعيتها بالكتاب، والسنة،
والإجماع، والمعقول: أولاً: الكتاب:

1- قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾⁽¹⁾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاستشهاد، وهو طلب
الشهادة، والأمر هنا للندب، فلو لم تكن الشهادة مشروعة ما
أمر الله بها، ولو على سبيل الندب⁽²⁾.

2- وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾⁽³⁾.

وجه الدلالة: حيث أمر الله تعالى أمر ندب، وإرشاد - لا
إيجاب - بالإشهاد على التبايع عند وقوعه، فدل ذلك على
مشروعية الشهادة⁽⁴⁾.

3- وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ

(1) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

(2) أحكام القرآن، لابن العربي، 332/1، تفسير القرطبي، 389/3.

(3) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

(4) أحكام القرآن، لأحمد بن علي الجصاص، 222/2.

لله ﴿١﴾.

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الأزواج بالإشهاد على الرجعة، وأمر الشهود بتأدية الشهادة قربة، خالصة، لله تعالى، فلو لم تكن الشهادة مشروعة، ما أمر بها الأزواج، ولا الشهود، وما أضافها إلى نفسه العلية (٢).

ثانياً: السنة النبوية:

1- عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةٌ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ، أَوْ يَمِينُهُ" فَقُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يَبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ؛ لَيْسَتْ حَقٌّ فِيهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ". فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. [آل عمران: 77] الآية (٣).

وجه الدلالة ألزم النبي - ﷺ - المدعي إقامة البينة، أو الشهود؛ لإثبات ما يدعيه، فإن لم يُقمها، حلف المدعي عليه، وهو أمر متفق عليه، فلو لم تكن الشهادة حجة، ما ألزم بها

(1) سورة الطلاق، جزء من الآية رقم: 2.

(2) فتح القدير، لمحمد بن علي، الشوكاني، 288/5.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، 134/3، حديث رقم: 2515؛ والنسائي في سننه الكبرى، واللفظ له، 427/5، حديث رقم: 5950.

المدعي⁽¹⁾.

2- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
- قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى
عَلَيْهِ".

وجه الدلالة: دلّ الحديث على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه
لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعي عليه،
فإن طلب يمين المدعي عليه، فله ذلك⁽²⁾. فدل على حجية
البينة، فلو لم تكن حجة، ما ألزم رسول الله ﷺ بها المدعي.
قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من
أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن البينة على المدعي، واليمين
على المدعى عليه⁽³⁾.

3- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: "أَلَا
أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا"⁽⁴⁾.
وجه الدلالة: حيث بين الحديث أن أكمل الشهداء في رتبة
الشهادة، وأكثرهم ثوابا عند الله تعالى، من عنده شهادة
لإنسان بحق، ولما يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للقرطبي، 348/1.

(2) سبل السلام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، 588/2.

(3) سنن الترمذي، 618/3، حيث رقم: 1342.

(4) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود 3/1344،

حديث رقم: 1719.

فيخبره بأنه شاهد له. أو من يسارع في أداء الشهادة بعد طلبها، لا قبله، أو من يؤدي شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى، فلو لم تكن الشهادة حجة، ما امتدح النبي - ﷺ - من سارع في تأديتها⁽¹⁾.

ثالثاً: الإجماع: أجمع أهل العلم من لدن رسول الله - ﷺ - إلى يومنا هذا على مشروعية الشهادة).

رابعاً: المعقول: أن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لحصول التجاحد بين الناس، فوجب الرجوع إليها؛ إحياء لحقوق الناس، وحفظاً للأموال على أربابها، وصوناً للعقود عن التجاحد⁽²⁾.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: -دَلِّلْ على حجية الشهادة بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، مبيناً وجه الدلالة.

السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- استدلل الفقهاء بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ على مشروعية: (1- الدعوى. 2- الشهادة. 3- الإقرار).
- استدلل الفقهاء بقوله ﷺ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ، الَّذِي

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ليحيى بن شرف النووي،

17/12..؛ نيل الأوطار، لمحمد بن علي، الشوكاني، 341/8..

(2) الاختيار لتعليل المختار، 139/2.

يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَأَّلَهَا عَلَى حُجِيَّة: (1-الأيمان. 2-
الشهادة. 3-الدعوى).

المطلب الثاني

حكم الشهادة⁽¹⁾، وصفتها تحملاً، وأداء، وركنها

أولاً: حكم الشهادة: الشهادة حجة، شرعية، تظهر الحق المدعى، ولما توجبها، لكنها تُوجِبُ⁽²⁾ على القاضي الحكم بمقتضاها، بعد تزكية الشهود، متى استوفت شرائطها. فلو امتنع عن الحكم بمقتضاها، بعد وجود شرائطها، أثم⁽³⁾؛ لتزكته الفرض. وأستحق العزل؛ لفسقه. وعزّر؛ لارتكابه ما لا يجوز شرعاً⁽⁴⁾.

دليل ذلك من المعقول: أن الشهادة عند استجماع شرائطها، تُظهر الحق، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق، قال الله تبارك

(1) المقصود بحكم الشهادة: هنا الأثر المترتب عليها.

(2) بمعنى تفرض عليه. (رد المحتار، لابن عابدين، 463/5، .

(3) ويستثنى من ذلك ثلاث حالات، يجوز فيها للقاضي أن يؤخر العمل بمقتضى الشهادة، بعد وجود شرائطها، وهي: 1- أن تكون الدعوى بين الأقرباء، فيأمل القاضي حصول الصلح بينهما. 2- أن يدعي المدعى عليه أن لديه دفعا للدعوى، ويطلب الإمهال. 3- أن يكون لدى القاضي ريب وشبهة في الشهود. (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 342/4؛ حاشية الشرنبلالي، لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي، 371/2، مطبوع مع درر الحكام شرح غرر الأحكام.

(4) رد المحتار، 463/5؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 342/4.

وتعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾⁽¹⁾. فكانت مُلْزِمة للقاضي للحكم بمقتضاها⁽²⁾.
والقياس يأبى أن تكون الشهادة حجة ملزمة للقاضي.
دليل ذلك من المعقول: أن الشهادة خبر مُحْتَمِلٌ للصدق والكذب، لكن لما شُرِطَت العدالة؛ لِيَتَرَجَّحَ جانب الصدق، ووردت النصوص بالاستشهاد، ترك القياس بالنصوص والاجماع، وجُعِلَت مُوجِبَةً للعمل بمقتضاها⁽³⁾.

ثانياً: صفة الشهادة تحملاً، وأداء

أولاً: تحمل الشهادة: تحمل الشهادة قد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وقد يكون مباحاً:
1- يكون التحمل فرض كفاية: وهذا هو الأصل في تحمل الشهادة، إذا وُجِدَ جَمْعٌ مِنَ الشُّهُودِ، مِمَّنْ هُمْ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ، فيكون التحمل في حقهم جميعاً، فرض كفاية، إذا قام به البعض، سقط الباقين عن الباقيين⁽⁴⁾.
دليل ذلك الكتاب:- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

(1) سورة ص، جزء من الآية رقم: 26.

(2) بدائع الصنائع: للكاساني، 282/6 ؛ تبیین الحقائق، 207/4.

(3) تبیین الحقائق، 207/4؛ العناية، 365/7؛ البحر الرائق 57/7 .

(4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 57/7؛ الدر المختار: للحصكفي،

ص: 483 . درر الحکام في شرح مجلة الأحكام، 342/4.

دُعُوا⁽¹⁾. وجه الدلالة: حيث نهى الله تعالى الشاهد عن الامتناع عن الشهادة، إذا دعي إليها، وهو عام يشمل التحمل، والأداء، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده، إذا كان له ضد واحد؛ لأن الانتهاء لا يكون إلا بالاشتغال به، فكان تحمل الشهادة فرضاً، مأموراً به⁽²⁾.

2- يكون التحمل فرض عين: إذا لم يكن إلا شاهدان، وكانا من أهل الشهادة، وطلب منها التحمل، فيكون التحمل في حقهما، فرض عين، يأثمان بتركه كالصلاة. أو وجدت امرأة واحدة، في الشهادة على الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، فيكون التحمل في حقها فرض عين⁽³⁾.

دليل ذلك من المعقول: أن في الامتناع عن تحمل الشهادة، بعد تعيينه، تضييع للحقوق، وهو محرم شرعاً⁽⁴⁾.

3- يكون التحمل مباحاً: إذا وجد غيره، ممن هم أهل للشهادة، وطلب منهم تحمل الشهادة، وتحملوها، فيكون الشاهد مخيراً

(1) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

(2) مفاتيح الغيب، لمحمد بن عمر بن الحسن الرازي، 96/7، تبين الحقائق، 207/4؛ مجمع الأنهر، 185/2.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 139/2؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 57/7؛ مجمع الأنهر، 185/2؛ الدر المختار، ص: 483.

(4) الاختيار لتعليل المختار، 193/2؛ مجمع الأنهر، 185/2.

بين تحمل الشهادة، والتحرز عنه⁽¹⁾.
 دليل ذلك من المعقول: - أَنَّهُ التَّزَامُ لِلْوُجُوبِ، فَهُوَ كَمَا يُوْجِبُهُ
 عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النَّذْرِ، وَغَيْرِهِ⁽²⁾.
 ثانياً: أداء الشهادة: الشهادة إما أن يكون بحق من حقوق
 العباد، وإما أن يكون بحق من حقوق الله تعالى، والشهادة
 بحقوق الله تعالى إما أن تكون بغير أسباب الحدود، وإما أن
 تكون بأسباب الحدود:

1- فإن كانت الشهادة بحق من حقوق العباد: فإن أداءها
 فرض⁽³⁾، يلزم الشهود، وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا، فَلَوْ امْتَنَعُوا،
 أَثَمُوا⁽⁴⁾. دليل ذلك الكتاب، والمعقول:

أولاً: الكتاب: - قوله تعالى: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا». -
 وقوله تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ»⁽⁵⁾. وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى الشهود عن الِامْتِنَاعِ
 عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَعَنْ كِتْمَانِهَا، عِنْدَ احْتِيَاجِ صَاحِبِ الْحَقِّ
 إِلَيْهَا، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَهْيًا عَنِ الْإِبَاءِ، وَالْكِتْمَانِ، لَكِنَّ النَّهْيَ عَنِ

(1) الاختيار لتعليل المختار، 193/2؛ مجمع الأنهر، 185/2؛ درر

الحكام في شرح مجلة الأحكام، 342/4؛

(2) الجوهرة النيرة، 224/2.

(3) سواء أكان فرض عين، أو كفاية، حسب تحمل الشاهد للشهادة.

(4) مختصر القدوري، ص: 219، ؛ بدائع الصنائع، 282/6؛ تبيين

الحقائق، 207/4؛ الجوهرة النيرة، 224/2؛ مجمع الأنهر، 185/2.

(5) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

الشَّيْءُ يَكُونُ أَمْرًا بِضَدِّهِ إِذَا كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْتِهَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاسْتِغَالِ بِهِ، فَكَانَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فَرْضًا قَطْعًا، كَفَرِيضَةِ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْكُتْمَانِ، فَصَارَ كَالْأَمْرِ بِهِ، بَلْ أَكْدُ(1).
 ثانيًا: المعقول: أَنَّ الشَّهَادَةَ أَمَانَةٌ الْمَشْهُودِ لَهُ، فِي ذِمَّةِ الشَّاهِدِ، وَتَأْدِيَةُ الْأَمَانَةِ وَاجِبٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾(2). فَكَانَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَاجِبًا(3).
 ثُمَّ إِنَّمَا يَلْزَمُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ إِذَا كَانَتْ تَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ بِالشُّرُوطِ التَّسْعَةِ الْآتِيَةِ:

- 1- طَلَبُ الْمُدَّعِي حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا. وَإِنَّمَا قُلْنَا: أَوْ حُكْمًا؛ لِيَدْخُلَ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُ الْحَقِّ، وَخَافَ فَوَتْ الْحَقِّ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا طَلَبَ(4).
- 2- أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقَاضِيَّ يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُهَا، لَا يَلْزَمُهُ(5).
- 3- أَنْ يَتَّعِنَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَتَّعِنَ، بِأَنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَادَّى غَيْرَهُ مِمَّنْ تَقْبَلُ شَهَادَتَهُ فَقَبِلَتْ لَمْ يَلْزَمُهُ(6).
- 4- أَنْ لَا يُخْبِرَ عَدْلَانِ الشَّاهِدَ بِبُطْلَانِ الْمَشْهُودِ بِهِ، فَلَوْ شَهِدَ

(1) مفاتيح الغيب، 96/7؛ تبیین الحقائق، 207/4.

(2) سورة النساء، جزء من الآية رقم: 58.

(3) بدائع الصنائع، 282/6.

(4) بدائع الصنائع، 282/6؛ البحر الرائق، 57/7.

(5) تبیین الحقائق، 207/4؛ مجمع الأنهر، 186/2.

(6) الجوهرة النيرة، 224/2؛ البحر الرائق، 58/7.

عِنْدَ الشَّاهِدِ عَدْلَانِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَبَضَ دَيْنَهُ، فَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الدَّيْنِ (1).

5- أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي الَّذِي سَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ فِي حُضُورِهِ عَادِلًا؛ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاضِي غَيْرَ عَدْلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرُدَّ شَهَادَتَهُ، فَيَتَحَمَّلُ الشَّاهِدُ الْعَارَ وَالْخَجَلَ).

6- إِذَا كَانَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الْإِقْرَارِ: أَنْ لَا يَعْلَمَ الشَّاهِدُ أَنَّ الْمُقَرَّرَ أَقْرَبُ خَوْفًا، فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ، لَا يَشْهَدُ (2).

7- أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الشَّاهِدِ قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْقَاضِي، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، بَحِيثٌ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْقَاضِي لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَيَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ (3).

8- أَنْ لَا يَخَافَ الشَّاهِدُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، فَإِنْ خَافَ الشَّاهِدُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَيَسْعَهُ الْاِمْتِنَاعُ عَنِ الشَّهَادَةِ (4)؛ لَأَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بِذَلِكَ، وَقَالَ تَعَالَى: «وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ» (5). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لَا

(1) البحر الرائق، 58/7؛ درر الحكام، 344/4.

(2) البحر الرائق، 58/7؛ درر الحكام، 344/4.

(3) تبیین الحقائق، 207/4؛ البحر الرائق، 58/7.

(4) الجوهرة النيرة، 225/2؛ درر الحكام، 345/4.

(5) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ¹.

9- أن يتذكر الشهادة على وجهها، فإن لم يتذكر الشهادة على وجهها، وسعه الامتناع عن أدائها⁽²⁾.

متى تحققت هذه الشروط، وجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة، ولا يسعه الامتناع عنها. وإن تخلفت هذه الشروط، أو تخلف بعضها، وسع الشاهد عدم الأداء من غير ذنب، أو وزر.

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "الشهادة فرض، يلزم الشهود أدائها، ولا يسعهم كتمانها، إذا طالبهم المدعي"⁽³⁾.

2- إن كانت الشهادة بحق من حقوق الله تعالى بغير أسباب الحدود، كالشهادة على هلال رمضان، وطلاق امرأة طلاقاً بائناً، والظهار، والأيلاء، والرضاع، وغير ذلك من أسباب الحرّمات، فإنه يلزم إقامة الشهادة، حسبة لله تبارك وتعالى، عند الحاجة إلى الإقامة، من غير دعوى، أو طلب من أحد من العباد⁽⁴⁾.

وسبب وجوب الشهادة في حق الله تعالى بدون طلب: أن

1 أخرجه الحاكم في المستدرک، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، 66/2، حديث رقم: 2345. وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

(2) الجوهرة النيرة، 225/2.

(3) مختصر القدوري، ص: 219.

(4) بدائع الصنائع، 282/2؛ رد المحتار ، 463/5.

حق الله تعالى وأجب على كل أحد القيام بإثباته، والشاهد من جملة من عليه ذلك، فكان قائماً بالخصومة من جهة الوجوب عليه، وشاهداً من جهة تحمل ذلك، فلم يحتج فيها إلى خصم آخر⁽¹⁾.

أما إن كانت الشهادة بحق من حقوق الله تعالى بأسباب الحدود: كالشهادة على الزنا، والسرقعة، وشرب الخمر، والقذف، فإن الشاهد مخير بين أن يؤدي الشهادة حسبة لله تعالى، وبين الستر⁽²⁾، والستر أفضل⁽³⁾⁽⁴⁾.

دليل كونه مخيراً بين إقامة الشهادة، أو الستر، من المعقول: أنه بين حسبتين: إقامة الشهادة، والتوقي عن الهتك، فإن ستر، فقد أحسن، وإن أظهر، فقد أظهر حقاً لله تعالى؛

(1) تبين الحقائق، 229/4؛ فتح القدير، 436/7؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص: 150.

(2) بشرط أن يكتمل نصاب الشهادة، فإن نقص نصاب الشهادة، بأن كانوا أقل من أربعة في الشهادة على الزنا، فلا يكون مخيراً بين الستر، والإظهار، بل يكون الستر واجباً؛ لأنها لا تكون شهادة، بل تكون قذفاً. (الجوهرة النيرة، 225/2).

(3) شريطة أن لا يكون المشهود عليه معتاداً للفاحشة، مجاهراً بها، فإن كان متظاهراً بالفاحشة، مجاهراً بها، معتاداً لها، فيجب كون إقامة الشهادة أولى من تركها. (البحر الرائق، 60/7؛ الدر المختار، 484؛ فتح الباري، لابن العسقلاني، 125/12).

(4) مختصر القدوري، ص: 219؛ بدائع الصنائع، 282/6.

فَلَذَلِكَ خَيْرٌ فِيهَا⁽¹⁾.

دليل أن الستر أفضل: السنة النبوية، والمعقول:

أولاً: السنة النبوية: قوله ﷺ: "وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةِ"⁽²⁾.

وجه الدلالة: بين الحديث أن الستر أفضل من الإظهار، لولا ذلك ما رَغِبَ رسول الله - ﷺ فيه، ووعد بالجزاء عليه في الدنيا، والآخرة.

- وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِنَ مَاعِزًا الرَّجُوعَ، وَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ سَتْرًا عَلَيْهِ؛ لَنَلَّا يَرْجَمَ، وَيُسْتَهْرَ⁽³⁾، ففيه دلالة ظاهرة على أن السَّتْرَ أَفْضَلُ، وَكَفَى بِهِ قُدُوءٌ⁽⁴⁾.

ثانياً: المعقول: أَنَّ الْإِظْهَارَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ، وَالسَّتْرُ تَرْكُ كَشْفِ الْإِدْمِي، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، فَكَانَ أَوْلَى⁽⁵⁾.

(1) الاختيار لتعليل المختار، 139/2؛ الجوهرة النيرة، 225/2.

(2) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، 2074/4، حديث رقم: 2699.

(3) رَوَى الْبُخَارِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبِلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَنْكُتَهَا". لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. (صحيح البخاري، حديث رقم: 6824).

(4) أَلَاخْتِيَارٌ لَتَعْلِيلِ الْمَخْتَارِ، 139/2؛ تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ، 208/4؛ الْبَحْرُ الرَّائِقُ، 59/7.

(5) الجوهرة النيرة، 225/2.

تلخيص: قال القدوري رحمه الله: "والشهادة في الحدود،
يخير فيها الشاهد بين الستر، والبظهار، والستر أفضل" (1).

ثالثاً: ركن الشهادة: للشهادة ركن واحد عند الحنفية، وهو
الصيغة: وهي اللفظ الخاص، الذي هو متعلق بالخبر، وهو
لفظ: (أشهد)، ما لم يأت في آخرها بما يوجب الشك، فلو قال
أشهد بكذا فيما أعلم، أو أظن، لا تقبل؛ لأن قوله فيما أعلم بعد
الخبر، موجب للشك فيه عرفاً، فيبطل.

فإن لم يأت الشاهد بلفظ الشهادة، وأتى بغيره من الألفاظ الدالة
على تحقيق الشيء، نحو قوله: أعلم، وأتقن، لم تقبل شهادته؛
لأن هذه الألفاظ لا تتضمن معنى المشاهدة، والقسم. حتى لو
قال: (شهدت)، لا تقبل شهادته؛ لأن الماضي موضوع للخبر
عماً وقعاً، والشهادة يقصد بها الخبر في الحال (2).

دليل ذلك الكتاب، والمعقول: أولاً: الكتاب:

- قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.
وجه الدلالة: أنه صريح في طلب الشهادة، فيجب عليه الإتيان
بلفظها (3).

ثانياً: المعقول: - أن النصوص ناطقة بالاستشهاد، نحو قوله

(1) مختصر القدوري، ص: 219.

(2) مختصر القدوري، ص: 219؛ بدائع الصنائع، 6/266؛ درر الحكام

371/2؛ البحر الرائق، 7/55.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 2/141.

تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ». وقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ». فَلَا يَقُومُ مَقَامُهَا غَيْرُهَا؛ لِمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ تَوْكِيدٍ⁽¹⁾.
 - وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ يَنْفِي قَبُولَ قَوْلِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْغَيْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِزَامَةِ، إِلَّا أَنَا قَبْلُنَا فِي مَوْضِعٍ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِهِ، وَأَنَّهُ وَرَدَ مَقْرُونًا بِالشَّهَادَةِ، فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ⁽²⁾.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بَيِّنْ صَحَّةَ، أَوْ خَطَأَ الْعِبَارَاتِ الْآتِيَةِ:

- الشهادة حجة، شرعية، تظهر الحق المدعى، وتوجبه. (...).
- يجوز للقاضي أن لا يحكم بمقتضى الشهادة، بعد تزكية الشهود، واستيفاء شرائطها. (...).
- القياس يدل على أن الشهادة حجة ملزمة للقاضي. (...).
- تحمل الشهادة فرض عين إذا لم يكن إلا شاهدان، وكانا من أهل الشهادة، وطلب منهما التحمل. (...).
- يلزم أداء الشهادة إذا كانت تتعلق بحقوق العباد، وإن لم يطلب ذلك المدعي. (...).
- لا يجوز للشاهد أن يمتنع عن أداء الشهادة، وإن خاف على نفسه من سلطان جائر، أو غيره. (...).

(1) الهداية: للمرغيناني، 118/3. تبين الحقائق، 210/4؛ العناية شرح الهداية، 376/7.

(2) الاختيار لتعليل المختار، 141/2.

- ستر الشهادة في الحدود أفضل، وإن كان المشهود عليه معتاداً للفاحشة، مجاهرًا بها. (...).

- أركان الشهادة عند الحنفية خمسة: شاهد. ومشهود له. ومشهود عليه. ومشهود به. وصيغة. (...).

- الشاهد: وهو من أخبر بأن ما في يد غيره له. (...).

السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- حكم تحمل الشهادة إذا وجد غيره، ممن هم أهل للشهادة، وطلب منه تحملها: (1-فرض عين. 2-فرض كفاية. 3-مباح).

- إذا وجد جمع من الشهود، ممن هم أهل للشهادة، كان تحمل الشهادة في حقهم جميعاً: (1-مباحاً. 2-فرض عين. 3-فرض كفاية).

- أداء الشهادة إذا كانت بحق من حقوق العباد، وطلب إليها الشهود: (1-سنة. 2-مباح. 3-فرض).

- إقامة الشهادة إذا كانت بحق من حقوق الله تعالى فيما سوى الحدود، كالشهادة على الطلاق البائن: (1-سنة. 2-لازم إذا طلب إليها الشهود. 3-لازم من غير دعوى، أو طلب من أحد).

- أداء الشهادة إذا كانت بحق من حقوق الله تعالى المتعلقة بالحدود: (1-فرض. 2-يخير الشاهد بين الستر والإظهار، والإظهار أفضل. يخير الشاهد بين بين الستر والإظهار،

والستر أفضل).

- قال الشاهد: أَشْهَدُ بِكَذَا فِيمَا أَعْلَمُ، أو أَظُنُّ، (1-تقبل شهادته.

2- لا تقبل شهادته. 3-تقبل إذا صدقه القاضي).

- قال الشاهد شهدتُ: (1-تقبل شهادته. 2- لا تقبل شهادته.

3-تقبل إذا صدقه القاضي).

- أركان الشهادة عند الجمهور: (1-أربعة. 2-خمسة. 3-

ثلاثة).

الفصل الثاني

شروط الشهادة

شرائط الشهادة نوعان:

النوع الأول: شروط تحمل الشهادة.

النوع الثاني: شروط صحة أداء الشهادة.

المبحث الأول

شروط تحمل الشهادة

تحمل الشاهد الشهادة معناه: علمه بالحادثة، وفهمها، وضبطها، وقت حصولها، إما بالمعاينة، أو السماع (1).

ويشترط لصحة تحمل الشهادة عند الحنفية ثلاثة شروط:

الشرط الأول: العقل: بأن يكون الشاهد مميزاً عند تحمل الشهادة. وعليه، فلا يصح تحمل الشهادة من المجنون، والصبي الذي لا يعقل، والمعتوه عتياً شديداً، والسكران، والنائم، والمغمى عليه (2)، دليل ذلك: السنة، والمعقول:

أما السنة: فعن عليّ رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ" (3).

(1) بدائع الصنائع، 6/277؛ الفقه الإسلامي : للزحيلي، 8/6030.

(2) بدائع الصنائع، 6/277.

(3) أخرجه أبو داود في سننه، 1/141، حديث رقم: 4403؛ والترمذي في سننه، 4/32، حديث رقم: 1423.

وأما المعقول: فلأنَّ تَحْمَلَ الشَّهَادَةَ عِبَارَةٌ عَنْ فَهْمِ الْحَادِثَةِ، وَضَبْطِهَا، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَلَةِ الْفَهْمِ وَالضَّبْطِ، وَهِيَ الْعَقْلُ، فَإِذَا لَمْ يَوْجَدْ، لَمْ يَحْصُلْ فَهْمُ الْحَادِثَةِ، فَلَا يَصِحُّ التَّحْمَلُ (1).

الشرط الثاني: البصر: أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا وَقَدْ تَحْمَلَ. وعليه: فَلَا يَصِحُّ تَحْمَلُ الشَّهَادَةِ مِنَ الْأَعْمَى، سَوَاءَ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ دَيْنًا، أَوْ عَيْنًا، عَقَارًا، أَوْ مَنْقُولًا. وَسَوَاءَ كَانَتْ الشَّهَادَةُ بَحْدٍّ، أَوْ قِصَاصٍ، أَمْ لَأٍ، وَسَوَاءَ فِيمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ، وَالتَّاسْتَفَاضَةِ، وَالشَّهْرَةِ: كَالنَّسَبِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْمَوْتِ، أَمْ لَأٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (2).

وقال أبو يوسف، وزفر، وهو رَوَايَةُ ابْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ تَحْمَلُ الْأَعْمَى لِلشَّهَادَةِ، فِيمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ، وَالتَّاسْتَفَاضَةِ، وَالشَّهْرَةِ: كَالنَّسَبِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْمَوْتِ (3).

دليل الإمام أبي يوسف، وزفر، المعقول: - أَنَّ ذَلِكَ أَيْ مَا يَجْرِي فِيهِ بِالتَّسَامُعِ مِمَّا يَقَعُ بِالتَّاسْتَفَاضَةِ، وَالتَّسَامُعِ، وَالشَّهْرَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى نَظَرٍ، وَمَعَايِنَةٍ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى

(1) بدائع الصنائع، 277/6؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص: 151.

(2) بدائع الصنائع، 266/6؛ الهداية شرح بداية المبتدي، 121/3؛ الاختيار لتعليل المختار، 146/2.

(3) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ الاختيار لتعليل المختار، 146/2؛ تبين الحقائق، 218/4، 217؛ .

السَّمَاعُ، والأَعْمَى يساوي البصير في السماع؛ إذ لا خلل في سماعه، فصَحَّ تحمله (1).

ونَوْقَشَ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ، لَا تُقْبَلُ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ التَّسَامُعُ، كَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ (2).

دليل الطرفين (أبو يوسف، وزفر) السنة، والمعقول:

أولاً: السنة: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: "هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" (3).

وجه الدلالة: جعل رسول الله - ﷺ - مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ - تحملاً وأداءً - مُعَايِنَةَ الشَّاهِدِ لِمَا شَهِدَ بِهِ، وَالْأَعْمَى لَا يُعَايِنُ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، لَا تحملاً، وَلَا أداءً (4).

-عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاحِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمْ يُجْزِ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ" (5). وفي رواية: أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

(1) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ تبیین الحقائق، 218/4؛ العناية

شرح الهداية، 398/7؛ الجوهرة النيرة، 229/2.

(2) العناية شرح الهداية، 398/7.

(3) أخرجه البيهقي في الشعب، 349/13، حديث رقم: 10469؛ وأبو

نعيم في الحلية، 18/4. قال: "غريب من حديث طاووس، تفرد به عبيد الله بن سلمة عن أبيه".

(4) أحكام القرآن، للجصاص، 227/2.

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، 324/8، حديث رقم: 15380.

طَالِب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَعْمَى، فَقَالَتْ أَخْتُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ:
إِنَّهُ أَعْمَى، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَرَدَّ
شَهَادَتَهُ⁽¹⁾.

وجه الدلالة: أن علياً عليه السلام ردَّ شهادة الأعمى، ولم يستفسر أنه
وَقْتَ التَّحْمَلِ كَانَ بَصِيرًا، أَوْ أَعْمَى، فدل أن الحكم لا يختلف.
وفي هذا الحديث دليل أن ذلك معروفاً بينهم؛ حتى لم يخفَ
على النساء (2).

ثانياً: المعقول: أنه لا بد للشاهد عند تحمل الشهادة، أن يعرف
الخصمين، ويميز بينهما؛ حتى يشهد لأحدهما على الآخر،
ومن لم يكن بصيراً وقت التحمل، لم يتمكن من معرفة
الخصمين، أو التمييز بينهما، والسمع وحده لا يكفي للمعرفة،
أو التمييز؛ لأنَّ النِّعَمَاتِ يُشَبِّهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، والأصوات يعدل
بعضها بعضاً، وكم سمعنا من أصوات، ظنناها أصوات أناس
نعرفهم، فإذا بها أصوات آخرين، فلو جوزنا للشاهد الأعمى
أن يتحمل الشهادة بالسماع، لعرضنا حقوق الناس للسلب،
والضياع، وفي هذا خطر كبير (3).

1 المبسوط، للسرخسي، 129/16.

(2) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ المحيط البرهاني في الفقه النعماني،
لمحمود بن عمر بن مازة، البخاري، 323/8.

(3) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ بدائع الصنائع، 266/6؛ درر
الحكام في شرح مجلة الأحكام، 356/4؛ الأصول القضائية في المرافعات
الشرعية، ص: 151.

والراجح من هذين القولين: هو قول الطرفين؛ لقوة أدلته، ووجهاتها. ولأن الشاهد مأخوذٌ عليه بأن يأتي بلفظ الشهادة، ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة، بأن قال: أعلم، أو أتيقن، لم تقبل شهادته، فعلمنا أنها مخصوصة بهذا اللفظ، وهذا اللفظ يقتضي مشاهدة المشهود به، ومعاينته، فلم تجز شهادة من خرج من هذا الحد، وشهد عن غير مشاهدة، ومعاينة (1).

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا تقبل شهادة الأعمى" (2).

الشرط الثالث: أن يكون التَّحْمَلُ بِمُعَايَنَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ بِنَفْسِهِ، أو دليله، لا بغيره، إلّا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتّسامع من الناس، وإن لم يعاين المشهود به بنفسه، أو دليله، وهي: النّكاح، والنسب، والموت، فله تحمل الشهادة فيها بالتّسامع من الناس، وإن لم يعاين بنفسه؛ لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة. فلو شهد العرس، والزفاف، يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنه دليل النكاح. وكذا في الموت، إذا شهد جنازة رجل، أو دفنه، حلّ له أن يشهد بموته (3).

(1) أحكام القرآن، للجصاص، 227/2.

(2) مختصر القدوري، ص: 220.

(3) بدائع الصنائع، 266/6؛ البحر الرائق، 56/7؛ الفتاوى الهندية، للجنة

علماء، برئاسة نظام الدين البلخي، 450/3، الناشر: دار الفكر، الطبعة

فمثال معاينة المشهود به بنفسه: أن يرى الشاهد إنساناً باع بيته لآخر، بإيجاب وقبول شرعيين، فيشهد بالبيع. أو قتل غيره بسلاح حتى فارق الحياة، فيشهد بالقتل، وهكذا في كل حادثة تكون بمرأى، ومسمع من الشاهد⁽¹⁾.

ومثال معاينة دليل الشيء: كأن يرى ثوباً، أو دابة، أو سيارة، أو داراً في يد إنسان، يستعملها استعمال الملاك، من غير منازع، ووقع في قلبه أنه له، حتى لو خاصمه غيره فيه، يحل له أن يشهد بالملك لصاحب اليد؛ لأنه وإن لم يشاهد سبب الملك، وهو الشراء، أو الميراث، أو الهبة، إلا أنه شاهد لدليله، وهو التصرف المذكور، ودليل الشيء يقوم مقامه⁽²⁾.

دليل هذا الشرط: الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب: - قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»⁽³⁾. وقوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا»⁽⁴⁾.

وجه الدلالة: حيث شرط الله تعالى في الشاهد لصحة شهادته، أن يكون عالماً بالمشهود به، والعلم بالمشهود به، إنما يكون بمعاينة المشهود به بنفسه، أو دليله⁽¹⁾.

الثانية، 1310هـ؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص: 151، 152.

(1) الأصول القضائية في المرافعات الشرعية، ص: 152.

(2) بدائع الصنائع، 267/6.

(3) سورة الزخرف، جزء من الآية رقم: 86.

(4) سورة يوسف، جزء من الآية رقم: 81.

ثانيًا: السنة: - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: "هل ترى الشمس؟" قال: نعم، قال: "فعلَى مثلها فاشهد، أو دَع" (2).

وجه الدلالة: حيث جعل رسول الله ﷺ من شرط صحة الشهادة - تحملاً وأداءً - أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به، كما يعلم الشمس، ولما يعلم مثل الشمس إلا بمعاينة المشهود به بنفسه، أو دليله (3).

ثالثًا: المعقول: أن الشاهد يعلم القاضي حقيقة الحال، ويميز الصادق المخبر، من الكاذب، ولما يتحقق ذلك منه إذا لم يعلم به، وطريق العلم، المعاينة، إذا كان المشهود به مما يعاين، والسمع، إذا كان ذلك مما يسمع، كإقرار المقر (4).

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه، إلا النسب، والموت، والنكاح، والدخول، وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء، إذا أخبره بها من يثق به" (5).

(1) أحكام القرآن، للجصاص، 247/2.

(2) سبق تخريجه، ص:.

(3) بدائع الصنائع، 266/6؛ تبیین الحقائق، 214/4؛ أحكام القرآن، للجصاص، 227/2.

(4) المبسوط، للمرخسي، 116/16.

(5) مختصر القدوري، ص/221.

وَأَمَّا الْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْعَدَالَةُ، فَلَيْسَتْ مِنْ شَرَائِطِ التَّحْمَلِ، بَلْ مِنْ شَرَائِطِ الْأَدَاءِ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَقْتُ التَّحْمَلِ صَبِيًّا عَاقِلًا، أَوْ مُمِيزًا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ فَاسِقًا، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيَّ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ، فَشَهِدُوا عِنْدَ الْقَاضِي، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ⁽¹⁾.

المبحث الثاني

شروط صحة أداء الشهادة العامة التي ترجع إلى الشاهد
اشتراط الفقهاء في الشاهد حتى تقبل شهادته، أحد عشر شرطًا، بيانها فيما يأتي:

الشرط الأول: العقل: أن يكون الشاهد عاقلًا عند أداء الشهادة، فلا تقبل شهادة غير العاقل اتفاقًا⁽²⁾، كالمجنون حال جنونه، أو المعتوه عتوها شديدًا، أو الصبي غير المميز، أو المبرسم⁽³⁾،

(1) بدائع الصنائع، 266/6؛ البحر الرائق، 56/7؛ الفتاوى الهندية، 450/3.

(2) بدائع الصنائع، 267/6؛ القوانين الفقهية، لمحمد بن أحمد، ابن جزي، الكلبي، الغرناطي، ص: 202؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي: للعمري، 275/13، ؛ المغني، لابن قدامة المقدسي، 144/10؛ الإجماع، لابن المنذر، ص: 68.

(3) المبرسم: المصاب بعلة البرسام، والبرسام بكسر الباء: وجع يحدث في الدماغ، يذهب منه عقل الإنسان، وكثيرا ما يهلك. (طلبة الطلبة، ص: 124).

أو السكران، أو النائم، أو المغمى عليه⁽¹⁾. دليل ذلك: الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب: - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾⁽²⁾. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الشاهد أن لا يكتُم الشهادة، والخطاب إنما يكون للمكلف، وغير العاقل، ليس مكلفاً، فلا يكون أهلاً لأداء الشهادة.

ثانياً: السنة: عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"⁽³⁾.

وجه الدلالة: بين الحديث أن المجنون، غير مكلف، ولا حكم لقوله، فلا تقبل شهادته.

ثالثاً: المعقول، وذلك من وجوه: - أَنَّ مَنْ لَا يَعْقِلُ، لَا يَعْرِفُ الشَّهَادَةَ، فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى أدائها⁽⁴⁾.

- وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوَلَايَةِ؛ فَفِيهَا مَعْنَى الْإِزَامِ الْغَيْرِ، وَغَيْرِ الْعَاقِلِ لَا وَلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَبِطَرِيقِ الْأَوَّلَى أَنَّ لَا تَكُونُ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَى الْغَيْرِ⁽¹⁾.

(1) لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأحمد بن محمد بن محمد، ابن الشحنة النقي الحلي، ص: 245، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 7/78؛ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 4/357، 356.

(2) سبق عزو الآية الكريمة، ص: .

(3) سبق تخريجه، ص: .

(4) بدائع الصنائع، 6/267.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:

-العقل شرط لتحمل، وأداء الشهادة، باتفاق الفقهاء. (...).

- السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- أدى الشهادة حال عقله، وَقَبْلَ أَنْ يَحْكَمَ الْقَاضِي بِشهادته، طَرَأَ عَلَيْهِ جنون في الحال، فلا تقبل شهادته عند الإمام: (1- زفر. 2-أبي يوسف. 3-أبي حنيفة، ومحمد).

الشرط الثاني: البلوغ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ غير البالغ بحال، لا على بالغ، أو صبي، وإليه ذهب الحنفية، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المشهور من المذهب، والظاهرية⁽²⁾. دليل ذلك: الكتاب، والسنة، والمعقول: أولاً: الكتاب:

-قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾⁽³⁾. وجه الدلالة من وجهين:

(1) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 357/4.

(2) بدائع الصنائع، 267/6؛ التبصرة، لعلي بن محمد الربيعي، المعروف بالخمعي، 5435/11، الحاوي الكبير، للماوردي، 60/17، المغني، 144/10؛ المحلى بالآثار، لعلي بن أحمد بن سعيد، بن حزم الظاهري، 513/8.

(3) سبق عزو الآية الكريمة، ص:

الأول: أن الله تعالى أمرنا أن نُشهد شاهدين من رجالنا،
والصبي ليس من رجالنا، فلا تقبل شهادته.

الثاني: أنه لما عدل عن الرجلين، إلى أن قال: «فَرَجُلٌ
وامرأتان»، دلّ على أنه لا يُعدّل إلى غيرهم من الصبيان⁽¹⁾.
قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ». وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا أن
نشهد من يرضى، والصبي ممن لا يرضى⁽²⁾. قوله تعالى:
«وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ».

وجه الدلالة: أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم،
والصبي لا يَأْتِم، فيدلّ على أنه ليس بشاهد⁽³⁾.

ثانياً: السنة: عن عليٍّ عليه السلام عن النبي ﷺ قال: «رَفَعَ الْقَلَمُ
عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ». وجه الدلالة: بين الحديث أن
الصبي، غير مكلف، ولا حكم لقوله، فلا تقبل شهادته.

ثالثاً: المعقول: وذلك من وجوه: - أن الشهادة فيها معنى
الولاية، والصبي مولى عليه، فلا ولاية له على غيره، من باب
أولى⁽⁴⁾. - ولأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ، والتحفظ

(1) الجامع لأحكام القرآن، 3/389؛ أحكام القرآن: للجصاص، 2/225.

(2) تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم، 2/561.

(3) أحكام القرآن، للجصاص، 2/225؛ المغني، 10/145.

(4) بدائع الصنائع، 6/267.

بِالتَّذَكُّرِ، وَالتَّذَكُّرُ بِالتَّفَكُّرِ، وَلَا يُوجَدُ مِنَ الصَّبِيِّ عَادَةٌ⁽¹⁾.
 - وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ شَهَادَةٌ، لَلَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ عِنْدَ الدَّعْوَةِ؛ لِلْأَيَّةِ
 الْكَرِيمَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»⁽²⁾.
 أَيِ دُعُوا لِلْأَدَاءِ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ إِجْمَاعًا⁽³⁾.
 - وَلِأَنَّهُ لَمْ يَجْزَ أَنْ يَلْحَقَهُ ضَمَانٌ بِالرُّجُوعِ، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ
 مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ شَهَادَتُهُ، لَزِمَهُ الضَّمَانُ
 عِنْدَ الرُّجُوعِ عَنْهَا⁽⁴⁾.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:

- البلوغ شرط لتحمل الشهادة، وأدائها، عند الحنفية. (...).
 - ذهب جمهور الفقهاء إلى قبول شهادة الصبيان بعضهم على
 بعض في القتل، والجراح، للضرورة. (...).

السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات
 الآتية:

- لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغِ بِحَالٍ، لَا عَلَى بَالِغٍ، أَوْ
 صَبِيٍّ، وَلَا فِي قَلِيلٍ، وَلَا كَثِيرٍ مِنْ مَالٍ، وَلَا فِي قَتْلِ، أَوْ
 جَرَّاحٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ (1-المالكية. 2-الحنابلة في غير

(1) بدائع الصنائع، 267/6.

(2) سبق عزو الآية الكريمة، ص:.

(3) بدائع الصنائع، 267/6.

(4) أحكام القرآن، للجصاص، 226/2.

المشهور. 3- الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور من المذهب).

لو تحمل الشهادة صبي مميز، وأداها بعد البلوغ: (1- لا تقبل شهادته مطلقاً. 2- تقبل شهادته مطلقاً. 3- لا تقبل شهادته إلا في القتل والجراح؛ للضرورة).

الشرط الثالث: الحرية، فلا تقبل شهادة العبد⁽¹⁾ على الأحرار، أو العبد، في كثير المال، أو قليله، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في رواية⁽²⁾. دليل ذلك: الكتاب، والأثر، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»⁽³⁾. وجه الدلالة: حيث نفت الآية الكريمة حكم أقوال العبد، وعقوده وتصرفه، وبينت أنه لا يملك شيئاً، والشهادة شيء، فلا يقدر على أدائها، بظاهر الآية الكريمة⁽⁴⁾.
قوله تعالى: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ». وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا أن نشهد من نرضى من الشهداء، والذي

(1) سواء أكان عبداً خالصاً، أو مكاتباً، أو مديراً. وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة. وعندهما تقبل شهادته؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده. وعندهما بمنزلة حر عليه دين. (بدائع الصنائع، 6/268).

(2) الاختيار لتعليل المختار، 2/141؛ المدونة للإمام مالك 4/541؛ الحاوي الكبير، 17/58؛ الإنصاف، 29/397.

(3) سورة النحل، جزء من الآية رقم: 75.

(4) أحكام القرآن، للجصاص، 2/223؛ بدائع الصنائع، 6/267.

نرضى أحرارنا، لا ممالكنا، الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم، فدلّت الآية الكريمة على عدم قبول شهادتهم⁽¹⁾.

ثانياً: الأثر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ"⁽²⁾. وجه الدلالة: بين الأثر أن شهادة العبد، لا تقبل، ومثله لا يقال بالرأي.

ثالثاً: القياس: أَنَّ الشَّهَادَةَ فَرَضٌ عَلَى الْكُفَايَةِ كَالْجِهَادِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِالْجِهَادِ، وَلَوْ حَضَرَهُ وَقَاتَلَ، لَمْ يُسَمَّ لَهُ، وَجِبَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ بِالشَّهَادَةِ، وَمَتَى شَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ⁽³⁾.

— أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث، فقال في الشهادة: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»⁽⁴⁾. وقال في الميراث: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»⁽⁵⁾. ثم لا حظ للعبيد في الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم في الشهادة⁽⁶⁾.

رابعاً: المعقول: — أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ شَهَادَةٌ، لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِابَةُ، إِذَا دُعِيَ لِأَدَائِهَا؛ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَلَا يَجِبُ؛ لِقِيَامِ حَقِّ

(1) تفسير الإمام الشافعي، 810/2، فتح القدير، للشوكاني، 349/1.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 293/4، حديث رقم: 20286.

(3) أحكام القرآن، للجصاص، 224/2.

(4) سبق عزو الآية الكريمة، ص:.

(5) سورة النساء، جزء من الآية رقم: 11.

(6) تفسير الماتريدي، 284/2.

المَوْلَى (1).

- وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الشَّهَادَةِ ضَمَانٌ مَعْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ بِإِزَاءٍ مِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ؛ فَدَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ (2).

تلخيص: قال القدوري رحمه الله: "ولما تقبل شهادة الأعمى، ولما المملوك" (3).

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:

- استدل الفقهاء بقوله - ﷺ: "رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ". على عدم قبول شهادة العبد. (...).
- استدل الفقهاء بقوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ». على قبول شهادة العبد. (...).
- لو تحمل الشهادة عبد، ثم أعتق، قبلت شهادته. (...).
- حرية الشاهد شرط للتحمل وأداء الشهادة. (...).

الشرط الرابع: البصر: أن يكون الشاهد بصيراً عند أداء الشهادة، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى، سَوَاءً كَانَ بَصِيرًا وَقَبْلَ

(1) بدائع الصنائع، 6/268؛ الجوهرة النيرة، 2/229.

(2) الجوهرة النيرة، 2/229؛ تفسير الماتريدي، 2/284.

(3) مختصر القدوري، ص: 220.

التَّحْمَلِ، أَوْ لَنَا، وسواء أكانت الشهادة على فعل، أو إقرار. وهذا شرط عند الإمام أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله تعالى⁽¹⁾. وقال أبو يوسف: بصر الشاهد عند الأداء ليس شرطاً، فتقبل شهادة الأعمى إذا كان بصيراً وقت التحمل، ما لم يكن المشهود به شيئاً منقولاً⁽²⁾، يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء. فإن كان المشهود به، شيئاً منقولاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فلا تقبل شهادته باتفاق الحنفية⁽³⁾.

دليل أبي يوسف: الكتاب، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ». وجه الدلالة: قال الإمام القرطبي: وقوله: «مِنْ رِجَالِكُمْ» دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة، لكن إذا علم يقيناً⁽⁴⁾. ونوقش وجه الاستدلال: بأن ظاهر الآية يدل على أن الأعمى غير مقبول الشهادة؛ لأنه قال: "وَأَسْتَشْهِدُوا". والأعمى لا يصح استشهاده؛ لأن الاستشهاد هو إحضار المشهود عليه، ومعاينته إياه، وهو غير معاين، ولنا مشاهد لمن يحضره؛ لأن العمى

(1) الأصل، لمحمد بن الحسن الشيباني، 472/4؛ بدائع الصنائع،

268/6؛ المحيط البرهاني، 323/8، 322.

(2) بأن كان عقاراً، أو ديناً. (المحيط البرهاني، 322/8).

(3) بدائع الصنائع، 268/6؛ المحيط البرهاني، 323/8.

(4) الجامع لأحكام القرآن، 390/3؛ وينظر: أحكام القرآن، للجصاص،

228/2؛ أحكام القرآن، لابن العربي، 333/1.

حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ⁽¹⁾.

ثانيًا: القياس: أن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، ولا تمنع قبول الشهادة، كالصمم، أو فقد اليدين، أو الرجلين⁽²⁾.

ثالثًا: المعقول: أن اشتراط البصر ليس لعينه، بل لحصول العلم بالمشهود به، وإذا حصل إذا كان بصيرًا وقت الحمل، والأداء إنما يكون بالقول، ولا خلل في القول، فتقبل شهادته⁽³⁾.

دليل الإمام أبي حنيفة، ومحمد: السنة، والقياس، والمعقول:

أولًا: السنة: ما روي أن عليًا، لم يجز شهادة أعمى في سرقة⁽⁴⁾. وجه الدلالة: أن عليًا رضي الله عنه ردّ شهادة الأعمى، ولم يستفسر أنه وقت الحمل كان بصيرًا، أو أعمى، فدل أن الحكم لا يختلف. وفي هذا الحديث دليل أن ذلك معروفًا بينهم؛ حتى لم يخف على النساء⁽⁴⁾.

ثانيًا: القياس: - أن العمى يمنع الحمل، فيمنع الأداء، كالجنون؛ لأن حالة الأداء أكد، وأظهر، من حالة الحمل؛ بدليل أن الحمل يصح في حال لا يصح فيه الأداء، مثل أن يكون فاسقًا، أو عبدًا، أو صبيًا، وقت الحمل، فإن تحمله صحيح، فإذا كان العمى يمنع الحمل، فأولى، وأحرى أن

(1) أحكام القرآن، للجصاص، 228/2.

(2) بتصرف: المبسوط، للسرخسي، 129/16.

(3) بدائع الصنائع، 6/268؛ العناية شرح الهداية، 7/398.

(4) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ المحيط البرهاني، 8/323.

يَمْنَعُ الْأَدَاءَ⁽¹⁾.

- أنه لو استشهد به وبينه حائل، لما صحت شهادته، وكذلك لو أداها وبينهما حائل، لم تجز شهادته، والعمى حائل بينه وبين المشهود عليه، فوجب أن لا تجوز⁽²⁾.

ثالثاً: المعقول: - أن الشاهد عند أداء الشهادة يحتاج إلى التمييز بين المشهود له □ والمشهود عليه، والإشارة إليهما، وإلى المشهود به، فيما يجب إحصاءه، وقد عدم آلة التمييز حقيقة؛ لأن العمى لا يميز بين الناس إلا بالصوت والنعمة، فيخشى عليه التأقن من الخصم؛ إذ النعمة تشبه النعمة، فتتمكن من شهادته شبهة، يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، وذلك مانع من قبول الشهادة⁽³⁾.

- أن العمى يشهد عن اجتهاد، وغلبة رأي، لا عن حقيقة علم، فذلك إذا شهد بعد ما عمى، فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودة، وهي أنه يؤديها باستدلال، وغلبة رأي⁽⁴⁾.

ولو أدى الشهادة عند الحاكم وهو بصير، ثم عمى قبل الحكم بها، بطلت شهادته، ولم يجز للحاكم أن يقضي بها عند أبي

(1) شرح مختصر الطحاوي، للجصاص، 58/8، الجوهرة النيرة، 229/2.

(2) شرح مختصر الطحاوي، 58/8؛ المحيط البرهاني، 322/8.

(3) المبسوط، للسرخسي، 129/16؛ بدائع الصنائع، 268/6.

(4) شرح مختصر الطحاوي، 58/8؛

حنيفة، ومحمد⁽¹⁾.

وقال أبو يوسف: لا تبطل شهادته، ويقضي بها القاضي⁽²⁾.

دليل الإمام أبي حنيفة، ومحمد: المعقول: أَنَّ قِيَامَ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ شَرْطٌ وَقْتَ الْقَضَاءِ؛ لَصَيَرُورَةِ الشَّهَادَةِ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُرَادُّ لِلْقَضَاءِ، فَمَا يَمْنَعُ الْأَدَاءَ، يَمْنَعُ الْقَضَاءَ، وَالْعَمَى، وَالْخَرَسَ، وَالْجُنُونَ، وَالْفِسْقَ، يَمْنَعُ الْأَدَاءَ، فَيَمْنَعُ الْقَضَاءَ⁽³⁾.

دليل الإمام أبي يوسف: القياس: أَنَّ الْعَمَى حَالَةٌ قَدْ طَرَأَتْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ، فَلَا تَمْنَعُ الْحُكْمَ، كَمَا لَوْ مَاتَ الشَّاهِدُ، أَوْ غَابَ بَعْدَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَقَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَلَا تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ⁽⁴⁾.

ولو تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ وَهُوَ بَصِيرٌ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ عَمَى، ثُمَّ أَصْبَحَ بَصِيرًا، تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ بَصِيرًا، إِذَا كَانَ عَادِلًا⁽⁵⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "ولا تقبل شهادة الأعمى"⁽⁶⁾.

(1) الجوهرة النيرة، 229/2، فتح القدير، 399/7.

(2) فتح القدير، 399/7؛ درر الحكام، 357/4.

(3) العناية 399/7؛ فتح القدير، 399/7؛ درر الحكام 357/4.

(4) فتح القدير، 399/7؛ درر الحكام، 357/4.

(5) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 357/4.

(6) مختصر القدوري، ص: 220.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:

- لا تقبل شهادة الأعمى إذا كان المشهود به، شيئاً منقولاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، باتفاق الحنفية. (...).
- ذهب الإمام أبو يوسف إلى قبول شهادة الأعمى، سواء كان بصيراً وقت التحمل، أو لا. (...).
- لو تحمل الشهادة وهو بصير، ثم طرأ عليه عمى، ثم أصبح بصيراً، لا تقبل شهادته بعد أن يصبح بصيراً. (...).
- ذهب الإمام أبو يوسف إلى قبول شهادة الأعمى إذا كان بصيراً وقت التحمل، ولو كان المشهود به شيئاً منقولاً، يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء. (...).

السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- لا تقبل شهادة الأعمى، سواء كان بصيراً وقت التحمل، أو لا، عند الإمام: (1-أبي يوسف. 2-الحسن بن زياد. 3-أبي حنيفة ومحمد).

- ولو أدى الشهادة عند الحاكم وهو بصير، ثم عمى قبل الحكم بها، بطلت شهادته، ولم يجر للحاكم أن يقضي بها عند الإمام: (1-أبي يوسف. 2-الشافعي. 3-أبي حنيفة ومحمد).

- استدل من قال بقبول شهادة الأعمى متى كان بصيراً عند التحمل بقوله تعالى: 1- (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). 2- «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ». 3- «وَأَسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ».

— روى عبد الرزاق في المصنف، أن علياً، لَمْ يُجْزِ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ. استدل الحنفية بهذا الأثر على: (1-عدم قبول شهادة العبد. 2-عدم قبول شهادة الأعمى. 3-عدم قبول شهادة الأخرس).

الشرط الخامس: النطق: وهو شرط للأداء، لا للتحمل، فيشترط في الشاهد عند أداء الشهادة أن يكون قادراً على الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس، ولو بالإشارة المفهومة، أو الكتابة، وهو محل اتفاق عند الحنفية⁽¹⁾. دليل ذلك: الكتاب، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ». وجه الدلالة: أن الله تعالى أمرنا أن نُشْهِدَ مَنْ يَرْضَى مِنَ الشُّهَدَاءِ، والأخرس ليس مرضياً على الإطلاق، فلا تقبل شهادته.

ثانياً: القياس: أن إشارة الأخرس محتملة، فلا تصح الشهادة بها، كاللفظ المحتمل، نحو قول الشاهد: أعلم، أو أوقن⁽²⁾.

ثالثاً: المعقول: — أن شهادة الأخرس مشتبّهة؛ فَإِنَّهُ يَسْتَدِلُّ بِإِشَارَتِهِ عَلَى مُرَادِهِ، بِطَرِيقٍ غَيْرِ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ، فَتَتِمَّكُنْ فِي شَهَادَتِهِ تَهْمَةٌ، يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ.

(1) الأصل، للشيباني، 511/11؛ المبسوط، للسرخسي، 130/16؛

البحر الرائق، 77/7؛ درر، 356/4.

(2) التجريد، 5194/10.

- ولأنَّ مُرَاعَاةَ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ شَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا، حَتَّى لَوْ قَالَ الشَّاهِدُ: أَخْبِرْ، وَأَعْلَمْ، لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ لَا يَتَحَقَّقُ مِنَ الْآخِرَسِ، بَلْ لَا عِبَارَةَ لَهُ أَصْلًا، فَلَا شَهَادَةَ لَهُ⁽¹⁾.
أما الْأَصْمُ⁽²⁾: فَتَقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَمِّمَهُ بِدَرَجَةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا سَمَاعَ شَيْءٍ. فَلَوْ قَالَ الْأَصْمُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى إِقْرَارٍ: إِنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقْرَبَ بِصَوْتِ عَالٍ، تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ⁽³⁾.

نموذج الأسئلة

السؤال الأول: بين صحة، أو خطأ العبارات الآتية:
- استدلَّ الفقهاء بقوله تعالى: "مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ" على عدم قبول شهادة الآخرس. (...).
- النطق شرط لتحمل، وأداء الشهادة عند الحنفية. (...).
- تحمل الشهادة وهو ناطق، ثم طرأ عليه بكم، أو خرس، فلا تقبل شهادته الحنفية. (...).
السؤال الثاني: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية:

- لا تقبل شهادة الآخرس، ولو بالإشارة المفهمة، أو الكتابة، عند: (1- المالكية. 2- الظاهرية. 3- الحنفية).

(1) المبسوط، للسرخسي، 130/16؛ بدائع الصنائع، 6/268.
(2) الأصم: الذي لا يسمع من كل الحيوان: لابن الأثير، 3/53 المغرب في ترتيب المغرب، للخوارزمي، المطرزي، ص: 272 .
(3) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 356/4.

-شهادة الأصم: (1-لا تقبل مطلقاً. 2-تقبل مطلقاً. تقبل ما لم يكن صممه بدرجة لا يستطيع معها سماع شيء).
 الشرط السادس: الإسلام: وهو شرط للأداء، دون التحمل، فيشترط في الشاهد عند أداء الشهادة أن يكون مسلماً، إذا كان المشهود عليه مسلماً، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، ولأجله، في غير الوصية في السفر، باتفاق الفقهاء⁽¹⁾. دليل ذلك: الكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب: -قوله تعالى: «مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ». وجه الدلالة: أن الله تعالى أن نشهد المرضي من الشهداء، والكافر ليس مرضياً عند المسلمين، فلا تقبل شهادته عليهم⁽²⁾، وقوله تعالى: «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ». وجه الدلالة: من وجهين:

الأول: أن الله تعالى أمرنا أن نشهد شهيدين من رجالنا، والكفار ليسوا من رجالنا، فلا تقبل شهادتهم على المسلمين. لذا قال القرطبي: "قَوْلُهُ تَعَالَى: «مِنْ رِجَالِكُمْ». نَصٌّ فِي رَفْضِ الْكُفَّارِ وَالصَّبْيَانِ". وقال البيضاوي: «مِنْ رِجَالِكُمْ». من رجال

(1) بدائع الصنائع، 280/6؛ البحر الرائق، 57/7؛ الجامع لمسائل المدونة، للصقلي، 397/17، الحاوي الكبير، 61/17؛ المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، 301/3.

(2) المبسوط، للسرخسي، 134/16؛ تبیین الحقائق، 224/4.

المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود⁽¹⁾.
 الثاني: لما كَانَ ابْتِدَاءُ الْخُطَابِ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ: «يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ». ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ». اقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ الْإِيمَانِ
 شَرْطًا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ⁽²⁾.

-قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ»⁽³⁾. وجه الدلالة:
 أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِإِشْهَادِ الْعَدُولِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ
 بِذِي عَدْلٍ، وَلَا هُوَ مِنَّا، فَلَا تَقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْنَا⁽⁴⁾.

ثانيًا: السنة: - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «لَا تَرِثُ مِلَّةُ مَلَّةٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَلَّةٍ عَلَى مَلَّةٍ، إِلَّا
 شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ»⁽⁵⁾. وجه
 الدلالة: أَنَّ النَّبِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَفَى قَبُولَ شَهَادَةِ مَلَّةٍ عَلَى مَلَّةٍ،
 وَأَثْبَتَ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ الْمِلَلِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو، وَلَا
 يَعْلى عَلَيْهِ.

القياس: - أَنَّ الْفَاسِقَ الْمُسْلِمَ، أَكْمَلُ مِنَ الْكَافِرِ الْعَدْلِ، لِصِحَّةِ

(1) الجامع لأحكام القرآن، 389/3.

(2) أحكام القرآن، للجصاص، 222/2، 221.

(3) سبق عزو الآية الكريمة، ص:

(4) فتح القدير، 417/7؛ الكافي في فقه الإمام أحمد، 217/4؛ المغني،
 167/10.

(5) أخرجه البيهقي في سننه لكبرى، 275/10، حديث رقم: 20617؛
 والطبراني في الأوسط، 323/5، حديث رقم: 5434.

الْعِبَادَاتِ مِنَ الْفَاسِقِ، وَاسْتَحْقَاقِ الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِنَ الْكَافِرِ، ثُمَّ كَانَ الْفَسِقُ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، فَكَانَ الْكَفَرُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَانِعًا مِنْهَا⁽¹⁾.

المعقول: - أَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا مَعْنَى الْوِلَايَةِ، وَهُوَ تَفْهِيمُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ، وَلَا وِلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُ عَلَيْهِ⁽²⁾.

- وَلِأَنَّ تَغْيِظَ الْكَافِرِ بِقَهْرِ الْمُسْلِمِ إِيَّاهُ، يَحْمِلُهُ عَلَى التَّقَوُّلِ عَلَيْهِ، فَكَانَ مَتَهُمَا فِي شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ، فَلَا تَقْبُلُ شَهَادَتَهُ⁽³⁾.

ويندرج تحت هذا الشرط مسائل، منها:

المسألة الأولى: شهادة المسلم على غير المسلم

اتفق الفقهاء على قبول شهادة المسلم على غير المسلم في السفر والحضر، والحدود، والقصاص، وما دونها⁽⁴⁾.

دليل ذلك: الكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول:

الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾⁽⁵⁾. وجه الدلالة: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثَبَّتْ

(1) الحاوي الكبير، 62/17.

(2) بدائع الصنائع، 280/6.

(3) المبسوط، للسرخسي، 136/16؛ العناية، 418/7.

(4) تبیین الحقائق، 221/4؛ الجامع لمسائل المدونة، 397/17؛ البيان

في مذهب الإمام الشافعي، 277/14؛ الجامع لعلوم الإمام أحمد،

101/13؛ مراتب الإجماع، ص: 53.

(5) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 143.

لِلْمُؤْمِنِينَ شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا، فَتَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ (1).

السنة: - قوله - ﷺ: "لَا تَرِثُ مِلَّةَ مَلَّةٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إِلَّا شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْمَلَلِ".
وجه الدلالة: حيث منع النبي ﷺ قبول شهادة ملة، على ملة أخرى، وأثبت شهادة المسلمين على الملل كلها، فدل الحديث على قبول شهادة المسلم على غيره.

القياس: - أنه لما قُبِلَتْ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَعَلَى الْكَافِرِ أَوْلَى (2). - ولأنَّ المسلم أهلٌ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَعَلَى الْكَافِرِ أَوْلَى (3).

المعقول: - أَنَّ الْمُسْلِمَ مُحَقٌّ فِي عِدَاوَتِهِ لِلذِّمِّيِّ، فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَالذِّمِّيُّ مُبْطَلٌ فِي عِدَاوَتِهِ لِلْمُسْلِمِ، فَلَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ (4).

المسألة الثانية: شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض: ذهب الحنفية إلى أنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، إذا كانوا عدولاً في دينهم، سواء اتفقت ملتهم، أو اختلفت، فتقبل شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي

(1) المبسوط، للسرخسي، 133/16.

(2) المبسوط، للسرخسي، 133/16.

(3) بدائع الصنائع، 280/6.

(4) الجوهرة النيرة، 232/2.

وَالْيَهُودِيَّ عَلَى الْمَجُوسِيِّ (1).

واستدلوا على ذلك: بالكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول:
 أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا
 حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
 آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (2).

وجه الدلالة: دلّت الآية على جواز شهادة أهل الذمة على
 وصية المسلم في السفر، ومن ضرورة جواز شهادتهم على
 وصية المسلم، جوازها على وصية الكافر، فكل شهادة جازت
 على المسلم، جازت على الذمي من باب أولى. ثم نسخ حكمها
 في حق المسلمين بقوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم".
 فوجب أن تبقى دلالتها على جوازها على أهل الذمة؛ لعدم
 وجود ما يدل على نسخها في حقهم، فدلّت الآية الكريمة على
 قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (3).

ثانياً: السنة: - عَنْ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ -
 ﷺ - بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا، قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ

(1) المبسوط، للسرخسي، 133/16؛ بدائع الصنائع، 280/6؛ الهداية ،

123/3؛ الاختيار لتعليل المختار، 149/2.

(2) سورة المائدة، جزء من الآية رقم: 106.

(3) شرح مختصر الطحاوي، 111/8، 110؛ المبسوط، للسرخسي،

134، 135/16؛

تَوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ⁽¹⁾. وجه الدلالة: قال ابن حجر:

وَفِيهِ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ⁽²⁾.

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ"⁽³⁾.

وجه الدلالة: دل الحديث على قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، ولولا ذلك ما أجازها رسول الله - ﷺ.

ثالثاً: القياس:

- أن وصية الذمي إلى الذمي جائزة، وهي أمانة لا يقر عليها الفاسق، فلما جازت وصية بعضهم إلى بعض، وإن كانت أمانة، ومن شرط الوصي كونه عدلاً، وجب أن تجوز شهادتهم أيضاً بعضهم على بعض⁽⁴⁾.

- أَنَّ مَنْ كَانَ عَدْلًا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَالْمُسْلِمِينَ⁽⁵⁾.

رابعاً: المعقول، وذلك من وجوه:

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، 105/9، حديث رقم: 7332.

(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري، 171/12؛ الحاوي الكبير، 62/17.

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه، 794/2، حديث رقم: 2374. قال ابن حجر: "وفي إسناده مجالد، وهو سيئ الحفظ". (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي، بن حجر العسقلاني، 364/4.

(4) شرح مختصر الطحاوي، 113/8.

(5) الحاوي الكبير، 62/17.

- أَنَّ الذَّمِّيَّ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، وَكُلِّ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ، فَلَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى جَنْسِهِ، كَالْمُسْلِمِينَ⁽¹⁾.

- أَنَّ الْحَاجَةَ مَسَّتْ إِلَى صِيَانَةِ حُقُوقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَمَّا تَحَصَّلَ الصِّيَانَةُ إِلَّا بِقَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَاتُ تَكْثُرُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالْمُسْلِمُونَ لَا يَحْضُرُونَ مُعَاقِدَتِهِمْ؛ لِيَتَحَمَّلُوا حَوَادِثَهُمْ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ شَهَادَةٌ، لَضَاعَتْ حُقُوقُهُمْ عِنْدَ الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ، فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى الصِّيَانَةِ بِالشَّهَادَةِ⁽²⁾.

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم"⁽³⁾.

المسألة الرابعة: شهادة المُسْتَأْمَنِ⁽⁴⁾

شهادة المُسْتَأْمَنِ: إما أن تكون على ذمِّي⁽⁵⁾. وإما أن تكون

(1) المبسوط، للسرخسي، 135/16؛ الاختيار، 149/2.

(2) المبسوط، للسرخسي، 135/16؛ بدائع الصنائع، 280/6.

(3) مختصر القدوري، ص: 220.

(4) المُسْتَأْمَنُ: هُوَ الْحَرَبِيُّ الَّذِي دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِأَمَانٍ. وَقِيلَ: هُوَ مَنْ يَدْخُلُ غَيْرَ دَارِهِ بِأَمَانٍ، مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ حَرَبِيًّا. (درر الحكام شرح غرر الأحكام، 292/1؛ تحرير ألفاظ التنبيه، للنووي، ص: 325).

(5) الذمي: هُوَ الْمَعَاهِدُ، الَّذِي أُعْطِيَ عَهْدًا، يَأْمَنُ بِهِ عَلَى مَالِهِ، وَعَرْضِهِ، وَدِينِهِ. وَأَهْلُ الذِّمَّةِ: الْمَعَاهِدُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَغَيْرِهِمْ، مِمَّنْ يُقِيمُ

على مستأمن مثله. فإن كانت شهادة المستأمن على ذمّي، فلا تقبل باتفاق الحنفية⁽¹⁾. دليل ذلك من المعقول: أن الشهادة من باب الولائية، والمستأمن لا ولاية له على الذمّي؛ لكونه من أهل دارنا؛ حتى لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب، والمستأمن من أهل دار الحرب، واختلاف الدارين حكماً يقطع الولائية، فيمنع قبول الشهادة⁽²⁾.

وإن كانت شهادة المستأمن على مستأمن مثله: فإما أن يتفقا في الدار. وإما أن يختلفا. فإن اتفقا في الدار: بأن كانا من وطن واحد، أو يحملان جنسية واحدة، فتقبل شهادة بعضهم على بعض.

وإن اختلفا في الدار: بأن كان كل واحد منهما من وطن غير الآخر، أو يحمل جنسية غير جنسية صاحبه، فلا تقبل شهادة بعضهم على بعض⁽³⁾.

دليل ذلك من المعقول: أن اختلاف الدارين يقطع الولائية، ويمنع التوارث بينهما، فيمنع قبول الشهادة⁽⁴⁾.

بدار الإسلام، ويحملون جنسية الدولة المسلمة. (التعريفات الفقهية، ص: 39؛ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، ص: 138؛ معجم لغة الفقهاء، ص: 95).

(1) المبسوط، للسرخسي، 139/16؛ الاختيار، 149/2.

(2) العناية، 419/7؛ لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص: 264.

(3) المبسوط، للسرخسي، 139/16؛ المحيط البرهاني، 406/8.

(4) العناية، 420/7؛ الجوهرة النيرة، 232/2؛ البناية، 155/9.

المسألة الخامسة: شهادة الذمي على المستأمن

شهادة الذمي على المستأمن مقبولة باتفاق الحنفية⁽¹⁾.

الدليل على ذلك من القياس، والمعقول:

أولاً: القياس: - أن الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم، وشهادة المسلم تقبل على المستأمن، فكذا الذمي. وإنما لا يجري التوارث بين الذمي والمستأمن؛ لأن المستأمن من أهل دارنا فيما يرجع إلى المعاملات، والشهادة منها. ومن أهل دار الحرب في الإرث، والمال⁽²⁾.

ثانياً: المعقول، وذلك من وجهين: - أن الذمي أعلى حالاً من المستأمن؛ لأن الذمي من أهل دارنا، ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفها، فكان الواجب قبول شهادة الذمي على المستأمن⁽³⁾.

- ولأن الذمي له ولاية ثابتة في دارنا على نفسه، وأولاده الصغار، فتكون ثابتة في جنسه⁽⁴⁾.

الشرط السابع: أن لا يجرّ الشاهد إلى نفسه مغنماً، ولا يدفع عن نفسه مغرمًا بشهادته، فإن جرّ الشاهد إلى نفسه بشهادته

(1) المبسوط، للسرخسي، 139/16.

(2) فتح القدير، 420/7.

(3) المبسوط، للسرخسي، 139/16؛ تبين الحقائق، 225/4.

(4) الاختيار لتعليل المختار، 149/2.

مغنماً، أو دفع عن نفسه مغرمًا، لا تقبل شهادته⁽¹⁾. دليل ذلك السنة، والمعقول:

أولاً: السنة: روى عبد الرزاق في مصنفه، عن محمد بن سيرين قال: سمعت شريحاً يقول: "لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلَا الشَّرِيكَ، وَلَا دَافِعَ مَغْرَمٍ، وَلَا جَارَ مَغْنَمٍ، وَلَا مُرِيبٍ"⁽²⁾. وجه الدلالة: حيث نفى الأثر صحة الشهادة ممن يجلب لنفسه مغنماً، أو يدفع عنها مغرمًا؛ للتهمة في شهادته.

ثانياً: المعقول، وذلك من وجهين:

- أن شهادته إذا تضمنت معنى النفع والدفع، فقد صار متهمًا، وَلَا شَهَادَةَ لِلْمُتَّهِمِ⁽³⁾؛ لقوله - ﷺ: "لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ"⁽⁴⁾.

- ولأنه إذا جرَّ النفع إلى نفسه بشهادته، لم تقع شهادته لله تعالى - عزَّ وجلَّ - بلَ لِنَفْسِهِ، وشهادة المرء لنفسه دعوى، فلا تقبل⁽⁵⁾. وبناء على هذا الشرط: لا تقبل شهادة الآباء للأبناء من الولاد وإن نزلوا، ولا شهادة الأبناء للآباء وإن علوا، سواء اتفقوا في دينهم، أو اختلفوا، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية،

(1) المبسوط، للسرخسي، 146/16؛ بدائع الصنائع، 272/6.

(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، 321/8، حديث رقم: 15371.

(3) المبسوط، للسرخسي، 146/16؛ بدائع الصنائع، 272/6.

(4) أخرجه البيهقي في سننه الصغرى، 172/4، حديث رقم: 3339.

(5) المبسوط، للسرخسي، 146/16؛ بدائع الصنائع، 272/6؛

والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب⁽¹⁾.

دليل ذلك: الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾⁽²⁾. وجه الدلالة: أن الرِّبِّيَّةَ والتهمة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضاً؛ لما جَبَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمِيلِ وَالْمَحَبَّةِ⁽³⁾.

ثانياً: السنة: روى الترمذي في سننه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا مَجْلُودَةٍ، وَلَا ذِي غَمَرٍ لِأَخِيهِ، وَلَا مُجَرَّبٍ شَهَادَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ، وَلَا ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ"⁽⁴⁾.

وجه الدلالة: بين الحديث أن شهادة القانع أهل البيت - وهو الخادم لهم، الذي معاشه منهم - لا تقبل، فإذا ثَبَتَ رَدُّ الْقَانِعِ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، فَالْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَنَحْوُهُمَا أَوْلَىٰ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ

(1) المبسوط، للسرخسي، 121/16؛ الهداية شرح بداية المبتدي، 122/3؛ التفريع في فقه الإمام مالك، لابن الجلاب، 237/2، -2007م؛ الحاوي الكبير، 163/17؛ المغني، 172/10؛ المبدع في شرح المقنع، 322/8.

(2) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

(3) الحاوي الكبير، 164/17.

(4) أخرجه الترمذي في سننه، 545/4، حديث رقم: 2298. وقال: "هذا حديث غريب".

الْوَلَدِ أَعْظَمُ فِي ذَلِكَ، فَيَثْبُتُ حِينَئِذٍ رَدُّ شَهَادَتِهِمْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ (1).

- رُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ شَهِدَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَعَ قَنْبَرٍ عِنْدَ شَرِيحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِدِرْعٍ لَهُ، فَقَالَ شَرِيحٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْتَ بِشَاهِدٍ آخَرَ، فَقَالَ عَلِيٌّ - ﷺ - مَكَانَ الْحَسَنِ، أَوْ مَكَانَ قَنْبَرٍ، قَالَ: لَا بَلْ مَكَانَ الْحَسَنِ - ﷺ - قَالَ عَلِيٌّ - ﷺ -: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ "هُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ". فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ، وَلَكِنْ أَنْتَ بِشَاهِدٍ آخَرَ، فَعَزَلَهُ عَنِ الْقَضَاءِ، ثُمَّ أَعَادَهُ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي رِزْقِهِ (2).

وجه الدلالة: دَلَّ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَلَدِ لَوَالِدِهِ لَا تُقْبَلُ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ لِعَلِيٍّ - ﷺ - فِي الْإِبْتِدَاءِ أَنَّ لِلْحَسَنِ - ﷺ - خُصُوصِيَّةً فِي ذَلِكَ؛ لِمَا خَصَّهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ السِّيَادَةِ وَوَقَعَ عِنْدَ شَرِيحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ السَّبَبَ الْمَانِعَ وَهُوَ الْوَلَدُ قَائِمٌ فِي حَقِّهِ، فَيَنْبِي الْحُكْمَ عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ شَرِيحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَإِلَيْهِ رَجَعَ عَلِيٌّ - ﷺ (3).

ثالثًا: المعقول، وذلك من وجوه: - لَأَنَّ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ، يَنْتَفِعُ الْبَعْضُ بِمَالِ الْبَعْضِ عَادَةً، فَيَتَحَقَّقُ مَعْنَى جَرِّ النَّفْعِ،

(1) فتح القدير، 405/7، 404.

(2) أخرجه أبو نعيم في الحلية، بلفظ قريب منه، 4/140، 139.

(3) المبسوط، للسرخسي، 122/16؛

وَالْتُّهْمَةَ، وَالشَّهَادَةَ لِنَفْسِهِ، فَلَا تُقْبَلُ⁽¹⁾.
 - وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ، حَتَّى لَا يَجُوزَ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِمْ،
 فَيَكُونُ شَهَادَةُ لِنَفْسِهِ مِنْ وَجْهِ، أَوْ تَتِمَّكَنَ فِيهِ التُّهْمَةُ، وَشَهَادَةُ
 الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، أَوْ الْمَتَّهِمِ، لَا تُقْبَلُ⁽²⁾.
 - لِأَنَّ مَالَ الْبَائِنِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْآبِ؛ قَالَ - ﷺ -: "أَنْتَ وَمَالُكَ
 لِأَبِيكَ"⁽³⁾. فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ بِمَالِ أَبِيهِ، كَالشَّهَادَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ، فَلَا
 تُقْبَلُ⁽⁴⁾.

-أَنَّ الْآبَ وَافِرَ الشَّفَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ، يَحِبُّ إِصْصَالِ النِّفْعِ إِلَيْهِ،
 وَدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ، وَيُؤْثِرُ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ، حَتَّى إِنَّهُ رُبَّمَا دَعَاهُ
 أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالزُّورِ، فَيَتَّهِمَ بِالْمِيلِ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ شَهَادَتُهُ لَهُ،
 كَشَهَادَتِهِ لِنَفْسِهِ، فَلَا تُقْبَلُ⁽⁵⁾.

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا تقبل شهادة
 الأعمى، ولا المملوك، ولا المحدود في قذف، وإن تاب، ولا

(1) بدائع الصنائع، 6/272.

(2) الهداية ، 3/122؛ الاختيار لتعليل المختار، 2/147.

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله
 عنهما-، 2/769، حديث رقم: 2291. وقال ابن حجر: "رجاله ثقات".
 (الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي، ابن حجر
 العسقلاني، 2/102، .

(4) الجوهرة النيرة، 2/229؛ الحاوي الكبير، 17/164.

(5) المحيط البرهاني، 8/324؛ الإشراف على نكت مسائل الخلاف،
 لعبد الوهاب بن علي بن نصر، البغدادي، المالكي، 2/973، .

شهادة الوالد لولده، وولد ولده، ولنا شهادة الولد لأبويه، وأجداده⁽¹⁾.

شهادة سائر القربات

أَمَّا سَائِرُ الْقَرَابَاتِ: كَالْأَخِ، وَالْعَمِّ، وَالْخَالِ، وَنَحْوِهِمْ، فَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ⁽²⁾. دليل ذلك من المعقول: أَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ تَسَلُّطٌ فِي مَالِ الْبَعْضِ، عُرْفًا، وَعَادَةً، فَالْتَحَقُوا بِالْأَجَانِبِ⁽³⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "وتقبل شهادة الرجل لأخيه، وعمه"⁽⁴⁾.

شهادة الآباء للأبناء من الرضاع

تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ مِنَ الرِّضَاعِ لَوْلَدِهِ مِنَ الرِّضَاعِ، وَشَهَادَةُ الْوَلَدِ مِنَ الرِّضَاعِ لَوَالِدِهِ مِنَ الرِّضَاعِ⁽⁵⁾. دليل ذلك من المعقول، وذلك من وجهين:

- أَنَّ الْعَادَةَ مَا جَرَتْ بِإِنْتِفَاعِ هَؤُلَاءِ بَعْضُهُمْ بِمَالِ الْبَعْضِ، فَكَانُوا كَالْأَجَانِبِ⁽⁶⁾. - وَلِأَنَّهُ لَا جُزْئِيَّةَ بَيْنَهُمَا، فَانْتَفَتِ التُّهْمَةُ⁽⁷⁾.

(1) مختصر القدوري، ص: 220.

(2) بدائع الصنائع، 272/6؛ الاختيار لتعليل المختار، 147/2.

(3) بدائع الصنائع، 272/6.

(4) مختصر القدوري، ص: 220.

(5) بدائع الصنائع، 272/6؛ الاختيار لتعليل المختار، 147/2.

(6) بدائع الصنائع، 272/6.

(7) الاختيار لتعليل المختار، 147/2.

الشرط الثامن: أَنْ لَا يَكُونَ الشَّاهِدُ خَصْمًا⁽¹⁾ للمشهود عليه، فإن كان الشاهد خصمًا، لا تقبل شهادته⁽²⁾؛ دليل ذلك السنة، والمعقول:

أولًا: السنة: - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مُنَادِيًا، فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنِيَّةَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ"⁽³⁾.
ثانيًا: المعقول: أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَصْمًا، فَشَهَادَتُهُ تَقَعُ لِنَفْسِهِ، فَلَا تُقْبَلُ⁽⁴⁾.

الشرط التاسع: أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَقْتُ آدَاءِ الشَّهَادَةِ، عَالِمًا بِالْمَشْهُودِ بِهِ، وَذَاكَرًا لَهُ. وَعَلَيْهِ: إِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ الَّتِي حَرَّرَهَا، بَأَن رَأَى اسْمَهُ، وَخَطَّهُ، وَخَاتَمَهُ فِي الْكِتَابِ، لَكِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْآدَاءِ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ، وَلَوْ شَهِدَ، وَعَلِمَ الْقَاضِي بِهِ، لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ. وَعِنْدَ الصَّاحِبِينَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ، حَتَّى إِنَّهُ لَوْ رَأَى

(1) الخصم: بفتح الخاء، وسكون الصاد: المنازع في الحق، المجادل فيه. أو هو المدعي، والمدعى عليه؛ لأن كل واحد منهما خصم للآخر. (التعريفات الفقهية، ص: 87؛ معجم لغة الفقهاء، ص: 196).

(2) بدائع الصنائع، 272/6؛ البحر الرائق، 57/7.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 339/4، حديث رقم: 20823؛ والبيهقي في سننه الكبرى، 339/10، حديث رقم: 20860. وقال: "أخرجه أبو داود مع حديث الأعرج في المراسيل".

(4) بدائع الصنائع، 272/6.

خطه، وختمه، ولم يتذكر الشهادة التي حررها، له أن يشهد، ولو شهد، تقبل شهادته⁽¹⁾.

دليل صاحبين: المعقول، وذلك من وجهين:

– أنه لما رأى اسمه، وخطه، وخاتمه على الصك، دل أنه تحمل الشهادة، وهي معلومة في الصك، فيحل له أدائها، وإذا أدّاها تقبل⁽²⁾.

– ولأن النسيان أمر جيل عليه الإنسان، خصوصاً عند طول المدة بالشيء؛ لأن طول المدة ينسي، فلو شرط تذكر الحادثة لأداء الشهادة، لانسد باب الشهادة، فيؤدي إلى تضييع الحقوق، وهذا لا يجوز⁽³⁾.

دليل الإمام أبي حنيفة: الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب: - قوله تعالى: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى»⁽⁴⁾.

وجه الدلالة: قال الإمام الجصاص: "وفي هذه الآية دلالة على أنه غير جائز لأحد، إقامة شهادة، وإن عرف خطه، إلا أن يكون ذاكرًا لها؛ ألا ترى أنه ذكر ذلك بعد الكتاب، والشهاد، ثم قال تعالى: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى».

(1) الهداية، 119/3؛ بدائع الصنائع، 272/6.

(2) بدائع الصنائع، 272/6.

(3) بدائع الصنائع، 272/6.

(4) سورة البقرة، جزء من الآية رقم: 282.

فَلَمْ يَقْتَصِرْ بِنَا عَلَى الْكِتَابِ، وَالْخَطِّ، دُونَ ذِكْرِ الشَّهَادَةِ⁽¹⁾.
 - وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾⁽²⁾. وجه الدلالة: دلت الآية على أَنَّ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ، ذِكْرَ الشَّاهِدِ لَهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ فِيهَا عَلَى الْخَطِّ؛ إِذِ الْخَطُّ، وَالْكِتَابُ مَأْمُورٌ بِهِ؛ لِتَذَكُّرِ بِهِ الشَّهَادَةِ، فَإِذَا لَمْ يَتَذَكَّرِ الشَّهَادَةَ، فَلَا تَقْبَلُ⁽³⁾.

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.
 وجه الدلالة: حيث شرط الله تعالى في الشاهد أن يكون عالمًا بالشهادة، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا عِنْدَ أَدَائِهَا، فَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِهَا، فَلَا تَقْبَلُ⁽⁴⁾.

ثَانِيًا: السُّنَّةُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ - عَنِ الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: "هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟". قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ".
 وجه الدلالة: حيث شرط رسول الله ﷺ في الشاهد أن يكون عالمًا بالشهادة، كما يعلم الشمس، وَلَا يَتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِدُونِ تَذَكُّرِ الْوَاقِعَةِ، فَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةُ لَا يَذْكُرُهَا الشَّاهِدُ، وَإِنْ رَأَاهَا بِخَطِّهِ⁽⁵⁾.

(1) أحكام القرآن، للجصاص، 245/2.

(2) سبق عزو الآية الكريمة، ص: .

(3) أحكام القرآن، للجصاص، 247/2، 246.

(4) أحكام القرآن، للجصاص، 247/2.

(5) تبیین الحقائق، 214/4.

ثالثاً: المعقول، وذلك من وجهين: - أنه لا اعتماد على الخط، والختم؛ لأن الخط يشبه الخط، والختم يشبه الختم، ويجري فيه الاحتيال، والتزوير، مع ما أن الخط للتذكر، فخط لا يذكر، وجوده وعدمه بمنزلة واحدة⁽¹⁾.

- أنه لما كانت الشهادة من مشاهدة الشيء، وحقيقة العلم به، فمن لا يذكر الشهادة، فهو بخلاف هذه الصفة، فلا تجوز له إقامة الشهادة به⁽²⁾.

والراجع من هذين القولين: هو قول الإمام أبي حنيفة - رحمته؛ لقوة أدلته، ووجاهتها. ولأن الشرع قد أكد أمر الشهادة، حتى صار لا يقبل فيها إلا صريح لفظها، ولا يقبل ما يقوم مقامها من الألفاظ، فكيف يجوز العمل على الخط الذي يجوز عليه التزوير، والتبديل⁽³⁾. وهذا هو الأحوط، لا سيما في هذا الزمان الذي ماتت فيه الضمان، وخربت فيه الذمم، وفشى فيه الاحتيال والتزوير.

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه، أن يشهد، إلا أن يذكر الشهادة"⁽⁴⁾.

الشرط العاشر: أن لا يكون محدوداً في قذف: فلو كان

(1) بدائع الصنائع، 27/6، 214/4؛ أحكام القرآن، 247/2.

(2) أحكام القرآن، للجصاص، 247/2.

(3) أحكام القرآن، للجصاص، 247/2.

(4) مختصر القدوري، ص: 220.

محدوداً في قذف، لا تقبل شهادته، ولو بعد التوبة، وهذا شرط لصحة أداء الشهادة عند السادة الحنفية رحمهم الله (1). استدل الحنفية لقولهم بالكتاب، والسنة، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب: -قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (2). وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عَنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الرَّامِي عَلَى التَّائِبِ، فقال: (أبدًا). والأبد: هو مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، فَيَتَنَاوَلُ زَمَانَ مَا قَبْلَ التَّوْبَةِ، وبعدها (3).

ثانياً: السنة: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ".

وجه الدلالة: نص الحديث على عدم قبول شهادة المحدود، وجاء النهي عاماً، ولم يفرق بين شهادته قبل التوبة، أو بعدها، فدل الحديث على عدم قبول شهادة القاذف، وإن تاب.

ثالثاً: القياس، وذلك من وجهين: - أنه بِإِقَامَةِ الْحَدِّ، يَصِيرُ مَحْكُومًا بِكَذِبِهِ، وَالْمُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ، لَا شَهَادَةَ لَهُ، فَالْمَحْكُومُ

(1) بدائع الصنائع، 271/6؛ البحر الرائق، 56/7.

(2) سورة النور، الآية رقم: 4.

(3) شرح مختصر الطحاوي، 218/6؛ المبسوط، للسرخسي، 126/16؛

بدائع الصنائع، 271/6؛ العناية الهداية، 400/7.

بِالْكَذِبِ أُولَى (1).

- وَلَئِنْ مَا تَعَلَّقَ بِالْقَذْفِ مِنْ حَقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ، لَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ، كَالْجَلْدِ، وَالشَّهَادَةِ مِنْ حَقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ، فَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ (2).

المعقول: - أَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ مِنْ تَمَامِ حَدِّ الْقَذْفِ؛ لِكَوْنِهِ مَانِعًا عَنْ الْقَذْفِ، كَالْجَلْدِ. وَأَصْلُ الْحَدِّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، فَمَا هُوَ مُتِمٌّ لَهُ لَا يَسْقُطُ أَيْضًا؛ اعْتِبَارًا لَهُ بِالأَصْلِ؛ لِإِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ﴾. مَعْطُوفٌ عَلَى الْجَلْدِ، وَالْعَطْفُ لِلإِشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ حَدًّا، كَانَ الْمَعْطُوفُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ، وَالْحَدُّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ، فَكَذَا مَا هُوَ مُتِمٌّ لَهُ (3).

تلخيص: قَالَ الْقُدُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى، وَلَا الْمَمْلُوكِ، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ، وَإِنْ تَابَ" (4).
شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ: أَمَّا الْمَحْدُودُ فِي غَيْرِ قَذْفٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ، إِذَا كَانَ عَدْلًا: كَالْمَحْدُودِ فِي الزِّنَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُحَصَّنٍ وَالسَّرِقَةِ، وَالشُّرْبِ، فَتَقْبَلُ شَهَادَتَهُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ، وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ (5).

(1) المبسوط، للسرخسي، 128/16.

(2) الحاوي الكبير، 25/17.

(3) المبسوط، للسرخسي، 127/16، 126؛ الهداية شرح بداية المبتدي،

212/3؛ الاختيار لتعليل المختار، 147، 136/9.

(4) مختصر القدوري، ص: 220.

(5) المبسوط، للسرخسي، 132/16؛ الهداية، 121/3.

وذلك: لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾⁽¹⁾. وجه الدلالة: دلت الآية على أن التوبة توجب القبول، والعفو، ومن قبلت توبته، وعفي عن سيئته، فهو مقبول الشهادة.

ولقوله ﷺ: "التائب من الذنب، كمن لا ذنب له".

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من تاب من الذنب، فإنه يرجع حكمه، كأنه لا ذنب له، ومن لا ذنب له مقبول الشهادة، فالتائب يجب أن يكون أيضاً مقبول الشهادة⁽²⁾.

- عن الحسن، أن رجلاً من قريش سرق ناقة، فقطع رسول الله - ﷺ - يده، وكان جائز الشهادة⁽³⁾.

وجه الدلالة: دل الأثر على قبول شهادة السارق، بعد إقامة الحد عليه، والتوبة، وأنه كان معروفاً بين الصحابة - رضوان الله عليهم -، وتناقلوه خلفاً عن سلف.

- عن أبي حصين، عن شريح، أنه: "أجاز شهادة أقطع"⁽⁴⁾. من بني أسد، فقال: أتجيز شهادتي؟ فقال: نعم، وأراك لذلك

(1) سورة الشورى، الآية رقم: 25.

(2) مفاتيح الغيب، 327/23؛ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 125/9.

(3) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، 263/10، حديث رقم: 20577. والطحاوي في معرفة السنن والآثار، 265/14، حديث رقم: 19883. وقال: "وهذا مرسل".

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 534/4، حديث رقم: 22890.

أَهْلًا. وَكَانَ أَقْطَعَ فِي سَرِقَةٍ(1).

وجه الدلالة: أن شريحاً تابعي، أجاز شهادة المحدود في السرقة، ولم ينقل عن أحد خلافه(2).

ثالثاً: المعقول: أن بطلان شهادته متعلق بالفسق، فمتى زالت عنه سمة الفسق، كانت شهادته مقبولة، وقد زالت عنه بالتوبة؛ لأنه بالتوبة صار عدلاً، فتقبل شهادته(3).

الشرط الحادي عشر: العدالة(4): فيشترط في الشاهد عند أداء الشهادة، أن يكون عدلاً، وذلك باتفاق الفقهاء(5).

والعدل: هو من لا يأتي بكبيرة، ولا يصير على صغيرة،

(1) المبسوط، للسرخسي، 132/16.

(2) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 125/9.

(3) أحكام القرآن، للجصاص، 127/5؛ المبسوط، للسرخسي، 132/16؛ بدائع الصنائع، 272/6.

(4) والعدالة لغة: المساواة، والاستقامة. (المصباح المنير، 396/2؛ التوقيف على مهمات التعاريف، ص: 238؛ الكليات، ص: 639). واصطلاحاً: صفة في الإنسان، تحمله على اجتناب الكبائر، وعدم الاصرار على الصغائر، وتجنب ما فيه خسة من التصرفات. (معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ص: 66، طبعة: مكتبة الآداب - القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1424هـ - 2004م؛ التوقيف على مهمات التعاريف، ص: 237؛ معجم لغة الفقهاء، ص: 306).

(5) بدائع الصنائع، 268/6؛ مجمع الأنهر، 188/2؛ المعونة، ص:

1517؛ كفاية الأختار، للحصني، ص: 566؛ المغني، 145/10.

وَيَكُونُ سِتْرُهُ أَكْثَرَ مِنْ هَنْكِهِ، وَصَوَابُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَطْئِهِ،
وَمُرُوءَتُهُ ظَاهِرَةٌ (1)، والعدالة عند الحنفية: شرط لوجوب
القضاء على القاضي بالشهادة، لا شرط أهلية الشهادة، أو
صحة أدائها؛ فلو قضى القاضي بشهادة الفاسق، بعد أن
تحرى الصدق في شهادته (2)، صحّ قضاؤه عندنا، وكان
القاضي عاصياً. إلّا أن يمنع الخليفة من القضاء بشهادة
الفاسق، فحينئذ لا يصح؛ إذ الفاسق أهل لولاية القضاء،
والسلطنة، فيكون أهلاً للشهادة، إلّا أن فسقه أوجب التوقف في
خبره؛ لتهمته؛ قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ
فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا». فأمر بالتبين، والتثبت لا بالرد (3). دليل
هذا الشرط: الكتاب، والسنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ»
وجه الدلالة: أمرنا الله عز وجل أن نشهد المرضي من
الشهداء، والشاهد المرضي هو الشاهد العدل، فدلّت الآية
الكريمة على اشتراط عدالة الشاهد (4).
-وقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ». وجه الدلالة: أن

(1) فتح القدير، 421/7؛ الفتاوى الهندية، 450/3.

(2) ولو قضى بشهادة الفاسق من غير تحرّ، لا يصح بالإجماع. (بدائع
الصنائع، 270/6؛ قرّة عين الأخيار، 491/7).

(3) بدائع الصنائع، 270/6؛ تبیین الحقائق، 210/4.

(4) بدائع الصنائع، 268/6؛ تبیین الحقائق، 210/4.

الله تعالى أمرنا أن نُشهد العدول منا، فدلّت الآية على أن عدالة الشاهد، شرط لقبول شهادته (1).

ثانياً: السنة: ما روي عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". وجه الدلالة: بين الحديث أنه لا تقبل شهادة الخائن، والخائنة.

ثالثاً: المعقول: - أن من يباشر غير الكذب من المعاصي، قد يباشر الكذب، وهذا؛ لأن الخبر يحتمل الصدق، والكذب، وبالعَدَالَةِ تترجح جهة الصدق، وهي الانزجار عما يعتقده حرمة، والحجة هو الخبر الصدق، ولا يلزم حجة دونها (2).

- ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد، وينفذه في حق الغير، فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق، ولا يكون ذلك إلا بالعدالة (3).

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا بد في ذلك كله من العدالة" (4).

وبناء على هذا الشرط: من لم يكن عدلاً، لا تقبل شهادته:

(1) شرح مختصر الطحاوي، 109/8.

(2) تبیین الحقائق، 210/4؛ العناية شرح الهداية، 375/4؛ درر الحکام شرح غرر الأحكام، 372/2.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 141/2.

(4) مختصر القدوري، ص: 219.

فلما تقبل شهادة الزاني، والسارق، وقاتل النفس بغير حق،
وآكل أموال اليتامى، وآكل الربا، وقاذف المحصنات الغافلات
المؤمنات، وقاطع الطريق، والمتلصص، ومن يفجر بالنساء،
من يعمل عمل قوم لوط؛ لَأَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ رُءُوسِ الْكِبَائِرِ،
والموبقات (1)، ولا تقبل شهادة شارب الخمر؛ لَأَنَّ شُرْبَهُ
كَبِيرَةٌ، فَتَسْقُطُ بِهِ الْعَدَالَةُ (2)، ولا تقبل شهادة الْمُخْنَثِ (3)؛ لَأَنَّ
فَعْلَهُ، وَعَمَلَهُ كَبِيرَةٌ (4)، ولا تقبل شهادة مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ
يَكْتَسِبُ الدَّرَاهِمَ، مِنْ أَيِّ وَجْهِ كَانَ.

تلخيص: قال القدوري - رحمه الله: "ولا تقبل شهادة
مخنث، ولا نائحة، ولا مغنية، ولا مدمن الشرب على
اللهو،... ولا من يأتي باباً من الكبائر، التي يتعلق بها
الحد"..... "وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة
المسلم، إلا في الحدود، والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود،
وإن طعن الخصم فيهم، سأل عنهم. وقال أبو يوسف
ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر، والعانية" (5).

(1) بدائع الصنائع، 269/6.

(2) بدائع الصنائع، 268/6.

(3) الْمُخْنَثُ: هو الذي يباشر الرِّدْيَ من أفعال النساء من التَّزْيِينِ
بِزِينَتِهِنَّ، والتَّشَبُّهِ بِهِنَّ في الفعل، والقول. (البحر الرائق، 85/7).

(4) بدائع الصنائع، 269/6؛ البحر الرائق، 85/7.

(5) مختصر القدوري، ص: 220، 219.

المبحث الثالث

شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الصيغة،

والمشهود به، ومكان الشهادة

المطلب الأول: شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى الصيغة

اشتراط الفقهاء في صيغة الشهادة شرطين:

الشرط الأول: لفظ الشهادة: أَي لَفْظُ أَشْهَدُ، بَأَن يَقُولُ

الشاهد: أَشْهَدُ بِكَذَا. فَلَا تُقْبَلُ بغيرها مِنَ الْأَلْفَافِ، التي تدل

على معنى الشهادة، كَلَفْظِ الْإِخْبَارِ، وَالْإِعْلَامِ، وَالتَّيَقُّنِ، وَنَحْوِ

ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي مَعْنَى الشَّهَادَةِ؛ تَعَبُّدًا غَيْرَ مَعْقُولٍ

الْمَعْنَى⁽¹⁾. دليل هذا الشرط: الكتاب، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.

وجه الدلالة: أنه صريح في طلب الشهادة، فيجب عليه الاتيان

بلفظها⁽²⁾.

ثانياً: المعقول، وذلك من وجوه:

– أَنَّ النُّصُوصَ نَاطِقَةً بِالِاسْتِشْهَادِ، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾. فَلَا يَقُومُ

(1) مختصر القدوري، ص: 319؛ بدائع الصنائع، 6/273؛ مجمع

الأنهر، 2/189؛ اللباب في شرح الكتاب، 4/57.

(2) الاختيار لتعليل المختار، 2/141.

- مَقَامَهَا غَيْرُهَا؛ لِمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ تَوْكِيدٍ⁽¹⁾.
- أَنَّ لَفْظَةَ (أَشْهَد) فِيهَا زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَلْفَافِ الْيَمِينِ، فَكَانَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الْكَذِبِ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ أَشَدَّ⁽²⁾.
- وَلِأَنَّ لَفْظَ (أَشْهَد) يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْمَشَاهِدَةِ، وَالْقَسَمِ، وَالْإِخْبَارِ فِي الْحَالِ، فَكَأَنَّ الشَّاهِدَ قَالَ: أَقْسَمُ بِاللَّهِ، لَقَدْ أَطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَا الْآنَ أَخْبِرُ بِهِ. وَهَذِهِ الْمَعْنَى مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَافِ، فَلِذَا؛ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ احْتِطَاءً، وَاتِّبَاعًا لِلْمَأْثُورِ⁽³⁾.
- وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّونَ: حَيْثُ لَا يَشْتَرِطُونَ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ، فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ، فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، كَالْوِلَادَةِ، وَالْبَكَارَةِ⁽⁴⁾.

دليلهم على ذلك من القياس:

- أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ، لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ، فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهَا لَفْظَ الشَّهَادَةِ، كَالشَّهَادَةِ عَلَى هَلَالِ رَمَضَانَ⁽⁵⁾.

وَالصَّحِيحُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمْهُورُ الْحَنْفِيَّةِ، وَمَشَايِخُ الْمَذْهَبِ مِنَ الْبُخَارِيِّينَ، وَالْبَلْخِيِّينَ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِيهَا لَفْظَ الشَّهَادَةِ؛

(1) الهداية شرح بداية المبتدي، 118/3؛ تبين الحقائق، 210/4؛

العناية شرح الهداية، 376/7.

(2) الاختيار لتعليل المختار، 141/2؛ تبين الحقائق، 210/4.

(3) البحر الرائق، 55/7.

(4) تبين الحقائق، 210/4.

(5) تبين الحقائق، 210/4؛ فتح القدير، 377/7، 376.

لأنها من باب الشهادة، لا من باب الإخبار؛ لما فيها من معنى الزام؛ ولهذا يشترط فيها شرائط الشهادة، من الحرية، والإسلام، ومجلس الحكم⁽¹⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "ولا بد في ذلك كله من العدالة، ولفظ الشهادة، فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة، وقال: أعلم، أو أتيقن، لم تقبل شهادته"⁽²⁾.

الشرط الثاني: أن تكون الشهادة موافقة للدعوى، فيما يشترط فيه الدعوى⁽³⁾: فإن خالفت الشهادة الدعوى، لا تقبل، إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى، وبين الشهادة، عند إمكان التوفيق، فتقبل⁽⁴⁾؛ دليل ذلك المعقول، وذلك من وجهين:

- أن تقدم الدعوى في حق العبد، شرط لقبول الشهادة؛ لأن القاضي إنما نصب لفصل الخصومات بين الخصوم، وفصله يفتقر إلى سبق أحد الشئيين بعد الدعوى: أما الشهادة، أو اليمين. وقد وجد تقدم الدعوى، فيما إذا وافقت الشهادة الدعوى، فأمكن الفصل بالشهادة. ولم يوجد فيما إذا خالفتها، فلم يمكن القضاء بها، وهذا؛ لأن الشهادة لأجل تصديق الدعوى، فإذا

(1) تبين الحقائق، 210/4؛ فتح القدير، 377/7.

(2) مختصر القدوري، ص: 219.

(3) وهو حقوق العباد. (تبين الحقائق، 229/4).

(4) بدائع الصنائع، 273/6؛ تبين الحقائق، 229/4؛ درر الحكام

، 408/4؛ الفتاوى الهندية، 451/3.

خَالَفَتْهَا فَقَدْ كَذَّبَتْهَا، وَالِدَعْوَى الْكَاذِبَةُ، لَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهَا، فَانْعَدَمَ الشَّرْطُ، وَهُوَ تَقَدُّمُ الدَّعْوَى⁽¹⁾.

-أَنَّ الشَّهَادَةَ إِذَا خَالَفَتْ الدَّعْوَى، فِيمَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الدَّعْوَى، وَتَعَذَّرَ التَّوْفِيقُ، انْفَرَدَتْ الشَّهَادَةُ عَنِ الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَةُ الْمُنْفَرِدَةُ عَنِ الدَّعْوَى، فِيمَا يَشْتَرِطُ فِيهِ الدَّعْوَى غَيْرُ مَقْبُولَةٍ⁽²⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "وإذا وافقت الشهادة الدعوى، قبلت، وإن خالفها، لم تقبل"⁽³⁾.

(1) تبيين الحقائق، 4/229؛ العناية، 7/433؛ مجمع الأنهر، 2/205.

(2) بدائع الصنائع، 6/273؛ لسان الحكام، ص: 274.

(3) مختصر القدوري، ص: 220، 221.

المطلب الثاني

شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى المشهود به

اشترط الفقهاء في المشهود به، لقبول شهادته شرطين:
الشرط الأول: أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ بِمَعْلُومٍ: فَإِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ
بِمَجْهُولٍ، لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ⁽¹⁾. ؛ وذلك لَأَنَّ عِلْمَ الْقَاضِي بِالْمَشْهُودِ
بِهِ، شَرْطٌ صَحَّةِ قَضَائِهِ، فَمَا لَمْ يَعْلَمْ، لَا يُمْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِهِ، فَلَا
تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ⁽²⁾.

الشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ مَعْلُومًا لِلشَّاهِدِ، عِنْدَ أَدَاءِ
الشَّهَادَةِ: حَتَّى لَوْ ظَنَّ، لَا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ رَأَى خَطَأَهُ،
وَحْتَمَهُ، وَأَخْبَرَهُ النَّاسُ بِمَا يَتَذَكَّرُ بِنَفْسِهِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَعِنْدَ الصَّاحِبِينَ: إِنْ رَأَى خَطَأَهُ، وَحْتَمَهُ لَهُ
أَنْ يَشْهَدَ. نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخِلَافِ، وَالْحُجَجِ مِنَ الْجَانِبِينَ⁽³⁾،
عِنْدَ الْحَدِيثِ الشَّرْطِ التَّاسِعِ مِنَ الشَّرُوطِ الْعَامَةِ الَّتِي إِلَى الشَّاهِدِ،
حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَةُ.

قال القدوري - رحمه الله: "ولا يحل للشاهد إذا رأى خطئه،
أن يشهد، إلا أن يذكر الشهادة"⁽⁴⁾.

(1) بدائع الصنائع، 6/277؛ الفتاوى الهندية، 3/451؛ الأصول القضائية
في المرافعات الشرعية، 158.

(2) بدائع الصنائع، 6/277؛ الفتاوى الهندية، 3/451.

(3) بدائع الصنائع، 6/277.

(4) مختصر القدوري، ص: 220.

المطلب الثالث

شروط أداء الشهادة التي ترجع إلى مكان الشهادة
 شرط الفقهاء في مكان الشهادة شرطاً واحداً، وهو: مجلس
 القضاء، سواء كان قضاء قاض، أو قضاء مُحَكَّم⁽¹⁾، فلو أدى
 الشاهد الشهادة في غير مجلس القضاء، لا تقبل⁽²⁾.
 دليل ذلك المعقول: أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَصِيرُ حُجَّةً، مُلْزِمَةً، إِلَّا
 بِقَضَاءِ الْقَاضِي، فَتَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ⁽³⁾.

1 المحكم: بالضم والتشديد، اسم مفعول، من اتفق الخصوم على نصبه
 حكماً بينهم. (معجم لغة الفقهاء، ص: 413).
 (2) بدائع الصنائع، 6/277؛ البحر الرائق، 7/57؛ رد المحتار، 5/462.
 (3) بدائع الصنائع، 6/277؛ .

المبحث الرابع

شروط أداء الشهادة الخاصة ببعض الشهادات

ما تقدم ذكره من شروط ترجع إلى الشاهد، والمشهود به، والصيغة، ومكان الشهادة، إنما هي شروط عامة تعم كل الشهادة. هناك شروط خاصة تخص بعض الشهادات، دون البعض الآخر، بيانها فيما يأتي:

الشرط الأول: تقدم الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدعي نفسه، أو وكيله: فإن لم تسبق الدعوى الشهادة فيما يتعلق بحقوق العباد، فلا تقبل الشهادة. فلو رأى شخصاً غصب مالا لآخر، أو ضربه، فشهد عند القاضي، قبل إقامة الدعوى من صاحب الحق، أو نائبة، لا تقبل شهادته⁽¹⁾ دليل ذلك المعقول، وذلك من وجوه:

- أَنَّ الشَّهَادَةَ شَرَعَتْ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ ؛ لِتَحْقِيقِ قَوْلِ الْمُدَّعِي، وَلَا يَتَحَقَّقُ قَوْلُهُ إِلَّا بِدَعَاوِهِ، إِمَّا بِنَفْسِهِ، وَإِمَّا بِنَائِبِهِ⁽²⁾.
- أَنَّ ثُبُوتَ حُقُوقِ النَّاسِ، يَتَوَقَّفُ عَلَى مَطَالِبَتِهِمْ، وَلَوْ بِالتَّوَكُّلِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْرِفُ حَقُوقَهُمْ، وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى اسْتِيفَائِهَا⁽³⁾.
- أَنَّ الْقَاضِيَ مَنْصُوبٌ لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ، وَالِدَّعَاوَى، فَإِذَا لَمْ

(1) بدائع الصنائع، 6/277؛ الهداية شرح بداية المبتدي، 3/125، 126؛

فتح القدير، 7/433؛ البحر الرائق، 7/57.

(2) بدائع الصنائع، 6/277.

(3) تبیین الحقائق، 4/229؛ درر الحکام شرح غرر الأحكام، 2/384.

تَكُنْ أَمَامَ الْقَاضِي دَعْوَى، أَوْ خُصُومَةٌ، فَالْإِخْبَارُ أَمَامَ الْقَاضِي لِإثْبَاتِ حَقٍّ، لَا يَكُونُ شَهَادَةً، وَإِنَّمَا يَكُونُ دَعْوَى⁽¹⁾.

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهَا تَقَدُّمُ الدَّعْوَى عَلَى الشَّهَادَةِ: كَأَسْبَابِ الْحُرْمَاتِ: كَالطَّلَاقِ، وَالظَّهَارِ، وَالْخَلْعِ، وَالْإِلْيَاءِ، وَالرِّضَاعِ. وَأَسْبَابِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى: لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، فَتَدْخُلُ فِي بَابِ الْحِسْبَةِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ إِقَامَةَ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ خَصْمًا فِي إِثْبَاتِهِ، فَصَارَ كَأَنَّ الدَّعْوَى مَوْجُودَةٌ⁽²⁾.

- أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ بِإِقَامَةِ حُقُوقِهِ، كَانَ طَالِبًا لَهَا، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا إِقَامَتُهَا، فَلَا يَشْتَرِطُ فِيهَا إِقَامَةُ الدَّعْوَى مِنْ أَحَدٍ⁽³⁾.

إِلَّا أَنَّهُ شَرِطَتْ الدَّعْوَى فِي بَابِ السَّرِقَةِ؛ وَإِنْ كَانَ حَقًّا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَسْرُوقِ مِلْكًا لِغَيْرِ السَّارِقِ، شَرِطٌ تَحَقُّقِ كَوْنِ الْفِعْلِ سَرِقَةً شَرْعًا، وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إِلَّا بِالدَّعْوَى، فَشَرِطَتْ الدَّعْوَى لِهَذَا⁽⁴⁾.

الشرط الثاني: العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال، سواء

(1) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، 388/4.

(2) تبیین الحقائق، 229/4؛ البناية شرح الهداية، 167/9؛ درر الحكام

شرح غرر الأحكام، 384/2؛ الدر المختار، ص: 493.

(3) تبیین الحقائق، 229/4.

(4) بدائع الصنائع، 277/6.

أكان الحق مالاً، أو غير مال: كالنكاح، والطلاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والإقرار⁽¹⁾. دليل ذلك الكتاب، والمعقول:

أولاً: الكتاب: قوله تعالى: «وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ».

وقوله تعالى: «ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»؛ وجه الدلالة: حيث اشترط الله تعالى العدد، في الآيتين الكريميتين، فدل ذلك على أن العدد شرط في الشهادة فيما يطلع عليه الرجال.

ثانياً: المعقول: وذلك من وجهين:

- أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الشَّاهِدِ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ؛ لقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ». وَلَا تَقَعُ الشَّهَادَةُ لِلَّهِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ خَالِصَةً، صَافِيَةً عَنْ جَرِّ النَّفْعِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ مَنَفَعَةً لِلشَّاهِدِ مِنْ حَيْثُ التَّصْدِيقُ؛ لِأَنَّ مَنْ صَدَّقَ قَوْلَهُ، يَتَلَذَّذُ بِهِ، فَلَوْ قَبْلَ قَوْلِ الْفَرْدِ، لَمْ تَخُلْ شَهَادَتُهُ عَنْ جَرِّ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ، فَلَا يَخْلُصُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَشُرْطَ الْعَدَدُ فِي الشَّهَادَةِ؛ لِيَكُونَ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مُضَافًا إِلَى قَوْلِ صَاحِبِهِ، فَتَصْفُو الشَّهَادَةُ لِلَّهِ - عَزَّ شَانَهُ⁽²⁾.

- أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَرْدًا، يُخَافُ عَلَيْهِ السَّهْوُ، وَالنِّسْيَانُ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ

(1) بدائع الصنائع، 6/277؛ البحر الرائق، 7/57؛ رد المحتار على الدر

المختار، 5/462؛ الفتاوى الهندية، 3/451.

(2) بدائع الصنائع، 6/277.

مَطْبُوعٌ عَلَى السَّهْوِ، وَالْغَفْلَةِ، فَشَرَطُ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ؛ لِيُذَكَّرَ
الْبَعْضُ الْبَعْضَ، عِنْدَ اعْتِرَاضِ السَّهْوِ، وَالْغَفْلَةِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي إِقَامَةِ امْرَأَتَيْنِ، مَقَامَ رَجُلٍ فِي الشَّهَادَةِ: «أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى».

❖ والعدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال، يختلف باختلاف
المشهود به؛ لأنَّ المشهود به إما أن يكون حداً من الحدود،
وإما أن يكون غيره من بقية الحقوق.

فإن كان المشهود به حداً من الحدود: فإما أن يكون حد الزنا،
وإما أن يكون غيره من بقية الحدود.

أولاً: إن كان المشهود به حد الزنا: فإنه لا يثبت إلا بأربعة
شهود، من الرجال، الأحرار، المسلمين، العدول، باتفاق
العلماء⁽¹⁾. دليل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس،
والمعقول:

أولاً: الكتاب الكريم: قوله تعالى: «الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً». -وقوله
تعالى: «لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ»⁽²⁾.

-وقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا

(1) شرح مختصر الطحاوي، 6/177؛ المبسوط للسرخسي، 16/114؛

الهداية في شرح بداية المبتدي، 3/116؛ تبیین الحقائق، 3/164.

(2) سورة النور، جزء من الآية رقم: 13.

عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ» (1).

وجه الدلالة: في الآيات الثلاث نص على اشتراط أربعة شهود في الزنا؛ لأن لفظ (أَرْبَعَةٌ) نص في العددِ وَالذُّكُورَةِ، فدللت الآيات على أنه لا يثبت بأقل من أربعة من الرجال (2).

ثانياً: السنة: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِأَمْرَاتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ - فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ - : "أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءُ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" (3).

وجه الدلالة: حيث اشترط رسول الله ﷺ - لإثبات القذف بالزنا أربعة شهود من الرجال، وهذا مما لا خلاف فيه (4).

ثالثاً: الإجماع: قال ابن الهمام: "اشْتَرَطُ الْأَرْبَعَةَ، - أي أربعة شهود على الزنا - قَطْعِيَّةٌ، مُجْمَعٌ عَلَيْهَا" (5) وقال النووي: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ، ذُكُورٌ، عُدُولٌ" (6).

رابعاً: القياس: وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِي بَابِ الزَّنا، أَحَدُ نَوْعِي الْحُجَّةِ، فَتُعْتَبَرُ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ، ثُمَّ عُدُّ الْقَارِيرِ الْأَرْبَعَةِ،

(1) سورة النساء، جزء من الآية رقم: 15.

(2) العناية شرح الهداية، 369/7.

(3) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، 280/5، حديث رقم: 5634؛ وابن

حبان في صحيحه، 302/10، حديث رقم: 4451.

(4) شرح مختصر الطحاوي، 177/6.

(5) فتح القدير، 214/5.

(6) الإجماع، لابن المنذر، ص: 119.

شَرْطُ ظُهُورِ الزَّانَا عِنْدَنَا، فَكَذَا عَدَدُ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُدُودِ، فَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْعَدَدُ فِي الْإِقْرَارِ لظُهُورِهَا، فَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ (1).

خامساً: المعقول، ذلك من وجهين:

- أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ السِّرَّ عَلَى عِبَادِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ نَدَبٌ، وَنَمَّ مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ، وَفِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ، تَحْقِيقُ مَعْنَى السِّرِّ؛ إِذْ وَقُوفُ الْأَرْبَعَةِ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَةِ نَادِرٌ (2).

- أَنَّ عَدَدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الزَّانَا، ثَبَتَ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ خَبَرَ مَنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مِنَ الْكُذْبِ، لَا يَخْلُو عَنْ احْتِمَالِ الْكُذْبِ، وَعَدَدُ الْأَرْبَعَةِ فِي احْتِمَالِ الْكُذْبِ، مِثْلُ عَدَدِ الْمُتَنَّى، مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي حَدِّ التَّوَاتُرِ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ شَرْطًا بِنَصِّ خَاصٍّ، مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، فَبَقِيَ سَائِرُ الْأَبْوَابِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ (3).

قال القدوري - رحمه الله: "والشهادة على مراتب: منها الشهادة في الزنا، يعتبر فيها أربعة من الرجال، ولنا تقبل فيها شهادة النساء" (4).

ثانياً: إن كان المشهود به غير حد الزنا، من بقية الحدود - كحدِّ الشُّرْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَحَدِّ الْقَذْفِ - أَوْ الْقَصَاصِ: فَإِنَّهُ

(1) بدائع الصنائع، 6/277.

(2) المبسوط للسرخسي، 16/114؛ تبيين الحقائق، 3/165.

(3) بدائع الصنائع، 6/277.

(4) مختصر القدوري، ص: 219.

فَتَثْبِتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، لَا مَعَ رَجُلٍ، وَلَا مَفْرَدَاتٍ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ⁽¹⁾.

دليل ذلك الكتاب، والأثر، والقياس، والمعقول:

أولاً: الكتاب الكريم: قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾. وجه الدلالة: هذا النص بعمومه، نص في بيان العدد، والذكورة، والبلوغ، غير أن باب الزنا خرج بما تلونا، فبقي الباقي على تناوله⁽²⁾.

ثانياً: الأثر: عن الزهري، قال: "مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ: أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ"⁽³⁾. وجه الدلالة: دل الأثر على عدم قبول شهادة النساء في الحدود، والقصاص، وهو مما اشتهر، من لدن رسول الله ﷺ وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما.

ثالثاً: القياس: أن الحدود تؤثر فيها الشبهة، والنساء شهادتهن فيها شبهة؛ لأنها قائمة مقام شهادة الرجال، فلا تقبل فيما تدرئ بالشبهات، كالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي⁽⁴⁾.

رابعاً: المعقول، وذلك من وجهين:

(1) مختصر القدوري، ص: 219؛ المبسوط، للسرخسي، 114/16.

(2) العناية شرح الهداية، 370، 369/7.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 533/5، حديث رقم: 28714.

(4) تبين الحقائق، 208/4؛ الجوهرة النيرة، 225/2.

- وَلِأَنَّ الْحُدُودَ وَالْقَصَاصَ، مَبْنَاهُمَا عَلَى الدَّرءِ، وَالْإِسْقَاطِ بِالشُّبُهَاتِ، وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ؛ لِأَنَّهُنَّ جِبِلْنَ عَلَى السَّهْوِ، وَالْغَفْلَةِ، وَنَقْصَانَ الْعَقْلِ وَالْدِّينِ، فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّهَا تَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ⁽¹⁾.

- وَلِأَنَّ جَوَازَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ، عَلَى الْبَدَلِ مِنْ شَهَادَةِ الرِّجَالِ، وَالْإِبْدَالِ فِي بَابِ الْحُدُودِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، كَالْكَفَالَاتِ، وَالْوَكَالَاتِ⁽²⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "ومنها الشهادة ببقية الحدود، والقصاص، تقبل فيها شهادة رجلين، ولما تقبل فيها شهادة النساء"⁽³⁾.

❖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ سِوَى الْحُدُودِ، وَالْقَصَاصِ، مِنْ الْحَقُوقِ: فَتَقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، سِوَاءَ كَانَ الْحَقُّ مَالًا، أَوْ غَيْرَ مَالٍ، النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَوَالَةِ وَالْوَقْفِ، وَالصَّلَحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ⁽⁴⁾، دَلِيلُ ذَلِكَ الْكِتَابُ، وَالتَّائِرُ، وَالْمَعْقُولُ:

أَوَّلًا: الْكِتَابُ الْكَرِيمُ: - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وَجِهَ الدَّلَالَةُ: قَالَ الْجِصَّاصُ: "ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ شَهَادَتِهِنَّ مَعَ الرَّجُلِ، فِي سَائِرِ عُقُودِ الْمَدَايِنَاتِ،

(1) المبسوط، للسرخسي، 114/16؛ بدائع الصنائع، 279/6.

(2) بدائع الصنائع، 279/6؛ الهداية شرح بداية المبتدي، 116/3.

(3) مختصر القدوري، ص: 219.

(4) العناية، 370/7؛ الجوهرة النيرة، 225/2؛ فتح القدير، 370/7.

وهي كل عقد واقع على دين، سواء كان بدله مائلاً، أو بضائعاً، أو منافع، أو دم عمْد؛ لأنه عقد فيه دين⁽¹⁾. وقال السيوطي: "فيه قبول شهادة النساء، في الأموال، ونحوها"⁽²⁾.

ثانياً: الأثر: عن عطاء، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح⁽³⁾.

وجه الدلالة: أفاد الأثر قبول شهادة النساء مع الرجال، في العقود المدنية، ومثله لا يقال بالرأي.

ثالثاً: المعقول: أنها من أهل الشهادة؛ بالآية، فتقبل شهادتها؛ لوجود المشاهدة، والحفظ، والأداء، كالرجل. وزيادة النسيان، تجبر بزيادة العدد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَتَذَكَّرْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى﴾⁽⁴⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "وما سوى ذلك من الحقوق، تقبل فيها شهادة رجلين، أو رجلين وامرأتين، سواء كان الحق مائلاً، أو غير مال، مثل: النكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية"⁽⁵⁾.

❁ وَأَمَّا مَا لَا يَطْلَعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ: كَالْوِلَادَةِ، الْبَكَارَةِ، وَالْعُيُوبِ

(1) أحكام القرآن، للجصاص، 2/232.

(2) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، ص: 64، .

(3) أخرجه سيعد بن منصور في سننه، 1/256، حديث رقم: 875.

(4) الاختيار لتعليل المختار، 2/140.

(5) مختصر القدوري، ص: 219.

الْبَاطِنَةُ فِي النِّسَاءِ، فَالْعَدَدُ فِيهِ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَنَا، فَتَقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالتَّثْنَانِ أَحْوْطُ، وَالتَّلَاثُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَبِالْأَرْبَعِ يُخْرَجُ عَنِ الْخِلَافِ⁽¹⁾ دَلِيلُ ذَلِكَ السَّنَةِ، وَالتَّأَثُّرُ، وَالمَعْقُولُ، وَالمَقْيَاسُ:

أَوَّلًا: السَّنَةُ: عَنْ حَذِيفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ"⁽²⁾. وَجِهَ الدَّلَالَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ مُنْفَرَدَةً، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْعَدَدُ فِيمَا لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ.

ثَانِيًا: التَّأَثُّرُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "مَضَتْ السَّنَةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فِيمَا لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ، مِنْ وَلَادَاتِ النِّسَاءِ، وَعَيُوبِهِنَّ"⁽³⁾. وَجِهَ الدَّلَالَةُ: أَنَّ الْإِلْفَ وَاللَّامَ لِلْجِنْسِ، فَيَتَّأَوَّلُ الْوَاحِدَةَ، فَمَا فَوْقَهَا⁽⁴⁾.

ثَالِثًا: المَقْيَاسُ: أَنَّ مَا يَقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَدُ، كَرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ⁽⁵⁾.

رَابِعًا: المَعْقُولُ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:
- أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَلَا يُمْكِنُ الرِّجَالُ الْبَاطِلَاعُ

(1) الهداية شرح بداية المبتدي، 217/3؛ المحيط البرهاني، 309/8.

(2) أخرجه الطبراني في الأوسط، 189/1، حديث رقم: 596.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 329/4، حديث قم: 20708.

(4) العناية شرح الهداية، 373/7؛ فتح القدير، 373/7.

(5) الاختيار لتعليل المختار، 140/2.

عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النِّسَاءُ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، فَوَجِبَ قَبُولُ شَهَادَتِهِنَّ عَلَى الْإِنْفِرَادِ؛ تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَةِ (1).

– أَنَّ الذُّكُورَةَ سَقَطَتْ؛ لِيَخَفَ النَّظَرُ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ أَخْفَ، وَفِي إِسْقَاطِ الْعَدَدِ تَخْفِيفُ النَّظَرِ، فَيُصَارُ إِلَيْهِ (2).

تَنْبِيهِ: وَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَاحِدٌ بِالْوِلَادَةِ، يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، فَشَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْلَى (3).

قال القدوري – رحمه الله: "وتقبل في الولادة، والبكارة، والعيوب بالنساء، في موضع لا يطلع عليه الرجال، شهادة امرأة واحدة" (4).

الشرط الثالث: اتِّفَاقُ الشَّاهِدَتَيْنِ، فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ، فَإِنْ اخْتَلَفَتِ الشَّاهِدَتَانِ، لَمْ تُقْبَلْ (5) دَلِيلُ ذَلِكَ الْمَعْقُولُ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

– أَنَّ اخْتِلَافَ الشَّاهِدَتَيْنِ، يُوجِبُ اخْتِلَافَ الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَةِ، وَمَتَى اخْتَلَفَتِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ، لَمْ تُقْبَلْ (6).

– وَلِأَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الشَّاهِدَتَيْنِ، لَمْ يُوجَدْ إِلَّا أَحَدُ شَطْرَيْ

(1) الاختيار لتعليل المختار، 140/2.

(2) تبين الحقائق، 209/4؛ العناية، 373/7؛ البحر الرائق، 61/7.

(3) بدائع الصنائع، 278/6.

(4) مختصر القدوري، ص: 219.

(5) بدائع الصنائع، 278/6؛ لسان الحكام، ص: 247.

(6) بدائع الصنائع، 278/6؛ لسان الحكام، ص: 247.

الشَّهَادَةِ، وَلَا يُكْتَفَى بِهِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ⁽¹⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "ويعتبر اتفاق الشاهدين، في اللفظ، والمعنى، عند أبي حنيفة"⁽²⁾.

والاختلاف في الشهادتين: قَدْ يَكُونُ فِي جِنْسِ الْمَشْهُودِ بِهِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي قَدْرِهِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الزَّمَانِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ⁽³⁾.

أولاً: الاختلاف في جنس المشهود به: قَدْ يَكُونُ فِي الْعَقْدِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَالِ. أما الاختلاف في العقد: فهو أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ، وَالْآخَرُ بِالْمِيرَاثِ، أَوْ بِالْهَبَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ؛ لِاخْتِلَافِ الْعَقْدَيْنِ صُورَةً، وَمَعْنَى؛ فَقَدْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ غَيْرِ مَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ⁽⁴⁾.

وأما الاختلاف في المال: فهو أَنْ يَشْهَدَ أَحَدُهُمَا بِمَكِيلٍ، وَالْآخَرُ بِمَوْزُونٍ، فَلَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ⁽⁵⁾.

ثانياً: اِخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي قَدْرِ الْمَشْهُودِ بِهِ: فَتَحْوُ مَا إِذَا ادَّعَى

(1) بدائع الصنائع، 6/278.

(2) مختصر القدوري، 221.

(3) بدائع الصنائع، 6/278.

(4) بدائع الصنائع، 6/278.

(5) بدائع الصنائع، 6/278.

رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَلْفِي جَنِيهِ، وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْأُفَيْنِ، وَالْآخَرُ بِالْفِ، فَلَا تُقْبَلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَصْلًا؛ لِأَنَّ شَطْرَ الشَّهَادَةِ خَالَفَ الدَّعْوَى؛ فَانْفَرَدَتْ الشَّهَادَةُ عَنِ الدَّعْوَى، فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الدَّعْوَى، فَلَا تُقْبَلُ⁽¹⁾.

ثالثًا: اِخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي الزَّمَانِ، وَالْمَكَانِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي الْأَقَارِيرِ. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلَافًا فِي الْأَفَاعِيلِ.

فَإِنْ كَانَ فِي الْأَقَارِيرِ: كَانَ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقْرَ لِفُلَانٍ بِالْفِ جَنِيهِ فِي مَكَّةَ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقْرَ بِهَا فِي الْمَدِينَةِ. أَوْ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقْرَ لِفُلَانٍ بِالْفِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَقْرَ بِهَا فِي النَّحْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ⁽²⁾.

وَإِنْ كَانَ فِي الْأَفَاعِيلِ: مِنَ الْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ، وَالْعَصَبِ، وَإِنْشَاءِ الْبَيْعِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَنَحْوِهَا: كَانَ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فِي الْقَاهِرَةِ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فِي أَسْيُوطَ. أَوْ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فِي يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ⁽³⁾.

قَالَ الْقُدُورِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: "وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ: أَنْ زَيْدًا قُتِلَ يَوْمَ النَّحْرِ، بِمَكَّةَ. وَشَهِدَ آخَرَانِ: أَنَّهُ قَتَلَ يَوْمَ النَّحْرِ، بِالْكُوفَةِ،

(1) بدائع الصنائع، 6/278.

(2) بدائع الصنائع، 6/279.

(3) بدائع الصنائع، 6/279.

واجتمعوا عند الحاكم، لم يقبل الشهادتين⁽¹⁾.
 الشرط الرابع: الذكورة في الشهادة بالحدود، والقصاص، ولو
 في الأعضاء، فلا تقبل فيها شهادة النساء⁽²⁾. دليل ذلك: الأثر،
 والمعقول:

أولاً: الأثر: عن الزهري، قال: "مضت السنة من رسول الله ﷺ
 والخليفين من بعده: ألا تجوز شهادة النساء في الحدود".
 ثانياً: المعقول، وذلك من وجهين: أن الحدود، والقصاص،
 مبناها على الدرء، والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو
 عن شبهة، بخلاف سائر الأحكام؛ لأنها تجب مع الشبهة⁽³⁾.
 - أن جواز شهادة النساء، على البديل من شهادة الرجال،
 والإبدال في باب الحدود، غير مقبول⁽⁴⁾.

(1) مختصر القدوري، ص: 221.

(2) بدائع الصنائع، 6/279؛ رد المحتار على الدر المختار، 5/462.

(3) بدائع الصنائع، 6/279.

(4) بدائع الصنائع، 6/279.

الفصل الثالث

الشهادة على الشهادة

تمهيد: الشهادة أحد الوسائل التي يتوصل بها إلى أداء الحقوق لأصحابها، لكن قد يطرأ للشاهد من الأعذار ما لا يتمكن معه من أداء الشهادة، كسفر أو مرض، فيترتب على ذلك أن لا يتمكن صاحب الحق من إثبات حقه عند القاضي، وفي هذا من الحرج والمشقة ما فيه، وهو مرفوع من الشريعة الإسلامية؛ فقال سبحانه: {وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (1)، وعدم تمكن الشاهد من أداء شهادته، فيه إضرار بصاحب الحق، وإزالة الضرر يتحقق، بنقل شهادة الشهود إلى القاضي بأن يشهد غيرهم أنهم شهدوا بحق للغير على الغير.

حكم الشهادة على الشهادة: الشهادة على الشهادة جائزة باتفاق الفقهاء في الجملة، وهي مشروعة على خلاف القياس؛ استحساناً؛ والقياس يأبى جوازها؛ ؛ لتمكن الشبهة فيها؛ لأنّ الأخبار إذا تداولتها الألسن يتمكن فيها الزيادة والنقصان، إلا أنّ الفقهاء قالوا بجوازها استحساناً؛ لتعامل الناس بها، لإحياء الحقوق؛ لأن الأصل قد عجز عن أداء الشهادة، إما بموت أو سفر، أو غير ذلك، فلو لم تجز الشهادة على الشهادة لأدى إلى ضياع كثير من الحقوق (2).

(1) سورة الحج: الآية 78.

(2) المحيط البرهاني: 394/8؛ الاختيار: 150/2؛ البناية: 185/9.

ما تدخله الشهادة على الشهادة: ذكر فقهاء الحنفية ضابطاً لما تُقبل فيه الشهادة على الشهادة، ويُقضى بها فيه، فقالوا: "الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة"، وعبر بعضهم عن ذلك بلفظ: "الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق يثبت مع الشبهة"⁽¹⁾؛ فتجوز في الأموال، وفيما حكمه حكم الأموال.

وإنما لم تجز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص؛ لأن شهادة الأصول تثبت بها الحقوق مع وجود الشبهة، وهي احتمال كذب الشهود؛ لأن الشارع نص عليها، ومع ذلك فإن الشارع احتاط في الشهادة على الحدود والقصاص، فلم يقبل فيها بشهادة النساء، واشترط العدد في الشهود، وغير ذلك من وسائل الاحتياط. والشهادة على الشهادة فيها زيادة شبهة على الشهادة الأصلية؛ لأنها بدل عنها، والبدل أضعف من الأصل.

ولأن الشهادة على الشهادة بدل، واعتبار البدل في موضع يحتاط في إثباته، لا فيما يحتاط في إبطاله، والحدود والقصاص مما يحطاط في إبطالها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم"⁽²⁾.

وفي فتاوى قاضي خان: الشهادة على الشهادة جائزة في

(1) الهداية: 129/3؛ فتح القدير: 431/7.

(2) أخرجه الترمذي، والحاكم، والبيهقي، عن عائشة - رضي الله عنها.

الأقارب، والحقوق، وأقضية القضاة وكتبهم، وكل شيء، إلا الحدود والقصاص.

فلو شهد رجلان على شهادة رجلين أن فلانا سرق مالا، فلا يثبت الحد - وهو السرقة الموجبة للقطع - بشهادتهما، ولكن يثبت به أخذ المال؛ لأن الثابت بهذه الشهادة رد العين، ووجوب الضمان، وهو مما يثبت مع الشبهات.

وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا، لم يحد⁽¹⁾. قال القدوري - رحمه الله: "والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة، ولنا تقبل في الحدود والقصاص"⁽²⁾.

كيفية الشهادة على الشهادة: يتعلق بهذا العنوان أمران:

الأول: صورة تحمل الشهادة على الشهادة.

والثاني: صورة أداء الشهادة على الشهادة.

أما تحمل الشهادة، فله صورة مختصرة، وأخرى مطولة.

أما المختصرة، فهي أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: "أشهد على شهادتي أنني أشهد أن لفلان على فلان كذا"، أو يقول: "أشهد أن لفلان على فلان كذا، فأشهد على شهادتي بذلك".

وأما المطولة فهي أن يقول شاهد الأصل: "أشهد أن لفلان على فلان كذا، أشهدك على شهادتي هذه، وأمرُك أن تشهد على

(1) المبسوط للسرخسي: 69/9-70؛ فتح القدير: 431/7.

(2) مختصر القدوري: 221.

شهادتي هذه، فاشهد⁽¹⁾.

شروط تحمل الشهادة على الشهادة

يشترطُ لتحمل هذه الشهادة ما يشترط لتحمل الشهادة الأصلية من الشروط التي سبق ذكرها، ويزادُ عليها ما يلي: الإشهاد: فلا يصح التحمل بمجرد السماع دون الإشهاد، فلو قال شاهد الأصل: "أشهد أن فلان على فلان كذا"، فسمعه شخص، لكن لم يقل له شاهد الأصل: "أشهد أنت"، لم يصح التحمل، بخلاف سائر الشهادات، فإنه يصح التحمل فيها بمجرد معاينة الفعل، وسماع الإقرار من المقر، من غير إشهاد.

والعلة في اشتراط الإشهاد هنا أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول؛ فلا بد من الإنابة منهم، وذلك بالإشهاد، بخلاف سائر الشهادات؛ لأن تحمل الشاهد فيها بطريق الأصلالة بنفسه لا بغيره، فيصح التحمل فيها بمجرد المعاينة.

قال القدوري - رحمه الله: "وصفة الإشهاد أن يقول شاهد لشاهد الفرع: أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أقرّ عندي بكذا وأشهدني على نفسه، وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز⁽²⁾".

1- العدد: وهو أن يتحمل الشهادة من كل واحد من شاهدي الأصل اثنان، فلو تحمل من أحدهما واحد، وتحمل من الآخر

(1) بدائع الصنائع: 281/6.

(2) مختصر القدوري: ص: 221.

واحد لا يصح التحمل؛ لأن الشهادة حق ثابت في ذمة الشاهد،
والحقوق الثابتة في الذمم لا ينقلها إلى القاضي إلا شاهدان، ولو
تحمل اثنان من أحدهما شهادته، ثم تحملا من الآخر شهادته،
جاز التحمل؛ لأنه اجتمع على التحمل من كل واحد منهما
شاهدان⁽¹⁾.

قال القدوري - رحمه الله: "ويجوز شهادة شاهدين على
شهادة شاهدين، ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد"⁽²⁾.

صورة أداء الشهادة على الشهادة

إذا تحمل شهود الفرع الشهادة من شهود الأصل فإنهم يؤدونها
إلى القاضي بصيغة مختصرة أو مطوّلة. فالمختصرة أن يقول
شاهد الفرع عند القاضي: "شهد فلان عندي أن لفلان على فلان
كذا، وأشهدني على شهادته بذلك، فأنا أشهد على شهادته بذلك".
وأما المطوّلة فهي أن يقول: "شهد عندي فلان أن لفلان على
فلان كذا، وأشهدني على شهادته بذلك، وأمرني أن أشهد على
شهادته بذلك، وأنا أشهد الآن على شهادته بذلك"، ولو لم يقل: "وأمرني أن أشهد على شهادته بذلك"، جاز؛ لأن معنى التحمل
والإثابة يتحقق بقوله: "أشهدني على شهادته" فكان قوله: "وأمرني بذلك من باب التأكيد"⁽³⁾.

(1) بدائع الصنائع: 282/6.

(2) بدائع الصنائع: 281/6.

(3) بدائع الصنائع: 282/6.

قال القُدوري - رحمه الله: "ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهدُ أن فلانَ ابنَ فلانٍ أشهدني على شهادته أنه يشهدُ أن فلاناً أقرّ عنده بكذا، وقال لي: اشهدُ على شهادتي بذلك" (1).

متى تُقبل الشهادة على الشهادة: لا تُقبل الشهادة على الشهادة إلا على شهادة ميّت، أو غائبٍ بينه وبين القاضي مسافة تُقصر في مثلها الصلاة، أو مريضٍ لا يستطيع إتيان القاضي؛ وذلك لأن الشهادة على الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل، وبديل منها، وشهود الأصل إذا كانوا حضوراً، يمكنهم إتيان القاضي، فعليهم إقامتها، فلا يصح لبدلها حكمٌ مع وجود المبدل عنه، كما لا يصح للتيمم حكمٌ مع وجود الماء المفروض به الطهارة، ولا يصح صوم الكفارة مع وجود الرقبة، ونظائرها من المسائل كثير.

قال القُدوري رحمه الله: "ولا تُقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل، أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً، أو يمرضوا مرضاً لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم" (2).

(1) بدائع الصنائع: 281/6.

(2) مختصر القُدوري: ص 221.

الفصل الرابع

الرجوع عن الشهادة

المبحث الأول

تعريف الرجوع لغة، واصطلاحاً، وأصله، وركنه، والناتر المترتب عليه

الرجوع في اللغة: من رجع يرجع رجوعاً وهو العود، يقال رجع من سفره، ورجع عن الأمر إذا عاد، قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب⁽¹⁾.

واصطلاحاً: عرف السادة الحنفية: الرجوع عن الشهادة بأنه: نفي ما أثبتته⁽²⁾

الأصل في الرجوع: قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في كتابه إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفيه: "ولا يمنعك قضاء قضيتته، وراجعت فيه نفسك، وهديت فيه رشذك أن ترجع فيه إلى الحق"⁽³⁾.
ومن المعقول: فإنه أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصاً من عقاب الكبيرة⁽⁴⁾.

(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 220.

(2) الفتاوى العالمية = الفتاوى الهندية 3/ 534.

(3) سنن الدارقطني 5/ 368، السنن الصغير للبيهقي 4/ 133، معين

الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ص15.

(4) التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار 2/ 407.

ركن الرجوع: أن يقول الشاهد رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور فيما شهدت به، أو كذبت في شهادتي، أما لو أنكرها لم يكن رجوعاً⁽¹⁾.

شرط الرجوع عن الشهادة: أن يكون الرجوع في مجلس القاضي فلا يصح الرجوع في غيره⁽²⁾؛ وذلك لأن الرجوع فسخ للشهادة، فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس، وهو مجلس القاضي، ولأن الرجوع توبة، والتوبة على حسب الجناية، فالسر بالسر، والإعلان بالإعلان⁽³⁾ كما أن الرجوع ثبت ضد ما أثبتته بالشهادة، وفسخ الشيء إثبات ضده كفسخ البيع وأشباهه، فيعتبر بابتداء الشهادة، ثم شرط لابتداء الشهادة مجلس القاضي، فكذا يشترط لفسخها مجلس القاضي⁽⁴⁾.

التأثر المترتب على الرجوع عن الشهادة: إيجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها والضمنان مع التعزير إن رجع بعد القضاء وكان المشهود به مالا⁽⁵⁾.

(1) البحر الرائق 127/7، الفتاوى الهندية 3/ 534.

(2) الفتاوى العالمية = الفتاوى الهندية 3/ 534.

(3) الهداية في شرح بداية المبتدي 3/ 132. البناية 201/9.

(4) المحيط البرهاني 8/ 539.

(5) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 2/ 237.

وفي هذا يقول القدوري رحمه الله: "إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلّفوه بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم"⁽¹⁾.

المبحث الثاني

الرجوع عن الشهادة في اتلاف النفس

في حد القصاص: الحكم أن شهد رجلان على رجل أنه قتل فلانا عمدا فقصى القاضي بشهادتهما وقتل المشهود عليه ثم رجعا عن الشهادة:

الحكم من ناحية القصاص: لا يقتص منهم رغم أن شهادتهم وقعت تسببا للقتل؛ لأن وجوب القصاص يتعلق بالقتل مباشرة لا تسببا؛ وضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيد بالمثل شرعا، ولا مماثلة بين القتل مباشرة وبين القتل تسببا وهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه⁽²⁾

الحكم من ناحية الضمان: يغرمان الدية، في مالهما في ثلاث سنين لأنهما معترفان، والعاقلة لا تعقل الاعتراف ولا يجب عليهما الكفارة⁽³⁾

وفي هذا يقول القدوري رحمه الله "وإن شهدا بقصاص ثم

(1) مختصر القدوري ص223:

(2) الهداية 3/ 134، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/ 285.

(3) البناية شرح الهداية 9/ 201.

رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما⁽¹⁾
 في حد الزنا: اذا شهد اربعة على رجل بالزنا وهو مُحصن
 فرجم الرجل ثم رجعوا عن الشهادة جميعا فإنهم يحدون حد
 القذف، سواء رجعوا بعد القضاء أو قبل القضاء.
 أما قبل القضاء؛ فلأن كلامهم قبل القضاء انعقد قذفا لا شهادة،
 إلا أنه لا يقام الحد عليهم للحال لاحتمال أن يصير شهادة
 بقرينة القضاء، فإذا رجعوا فقد زال الاحتمال فبقي قذفا
 فيوجب الحد بالنص.
 وأما بعد القضاء؛ فلأن كلامهم وإن صار شهادة باتصال
 القضاء به فقد انقلب قذفا بالرجوع فصاروا بالرجوع قذفة
 فيحدون.
 ولو رجعوا بعد القضاء وإقامة الحد، فلا خلاف في أنهم
 يحدون إذا كان الحد جلداً، وإن كان رجماً فكذلك عند
 أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر رحمه الله⁽²⁾.
 أما من ناحية الضمان فإن الشهود يغرمون الدية إن رجعوا
 جميعاً، وإن رجع اثنان فعليهما نصف الدية وإن رجع أحدهم
 فانه يغرم ربع الدية⁽³⁾.

(1) مختصر القدوري ص224.

(2) اكتفيت بذكر الأقوال فقط دون التعرض لتفصيل الخلاف، وللمزيد
 مراجعة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/ 288،

(3) النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 804

المبحث الثالث

الرجوع عن الشهادة في إتلاف بعض النفس

إن شهد رجلان على رجل بالسرقة فحكم القاضي بقطع يده ثم رجعا عن الشهادة فانهما يغرمان مَال دِيَةِ الْيَدِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وإن رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ (1)

هل الرجوع قبل القطع يؤدي إلى درء الحد؟

ج: إن رجعا عن شهادتهما بعد الحكم بالسرقة قبل أن تقطع يده أو قالوا شككنا في شهادتنا درئ الحد، ولكن السرقة تسلم للمشهود له. (2)

المبحث الرابع

الرجوع عن الشهادة في إتلاف المَال

صورة المسألة: أن يشهد رجلان لرجل على رجل بألف جنيه مصري وقضى القاضي بشهادتهما والزمه المَال ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا المَال المشهود عليه، لأنهما تسببا للإتلاف على وجه التعدي وذلك يوجب الضمان (3) أما إن رَجَعَ أَحَدُهُمَا فإنه يغرم له نصف المَال، ولزيادة التوضيح أذكر بعض المسائل المندرجة تحت هذا الفرع في صورة طرح أسئلة والجواب عليها.

(1) الننف في الفتاوى للسغدي 2/ 804.

(2) المبسوط للمرخسي 9/ 169.

(3) العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي 7/ 481.

س: مالحكم لو شهد ثلاثة لرجل على رجل بألف جنيه ورجع منهم واحد؟

ج: لو شهد ثلاثة رجال لرجل على رجل بألف جنيه مصري ثم رجع ادهم فانه لا يغرم شيئاً لانه بقى اثنان يقطعان الحكم فان رجع آخر غرم هو والاول نصف المال فان رجع الثالث بعد ذلك غرموا المال كله ورجع بعضهم على بعض حتى يستووا في الغرم

س: مالحكم لو شهد أربعة أو خمسة أو أكثر لرجل على رجل بألف جنيه ورجع منهم واحد؟

لو كانوا اربعة أو خمسة أو أكثر فهو على قياس ما ذكرنا في جميع وجوه الرجوع عن الشهادة

س: مالحكم لو شهد رجل وامرأتان لرجل على رجل بألف جنيه ورجع منهم امرأة واحدة؟

ج: إن رجعت أحدهما فانها تغرم ربع المال فان رجعت الأخرى غرمت ربعاً آخر فان رجع الرجل بعد ذلك غرم انصف الباقي (1)

س: ما الحكم لو أن ثلاث نسوة ورجلاً أو أربع نسوة أو خمس أو أكثر ورجعت منهن واحدة؟

ج: إن رجعت منهن واحدة فانهن بمنزلة رجل واحد فان رجعت امرأة لم تغرم شيئاً فان رجعت أخرى وكن ثلاثاً فانها

تغرم مع الأولى ربع المال فإن رجع الثالثة غرم من كلهن نصف المال بينهما سواء ولو رجع الرجل فإنه يغرم نصف المال وحده. (1)

وفي هذا يقول القدوري رحمه الله " وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمننت ربع الحق وإن رجعنا ضمننا نصف الحق، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت أخرى كان على النسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف" (2)

(1) مختصر القدوري ص 223.

(2) المنتقى في الفتاوى للسغدي 2 / 806.

المبحث الخامس

الرجوع عن الشهادة في اتلاف المتاع

إذا شهد رجلان لرجل على رجل بدار أو بستان أو ثوب أو غير ذلك وقضى القاضي بذلك ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فانهما يغرمان قيمة ذلك، لأنهما تسببا في اتلاف المتاع الذي يملكه، وإن رجع أحدهما غرم نصف قيمته على ما ذكرناه

الرجوع عن الشهادة في اتلاف الحق

إذا شهد رجلان بالبيع والبائع ينكر والمشتري يدعى فقضى القاضي بذلك فإن المشتري لا يحل له أن ينتفع بذلك فإن رجعا عن شهادتهما ينظر فإن كان الثمن مثل قيمة المبيع أو أكثر فانهما لا يغرمان شيئا للبائع برجوعهما لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وإن كان الثمن اقل من قيمة المبيع غرما ذلك الفضل، -أي الزيادة- وإن رجع أحدهما غرم نصف ذلك الفضل⁽¹⁾.

ولو كان البائع هو المدعي للبيع والمشتري منكرًا فقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة نظرا إلى الثمن أيضا وإلى قيمة المبيع فإن كانت قيمة المبيع مثل الثمن أو أكثر لم يغرما للمشتري شيئا لانهما اعطياه مثل ما اخذا منه وإن كانت قيمة المبيع اقل من الثمن غرما له ذلك الفضل وإن كان القاضي لم يقض بشهادتهما شيئا حتى رجعا فإن القاضي

(1) النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 807.

بمسك عن القضاء ويعزرهما على ما يرى. (1).
وفي هذا يقول القدوري "وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر
ثم رجعا لم يضمننا وإن كان بأقل من القيمة ضمننا
النقصان" (2).

المبحث السادس

الرجوع عن الشهادة في النكاح

إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته، والمرأة تنكر وأتي
بالشهود على ذلك، أو أن المرأة قد تدعي أنها زوجة لفلان
وتأتي بالشهود على ذلك والرجل ينكر، ثم يرجع الشهود بعد
الشهادة.

الحالة الأولى: الرجل يدعي أنها زوجته والمرأة تنكر: أن
يشهد رجلان بنكاح امرأة لرجل والرجل يدعيها والمرأة تنكره
فقاضى القاضي بذلك ثم رجعا عن الشهادة فإن القاضي لا
يبطل النكاح برجوعهما ولا يغرمهما شيئا للمرأة شهدا بمهر
مثلا أو بأقل من ذلك أو بأكثر لانهما لم يتلفا عليها مالا (3)؟
ومعتمد المذهب في الزيادة أنهما يضمنانها؛ لأنهما أتلفاها من
غير عوض (4).

(1) النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 807.

(2) مختصر القدوري ص، 223.

(3) النتف في الفتاوى للسغدي 2/ 806.

(4) الهداية 3/ 133، المحيط البرهاني 8/ 543.

الحالة الثانية: المرأة تدعي أنها زوجته والرجل ينكر: إذا ادعت المرأة نكاحها على رجل، وأقامت على ذلك بينة، وقضى القاضي بالنكاح بينهما، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنه ينظر إلى مهر مثلها وإلى المسمى، فإن كان مهر مثلها مثل المسمى الذي شهد به الشهود أو أكثر من المسمى، فإنهما لا يضمنان للزوج شيئاً؛ لأنهما أوجبا المهر بعوض يعدله إن كان مهر مثلها مثل المسمى، وبعوض يزيد عليه إن كان مهر مثلها أكثر من المسمى، والإيجاب بعوض يعدله لا يوجب على الشاهد شيئاً. (1).

وفي هذا يقول القدوري رحمه الله " وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة" (2).

المبحث السابع

الرجوع عن الشهادة في الطلاق

إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلثاً، فقضى القاضي بشهادتهما، ثم رجع عن شهادتهما: فإنهما لا يصدقان على إبطال الطلاق، والدليل على ذلك ما يلي:

(1) الهداية 3/ 133، المحيط البرهاني 8/ 543.

(2) مختصر القدوري ص 223.

أن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة، لأنه لا يحتاج إلى اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع، ودليل ذلك أنه لو قال: كذبت في شهادتي، أو رجعت عنها: صح الرجوع وأيضاً: فإنه مكذب نفسه في الرجوع عن الشهادة الأولى، فلا يثبت حكم الرجوع في إبطال الطلاق، مع حصول إكذاب نفسه به بدءاً. وأيضاً: فقد اعترف على نفسه بشهادة زور، وذلك يمنعه قبول شهادة أخرى منه لو شهد بها، كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير برجوعه (1).

لكن هل يغرم الشاهدان ما غرم الزوج لها؟ فرق بين ما إذا كانت الزوجة قد دخل بها أو لا: فإن كان الزوج دخل بالمرأة فإنها لا يغرمان شيئاً لأنه قد حصل له بدل المهر وإن لم يكن دخل بالمرأة وقد فرض لها صداقها فإنهما يغرمان ما غرم لأمراته من نصف الصداق فإن رجع أحدهما غرم نصف ذلك وهو ربع الصداق وإن لم يكن فرض لها الصداق فإنهما يغرمان له ما غرم لأمراته من المتعة فإن رجع أحدهما غرم نصف المتعة (2).

وفي هذا يقول القدوري "وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر فإن كان الدخول لم

(1) شرح مختصر الطحاوي للجصاص 8/ 161.

(2) المنتقى في الفتاوى للسعدي 2/ 807.

الباب الثاني

الإقرار

الفصل الأول

الإقرار وركنه وشروطه

المبحث الأول: تعريف الإقرار وأدلة مشروعيته وركنه

أولاً: تعريف الإقرار وحكمه ودليل مشروعيته

1- تعريف الإقرار: الإقرار لغة: إفعال، من قر الشيء: إذا ثبت يقر، من باب ضرب وعلم وثبت وسكن، وأقره في مكانه بعد أن كان مزلزلاً، وأقر بحقه، وأذن واعترف، إذا فالإقرار، إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار والجدود⁽²⁾.

والإقرار اصطلاحاً: هو إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه⁽³⁾، وعرفه الزيلعي بأنه عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوق وهو ضد الجدود⁽⁴⁾

حكمه: ظهور ما أقر به ولزومه لا إثباته ابتداءً، لذلك لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه، والإنشاء يصح

(1) مختصر القدوري ص 224، 223.

(2) ينظر: الصحاح 788/2، لسان العرب 3592/5.

(3) البناية 9/ 428. الفتاوى الهندية 4/ 156.

(4) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 5/ 2.

مع الإكراه عندنا ولهذا قالوا لو أقر بمال لغيره كاذباً والمقول له يعلم أنه كاذب لا يحل له أخذه عن كره منه ديانة إلا أن يسلمه بطيب نفس، فيكون كالتملك المبتدأ (1)، ولهذا لا يكون الإقرار سبباً للملك، وبناء عليه لو ادعى المدعي على المدعى عليه شيئاً وجعل سببه إقراره فقط لا تسمع دعواه، مثلاً لو ادعى المدعى بقوله: إن هذا المال لي وإن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي تسمع دعواه، وأما إذا ادعى بقوله: إن هذا المال لي لأن هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد أقر بأنه مالي، فلا تسمع دعواه. (2)

دليل مشروعية الإقرار: من الكتاب، والسنة:

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: {أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا} وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ { (3)

ومن السنة: قبوله ﷺ للإقرار والالتزام به في باب الحدود «فإنه ﷺ رجم ماعزاً بإقراره والغامدية باعترافها، والحديث بنصه أخرجه مسلم في صحيحه (4).

(1) العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي 8/ 321.

(2) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/ 205.

(3) سورة آل عمران: 81

(4) صحيح مسلم 5/ 120، حديث رقم 1695.

س: هل الإقرار حجة قاصرة

ج: الإقرار حجة قاصرة، أما حجته فلما تبين أنه ملزم وغير الحجة غير ملزم، وأما قصوره فلعدم ولاية المقر على غيره لأنه يحتمل، والمحتمل لا يصلح حجة ولكن جعل حجة بترجيح جانب الصدق بانتفاء التهمة فيما يقر به على نفسه والتهمة باقية في الإقرار على غيره (1).

ثانيا: ركن الإقرار: للإقرار عند الحنفية ركن واحد، وهو: اللفظ الذي يدل على الإقرار، أو بعبارة أخرى: الصيغة فقط، صراحة كانت، أو دلالة، لفظاً كانت، أو كتابة مستبينة، أو إشارة مفهومة (2)، وهذا الركن قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة، وقد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً: فالصريح نحو أن يقول: لفلان علي ألف درهم؛ لأن كلمة علي كلمة إيجاب لغة وشرعاً قال الله تبارك وتعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً}.

المبحث الثاني

شروط صحة الإقرار

اشتراط الفقهاء لصحة الإقرار شروطاً، بعضها يرجع إلى المقر، وبعضها يرجع إلى المقر له، وبعضها يعود إلى المقر به، وبعضها يرجع إلى الصيغة.

(1) العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي 8/ 322.

(2) تكملة رد المحتار، 8/ 216؛ شرح مجلة الأحكام، 4/ 88.

أولاً: شروط صحة الإقرار التي ترجع إلى المقر: اشترط الفقهاء في المقر حتى يصح إقراره، خمسة شروط، تبينها السطور الآتية:

الشرط الأول: البلوغ، فلا يصح إقرار الصبي غير البالغ.
 الشرط الثاني: العقل، فلا يصح الإقرار من زائل العقل، أو ذاهبه، كالمجنون، والمعتوه عنها شديداً، والنائم، والمغمى عليه، والمبرسم⁽¹⁾، باتفاق الفقهاء؛ وذلك لما روي، عن النبي ﷺ قال: "رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".
 وجه الدلالة: بين الحديث الشريف أن الصبي والمجنون، والنائم، مرفوع عنهم القلم، فلا يؤخذان بشيء من الأقوال، ولا يترتب على قولهما أثر، والمبرسم، والمغمى عليه، في معنى المجنون والنائم، فيلحقان بهما في الحكم.
 -المعقول: كما مأن إقراره غير ملزم؛ لنقصان العقل، وزواله الذي هو مناط التكليف.

إقرار السكران تعريف السكران: هو من وصل إلى درجة الهذيان، فغاب عقله، واختلط كلامه، واختل تصرفه، بحيث لا يعي بعد إفاقته ما قاله، أو فعله.

(1) المبرسم: من به علة البرسام. والبرسام بكسر الباء: وجع يحدث في الدماغ؛ من ورم، ويذهب منه عقل الإنسان، وكثيراً ما يهلك. (طلبة الطلبة، ص: 124؛ التعريفات الفقهية، ص: 192).

ذهب الحنفية إلى أن إقرار السكران جائز مطلقاً إذا كان سكره بطريق محظور؛ وسواء كان إقراره بعين، أو دين، بمال، أو حد، بحق من حقوق الله تعالى، أم بحق من حقوق العباد، واستدلوا: بقول الله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى) (1) ففي الآية دليل على تكليف السكران والنهي لا يتناول إلا المكلف (2).

وكما أن طلاقه يقع؛ تغليظاً، وزجراً له، فكذا يقبل إقراره. حكم إقرار السكران بالحدود: لا يصح إقرار السكران بما يقبل الرجوع: كَالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، كحد الزنا، أو الشرب، أو السرقة، إلا أنه لو أقر بسرقة، يضمن المسروق؛ لأنه حق العبد، ولا يحد؛ لأنه حق الله تعالى. (3) وحثهم في ذلك - أَنَّ السَّكَرَانَ لَا يَكَادُ يَثْبُتُ عَلَى شَيْءٍ، فَأَقِيمَ السُّكْرُ مَقَامَ الرَّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرَّجُوعَ، فَلَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ (4).

الشرط الثالث: الطَّوعُ، والاختيار: فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُكْرَهِ باتفاق الفقهاء، سواء كان الإكراه ملجئاً، أو غير ملجئ (5)،

(1) النساء 53

(2) التجريد للقدوري 4930 / 10.

(3) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 3 / 5.

(4) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 3 / 5.

(5) الإكراه الملجئ: الَّذِي يَكُونُ بِالصُّرْبِ الشَّدِيدِ الْمُؤْدِي إِلَى إِتْلَافِ النَّفْسِ، أَوْ قَطْعِ عَضْوٍ. وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ: الَّذِي يُوْجِبُ الْغَمَّ وَالْأَلَمَ فَقَطْ،

وسواء كان المقر به مما يحتمل الفسخ، (كالبيع، والإجارة) أو لا يحتمل (كالزواج، والعنق، والطلاق)، وسواء كان مما يسقط بالشبهات كالحدود والقصاص، أو لا (كالمال أو حقوق العباد) (1) وذلك لقوله تعالى: "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ". (2).

وما رواه أبو ذر الغفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" (3).

- ولأن الإقرار إنما جعل حجة في حق المقر، باعتبار ترجيح جانب الصدق على الكذب، ولأن يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه، إذ هو قرينة قوية على أن المقر لم يقصد بإقراره الصدق فيما أقر به، وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه (4).

الشرط الرابع: أن لا يكون متهماً في إقراره (5): فلو كان متهماً في إقراره، فلا يصح، كإقرار المريض مرض

كالضرب غير المبرح، والحبس غير المديد. (مجلة الأحكام العدلية، ص: 185).

(1) بدائع الصنائع، 7/189؛ لسان الحكام ص312،

(2). [النحل: 106] "

(3) سنن ابن ماجه 1/ 659 ت، حديث رقم 2043.

(4) بدائع الصنائع، 7/189.

(5) بدائع الصنائع، 7/223.

الموت لو ارثه البار، أو الإقرار لمن بينه وبينه مخالطة، أو صداقة، أو ملاطفة؛ وذلك لأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه شهادة قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (1) والشهادة على نفسه إقرار، دل أن الإقرار شهادة، وأنها ترد بالتهمة².

وفي هذا يقول القدوري رحمه الله: "وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره فإذا قضيت شيء كان فيما أقر به في حال المرض وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورثة وإقرار المريض لو ارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة"⁽³⁾.

الشرط الخامس: أن يكون المقر عليه معلوما حتى لو قال: رجلان لفلان على واحد منا ألف درهم، لا يصح لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتمكن المقر له من المطالبة فلا يكون في هذا الإقرار فائدة فلا يصح (4).

(1) [النساء: 135].

(2) بدائع الصنائع، 7/223.

(3) مختصر القدوري ص100.

(4) بدائع الصنائع، 7/224.

ثانياً: شروط صحة الإقرار التي ترجع إلى المقر له: اشترط الفقهاء في المقر له شروطاً حتى يصح الإقرار له، بيانها كما هو آتي:

1- أن يكون المقر له معلوماً، موجوداً: سواء أكان موجوداً في الظاهر، أم حملاً في البطن: وعليه: فلو كان المقر له مجهولاً، فلا يصح الإقرار، مثال ذلك أن يقول: لواحد من الناس علي ألف جنيه، فلا يصح الإقرار؛ لأنه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره، فلا يفيد الإقرار، حتى لو عين واحداً بأن قال: عنيت به فلاناً، يصح.

الشرط الثاني: أن يكون المقر له معيناً تعييناً يتوقع معه طلب(1): فلو كان المقر له غير معين تعييناً يتوقع معه الطلب، بأن كان مجهولاً جهالة فاحشة، فلا يصح الإقرار، كما لو قال شخص: عليّ مال لرجل من أهل هذه البلدة، لم يصح الإقرار؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقاً، إذ لا يجبر المقر على البيان، من غير تعيين المستحق، فلا يفيد الإقرار شيئاً(2). أما إذا كانت الجهالة غير فاحشة، بأن قال: عليّ مال لأحد هؤلاء الثلاثة، أو لأحد هؤلاء العشرة، فيصح؛ لأن

(1) النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص: 291.

(2) تكملة فتح القدير 8 / 349.

صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَعْدُو مَنْ ذَكَرَهُ، وَفِي مِثْلِهِ يُؤْمَرُ بِالتَّذَكُّرِ؛
لِأَنَّ الْمُقَرَّ قَدْ يَنْسَى صَاحِبَ الْحَقِّ (1).

الشرط الثالث: أَنْ تَكُونَ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْمَلِكِ، أَوْ أَهْلِيَّةُ
اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ حِسًّا، وَشَرْعًا: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ
استحقاق المقر به، فلا يصح الإقرار، كما لو أقر لبهيمة
فقال: لهذه البهيمة، أو الدابة علي ألف جنيه وأطلق، ولم
يذكر سببًا فلا يصح الإقرار؛ لأن البهيمة ليست لها أهلية
ملك، ولا استحقاق، فلا تملك المال مطلقًا، ولا يد لها (2).

الشرط الرابع: أَنْ لَا يَكْذِبَ الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقَرِّ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ (3)
فَإِنْ كَذَبَهُ، بَطُلَ إِقْرَارُهُ، كما لو قال المقر: لمحمد علي ألف
جنيه، فقال المقر له: لَيْسَ لِي عَلَيْكَ شَيْءٌ، أَوْ لَا عِلْمَ لِي،
وَأَسْتَمِرَّ التَّكْذِيبَ، فَلَا يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ؛ لَأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلإِنْسَانِ
مِلْكٌ لَا يَعْتَرِفُ بِهِ .

ثالثًا: شروط المقر به: اشترط الفقهاء في المقر به ثلاثة
شروط حتى يصح الإقرار:

الشرط الأول: أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مُمْكِنًا عَقْلًا، وَشَرْعًا: فَإِنْ
كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ غَيْرَ مُمْكِنٍ عَقْلًا: كَأَنْ يَقْرَ بِأَبَوْتِهِ لِأَحَدِ النَّاسِ،
وَهُوَ مَعْطُوبُ النَّالَةِ مِنَ الْأَصْلِ، أَوْ كَانَ أَصْغَرَ مِنْ ابْنِهِ، أَوْ

(1) تبين الحقائق، 4/5.

(2) النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص: 291.

(3) القضائي في الفقه الإسلامي، ص: 291.

أن فلاناً أقرضه وزن جبل ذهباً، أو ملء الأرض فضة، أو أن فلاناً أقرضه ألف جنيه يوم كذا، ثم تبين أن المقرض مات قبل هذا اليوم، فلا يصح الإقرار؛ لأن المقر به محال عقلاً. أو كان المقر به غير ممكن شرعاً: كما لو مات شخص، وترك ابناً وبناتاً، فأقر الأب أن الميراث بينهما بالسوية، فأقراره باطل؛ لأن الحكم الشرعي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

الشرط الثاني: أن لا يتعلق به حق للغير: فإن تعلق به حق الغير، أو كان مشغولاً بحق الغير لم يصح (1).
الشرط الثالث: أن يكون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له فلو أقر بشيء حقير، لا قيمة له عند الناس، فلا يصح.

رابعاً: شروط صحة الإقرار التي ترجع إلى الصيغة

اشتراط الفقهاء في صيغة الإقرار شرطين:

الشرط الأول: أن تكون الصيغة منجزةً، مثبتة للحق على سبيل الجزم، واليقين (2)، فلو علقت صيغة الإقرار على مشيئة، أو شرط، لم يصح الإقرار.

(1) بدائع الصنائع، 224/7.

2 النظام القضائي في الفقه الإسلامي، ص: 293؛ وسائل الإثبات في

الفقه الإسلامي، ص: 162.

الشرط الثاني: أن تكون صيغة الإقرار أمام القاضي: إن كان الإقرار يتعلق بحد من حدود الله الخالصة (1).

الفصل الثاني

الإقرار بالأموال

يصح الإقرار بالأموال، سواء أكان المال عيناً من الأعيان، أم ديناً ثابتاً في الذمة، وسواء أكان المقر به معلوماً أم مجهولاً باتفاق العلماء؛ لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ وذلك لأن الحق قد يلزم الإنسان مجهولاً بأن أتلف مالاً لا يدري قيمته، فلا تمنع الجهالة صحة الإقرار.

الثاني: أن الإقرار إخبار عن كائن، أو عن ثبوت الحق، وذلك قد يكون معلوماً، وقد يكون مجهولاً، وحينئذ يصح أن يقول المقر: علي شيء، أو حق، فيلزمه مجهولاً، ثم يطالب ببيان المجهول؛ ليتمكن الغير من استيفائه، فإن لم يبين، أجبره القاضي على البيان بالحبس، ونحوه.

1 وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، ص: 162.

الفصل الثالث

الرجوع عن الإقرار

الرجوع عن الإقرار: قَدْ يَكُونُ صَرِيحًا: كَأَن يَقُولَ: رَجَعْتُ عَنْ إِقْرَارِي، أَوْ كَذَبْتُ فِيهِ، أَوْ دَلَالَةً: كَأَن يَهْرُبَ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ؛ إِذِ الْهَرَبُ دَلِيلُ الرَّجُوعِ (1). كما أن الإقرار إما أن يكون بحق من حقوق العباد. وإما أن يكون بحق من حقوق الله تعالى. وحقوق الله تعالى: إما أن تكون حقوقاً خالصة تدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطها: لحد الزنا والشرب والردة. وإما أن تكون حقوقاً لا تدرأ بالشبهات: كالزكاة والكفارات، فإن كان الإقرار بحق من حقوق العباد، أو بحق من حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات: كالقصاص، والقتل، والزكاة، والكفارات، فإنه لا يقبل الرجوع عنها باتفاق الفقهاء. والدليل على ذلك من المعقول، وذلك من وجهين: - أَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لغيره، فَلَمْ يَمْلِكْ إِسْقَاطَهُ بِغَيْرِ رِضَاةٍ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَا يَحْتَمِلُ السَّقُوطَ بِالرَّجُوعِ (2).

- وَلِأَنَّ حَقَّوْقَ الْعِبَادِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمَشَاحَةِ، وَمَا دَامَ قَدْ ثَبَتَ لَهُ، فَلَا يُمْكِنُ إِسْقَاطُهُ بِغَيْرِ رِضَاةٍ.

(1) شرح أدب القاضي: للخصاف، ص 632، بدائع الصنائع 61/7.

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 61 / 7.

أما إن كان الإقرار بحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي تَسْقُطُ بِالشَّبْهِةِ: كَالزَّنا والرَّدة، والشَّرب، فقد ذهب الحنفية إلى أنه يقبل الرجوع، ويسقط الحد، سواء كان الرجوع بالقول، أو بالفعل - بِأَنْ يَهْرُبَ عِنْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ - وسواء كان الرجوع قبل القضاء، أم بعده، قبل إقامة الحد، أم في أثناءه. (1).

وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبِلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ" (2). وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لقن ماعزا الرجوع عن الإقرار بالزنا، فقال: لعلك قبلت، أو غمزت أو نظرت، فلو لم يكن محتملا للسقوط بالرجوع - ما كان للتلقين معنى (3).

- ما رواه أبو داود في سننه، من حديث هزال بن رثاب، أن ماعزا لما أمر رسول الله ﷺ برجمه، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رَجِمَ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، جَزَعُ، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ، وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوُظِيفٍ

(1) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ص 632 ت الأفغاني،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7 / 61.

(2) صحيح مسلم 5 / 120، حديث رقم 1695.

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7 / 61.

بغير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: "هَلَا تَرَكَتُمُوهُ؛ لَعَلَّه أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ" (1).

الباب الثالث

الرهن

الفصل الأول: تعريف الرهن، ومشروعيته، وحكمة مشروعيته، وأركانه، وصفته

المسألة الأولى: تعريف الرهن: الرهن لغة: الحبس مطلقاً، سواء أكان حسيّاً كحبس الأعيان، أم معنوياً كحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (1). أي حبيسة بما اقترفت من الذنوب والآثام. جاء في الحديث: "نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضي عنه دينه". مرهونة: أي محبوسة (2). ويطلق الرهن لغة أيضاً علي: (العين المرهونة).

واصطلاحاً: عرف الرهن بعدة تعريفات منها:

1- حبس الشيء بحق يمكن استيفاءه منه، كالدين.

(1) مسند أحمد 36/ 215 ط الرسالة، وهو حديث صحيح لغيره، وهذا

إسناد حسن. سنن أبي داود 6/ 471 ت الأرئوط.

(1) سورة المدثر آية 38.

(2) الترمذي 3/ 280، وردت (معلقة) بدل (مرهونة).

2- حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استفاؤه منه كلاً أو بعضاً.

3- جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها، أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء.

أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين، بحيث يمكن أخذ الدين كله، أو بعضه من تلك العين. أو هو عقد وثيقة بمال، ومعنى «وثيقة» أي متوثق بها، فقد توثق الدين وصار مضموناً محكماً بالعين المرهونة.

هذا ويسمى معطي الرهن: راهناً، ويسمى آخذه: مرتهناً، وتسمى العين المرهونة: رهناً، ومرهوناً ورهينة.

فالرهن: هو الشيء المحبوس وهو المرهون.

والراهن: مالك الرهن وهو المدين الذي أعطى الرهن.

والمرتهن: هو آخذ الرهن وحابسه وهو الدائن. ورهن:

أعطى الرهن، وارتهن إذا قبض الرهن وأخذه⁽³⁾.

المسألة الثانية: مشروعية الرهن:

الرهن مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ»⁽²⁾ أمر إرشاد للمؤمنين لا إيجاب؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَ

(3) راجع: أنيس الفقهاء: أحمد الكبيسي، ص 289.

(2) سورة البقرة، من الآية 283.

أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»⁽²⁾ ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب، ولما كانت الكتابة غير واجبة؛ بدليل قوله تعالى: «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا»⁽²⁾ فكذاك بدلها، وهو الرهن.

والرهن مشروع باتفاق الفقهاء في الحضر والسفر، خلافاً لمجاهد والظاهرية؛ لإطلاق مشروعيته في السنة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالباً.

ولا يشترط أيضاً عدم وجود الكاتب؛ لثبوت جوازه في السنة مطلقاً، فالآية أرادت إرشاد الناس إلى وثيقة ميسرة لهم عند فقدان كاتب يكتب لهم الدين⁽³⁾.

وأما السنة: فمنها ما رواه البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله ﷺ اشترى طعاماً من يهودي، ورهنه درعاً من حديد"⁽³⁾ وجه الاستدلال: أن هذا الحديث واضح في جواز الرهن في كل ما كان مالاً متقوماً.

(2) سورة البقرة، من الآية 283.

(2) سورة البقرة، من الآية 283.

(3) الفقه الإسلامي وأدلته: للزحيلي، 5/181، 5/182.

(3) أخرجه البخاري، الفتح 5/53.

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً⁽⁵⁾.

المسألة الثالثة: حكمة مشروعية الرهن: شرع الرهن لما فيه من فائدة متحققة لكل من المرتهن، والراهن: إذا الأول- وهو المرتهن- يأمن على دينه من الضياع. والثاني - وهو الراهن- يحصل على ثقة الدائن، فيقلل هذا من مخاصمته، والثقة في المعاملات سبيل الزواج، وتعود بالفائدة على المتعاقدين⁽¹⁾.

وشرع الرهن أيضاً: وثيقة للاستيثاق؛ ليضمن الراهن بحبس عينه، فيسارع إلى إيفاء الدين؛ ليفتكها، فينتفع بها، ويصل المرتهن إلى حقه⁽²⁾.

المسألة الرابعة: أركان الرهن:

أركان الرهن عند الحنفية اثنان: هما الإيجاب، والقبول، وهو أن يقول الراهن: رهنتك هذا الثوب مثلاً بمالك علي من الدين، فيقول المرتهن: ارتهنت، أو قبلت، أو رضيت، وما يجري مجراه. وقيل: ركنه الإيجاب فقط، والقبول

(5) المغني: لابن قدامة 4/ 362؛ المعاملات في الشريعة الإسلامية، لأحمد أبي الفتح، ص: 295.

(1) المعاملات، لأبي الفتح، ص: 592.

(2) الاختيار لتعليل المختار، ج 2، ص: 93.

شرط، وعلى كل حال فلا يتم إلا بالقبض، لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ﴾. وهذا محل اتفاق.

قال القدوري رحمه الله: "الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول، ويتم القبض"⁽¹⁾.

هذا. ولفظ الرهن ليس بشرط لصحة الرهن، فلو اشترى شخص من آخر شيئاً بعشرة دراهم مثلاً، ثم دفع المشتري إلي البائع ثوباً وقال له: أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن؛ لأنه أتى بمعنى العقد، والعبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني⁽³⁾.

وكما ينعقد الرهن باللفظ، ينعقد بالكتابة، وبالإشارة المفهومة للأخرس.

المسألة الخامسة: صفة عقد الرهن: عقد الرهن عقد جائز غير لازم قبل التسليم، كعقود التبرعات الأخرى؛ لأنه معتبر منها؛ لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء، والقاعدة (لا يتم التبرع إلا بالقبض).

المسألة السادسة: لزوم الرهن بالقبض: لا يتحقق لزوم الرهن إلا بالقبض لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾⁽³⁾.

(1) مختصر القدوري، ص: 92.

(3) البدائع 135/6؛ المعاملات الشرعية، للعلامة علي الخفيف.

(3) سورة البقرة، من الآية: 283.

إذ المعنى فارهن رهان مقبوضة؛ لأن المصدر المقترن
بالفاء في جواب الشرط هو في معنى الأمر، أي «فارهنوا»
فهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام، إلا
إذا حصل تسليم العين المعقود عليها (وهي هنا الرهن).

فلا تترتب آثار الرهن إلا بالقبض، فلا يختص المرتهن
بشمن العين المرهونة، ولا يثبت له حق الامتياز على غيره
من الدائنين إلا بالقبض، وإذا سلم الراهن للمرتهن تم العقد
ولزم من جانب الراهن، لا من جانب المرتهن، حتى جاز
للمرتهن أن يفسخه، ويرد المرهون إلى مالكه. فلزوم
الرهن هو بالنسبة للراهن لا للمرتهن، فلا يملك الراهن
فسخه؛ لأنه عقد وثيقة بالدين، ويملك المرتهن فسخه في أي
وقت؛ لأن العقد لمصلحته.

قال القدوري رحمه الله: "إذا قبض المرتهن الرهن
محوراً مفرغاً مميزاً، تم العقد فيه، وما لم يقبضه، فالراهن
بالخيار: إن شاء سلمه، وإن شاء رجع عن الرهن، فإذا
سلمه إليه، وقبضه، دخل في ضمانه، "وإذا اتفقا على
وضع الرهن على يد عدل جاز"⁽¹⁾.

(1) مختصر القدوري، ص: 92.

الفصل الثاني

شروط صحة الرهن

شروط صحة الرهن أربعة أنواع: منها ما يرجع إلى نفس العقد. ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين. ومنها ما يرجع إلى الشيء المرهون. ومنها ما يرجع إلى المرهون به.

أولاً: الشروط التي ترجع إلى نفس العقد: ألا يكون الرهن معلقاً على شرط، ولا مضافاً إلى وقت؛ لأن في الرهن والارتهان معني الإيفاء والاستيفاء، فيشبه البيع، وأنه لا يحتمل التعليق بشرط والإضافة إلى وقت، كذا هنا.

ثانياً: الشروط التي ترجع إلى المتعاقدين (الراهن والمرتهن): فيشترط أن يكونا عاقلين، أو مميزين، فلا يجوز الرهن والارتهان من المجنون، والصبي غير المميز، أو الذي لا يعقل، فالمجنون، والصبي غير المميز، لا يجوز منهما الرهن، والارتهان وكذا فاقد العقل.

ولا يشترط البلوغ، فيجوز الرهن من الصبي المميز المأذون له في التجارة؛ لأن ذلك من توابع التجارة. ويصح رهن الصبي المميز، والسفيه، موقوفاً على إجازة وليه؛ لأن الرهن من توابع التجارة.

ويشترط أن يكون القابض للرهن، وهو المرتهن، أو من يقوم مقامه أهلاً للقبض، بأن يكون عاقلًا مميزًا، ولا يشترط فيه البلوغ.

ثالثاً: الشروط التي ترجع إلى المرهون؛ لتعقاد الرهن:

يشترط في المرهون ما يشترط في المبيع حتى يمكن بيعه، لاستيفاء الدين منه؛ إذ القاعدة: أن كل ما يصح بيعه، يصح رهنه، وبالعكس، وإليك هذه الشروط:

1- أن يكون المرهون محلاً قابلاً للبيع: بأن يكون موجوداً وقت العقد، مالاً مطلقاً، متقوماً، مقدور التسليم. وعليه: فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد.

ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم، كما إذا رهن ما تلد أغنامه هذه السنة، ونحو ذلك، ولا رهن الميتة والدم؛ لانعدام ماليتها، ولا رهن صيد الحرم والإحرام؛ لأنه ميتة، ولا رهن الحر؛ لأنه ليس بمال أصلاً، ولا رهن جزء شائع من عقار؛ لأن قبض الجزء الشائع لا يتصور بانفراده، وقبض الكل لا يقتضيه العقد⁽¹⁾، ولا يجوز رهن الخمر والخنزير من المسلم، سواء كان العاقدان، أو أحدهما مسلماً؛ لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلم فإذا كان الراهن والمرتهن ذميّين، صح الرهن فيما بينهما في الخمر والخنزير.

هذا ولا يشترط في الشيء المرهون أن يكون مملوكاً للراهن. بل يجوز أن يكون الرهن مستعاراً من مالك أجنبي بإذنه، فيصح رهن المستعار بإذن المعير.

(1) البدائع 135/6؛ الاختيار لتعليل المختار، ج 2، ص: 95.

2_ أن يكون الرهن مفرغاً أي غير مشغول بما ليس
بمرهون، فلا يصح قبض الدار التي فيها أمتعة الراهن.
4_ أن يكون الرهن مفرزاً مميزاً، فلا يصح قبض
المشاع⁽²⁾.

قال القدوري: "فإذا قبض المرتهن الرهن محوزاً، مفرغاً،
مميزاً، تم العقد فيه... ولا يجوز رهن المشاع"⁽¹⁾.

رابعاً: الشروط التي ترجع إلى المرهون به:

المرهون به: هو الحق الذي أعطي بسببه الرهن.
ويجوز أخذ الرهن بكل حق لازم في الذمة، أو آيل إلى
اللزوم، ويشترط في الحق المرهون به ما يأتي:
الشرط الأول: أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه،
مثل القرض، وثن المبيع المؤجل؛ لأنه لو لم يكن واجب
التسليم فلا محل لأن يعطي به رهناً لتوثيقه، إذا لا إلزام
على المطالب بالحق حتى يستوجب التوثيق به⁽³⁾.

(2) الاختيار، 93/2؛ الباب شرح الكتاب، ص 125 ؛ حاشية
الطحطاوي، 250/4؛ حاشية ابن عابدين، 331/5.

(1) مختصر القدوري، ص: 92.

(3) الفقه الإسلامي وأدلته، 193/5 _ 194؛ المعاملات الشرعية،
للخفيف، ص: 435، 436.

الشرط الثاني: أن يمكن استيفاء الدين من المرهون، فإن لم يمكن الاستيفاء منه لم يصح الرهن؛ لأن الارتهان استيفاء، فإذا انتفي الاستيفاء انتفي الرهن والغرض منه (4).

الشرط الثالث: أن يكون الحق المرهون به معلوماً: فلا يصح الرهن بحق مجهول، مثل أن يسلمه رهناً بأحد الدينين دون أن يعينه، كأن اشتري منه صفتين مختلفي الثمن المؤجل، وسلم المشتري رهناً للبائع بأحد هذين الثمنين ولم يعينه (1).

(4) البدائع، 6/ 143، والمراجع السابقة.

(1) المراجع السابقة.

الفصل الثالث

آثار عقد الرهن

المسألة الأولى: الآثار التي تترتب على تسليم الرهن إلى

المرتتهن:

1- حق حبس الرهن: فيكون للمرتتهن حق حبسه، إلى أن يستوفي الدين الذي رهن به. ولا يجوز له أن يحبسه بدين آخر، لم يرهن به، سواء أكلن سابقاً على الرهن أم لاحقاً له، فيترتب على صحة الرهن، ثبوت حق المرتتهن في حبس العين المرهونة، على وجه الدوام، وعدم تمكين الراهن من استرداد المرهون قبل وفاء الدين؛ لأن الرهن شرع للتوثق، والتوثق لا يكون إلا بحبس ما يكون به الوفاء، وهو المال المرهون.

2- حق المطالبة بالدين مع الرهن: للمرتتهن حق المطالبة بدينه متى كان حالاً؛ لأن الرهن للتوثيق، والدين معه قائم، فإذا حل الدين كان لصاحبه حق المطالبة به.

3- اختصاص المرتتهن بالرهن: فالمرتتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، إذا كان الرهن لا يفي بسائر الديون، فيستوفي دينه أولاً، وما بقي يكون لسائر الغرماء⁽²⁾.

(2) المعاملات، للشيخ علي الخفيف، ص: 437؛ المعاملات، لأبي

الفتح، ص: 596 وما بعدها؛ الهداية، 4/ 141 .

4- حفظ المال المرهون: بناء على ثبوت حق حبس المال المرهون عند المرتهن في مذهب الحنفية، فإن المرتهن يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مال نفسه عادة، فيحفظه بنفسه، وزوجته، وولده، وخادمه، إذا كانا يسكنان معه، وبأجيريه الخاص؛ لأن عين المرهون أمانة في يد المرتهن، فصار من هذه الناحية كالوديعة، يحفظه كما تحفظ.

قال القدوري - رحمه الله تعالى: "وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، وزوجته، وولده، وخادمه الذي في عياله"⁽¹⁾.
5- بيع الرهن لأداء الحق: اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكاً للراهن بعد تسليمه للمرتهن، كما دلت السنة: «لَا يَغْلُقُ الرِّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ» فتكون ولاية بيع المرهون للراهن، لا لغيره، لكن لتعلق حق المرتهن به، وثبوت حق حبسه إياه، وكونه أولى بمالائه من الراهن، يتوقف نفاذ بيعه على رضا المرتهن وإذنه، ما دام حقه قائماً، وعليه يكون للراهن باتفاق الفقهاء أن يبيع الرهن بإذن المرتهن، ويسدد الدين.

المسألة الثانية: البيع الجبري للرهن:

الرهن وثيقة بالدين كما عرفنا، والهدف المقصود من الرهن، هو الحصول على الدين من ثمن المرهون، إذا لم

(1) مختصر القدوري، ص: 93، 94.

يوف الراهن المدين بالدين عند حلول أجل الدين، عن طريق بيع المرهون، ويتم البيع في الأحوال العادية بواسطة الراهن، أو وكيله؛ لأنه هو المالك للمرهون.

وبناء عليه، إذا حل أجل الدين، طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين، فإن استجاب إلى طلبه، فوفى، فبها ونعمت، وإن لم يستجب لمطل، أو إفسار، أو لغية، أجبره القاضي على البيع، وعزره وحبسه.

وهل للقاضي أن يبيع دون إذن الراهن: عند صاحبين يجوز للقاضي بيع الرهن؛ لسداد الدين عند امتناع الراهن من البيع بدون حاجة إلى إجباره بحبس، أو ضرب، أو تهديد، وقال أبو حنيفة: ليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن من غير رضا الراهن، لكنه يحبس الراهن، حتى يبيعه بنفسه.

فالخلاصة أنه: إذا حل الدين، لزم الراهن بطلب المرتهن إيفاء الدين؛ لأنه دين حال، فلزم إيفاءه كالذي لا رهن به، فإن لم يوف كل الدين، أو بعضه، وجب عليه بيع المرهون بنفسه، أو بوكيله بإذن المرتهن؛ لأن له حقاً فيه، ويقدم في ثمنه المرتهن على سائر الغرماء.

فإن امتنع عن وفاء الدين وبيع المرهون لأداء الدين من ثمنه:

عند أبي حنيفة: حبسه القاضي إن ظهر مطله، ولا يبيع القاضي المرهون لأنه نوع حجر، وفي الحجر إهدار

أهليته، فلا يجوز، ولكنه يديم الحبس عليه حتى يبيعه؛ دفعاً للظلم. فليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن من غير رضا الراهن، لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه. وعند صاحبين: يبيع الحاكم المرهون جبراً، ويقضى الدين من ثمنه؛ لأنه تعين طريقاً لأداء الواجب.

المسألة الثالثة: تأثير الموت في الرهن: لا تأثير لوفاة كل من الراهن والمرتهن في الرهن.

فإذا توفي الراهن، لم يكن لوارثه طلب العين المرهونة من المرتهن، إلا إذا أوفي الدين، لأنه ورث العين معلقة بحق المرتهن، فلا يستخلصها إلا بإيفائه حقه.

وإذا مات المرتهن، قام وارثه في احتباس الرهن مقامه؛ لأن حق الاحتباس حق مالي، ينتقل إلى الورثة كسائر الحقوق المالية⁽¹⁾.

المسألة الرابعة: حكم الانتفاع بالرهن:

انتفاع الراهن بالرهن في مدة الرهن: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداماً، أو ركوباً، أو لبساً، أو سكنى، وغيرها، إلا بإذن المرتهن.

انتفاع المرتهن بالرهن في مدة الرهن: ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن، وإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون، فاختلف الحنفية:

(1) أحكام المعاملات الشرعية، للعلامة علي الخفيف، ص: 431.

1-منهم من أجازَه مطلقاً.

2-ومنهم من منعه مطلقاً؛ لأنه رباً أو فيه شبهة الربا، والاذن أو الرضا لا يحل الربا، ولا يبيح شبهته.

3-ومنهم من فصل فقال: إن شرط الانتفاع على الراهن في العقد، فهو حرام؛ لأنه ربا، وإن لم يشرط في العقد، فجائز؛ لأنه تبرع من الراهن للمرتهن. والاشتراط كما يكون صريحاً، يكون متعارفاً، والمعروف كالمشروط.

والغالب من أحوال الناس أنهم عند دفع القرض إنما يريدون الانتفاع، ولولاه لما أعطوا الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يُعَيَّن المنع، كما قال ابن عابدين.

قال في التتارخانية ما نصه: «ولو استقرض دراهم، وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين، حتى يوفيه دينه، أو داره ليسكنها، فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة، إن استعمله، فعليه أجر مثله، ولا يكون رهناً». وعليه فما اعتاده الناس من رهن الدور ونحوها على أن ينتفع بها المرتهن، ريثما يرد إليه الراهن دينه، وهو قرض، غير جائز.

المسألة الخامسة: بيع الراهن للمرهون قبل فك الرهن:

ليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه، ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن، إن أجازَه جاز، لأن عدم النفاذ لمكان حقه،

فإذا رضي المرتهن زال المانع، وكان الثمن رهناً، سواء شرط المرتهن عند الإجازة كون الثمن رهناً أولاً. وروي عن أبي يوسف: أن الثمن لا يكون رهناً إلا بالشرط؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة، بل المرهون هو المبيع، وقد زال حقه عنه بالمبيع إلا إذا شرط عند الإجازة أن يكون الثمن مرهوناً فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببذل. وجه ظاهر الرواية: أن الثمن بدل المرهون، فيقوم مقامه، وبه تبين أنه مازال حقه بالمبيع، لأنه زال إلى خلف، والزائل إلي خلف قائم معنى، فيقام الخلف (الثمن) مقام الأصل (2).

قال القدوري: "وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فالبيع موقوف، فإن أجازره المرتهن، جاز، وإن قضاه الراهن دينه، جاز البيع" (1).

المسألة السادسة: هناك الرهن: اليد على المرهون بعد لزوم العقد، وقبض المرتهن للرهن يد ضمان، فيضمن المرتهن إن هلك بيده بالأقل من قيمته، ومن الدين، فإن تساوى كان المرتهن مستوفياً حقه، وإن زادت قيمة المرهون كانت الزيادة أمانة بيده، وإن نقصت عنها سقط بقدره من الدين، ورجع المرتهن بالفضل على الراهن.

(2) بدائع الصنائع، 6/146؛ انظر حاشية الطحطاوي، 4/236.

(1) مختصر القدوري، ص: 93.

قال القدوري - رحمه الله تعالى: "ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، وهو مضمون بالأقل من قيمته، ومن الدين، فإذا هلك في يد المرتهن، وقيمته والدين سواء، صار المرتهن مستوفياً لدينه حكماً. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين، فالفضل أمانة في يده، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها، ورجع المرتهن بالفضل"⁽¹⁾.

إذا هلك الرهن عند المرتهن، وكان هلاكه بدون تعد، أو تقصير، فإنه يهلك بالأقل من قيمته وقت قبضه، ومن الدين، فإذا كانت قيمة الرهن وقت تسليمه إلى المرتهن مساوية لقيمة الدين، سقط الدين بهلاكه، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها، وكان للمرتهن أن يطالب الراهن بما بقي له بعد ذلك من دينه، وإن كانت أكثر سقط بهلاكه الدين كله، ولم يكن للراهن أن يطالب المرتهن بزيادة الرهن على الدين؛ لأنها أمانة في يده، فتهلك مجاناً.

الدليل على ما تقدم: ما روي (أن رجلاً رهن فرساً بدين فنفق، فاختصم إلى رسول الله ﷺ فقال ﷺ للمرتهن: ذهب حقك)، وما روي عنه ﷺ: (إذا عمي الرهن، هو بما فيه). قالوا: معناه والله أعلم إذا هلك أي الرهن، فاشتهدت قيمته.

3_ إجماع الأمة على أن الرهن مضمون، مع اختلافهم في كيفية الضمان.

4_ ولأنه لما ملك حبسه، صار مستوفياً حقه من وجه؛ لأنه للاستيثاق ليتوصل به إلى حقه مخافة الجحود، وقد تأكد هذا الاستيثاق بالهلاك، فلو وفاه ثانياً يؤدي إلى الربا⁽¹⁾.

الفصل الرابع

أحكام الرهن

ويشمل المسائل الآتية:

المسألة الأولى: الجناية على الرهن: جناية الراهن على الرهن مضمونة، لأنه كالأجنبي في المالية حيث تعلق بها حق الغير حبساً واستيفاء، وجناية المرتهن يسقط من الدين بقدرها؛ لأنه لو نقص لا بفعله، يسقط، فبفعله أولى.

وجناية الرهن على الراهن، وماله، هدر، والمراد جناية توجب المال؛ لأنها جناية المملوك على ماله.

قال القدوري رحمه الله تعالى: "وجناية الراهن على الرهن، مضمونة. وجناية المرتهن عليه، تسقط من دينه بقدرها. وجناية الرهن على الراهن، وعلى المرتهن، وعلى مالهما، هدر"⁽¹⁾.

(1) انظر: المعاملات، للخفيف، ص: 438؛ الاختيار لتعليل المختار،

2/ 95، 96. وانظر: المعاملات، لأبي الفتح، ص: 606، 607.

(1) مختصر القدوري، ص: 93.

المسألة الثانية: رهن العين المستعارة: يجوز للمدين أن يستعير مال غيره؛ ليرهنه بإذنه، والاذن بالرهن لا يخلو من أن يكون مطلقاً أو مقيداً.

فإن كان مطلقاً: جاز للمستعير أن يرهنه بأي مقدار أراد، وبأي جنس شاء، وفي أي مكان، ومن أي إنسان أحب؛ لأن العمل بإطلاق اللفظ أصل من الشريعة الغراء.

وإن كان مقيداً: بأن سمي المعير قدرأ، أو جنساً، أو مكاناً، أو إنساناً، فليس للمستعير مخالفته. فلو أذن له المعير برهن العارية بعشرة جنيهات، لا يجوز له أن يرهنها بأقل، ولا بأكثر؛ لأن المعير قد تكون له مصلحة، وبالمخالفة تقوت تلك المصلحة.

وليس للمستعير أن ينتفع بما استعاره ليرهنه، لا قبل الرهن، ولا بعده، فإن انتفع، وهلك أثناء الانتفاع، ضمنه. وإذا هلكت العارية بدون تعد في يد المستعير قبل رهنها، فلا ضمان عليه؛ لأنها هلكت وقت القبض للعارية، لا وقت قبض الرهن⁽¹⁾.

المسألة الثالثة: وضع الرهن تحت يد العدل: الأصل أن يحفظ الرهن عند المرتهن، أو من يقوم مقامه ممن هو في عياله وعند كل من يحفظ أمواله عنده، وإذا اتفق الراهن

(1) انظر: المعاملات، لأبي الفتح، ص: 599 _ 600؛ المعاملات

للخفيف، ص: 439؛ الاختيار لتعليل المختار، 106/2.

والمرتتهن على أن يكون الرهن تحت يد عدل، جاز ذلك، وقام قبض العدل مقام قبض المرتتهن، وترتب على ذلك جميع ما ذكر من الأحكام الخاصة بالرهن، وليس للعدل في هذه الحالة، أن يسلمه إلى واحد منهما إلا باتفاقهما؛ لأنه وديع الراهن بالنسبة للعين، ووديع المرتتهن بالنسبة للمالية. فيكون تسليمه الرهن إلى أحدهما تسليماً لأجنبي، إما بالنسبة للمالية، وإما بالنسبة للعين، وذلك لا يجوز.

وإذا سلم العدل الرهن إلى الراهن، أو المرتتهن لم يبطل الرهن، ووجب عليه أن يسترده، فإن هلك قبل استرداده، ضمن العدل قيمته بتعديه بالتسليم، وإذا أدي الراهن الدين إلى المرتتهن، سلمت القيمة عندئذ للعدل، إن كان ضمانها بسبب تسليمه إلى الراهن؛ ذلك لأن الراهن قد وصله حقه بصيرورة الرهن إليه، والمرتتهن قد وصله حقه بأداء الدين إليه، وإذا كان ضمانها في هذه الحال بسبب تسليمه إلى المرتتهن، كانت للراهن عوضاً عن ملكه، وهو الرهن.

ويجوز للراهن أن يوكل العدل في بيع الرهن، وتسديد الدين من ثمنه، وحينئذ لا يملك عزله من الوكالة قبل أداء مهمته⁽¹⁾.

(1) الاختيار ، 105/2؛ المعاملات، للخفيف، ص: 440.

قال القدوري رحمه الله: "وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز، وليس للمرتهن ولأهله، أخذ من يده، فإن هلك في يده، هلك من ضمان المرتهن"⁽¹⁾.

المسألة الرابعة: نماء المرهون: زيادة المرهون المتصلة: كالسمن، وكبر الشجر، تتبع الأصل. ونماء المرهون المنفصل: كالولد، والثمر، واللبن، والصوف، رهن مع الأصل⁽²⁾.

المسألة الخامسة: نفقات الرهن: الأصل الذي تبني عليه مسائل الإنفاق على الرهن: هو أن كل ما كان منه لحفظ الرهن، وصيانته من الضياع، والتلف، فهو على المرتهن؛ لأن الحفظ واجب عليه، وذلك كأجرة الحافظ، والمكان الذي يحفظ فيه، هذا إذا كانت قيمة الرهن مساوية للدين، أو أقل منه، فإن كانت أكثر كان على المرتهن من النفقات ما يقابل الجزء المضمون، وهو المساوي للدين، وعلى الراهن ما يقابل الأمانة، وهو الزائد على المضمون إلا المسكن فإنه على المرتهن خاصة، وكل ما كان من النفقات لازماً لبقاء العين المرهونة: كالمؤنة ورم المباني، وعلف

(1) مختصر القدوري، ص: 92.

(2) حاشية ابن عابدين، 335/5؛ فتح القدير، 9/129.

الدواب، أو واجباً أدائه للحكومة، كالخراج، فعلى الراهن⁽³⁾.

قال القدوري - رحمه الله تعالى: "وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن، على المرتهن، وأجرة الراعي، ونفقة الرهن، على الراهن"⁽¹⁾.

المسألة السادسة: حكم الرهن الفاسد، والباطل: الرهن الفاسد: إذا فسد الرهن بسبب فقده شرطاً من شروط صحته (كأن كان مشاعاً) فلا حكم له حال قيام المرهون، حتى لا يثبت للمرتهن حق حبس الرهن، ويثبت للراهن حق استرداده منه، فإن منعه حتى هلك، يضمن مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً، باعتبار قيمته يوم قبضه؛ لأنه بالمنع صار غاصباً. وإن لم يمنعه، ثم هلك الرهن في يده فقل: يهلك هلاك الأمانات؛ لأن الرهن إذا لم يصح، يكون القبض قبض أمانة؛ لأنه مأذون فيه من المالك، فأشبهه قبض الوديعة. وقيل: يهلك بالأقل من قيمته، ومن الدين⁽¹⁾.

(3) الاختيار لتعليل المختار، 97/2.

(1) مختصر القدوري، ص: 93.

(1) المعاملات، لأبي الفتح، ص: 608، 609.

حكم الرهن الباطل: الرهن الباطل لا يتعلق به ضمان، ولا يملك به المرتهن حبس الرهن⁽²⁾.

(2) المعاملات، للخفيف، ص: 442.

كتاب الإكراه

ويشمل الفصول التالية:

الفصل الأول

تعريف الإكراه، وأقسامه، وشروطه

أولاً: تعريف الإكراه: الإكراه لغة: هو حمل الإنسان على شيء يكرهه، تقول: أكرهت فلانا إكراها: إذا حملته على فعل أمر يكرهه. والكره بالفتح: هو الإكراه، والكره بالضم: الكراهة⁽¹¹⁾.

الإكراه اصطلاحاً: جاء في الهداية للمرغيناني: الإكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته⁽³⁾.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: إن الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإخافة والتهديد، ويقال له: المكره بفتح الراء، ولمن أجبره: مجبر، ولذلك العمل: مكره عليه، وللشيء الموجب للخوف: مكره به⁽⁴⁾.

(11) المغرب ص407، المصباح المنير ص532، مختار الصحاح 237/1.

(3) الهداية وبهامشها العناية 233/9.

(4) شرح مجلة الأحكام العدلية 658/2، مادة (948).

وجاء في الدر المختار: إن الإكراه هو فعل يوجد من المكره فيُحدث في المحل معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذي طُلِبَ منه⁽⁵⁾.

وعرفه الخادمي الحنفي: بأنه حمل الغير على ما لا يرضاه ولا يختاره إذا خلى ونفسه⁽⁷⁾.

وجاء في حاشية الشبراملسي: إن الإكراه هو التهديد بعقوبة عاجلاً ظلماً. (8)

وعرفه الكمال بن الهمام: بأنه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدهد بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا. (9)
فهذه التعاريف كلها وإن تعددت واختلفت ألفاظها، إلا أنها كلها يجمعها معنى واحد هو أن الإكراه: هو صدور الفعل أو القول من الشخص أو امتناعه عنه تحت تأثير الإكراه والتهديد والتخويف والوعيد الذي ينعدم معه الرضا بالفعل أو الامتناع عنه.

ثانياً: أقسام الإكراه: قسم فقهاء الحنفية الإكراه قسمين:

(5) الدر المختار وعليه حاشية ابن عابدين 129/6، تبين الحقائق 181/5.

(7) بريقة محمودية 84/2، شرح التلويح على التوضيح 390/2.

(8) حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج 387/3.

(9) شرح فتح القدير 233/9.

الأول: إكراه ملجئ: وهو التهديد التام، وهو ما يكون التهديد فيه بقتل النفس، أو إتلاف عضو من الأعضاء، أو ضرب مبرح شديد يخاف منه تلف النفس أو العضو، أو إتلاف جميع المال، وهذا النوع من التهديد والإكراه يفسد الاختيار ويُعَدُّ الرضا.

الثاني: إكراه غير ملجئ: وهو التهديد الناقص، وهو ما كان بغير ذلك مما يستطيع الإنسان الصبر عليه عادة مع احتمال المشقة، كالحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف. وهذا النوع من الإكراه ليس له مقياس ثابت إذ هو يختلف باختلاف الأشخاص، بل باختلاف حالات الشخص الواحد، من صحة، ومرض، وقوة، وضعف، وغير ذلك، ويختلف باختلاف الظروف المحيطة بالحادثة التي وقعت تحت تأثير الإكراه، فالواجب هو النظر في كل حادثة نظراً خاصاً، ليعرف إلى أي حد كان تأثير الإكراه فيها⁽¹⁾. وهذا النوع من الإكراه يعدُّ الرضا فقط ولا يفسد الاختيار، وذلك لعدم اضطرار الشخص الواقع عليه التهديد إلى التآيُّن به، لتمكُّنه من الصبر عليه وتحمل ما هدد به.

(1) بدائع الصنائع 175/7، تبیین الحقائق 182/5، الفتاوى الهندية 35/5.

ثالثاً: شروط تحقق الإكراه: لابد من أن تتوافر في الإكراه عدة شروط، ليكون لكي يكون الإكراه معتبراً يترتب عليه أثره، لا بد من أن تتوافر فيه عدة شروط هي:

الشرط الأول: أن يكون الإكراه بغير حق، فإن كان بحق فلا اعتبار به ولا يترتب عليه أثره.

الشرط الثاني: أن يكون القائم بعملية التهديد قادراً على إيقاع ما هدد به، وذلك لكونه متغلباً ذا سطوة وبطش، وذلك لأن تهديد غير القادر لا اعتبار به.

الشرط الثالث: الخوف من وقوع المهدد به، وذلك بأن يغلب على ظن الشخص المهدد تنفيذ القائم بعملية التهديد لما هدد به، وذلك لأن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة، وتعذر التوصل إلى الحقيقة.

الشرط الرابع: أن يكون الإكراه بقتل النفس أو قطع عضو أو إتلافه، ولو بإذهاب قوته مع بقاء صورته، حيث لا فائدة من بقاء العضو مع فوات منفعته، وذلك كإذهاب البصر مع إبقاء العين، وإذهاب السمع مع إبقاء الأذن، وإذهاب البطش والمشي مع إبقاء الأيدي والأرجل، فإن ذهاب منفعة هذه الأعضاء مع بقاء صورتها مما يوجب غماً أو ضرراً نفسياً يلحق بالشخص المهدد، فينعدم الرضا.

الشرط الخامس: أن يكون الشخص المكره ممتنعاً قبل التهديد عن فعل ما هدد لأجله، سواء أكان ذلك لحق نفسه: كبيع ماله أو إتلافه بلا عوض، أو إعتاق عبده ولو بمال أو أجر

أخروي، أو لحق شخص آخر: كإتلاف مال الغير، أو لحق الشرع: كشرب الخمر والزنا ونحوهما، لأن التهديد لأجل هذه الحقوق يعدم الرضا، لكونه ممتنعاً عن الفعل قبل التهديد. الشرط السادس: أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله ولا يستطيع التخلص منه لا بالهرب ولا بالاستغاثة ولا بالمقاومة. (1)

الشرط السابع: أن يكون الإكراه واقعاً على شيء واحد معين، أما إذا كان واقعاً على أحد الشيئين أو أشياء، فإنه لا يتحقق التهديد بذلك، لوجود الاختيار. (2) فإذا توافرت هذه الشروط تحقق التهديد، أما إذا تخلف أحد هذه الشروط، فإن التهديد لا يتحقق ولا يكون معتبراً، وذلك كما إذا كان الشخص الواقع منه التهديد غير قادر على تنفيذ ما هدد به، إما لعجزه عن ذلك، أو لقدرته الشخص الواقع عليه التهديد على الإفلات، أو كان هازلاً فيما هدد به، أو كان ما هدد به أمراً بسيطاً يمكن تحمله بدون مشقة. (1)

هل يتوقف اعتبار الإكراه على صدوره من الحاكم أو رئيس الدولة؟

(1) شرح مجلة الأحكام 727/2، تبين الحقائق 182/5، البحر الرائق

80/8، الفتاوى الهندية 35/5، مجمع الأنهر 429/2 وما بعدها.

(2) المدخل لدراسة بعض النظريات في الفقه الإسلامي ص 202.

(1) الملكية، د. محمد فهمي السرجاني ص 216.

اختلف فقهاء الحنفية في ذلك على النحو الآتي: القول

الأول: لأبي حنيفة: حيث ذهب إلى عدم اعتبار الإكراه إلا

إذا صدر من الحاكم أو رئيس الدولة. (3)

واستدل لذلك: أن غير الحاكم أو رئيس الدولة غير قادر على

تحقيق ما هدد به، لأن الشخص الواقع عليه التهديد يستغيث

بالحاكم فيغيثه، فإذا كان القائم بعملية الإكراه هو السلطان أو

رئيس الدولة فلا يجد الشخص المهدد عوناً، لأن القدرة لا

تكون بلا منعة، والمنعة إنما تكون للحاكم أو رئيس الدولة.

القول الثاني: للصاحبين، فقد ذهبوا: إلى أن الإكراه معتبر،

سواء أصدر من الحاكم - رئيس الدولة - أم من غيره فلا

يتوقف على السلطان (4).

واستدلوا لذلك بما يأتي من السنة: قول النبي - ﷺ - لعمار

بن ياسر حين أكرهه الكفار على التلفظ بكلمة الكفر: (إن

عادوا فعد). (5)

وجه الدلالة: دل الحديث على اعتبار الإكراه إذا وقع من غير

الحاكم أو رئيس الدولة، أي يستوي فيه صاحب الشوكة

(3) بدائع الصنائع 176/7، مجمع الأنهر 429/2، تبين الحقائق

182/5.

(4) بدائع الصنائع 176/7، مجمع الأنهر 429/2، تبين الحقائق

182/5.

(5) المستدرک علی الصحیحین 389/2، سنن البيهقي 208/8.

وغيره، حيث إن الذين أكرهوا سيدنا عمار بن ياسر لم يكونوا من السلاطين والحكام، فدل ذلك على صحة وقوع الإكراه من غيرهم.

ومن المعقول: إن الإكراه ليس إلا إبعاد بالحاق ما هدد به، وهذا يتحقق من كل شخص متسلط متغلب، ولأن الله - تعالى - لم يفرق بين شيء من ذلك ولا رسوله - ﷺ -، فقد ورد الشرع في ذلك بدون تفريق بين سلطان وغيره.

التوفيق بين القولين:

يمكن التوفيق بين الرأيين بأن هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، ففي زمان أبي حنيفة لم يكن لغير الحاكم من القوة والمنعة ما يتحقق منه التهديد، فلما فسد الزمان وتغيرت الأحوال أصبح التهديد والإكراه يتحقق من كل مفسد متلصص متغلب له القدرة على التهديد.

القول الراجح: هو القول الأول لقوة ما استدلوا به، ولأنه هو الذي يتفق وعصرنا الحالي حيث لم يعد التهديد والإكراه مقصورا على شخص بعينه فقد يقع من الحاكم ومن الشخص العادي، بل وقد يقع من جهة معينة على جهة أخرى كما يحدث بين الدول بعضها البعض، حيث تفرض الدول القوية هيمنتها على الدول الضعيفة وتجبرها على تنفيذ ما يتفق مع مصالحها بغض النظر عن مصلحة الدولة نفسها.

أثر الإكراه في إصدار التصرفات: عند الحنفية: التصرفات الصادرة عن الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه إما قولية وإما فعلية.

(أ) التصرفات القولية: تنقسم التصرفات القولية التي تصدر تحت تأثير الإكراه إلى قسمين: -

القسم الأول: تصرفات لا تحتل الفسخ أي "النقض".

وهذا النوع من التصرفات الذي لا يقبل النقض والفسخ ولا يؤثر فيه الهزل، كعقد النكاح والطلاق والعتاق واليمين والرجعة، إذا صدر تحت تأثير التهديد والإكراه، فإنه ينعقد مع الكراهة، والدليل على ذلك ما يأتي:

إن كل ما يصح مع الهزل يصح معه التهديد والإكراه، أي أن التهديد والإكراه لا يؤثر فيه، لأن ما يصح مع الهزل لا يحتل الفسخ، وكل ما لا يحتل الفسخ لا يؤثر فيه التهديد والإكراه.

إن صحة هذه الأشياء مع الهزل دليل على عدم اعتبار الرضا في انعقادها، والتهديد والإكراه لا يعدم الرضا، فالاختيار في هذه التصرفات وجد مع التهديد والإكراه، حيث إنه لا يستلزم الرضا فيها.

إن هذه التصرفات لا تنفصل أحكامها عن أسبابها وهي الصيغ، فمجرد وجودها يثبت أحكامها كاملة، والرضا تأثيره إنما هو في ثبوت الأحكام لا في وجود العقد، فلما كانت الأحكام توجد فور وجود العقد في هذه التصرفات لم يكن

للرضا تأثير في أحكامه، فصحت هذه التصرفات مع فقد الرضا. (1)

القسم الثاني: تصرفات تحتل الفسخ، أي "النقض".

وهذا النوع من التصرفات التي تحتل الفسخ والنقض ويؤثر فيها الهزل، كالبيع والإجارة والوصية والرهن وغير ذلك إذا صدرت تحت تأثير التهديد والإكراه: -

فعند أبي حنيفة والصاحبين: إذا صدر هذا النوع من التصرفات تحت تأثير التهديد والإكراه، فإنه يقع فاسداً، ولكن إذا حصل الرضا بعد زوال التهديد والإكراه فإنه يصير صحيحاً.

واستدلوا لذلك بما يلي: إن عقود المبادلات المالية إذا حصلت مع التهديد والإكراه كانت حاصلة مع النهي عنها، لقول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ﴾. (2) فالنهي هنا لوصف زائد عن ركن العقد، وإذا كان النهي واقعاً على وصف للعقد، وقع العقد معها فاسداً.

(1) بدائع الصنائع 182/7، تبیین الحقائق 187/5، العناية 248/9، درر الحکام شرح غرر الأحکام 271/2، البحر الرائق 85/8، مجمع الأنهر 435/2، الدر المختار، 139/6، الملكية ونظرية العقد، لأبي زهرة ص 389 وما بعدها، المدخل للسريتي ص 204.

(2) سورة النساء: من الآية 29.

كما إن التهديد والإكراه يعدم الرضا، والرضا شرط لصحة هذه العقود كما في الآية السابقة، فتفسد هذه التصرفات عند فوات الرضا.

أيضا إن الركن في هذه التصرفات قائم لا خلل فيه، حيث صدرت هذه التصرفات من أهلها مضافة إلى محلها قابلية لحكمها، غير أن الذي أوجد الخلل فيها فأفسدها هو عدم الرضا، والرضا أمر يتعلق بالشخص الواقع عليه التهديد والإكراه، فإذا ثبت الرضا بعد زوال التهديد والإكراه فقد زال سبب النهي، فسلمت هذه التصرفات من الخلل، لذا تصير صحيحة.

وعند زفر: إن هذا النوع من التصرفات إذا صدر تحت تأثير التهديد والإكراه، فإنه يقع موقوفاً، فيتوقف على إجازة الشخص الواقع عليه التهديد بعد زوال ما هدد به. واستدل على ذلك فقال: إن هذه التصرفات لو كانت فاسدة، لصدورها تحت تأثير التهديد والإكراه لما جازت بعد زوال التهديد، لأن الفاسد لا يجوز بالإجازة ولا يرتفع بها، فالفاسد لا تجعله الإجازة صحيحاً، وإنما الذي تلحقه الإجازة هو الموقوف، فكان كعقد الفضولي موقوفاً على إجازة صاحبه. (1)

(1) تبين الحقائق 182/5 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 131/6 وما بعدها، العناية 236/9، مجمع الأنهر 430/2 وما بعدها، درر الحكام

ثمرة هذا الخلاف:

تظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية فيما لو باع شخص عينا تحت تأثير الإكراه، فقبضها المشتري، فهل تدخل هذه العين في ملك المشتري أو لا تدخل في ملكه وتظل على ملك الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه؟

ف عند الإمام وصاحبيه: تدخل في ملك المشتري، لأن البيع الفاسد يثبت به الملك إذا حصل معه قبض.

وعند زفر: لا تدخل في ملك المشتري، لأن العقد الموقوف لا يثبت أحكاما قبل الإجازة قط.

والحاصل: أن التصرفات القولية التي تصدر عن الشخص الواقع تحت تأثير التهديد والإكراه، سواء أكان التهديد تاما أم ناقصا تتعقد عند الحنفية، فإن كانت مما لا يقبل النقص والفسخ، فإنها تتعقد مع الكراهة، وإن كانت مما يقبل الفسخ والنقص فعند أبي حنيفة وصاحبيه: تتعقد فاسدة وتصير صحيحة بعد زوال التهديد، وعند زفر: تتعقد موقوفة.

(ب) التصرفات الفعلية:

وهذا النوع من التصرفات إذا صدر من الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه، كما لو هدد شخص شخصا آخر بقتله إن لم يقتل غيره، أو بإتلاف مال غيره، أو شرب الخمر ونحو

ذلك، فإن الحكم في هذه التصرفات يختلف حسب نوع الإكراه
والفعل المهدد به.

الفصل الثاني

التصرفات الصادرة تحت الإكراه

في مجال العقائد والعبادات

أولاً: التلفظ بالكفر تحت الإكراه:

من المعلوم أن التلفظ بالكفر عن قصد واختيار يعد مفسدة محرمة ويخرج الإنسان عن رتبة الدين ويعتبر مرتدّاً، لكن إذا حدث وتلفظ الشخص بكلمة الكفر تحت تأثير الإكراه، فهل يعتد بذلك أو لا؟.

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن من تلفظ بالكفر تحت تأثير التهديد والإكراه لم يصر كافراً، أي لا يعتد بهذا التصرف الصادر تحت التهديد، فلا يأثم ولا يكفر ولا تبين منه زوجته.⁽¹⁾ واستدلوا على ذلك: بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: أما الكتاب: فقول الله - تعالى -: «إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»⁽²⁾ فقد دلت هذه الآية على أن من تلفظ بالكفر تحت تأثير التهديد والإكراه فأتى به بلسانه ولم تتغير عقيدته في قلبه فهو على إيمانه.

وأما السنة فيما يلي:

(1) بدائع الصنائع 176/7 وما بعدها، تبين الحقائق 186/5، العناية 241/9.

(2) سورة النحل: من الآية 106.

1- ما روي أن عماراً بن ياسر أخذ المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي ﷺ وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي ﷺ - إن عادوا فعد". (3) فقد رخص النبي ﷺ - في ذلك، حيث قال له: " إن عادوا فعد " وهو أمر من النبي ﷺ - وأدنى درجات الأمر بالإباحة.

2- وبما روي عن النبي ﷺ - أنه قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". (1) ففي الحديث دلالة على عدم المؤاخظة في حالة الإكراه والتهديد.

3- وبما روي أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين، فما منهم من أحد إلا أجابهم، إلا بلالاً، فإنه كان يقول أحد أحد " فقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: " كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ﷺ - وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أذراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً، فإنه هانت عليه نفسه في الله،

(3) المستدرك على الصحيحين، 289/2، فتح الباري 312/12.

(1) سبق تخريجه.

وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول " أحد أحد " (1).

وجه الدلالة: في كل هذه الأحاديث دلالة واضحة على أنه لا اعتبار بالتلفظ بالكفر الصادر تحت تأثير التهديد والإكراه طالما أن القلب مطمئن بالإيمان عامر به.

وأما الإجماع: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر **وأما المعقول:**

1- إن إظهار الكفر تحت تأثير التهديد والإكراه لا تفوت به حقيقة الإيمان، لأن التلفظ به في هذه الحالة أي تحت التهديد لا يدل على تبدل الاعتقاد، لعدم الرضا به، فلا يفوت به حق الله - تعالى - في المعنى، فيرخص للشخص الواقع تحت التهديد الإقدام على ذلك إحياء لنفسه أو طرفه، لأن حرمة العضو كحرمة النفس.

2- إن حفظ المَهَج والأرواح أكمل مصلحة من مفسدة التلفظ بكلمة لا يعتقد بها القلب، لذا أبيح التلفظ بها تحت تأثير التهديد والإكراه.

3- إنه إكراه بغير حق نتج عنه صدور التلفظ بكلمة الكفر فلم يثبت حكمه.

4- كما إن الركن الأصلي في الإيمان هو التصديق، وهو قائم حقيقة في حق الواقع عليه الإكراه، والإقرار ركن وهو قائم تقديراً، لأن التكرار ليس بشرط، وفي الامتناع عن التلفظ تحت التهديد والإكراه فوت النفس حقيقة، فكان مما اجتمع فيه حق العبد يقيناً وحق الله توهماً، فيسع الشخص الواقع تحت التهديد الميل إلى إحياء حقه، وذلك بالتلفظ من غير قصد. (1)

القول الثاني: للإمام محمد بن الحسن: فقد ذهب إلى أن من تلفظ بالكفر فأظهره تحت تأثير التهديد والإكراه كان مرتداً في الظاهر، لأنه نطق بكلمة الكفر فأشبهه المختار، وفيما بينه وبين الله - تعالى - يكون مسلماً إن أخلص الإيمان، وهي رواية الحسن.

وعلى هذا القول: تبين منه امرأته، ولا يرثه المسلمون إن مات، ولا يغسل ولا يصلى عليه. (2)

(1) بدائع الصنائع 176/7 وما بعدها، تبين الحقائق 186/5، العناية 241/9، أحكام القرآن لابن العربي 160/3، تفسير القرطبي 182/10، منح الجليل 220/9، بلغة السالك 548/2 وما بعدها، شرح مختصر خليل 35/4، أسنى المطالب 9/4، شرح البهجة 249/4 وما بعدها، كشف القناع 185/6، المغني لابن قدامة 30/9 وما بعدها، التاج المذهب 182/4 وما بعدها، المحلى 203/7.

(2) الجوهرة النيرة 256/2.

الأفضل لمن وقع تحت تأثير التهديد والإكراه أن يصبر على التهديد ولا ينطق بالكفر، فإن صبر وقتل كان مأجوراً وهو شهيد.

ثانياً: سب النبي - ﷺ - تحت الإكراه والتهديد:

إذا وقع شخص تحت تأثير التهديد والإكراه، فأجبر على أن يتلفظ بسب النبي - ﷺ - فهل يحكم برده أو لا؟.

أقول إن الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يقول الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه لم يخطر ببالي شيء، وسب النبي - ﷺ - تحت تأثير التهديد والإكراه، ففي هذه الحالة لا يكفر قضاء ولا ديانة، ولا تبين منه امرأته.

الثاني: أن يقول خطر ببالي رجل من النصاري يقال له محمد فشتمته ولم أستم النبي - ﷺ - فهو كالأول، لأن شتم النصراني دون المسلم في الحرمة.

الثالث: أن يقول خطر ببالي رجل من النصاري فتركته وسميت رسول الله - ﷺ - ففي هذه الحالة يكفر قضاء وديانة وتبين منه امرأته، لأنه بعدما خطر بباليه شخص آخر غير النبي قد وجد مخرجاً عما ابتلي به ولم يفعل فكان كافراً. (1)

ثالثاً: ترك الطهارة والصلاة تحت التهديد:

(1) المبسوط للسرخسي 130/24 وما بعدها، البحر الرائق 83/8، تبين الحقائق 190/5.

الطهارة من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لكن إذا حدث وترك الإنسان الطهارة والصلاة أو صلى بغير طهارة، لوقوعه تحت التهديد والإكراه، فهل تسقط عنه الصلاة، أو يتيمم ويعيد الصلاة؟ للفقهاء في ذلك تفصيل على النحو التالي: -

وعند الحنفية: الشخص الواقع تحت التهديد إذا أُجبر على ترك الوضوء فصلى بغير طهارة يتيمم ويعيد الصلاة، فإن منع من الوضوء والصلاة بتهديد ووعيد يتيمم ويصلى. أما إذا صبر الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه ولم يترك الصلاة المكتوبة في وقتها وهو يعلم أنه يسعه ذلك، حيث يجوز له إفسادها، كان مأجوراً، لأنه تمسك بالعزيمة، لأن حق الله - تعالى - وهو الصلاة لم يسقط عنه بالإكراه، وفيما فعله إظهار للصلابة في الدين. (1)

رابعاً: الإفطار الواقع تحت الإكراه في نهار رمضان:

1- الأكل والشرب تحت الإكراه في نهار رمضان:

يحرم على الصائم في نهار رمضان أن يأكل أو يشرب متعمداً، لما فيه من انتهاك لحرمة الشهر الكريم، وأن من فعل ذلك طائعا مختاراً فعليه القضاء والكفارة، لكن إذا وقع الشخص تحت تأثير التهديد والإكراه فأجبر على الأكل

(1) كشف الإسرار شرح أصول البيزوي 399/4، حاشية ابن عابدين 135/6.

والشرب في نهار رمضان، فهل يبطل صومه أولاً، وهل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ للفقهاء في ذلك تفصيل على النحو التالي: -

عند الحنفية: إذا وقع الشخص تحت تأثير التهديد والإكراه فأجبر على الأكل والشرب في نهار رمضان فعليه القضاء ولا كفارة عليه. ولهم في ذلك تفصيل على النحو التالي: -

فيرى الحنفية: أن الصائم إذا أكرهه أو هدّده شخص بالقتل ونحوه إذا لم يفطر في نهار رمضان، وكان الصائم صحيحاً مقيماً فله أن يفطر والأفضل الصوم، حتى إنه لو امتنع من الإفطار حتى قتل فإنه يثاب على ذلك، لأن الواجب وهو الصوم ثابت في حقه حالة التهديد والإكراه.

أما إذا كان الصائم مريضاً أو مسافراً، فالتهديد والإكراه بذلك صحيح مبيح للفطر في حقهما بل موجب لذلك، والأفضل لهما الإفطار بل يجب عليهما ذلك، حتى إنهما لو امتنعا من ذلك فقتلتهما القائم بعملية التهديد أثماً، لأن الواجب وهو الصوم مع رخصة الترك كان ثابتاً في حقهما قبل التهديد والإكراه، فلا بد وأن يكون للتهديد والإكراه أثر آخر لم يكن ثابتاً قبله.

وكذا: لو أوجر الشخص في حلقه تحت التهديد والإكراه أو وهو نائم، أفطر وعليه القضاء ولا كفارة عليه، إلا إذا كان طائعا فعليه القضاء والكفارة. (1)

2-الجماع الواقع تحت الإكراه في نهار رمضان:

عند الحنفية: الجماع الواقع تحت تأثير التهديد والإكراه في نهار رمضان، إما أن يكون التهديد والإكراه من جانب الزوجة، وإما أن يكون من جانب الزوج، فإن كان من جانب الزوجة: بأن هددت الزوجة زوجها وأكرهته على أن يجامعها في نهار رمضان، ولم يستطع الزوج دفعها عن ذلك فجامعها تحت تأثير التهديد والإكراه فعليه وعليها القضاء والكفارة، لأن الجماع لا يتصور من الزوج إلا بعد الانتشار واللذة، وذلك دليل على الاختيار، وعند ذلك يزول التهديد والإكراه.

والأصح: أنه لا يجب على الزوج كفارة، لأنه واقع تحت تأثير التهديد، فهو مكره، والانتشار أمر لا يملكه، وهذا ما عليه الفتوى في المذهب.

أما إذا كان الإكراه والتهديد من جانب الزوج: بأن هدد الزوج زوجته وأكرهها على الجماع في نهار رمضان، فلا كفارة

(1) بدائع الصنائع 96/2 وما بعدها، المبسوط للسرخسي 98/3، تبيين الحقائق 322/1، الهداية 328/2 وما بعدها، الجوهرة النيرة 138/1، 141، حاشية ابن عابدين 397/2، 401.

على الزوجة إجماعاً، لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة، وهذه ليست بجناية، لأن التهديد والإكراه يرفع المأثم، والكفارة تجب لرفع المأثم ولا إثم ها هنا. (1)

خامساً: أفعال الحاج الصادرة تحت الإكراه:

هناك بعض التصرفات التي يحرم على الحاج المحرم الإتيان بها في الحج، لكن إذا حدث و فعلها تحت التهديد والإكراه، فهل يؤثر ذلك في حجه أو لا؟ للفقهاء في ذلك تفصيل على النحو التالي: -

عند الحنفية: التصرفات الصادرة عن الحاج تحت التهديد والإكراه تؤثر في أفعال الحج من حيث الصحة والفساد: -
وعليه: فإذا جامع الحاج زوجته في حجه تحت تأثير التهديد والإكراه فسد حجه، لأن التهديد والإكراه لا يزيل الحظر، لحرمة وعظمة هذا الركن.

ولو كانت المرأة هي الواقع عليها التهديد، بأن كانت هي المكرهة، فإنها لا ترجع بما لزمها على من قام بتهديدها، لأنها في هذه الحالة قد حصل لها قدر من الاستمتاع بالجماع، فلا ترجع على أحد كالمغرور، ولأن التهديد والإكراه إنما يؤثر في رفع الإثم لا في إعدام الفعل.

هذا: ويمضي من وقع عليه التهديد والإكراه في حجه كما يمضي من لم يفسد حجه، لأن الإحرام لا يجوز التحلل منه إلا

بأداء أفعاله، أو بالإحصار ويكون عليه الحج في المستقبل،
لأن الإحرام الأول لم يقع موقع الواجب، حيث فسد بفعله،
فبقي الوجوب بحاله.

وكذا: الحاج الواقع تحت التهديد إذا أكره على حلق رأسه
وهو في الإحرام، فعليه دم، لأن التهديد والإكراه لا يسلب
الحظر، ولا يختلف ذلك باختلاف الأحوال⁽²⁾.

(2) بدائع الصنائع 193/2، 217، تبيين الحقائق 55/2، العناية على
الهداية 48/3 وما بعدها، المبسوط للسرخسي 121/4، الجوهرة 170/1.

الفصل الثالث

التصرفات الصادرة تحت الإكراه

في مجال المعاملات

أولاً: البيع الواقع تحت الإكراه:

إن البيع الصادر تحت التهديد والإكراه إذا كان بحق، أي لأجل حق مشروع صح البيع، وإن كان التهديد بغير حق لم يصح ويعتبر تصرفه غير نافذ، لأنه مجبور ومهدد في بيعه، وشرط صحة التعاقد أن يكون العاقد مختاراً، والاختيار هو الرضا بالشيء، وللحنفية في ذلك أقوال حسب الشخص الواقع عليه التهديد والإكراه:

القول الأول: لأبي حنيفة والصاحبين:

فقد ذهبوا: إلى أن البيع الصادر تحت التهديد لا يخلو من ثلاثة أوجه: -

إما أن يكون الواقع عليه التهديد والإكراه هو البائع، وإما أن يكون هو المشتري، وإما أن يكونا معا: -

أ- إذا كان الواقع عليه الإكراه هو البائع:

إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو البائع، فإن الأمر لا يخلو من وجهين: -

إما أن يكون البائع قد باع السلعة تحت الإكراه والتهديد، إلا أنه سلمها وهو طائع، وإما أن يكون باع وسلّم وهو تحت التهديد والإكراه، فإن كان قد باع وهو تحت التهديد إلا أنه سلم المبيع وقبض الثمن وهو طائع، جاز البيع.

والدليل على ذلك ما يلي: -

1- إن البيع في الحقيقة اسم للمبادلة، فإذا سلّم المبيع وقبض الثمن وهو طائع، فقد أجاز ذلك، لأن ذلك دلالة الإجازة، ودلالة الإجازة تقوم مقام الإجازة.

2- ولأنه أتى بحقيقة البيع باختياره، فيجوز بطريق التعاطي، فكان لفظ البيع منه تحت تأثير التهديد والإكراه وجوده كعدمه.

3- إن التسليم منه إجازة لذلك البيع، لأنه ليس من شرط صحة البيع صحة التسليم، حتى يكون التهديد والإكراه على البيع تهديداً وإكراهاً على صحة ما لا يصح له بدونه، إذ البيع يصح بدون التسليم، فكان طائعا في التسليم فصح أن يكون دليلاً للإجازة.

أما إذا كان البائع قد باع وسلّم وهو تحت التهديد والإكراه، فباعت مكرهاً وسلّم مكرهاً، كان البيع فاسداً عند أبي حنيفة وصاحبيه.

والدليل على ذلك: إن حقيقة البيع هي المبادلة، والتهديد والإكراه يؤثر فيها بالفساد، ويثبت به الملك، لأن ركن البيع وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله وهو البائع العاقل مضافاً إلى محله وهو الملك، والفساد لفقد شرطه وهو التراضي، فيثبت به الملك عند القبض.

القول الثاني: لزفر.

فقد ذهب: إلى أن البيع الصادر تحت التهديد والإكراه يكون موقوفاً، ولا يثبت به الملك، لتوقفه على الإجازة، والموقوف على الإجازة قبل الإجازة لا يفيد الملك.

هذا: وإن زال التهديد عن البائع فهو بالخيار إن شاء أمضى التصرف الذي صدر عنه تحت التهديد والإكراه، وإن شاء فسخ؛ لأن من شروط صحة العقود التراضي والله - تعالى - يقول: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. (2) والتهديد بعدم الرضا، وانتفاء الشرط انتفاء المشروط.

ويثبت هذا الخيار للبائع الواقع تحت التهديد قبل القبض وبعده؛ لأن الملك وإن ثبت بعد القبض لكنه غير لازم، لأجل الفساد، فيثبت له خيار الفسخ والإجازة قبل القبض وبعده دفعا للفساد.

أما المشتري فله حق الفسخ قبل القبض، لأنه لا حكم لهذا البيع قبل القبض، وليس له حق الفسخ بعد القبض؛ لأنه طائع في الشراء، فكان البيع لازماً في جانبه. (1)

ب- إذا كان الواقع عليه الإكراه هو المشتري:

إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو المشتري فقط دون البائع، فلكل واحد منهما حق الفسخ قبل القبض، أما بعد

(2) سورة النساء: من الآية 29.

(1) بدائع الصنائع 187/7، العناية على الهداية 234/9-237، شرح مجلة الأحكام 737/2.

القبض فيكون حق الفسخ للمشتري دون البائع، لأن بعد القبض يتفرد بالفسخ الشخص الواقع عليه التهديد منهما دون صاحبه الذي لم يقع عليه التهديد والإكراه، وقبل القبض كل واحد من البائع والمشتري متمكن من النقص بعد صحة النقص.

ج- إذا كان الإكراه واقعا عليهما معا " البائع والمشتري":

إذا كان التهديد والإكراه واقعا على البائع والمشتري معا، فلكل واحد منهما خيار الفسخ والإجازة؛ لأن البيع فاسد في حقهما جميعا، والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم، فكان بمحل الفسخ والإجازة، فإن أجازا جميعا جاز، وإن أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه وبقي الخيار في حق صاحبه.

هذا: ويستوي في البيع والشراء الواقع تحت التهديد والإكراه أن يكون التهديد والإكراه تاما أو ناقصا، لأن كل ذلك يفوت به الرضا.

كما يستوي في الإكراه على البيع تسمية المشتري وترك التسمية، حيث يفسد البيع في الحالين جميعا، لأن غرض القائم

بعملية التهديد والإكراه في الحالين جميعاً واحداً، وهو إزالة ملك البائع، وذلك يحصل بالبيع من أي إنسان كان. (2)

هذا: ولو أن شخصاً أكرهه آخر على أن يبيع ملكه بيعاً فاسداً أو جائزاً فخالف في ذلك، فإن الأمر لا يخلو من وجهين: -

الأول: إن أكرهه ببيع ملكه بيعاً فاسداً فباعه بيعاً جائزاً، جاز البيع. والدليل على ذلك: أنه أتى بغير ما هدد له لأجله، فالبيع الفاسد لا يزيل الملك بنفسه، والبيع الجائز يزيل الملك بنفسه، وكذلك الممتنع من البيع الفاسد لا يكون ممتنعاً من البيع الجائز، فهو طائع فيما أتى به من التصرف، فيقع جائزاً.

الثاني: لو أكرهه ببيع ملكه بيعاً جائزاً فباعه بيعاً فاسداً وسلمه للمشتري فهلك عنده، فالبائع بالخيار في الضمان، إن شاء ضمن المكره وإن شاء ضمن المشتري، لأنه لم يخالف ما أمر به، فإنه وإن أتى بالبيع على الوجه الذي أمره به القائم بالتهديد والإكراه، فإن البيع يكون فاسداً، لكونه أتى به تحت تأثير التهديد والإكراه، والممتنع من البيع الجائز يكون ممتنعاً من البيع الفاسد.

ثانياً: الكفالة الصادرة تحت الإكراه:

(2) بدائع الصنائع 188/7 وما بعدها، العناية على الهداية 235/9، المبسوط للسرخسي 99/24، الجوهرة النيرة 254/2، الفتاوى الهندية 36/5.

الكفالة: هي ضم ذمة إلى ذمة المطالب، والكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر.⁽¹⁾ وقد ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن الكفالة لا تصح تحت التهديد والإكراه، وعليه: فلو قام شخص بتهديد آخر بأن يكفل غيره في الدين، فكفل به وهو تحت تأثير التهديد والإكراه، فإنه لا تصح هذه الكفالة، ولنا يؤاخذ بها.

وأيضاً: لو قام شخص بإكراه آخر وأجبره على أن يخرج الكفيل بالنفس أو بالمال من الكفالة، فإنه لا يصح ذلك، وإن فعل بطلت الكفالة.⁽³⁾

وكذا: لو تكفلت امرأة لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك إنه هددني وأكرهني لم تُصدّق إلا أن يُعلم ذلك وتقوم عليه بينة، فتسقط عنها الكفالة.

ثالثاً: الوكالة الصادرة تحت الإكراه:

الوكالة: هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم.⁽¹⁾

(1) العناية 163/7، شرح مجلة الأحكام 736/1.

(3) الفتاوى الهندية 52/5، شرح مجلة الأحكام 744/2 المدونة 125/4،

منح الجليل 200/6، بلغة السالك 429/3، الفواكه الدواني 240/2، أسنى

المطالب 236/2، المغني لابن قدامة 344/4، التاج المذهب 148/4.

(1) العناية على الهداية 163/7، شرح مجلة الأحكام 736/1.

وقد ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن التوكيل يصح وينعقد مع التهديد والإكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة، لكونها من الإسقاطات، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل ولما ضمان في هذا على الوكيل، لأنه نائب معبر عن الموكل، فعبارته كعبارة الموكل، ولكن الضمان على المكره كما لو أكرهه على مباشرة الإيقاع. (6)

وعليه: فإن الشخص الواقع تحت تأثير التهديد والإكراه إذا أُجبر على التوكيل بالبيع، فوكّال غيره ببيع بعض أمتعته، وقبض الوكيل الأمتعة فباعها وسلمها المشتري، فهلك في يده، والوكيل والمشتري غير مكرهين، فإن الأمر لا يخلو: إما أن يكون التهديد والإكراه معتبراً كالإكراه بالقتل ونحوه، وإما أن يكون غير معتبر كالتهديد والإكراه بالحبس ونحوه. فإن كان التهديد والإكراه بالقتل، لم يجز البيع وله أن يسترد أمتعته، ولصاحب هذه الأمتعة في حالة الهلاك أن يضمّن من شاء من المكره أو الوكيل أو المشتري فإن ضمّن المشتري، فليس له حق في الرجوع على أحد بالقيمة، وإنما له الرجوع على الوكيل بالثمن، وإن ضمّن الوكيل رجع على المشتري بالقيمة، والمشتري يرجع عليه

(6) غمز عيون البصائر 205/3 وما بعدها، المبسوط للسرخسي 147/24، بدائع الصنائع 184/7، مجمع الأنهر 434/2، تبين الحقائق 188/5، حاشية ابن عابدين 235/3.

بالتّمن، فيتقاضان ويستردان الفضل — أي الزيادة —، وإذا
ضمّن المكره فله الرجوع على المشتري أو الوكيل.
أما إن كان التهديد والإكراه بالحبس لم يضمن المكره شيئاً،
وكان لصاحب الأمتعة أن يضمن من شاء من الوكيل أو
المشتري، فإن ضمن الوكيل رجع به على المشتري، لأنه قام
مقام من ضمنه، أو لأنه ملّكه بالضمان، ولم يقصد تنفيذ البيع
من جهته، فكان له أن يرجع على المشتري، لأنه بالقبض
متملك عامل لنفسه بغير إذن المالك فلا يسلم له مجاناً⁽¹⁾
وأيضاً: الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه، إذا أُجبر
على التوكيل بالطلاق، فأوقع الوكيل ذلك، فقد جاز توكيله
ووقع تصرفه استحساناً.
وفي القياس: لا يصح توكيله ولا يقع تصرفه؛ لأن الوكالة لا
تبطل بالهزل فكذا بالإكراه كالبيع ونحوه.
وجه الاستحسان: أن التهديد والإكراه لما لم يمنع صحة
الطلاق، فإنه لا يمنع صحة التوكيل من باب أولى.⁽²⁾
رابعاً: الإقرار الصادر تحت الإكراه:

(1) المبسوط للسرخسي 150/24، شرح مجلة الأحكام 744/2 وما بعدها.

(2) غمز عيون البصائر 205/3 وما بعدها، العقود الدرية 144/2،
العناية على الهداية 147/9.

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن الإقرار الصادر تحت التهديد والإكراه يكون باطلاً، فلا يجوز للقاضي أو من يتولى أمر المتهمين أن يهدده بالضرب أو الحبس، أو القيد، لجبره على الإقرار بما أتهم به من حد أو قصاص، أو أن يقر لشخص بحق مالي عليه، أو أن يقر بطلاق أو عتاق، فإن فعل ذلك كان الإقرار باطلاً، لأنه إقرار واقع تحت التهديد يحتمل الصدق والكذب، والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان الصدق على الكذب. (1)

بينما ذهب بعض المتأخرين من الحنفية: إلى صحة الإقرار مع التهديد والإكراه خاصة مع المتهمين، لأن الظاهر أن المتهمين لا يقرون في هذا الزمان طائعين، وقد سئل الإمام الحسن بن زياد - رحمه الله -: أيحل ضرب السارق حتى يقر؟ ، فقال: ما لم يقطع اللحم ولا يتبين العظم، وأفتى مرة بجواز ضربه، ثم ندم واتبع السائل إلى باب الأمير، فوجده قد ضرب، وأقر بالمال، وجاء به، فقال: ما رأيت جوراً أشبه بالحق من هذا. (1)

(1) المبسوط للسرخسي 185/9، 70/24، العقود الدرية 143/2، بدائع الصنائع 190/7، مواهب الجليل 275/5، منح الجليل 79/7 وما بعدها، تحفة المحتاج 359/5، مغني المحتاج 273/3، الفروع 419/6، المغني لابن قدامة 63/9.

(1) لسان الحكام 313/1، البحر الرائق 56/5، المبسوط للسرخسي 185/9، حاشية ابن عابدين 87/4.

خامساً: الإقرار بالقصاص والحدود تحت الإكراه:

عند فقهاء الحنفية: الإقرار بالحدود والقصاص تحت تأثير التهديد والإكراه لا يصح، لأن الحدود والقصاص تسقط بالشبهات.

وعليه: فإذا وقع الشخص تحت تأثير التهديد والإكراه، فأجبر على أن يقر بالحد أو القصاص، ثم أُخلى سبيله قبل أن يقر بذلك، ثم أخذ بعد ذلك فأقر من غير تجديد للتهديد والإكراه، ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر: -

إما أن يكون الشخص الواقع عليه التهديد قد توارى عن بصر القائم بعملية التهديد حين ما أُخلى سبيله، وإما أن يكون لم يتوارى عن بصره حتى بعث من أخذه وردّه إليه. فإن كان قد توارى عن بصره، ثم أخذ فأقر إقراراً مستقلاً، جاز إقراره.

والدليل على ذلك: أنه لما أُخلى سبيله حتى توارى عن بصر القائم بعملية التهديد، فقد زال عنه التهديد والإكراه، فإذا أقر بعد ذلك من غير تجديد للتهديد أو الإكراه، فيكون قد أقر طائعا، فيصح إقراره.

أما إن كان لم يتوارى عن بصر القائم بالتهديد والإكراه حتى رده إليه فأقر من غير تجديد للتهديد والإكراه، لم يصح إقراره.

والدليل على ذلك: أنه لم يتوارى عن بصره، فيكون على التهديد والإكراه الأول.

وأيضاً: الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه إذا أقر بالقصاص فقتل فور إقراره به من غير بينة، فإن الأمر لا يخلو: إما أن يكون المقر معروفاً بالذعر وهو الفرع والخوف، وإما أن يكون غير معروف بذلك.

ففي الاستحسان: إن القصاص يدرأ عنه إن كان معروفاً بالذعر والفرع، ويجب القصاص إن لم يكن معروفاً بذلك. وفي القياس: إنه لا يجب عليه القصاص كيف ما كان، أي على أي وجه كان المقر من الخوف وعدمه.

وجه القياس: إن الإقرار الصادر منه تحت التهديد والإكراه لما لم يصح شرعاً، صار وجوده وعدمه سواء، فصار كما لو قتله ابتداءً.

وجه الاستحسان: إن الإقرار وإن كان لا يصح تحت التهديد والإكراه، لكن في هذا الإقرار توجد شبهة الصحة إذا كان المقر معروفاً بالخوف والفرع، لوجود دليل الصدق في الجملة، فيورث الشبهة في وجوب القصاص فيدرأ للشبهة، وإذا لم يكن معروفاً بالذعر والخوف، فإقراره لا يورث شبهة، فيجب القصاص. (1)

سادساً: الإجارة الصادرة تحت الإكراه:

القول الأول: لأبي حنيفة والصاحبين:

(1) بدائع الصنائع 7/190.

فقد ذهبوا: إلى أن الإجارة الصادرة تحت التهديد والإكراه بغير حق تقع فاسدة، والشخص الواقع عليه التهديد والإكراه بالخيار بعد زوال التهديد والإكراه إن شاء أمضى الإجارة وإن شاء فسخ. (2) واستدلوا لذلك بما يأتي:

1- ظاهر النصوص التي وردت بمشروعية البيع والإجارة فقد وردت مطلقة غير مقيدة، منها قوله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. (3)، وقوله - تعالى -: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾. (4)، فهي عامة غير مقيدة بشرط التراضي ولما غيره. (5)

2- إن ركن الإجارة وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله مضافا إلى محله وهو الملك، والفساد هنا لفقد الشرط وهو التراضي، فيفيد الملك عند التسليم قياسا على سائر البياعات الفاسدة، إلا إن مسألتنا هنا تخالف سائر البياعات الفاسدة، حيث إن الفساد هناك يكون لحق الشرع فلا أثر لرضا العبد فيها، وفي مسألتنا الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه، فإذا أجاز فإن الفساد يزول بإجازته ورضاه. (6)

(2) بدائع الصنائع 186/7، تبين الحقائق 183/5.

(3) سورة البقرة: من الآية 275.

(4) سورة الطلاق: من الآية 6.

(5) بدائع الصنائع 186/7.

(6) بدائع الصنائع 186/7.

وعليه: فإذا وقع الشخص تحت التهديد فأكرهه على أن يؤجر ملكه كأرضه أو داره، أو مصنعه، أو شركته، أو حانوته، فالشخص الواقع عليه التهديد بالخيار بعد زوال التهديد والإكراه، إن شاء أمضى عقد الإجارة، وإن شاء فسخه، ويستوي في ذلك نوعي الإكراه التام والناقص، لأن التهديد والإكراه مطلقا يُعَدُّ الرضا، والرضا شرط صحة العقود، فتفسد بفواته، وكذا: من استعمل شخصا كبيرا تحت التهديد والإكراه، فإنه تلزمه أجرته مقابل ما قام به من عمل. (1)

القول الثاني: لزفر: فقد ذهب: إلى أن الإجارة الصادرة تحت التهديد والإكراه بغير حق تقع موقوفة على إجازة من وقع عليه التهديد والإكراه فإن أجازها جازت وإلا بطلت. (2)

واستدل لذلك فقال: إن الإجارة في هذه الحالة تنعقد موقوفة وليست بفاسدة، بدليل أن الشخص الواقع عليه التهديد والإكراه لو أجاز بعد زوال التهديد والإكراه جاز، ولو كانت فاسدة لما جازت بالإجازة؛ لأن الفاسد لا يجوز بالإجازة ولا يرتفع الفساد به، والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك بالقبض، فأشبهه بيع

(1) العقود الدرية 143/2 وما بعدها، البحر الزخار 35/5.

(2) تبیین الحقائق 182/5، بدائع الصنائع 186/7، الجوهرة النيرة 254/2،

مواهب الجليل 245/4، الروضة البهية 226/3.

الفضولي من حيث التوقف على إجازة من له حق الإجازة.
(3)

سابعاً: التنازل عن الحق في الشفعة تحت إكراه:

إن إسقاط الشفعة تحت التهديد والإكراه لا يبطل حق الشفيع فيها. وعليه: فلو سكت الشفيع عن طلب الشفعة تحت التهديد والإكراه، فإن حقه فيها لا يبطل، لأنه مكره في ذلك. وأيضاً: لو قام شخص بتهديد الشفيع وإكراهه على تسليم الشفعة بعد طلبها، فقام بتسليمها، كان تسليمه هذا باطلاً. وكذا: لو أراد الشفيع أن يتكلم بطلب الشفعة حيث علم بها فهدده شخص بأن لا ينطق بالطلب بها يوماً أو أكثر، فامتنع من طلبها هذه المدة المكره فيها، فهو على شفيعته إذا خلى سبيله، وله أن يطالب بها فإن طلبها عند ذلك فهي له، وإلا بطلت شفيعته.

وبهذا يتبين أن تسليم الشفعة ليس بإسقاط محض، وإلا لصح مع التهديد والإكراه كسائر الإسقاطات. (2)

(3) تبيين الحقائق 5/182، بدائع الصنائع 7/186، الجوهرة النيرة 2/254.

(2) غمز عيون البصائر 3/187، حاشية ابن عابدين 6/139، البحر

الرائق 6/208، الفتاوى الهندية 5/52، مجمع النهر 2/436.

الفصل الرابع

التصرفات الصادرة تحت الإكراه

في مجال الأحوال الشخصية

أولاً: الزواج الصادر تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن النكاح الصادر تحت التهديد والإكراه صحيح. (4) واستدلوا على ذلك بما يلي:
من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (5)
وغيره من العمومات من غير تخصيص.

ومن المعقول بما يلي:

- 1- إن النكاح الصادر تحت التهديد والإكراه تصرف قولي، لا يؤثر فيه التهديد والإكراه.
 - 2- قياس المكره على الهازل، فيكون النكاح صحيحاً مع الإكراه.
- هذا: وإذا صح النكاح الصادر تحت التهديد والإكراه، فإن الحال لا يخلو من أمور هي:
- إما أن يكون الواقع عليه التهديد والإكراه هو الرجل، وإما أن يكون الواقع عليه التهديد والإكراه هو المرأة.

(4) بدائع الصنائع 184/7 وما بعدها، تبين الحقائق 190/5، البحر الرائق 88/8، درر الحكام شرح غرر الأحكام 272/2، مجمع الضمانات ص 205، الفتاوى الهندية 294/1.

(5) سورة النور: من الآية 32.

أ-إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو الرجل:

فإذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو الرجل، فلا يخلو الحال: إما أن يكون قد سمي في الزواج المكره عليه مهر المثل، وإما أن يكون قد سمي فيه أقل من مهر المثل، وإما أن يكون قد سمي أكثر من مهر المثل، وبيان ذلك على النحو التالي:

(أ) إذا كان المسمى مهر المثل أو أقل منه:

ففي هذه الحالة يجب على من وقع عليه التهديد وهو الزوج القدر الذي سماه، ولا يرجع به على من قام بعملية التهديد والإكراه وهو المكره.

والدليل على ذلك: أن الشخص القائم بالتهديد والإكراه لم يتلف على من وقع عليه التهديد ماله، حيث إنه عوضه بمثله وهو الانتفاع بالبضع، حيث إن منافع البضع تعتبر أموالاً متقومة شرعاً عند دخولها في ملك الزوج، لكونها سبباً لوجود الآدمي تعظيماً له وصيانة له عن الابتدال، وحيث لم يوجد إلتاف من جهة القائم بالتهديد والإكراه، فلا يجب عليه الضمان.

(ب) إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل:

ففي هذه الحالة يجب على من وقع عليه التهديد والإكراه قدر مهر المثل، وتبطل الزيادة عليه.

والدليل على ذلك: أن الشخص الواقع عليه التهديد والإكراه لم يسم الزيادة على مهر المثل إلا تحت تأثير التهديد والإكراه، ومعلوم أن تسمية الزيادة على قدر مهر المثل لا تصح مع

التهديد والإكراه، فتبطل هذه الزيادة، ويجعل كأنه لم يفرض إلا قدر مهر المثل.

والقول بذلك: لأن التهديد والإكراه هنا وقع على النكاح وعلى إيجاب المال وهو الزيادة على مهر المثل، إلا أن التهديد والإكراه لا يؤثر في النكاح، وإنما يؤثر في إيجاب المال، فكان ينبغي ألا تصح التسمية أصلاً، إلا أنها صحت في مقدار مهر المثل، وهو القدر المشروع، لأن الشرع لو أبطل هذا القدر وهو مهر المثل لأثبتته ثانياً، حيث إنه حق المرأة، فلم يكن الإبطال مفيداً، لئلا يخرج الإبطال مخرج العيب، ولا ضرورة في الزيادة فلا تصح تسميتها.

ب- إذا كان الواقع عليه الإكراه هو المرأة:

أما إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه في الزواج هو المرأة، والزواج قد سمى لها مهراً قدر مهر المثل أو أكثر، جاز النكاح ولزم.

والدليل على ذلك: أن التهديد والإكراه لم يقع على الزوج، فكان ما سماه من مهر المثل أو أكثر إنما سماه مختاراً راضياً غير مكره عليه، فيجوز النكاح ويلزمه ما سماه.

أما إن كان قد سمى لها مهراً أقل من مهر المثل، بأن أكرهت الزوجة على النكاح بألف جنيه ومهر مثلها عشرة آلاف، فزوجه أولياؤها تحت التهديد وهم مكرهون، جاز النكاح،

وليس لمن وقع عليه التهديد والإكراه أن يرجع على من قام بالتهديد والإكراه بشيء من مهر مثلها.

والدليل على ذلك: أن القائم بعملية التهديد والإكراه لم يتلف عليها مالاً، لأن منافع البضع ليست بمتقومة بنفسها، وإنما تصير متقومة بالعقد، والعقد قوم هذه المنافع بالقدر المسمى من المهر، فلم يوجد من القائم بالتهديد والإكراه إتلاف مال متقوم عليها، وبالتالي فلا يجب عليه الضمان.

ثانياً: صدق المرأة المغتصبة تحت الإكراه:

إذا حدث وقام شخص باغتصاب امرأة تحت التهديد والإكراه، فعند فقهاء الحنفية: أنه إذا أُقيم الحد على من اغتصبها وزنى بها، فإنه يبطل صداقها، وإذا درى عنه الحد بشبهة وجب الصداق. (2)

واستدلوا على ذلك: بما روي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قالوا: " لا يجتمع حد ولا صداق على زان ". (3) في ذلك دلالة على أنه إذا حُد الزاني سقط عنه الصداق، حيث لا يجتمع الصداق والحد في جماع واحد.

ثالثاً: البَرَضاع الصادر تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أنه إذا تم البَرَضاع تحت التهديد والإكراه، فإنه يثبت حكمه وهو التحريم، ولا عبرة للقصد في

(2) تبين الحقائق 178/3.

(3) مصنف ابن أبي شيبة 14/4.

ذلك، لأن شرط التحريم بالرضاع هو وصول اللبن إلى الجوف، وهو يتحقق مع وجود التهديد والإكراه أو بدونهما. (1)

رابعاً: الطلاق الصادر تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى صحة وقوع الطلاق الصادر تحت التهديد والإكراه، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- إن عموم النصوص وإطلاقها يقتضي شرعية هذا التصرف من غير تخصيص ولا تقييد، مثل قول الله - تعالى -: ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ﴾. (3) وقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكِّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾. (4) وقوله - ﷺ -: " كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه ". (5) فهذه نصوص عامة ومطلقة لم تفرق بين طلاق المكره والطائع، فلا يجوز تخصيصها إلا بدليل ولا دليل.

2- ما روي عن محمد بإسناده عن صفوان بن عمرو الطائي: " أن رجلاً كان مع امرأته نائماً، فأخذت سكيناً، وجلست على صدره، فوضعت السكين على حلقه، وقالت

(1) حاشية الشلبي على كنز الدقائق 195/2، الفتاوى الهندية 52/5.

(3) سورة الطلاق: من الآية 1.

(4) سورة البقرة: من الآية 230.

(5) سنن الترمذي 496/3، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من

طريق عطاء بن عجلان وهو ضعيف.

لتطلقني ثلاثا البتة أو لأذبحك، فناشدها الله، فأبت عليه، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله -ﷺ- فقال: " لا قيلولة في الطلاق ". (1) في الحديث دلالة على وقوع الطلاق تحت التهديد والإكراه، لأن قوله -ﷺ-: " لا قيلولة في الطلاق "، فيه تأويلان: -

أحدهما: إنه بمعنى الإقالة والفسخ، أي أن هذا التصرف لا يحتمل الطلاق، والفسخ بعد وقوعه، وإنما لا يلزمه عند التهديد والإكراه ما يحتمل الرضا، أو يعتمد تمام الرضا.

الثاني: إن المراد إنما ابتليت بهذا، لأجل يوم القيلولة، وذلك لا يمنع وقوع الطلاق.

3- إن الفأنت بالتهديد والإكراه ليس إلا الرضا طبعاً، وإن الرضا ليس بشرط لوقوع الطلاق، بدليل أن طلاق الهازل يقع مع كونه غير راضٍ به طبعاً، وكذلك فإن الرجل قد يطلق امرأته الفائقة الجمال والحسن تغنجاً ودلالاً، لخلل في دينها، ومع ذلك يقع الطلاق عليها مع كونه غير راضٍ به. (2)

خامساً: مهر المطلقة تحت الإكراه:

بناء على قول الحنفية بصحة وقوع الطلاق الصادر تحت التهديد والإكراه، فمن الذي يغرم المهر بالنسبة للمطلقة، هل

(1) كتاب السنن 314/1، شرح سنن ابن ماجه 147/1، الدراية 69/2.

(2) بدائع الصنائع 182/7، تبیین الحقائق 187/5، المبسوط

للسرخسي 41/24، الجوهرة النيرة 255/2 وما بعدها.

هو القائم بعملية التهديد والإكراه، أو الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المكره؟ أقول:

إن الحال لا يخلو: -

إما أن يكون الطلاق الصادر تحت التهديد والإكراه قبل الدخول بالمرأة أو بعده:

فإن كان قبل الدخول: فإن الشخص القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المكره هو الذي يغرم للمرأة الأقل من نصف المهر، لأن الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للطلاق، إن التزم الأقل، فإلتفاف مضاف إلى القائم بعملية التهديد والإكراه، وهو المكره، وإن التزم الأكثر، فالضرورة إنما تحققت له في الأقل، لأنه كان متمكناً من دفع البلاء عن نفسه باختيار الأقل، فيكون غير مضطر في التزام الزيادة ورجوعه على القائم بالتهديد والإكراه، إنما هو بسبب الاضطرار، والاضطرار ثبت في الأقل لا في الزيادة، فيرجع عليه بالأقل.

وإن كان بعد الدخول: فإن الشخص القائم بعملية التهديد والإكراه لا يغرم شيئاً، لأن المهر قد تقرر عليه بالدخول، والذي حصل من القائم بالتهديد والإكراه إنما هو إلتفاف ملك البضع وذلك لا يُضمّن بالتهديد والإكراه. (1)

هذا إذا كان القائم بالتهديد والإكراه للزوج شخصاً أجنبياً، أما إذا كانت الزوجة هي التي قامت بتهديد الزوج وإكراهه على الطلاق لم يجب لها شيء. (2)

سادساً: سؤال المرأة زوجها الطلاق تحت الإكراه:

بناءً على القول بصحة وقوع الطلاق الصادر تحت التهديد والإكراه، إذا أكرهت المرأة على أن تسأل زوجها المريض الطلاق، فإنها ترثه، لعدم رضاها، حيث إنها مكرهة واقعة تحت التهديد.

أما لو أكره الزوج على أن يطلقها طلاقاً بائناً، فإنها لا ترثه. وأيضاً: لو وقعت الفرقة بين الزوج بسبب تمكين ابن الزوج منها: إذا أمره أبوه بذلك فجامعها أو قبلها وهي مكرهة فإنها ترثه، لأنه حينئذ ينتقل الفعل إليه فيصير كالمباشر. (1)

سابعاً: الرجعة الصادرة تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى صحة الرجعة الصادرة تحت التهديد والإكراه.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

(2) حاشية ابن عابدين 21/3.

(1) البحر الرائق 47/4، شرح فتح القدير 149/4.

1- قول النبي ﷺ: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح، والرجعة، والطلاق " (2)، وحيث إن الرجعة تصح مع الهزل فكذا مع الإكراه من باب أولى.

2- إن الرجعة عبارة عن استبقاء النكاح، وهو دون الإنشاء أي إنشاء عقد الزواج، وحيث إنه لم يشترط في إنشاء عقد الزواج عدم الإكراه، فلأن لا يشترط ذلك لاستيفاء النكاح وهو الرجعة من باب أولى. (3)

ثامناً: الإيلاء الصادر تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى صحة وقوع الإيلاء الصادر تحت التهديد والإكراه، واستدلوا لذلك:

1- أن الإيلاء من التصرفات التي تصح مع التهديد والإكراه، حيث إن الإيلاء ينطبق عليه ما ينطبق على الطلاق واليمين، حيث إنه يمين في أول الأمر، وطلاق باعتبار المآل.

2- بقياس الشخص الواقع تحت التهديد والإكراه على الهازل، حيث إن كلا منهما تصدر عنه صيغة التصرف عن قصد

(2) سنن الترمذي 490/3، وقال: حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ.

(3) بدائع الصنائع 186/3 وما بعدها، البحر الرائق 54/4، حاشية ابن عابدين 398/3 وما بعدها.

واختيار لكنه لا يريد حكمها، وطلاق الهازل ويمينه معتبران،
فكذلك من وقع عليه التهديد والإكراه⁽¹⁾.

تاسعاً: الخلع الصادر تحت الإكراه:

عند فقهاء الحنفية: يصح الخلع الصادر تحت التهديد
والإكراه، ويقع الطلاق ولا يسقط المال، واستدلوا لذلك:

1- أن تأثير التهديد والإكراه في انعدام الرضا لا في إهدار
القول حتى تتعد تصرفات من وقع عليه التهديد والإكراه،
ولكن ما يعتمد لزومه تمام الرضا، كالبيع لا يلزم الواقع عليه
التهديد والإكراه، وما لا يعتمد لزومه تمام الرضا، كالنكاح
والطلاق والعتاق، فإنه يلزمه بدون رضا.

2- ولأن الخلع من جانب الزوج طلاق وهو ظاهر، والتهديد
والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل، فكذا وقوعه ببدل أو
يمين، لوجود الشرط والجزاء، واليمين لا يعمل فيه التهديد
والإكراه.

وعليه: فلو كان الزوج هو المكره دونها، فإنه يلزمها البدل
لرضاها بالتزام مقابل ما سلّم لها من البينونة، ولا شيء على

(1) بدائع الصنائع 182/7، حاشية ابن عابدين 236/3 وما بعدها، مجمع
الأنهر 435/2، الجوهرة النيرة 38/2، مجمع الضمانات 207،
الموسوعة الفقهية 224/7 وما بعدها.

القائم بالتهديد والإكراه للزوج، لأنه أُلْغِيَ عليه ما ليس بمال وهو النكاح فلا يعتد به. (2)

عاشراً: الظهار الصادر تحت الإكراه:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى القول بصحة الظهار الواقع تحت التهديد والإكراه.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

1- قياس المكره على الهازل، لأن كلا منهما تصدر عنه صيغة التصرف عن قصد واختيار، لكنه لا يريد الحكم الذي يترتب عليه، وحيث إن ظهار الهازل معتبر كطلاقه، لقول النبي -ﷺ-: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". (1)، فيكون ظهار الواقع تحت التهديد والإكراه معتبراً بالقياس على الهازل.

2- إن الظهار من التصرفات القولية التي لا يؤثر فيها التهديد والإكراه فيصح وقوعه تحت ذلك كالطلاق. (2)

(2) المبسوط للسرخسي 76/6 وما بعدها، تبیین الحقائق 225/6، العناية على الهداية 248/9 وما بعدها، الفتاوى الهندية 46/5 وما بعدها، درر الحکام شرح غرر الأحكام 390/1.

(1) سنن الترمذي 178/1، سنن الدارقطني 257/3.

(2) المبسوط للسرخسي 233/6، الفتاوى الهندية 508/1، حاشية ابن عابدين 466/3، بدائع الصنائع 182/7، مجمع الأنهر 435/2.

الفصل الخامس

التصرفات الصادرة تحت التهديد

في مجال الجنايات والحدود والأقضية

أولاً: القتل الصادر تحت الإكراه:

اختلف الحنفية في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لأبي حنيفة ومحمد.

فقد ذهبوا إلى أن القتل الصادر تحت التهديد والإكراه يوجب القصاص على القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب في القتل دون الواقع عليه التهديد وهو المباشر للقتل. واستدلوا لذلك بما يأتي:

1- بما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

استكروهوا عليه ". (1) وعفو الشيء عفو عن مجبئه، فكان موجب من وقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للقتل معفو عنه بظاهر الحديث.

2- إن القاتل من حيث المعنى هو الشخص القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب في القتل، والذي وجد من الشخص الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للقتل هو صورة القتل، فأشبهه الآلة في يد القائم بعملية التهديد والإكراه، إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغير.

(1) سبق تخريجه.

³ إن الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للقتل ملجأً إلى هذا الفعل، والإلجاء بأبلغ الجهات يجعل الملجأ آلة للملجئ، وحيث إن المكره آلة في يد المكره، فيكون القصاص على المكره ولا شيء على المكره، حيث إنه صار محمولاً على ذلك الفعل بالتهديد بالقتل، والإنسان مجبول على حب الحياة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بالإقدام على القتل، فيفسد اختياره بهذا الطريق، وإذا فسد اختياره التحقق بالآلة التي لا اختيار لها، فيكون الفعل منسوباً إلى من أفسد اختياره وحمله على هذا الفعل لا على الآلة، فلا يكون على المكره شيء من حكم القتل من قصاص، ولا دية، ولا كفارة. (2)

القول الثاني: لأبي يوسف: فقد ذهب إلى أن القتل الصادر تحت التهديد والإكراه لا يوجب قصاصاً لا على القائم بالتهديد والإكراه وهو المتسبب ولا على المباشر، وإنما يوجب الدية على القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب.

واستدل لذلك بما يأتي:

1- إن القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب في القتل ليس بقاتل حقيقة، بل هو متسبب، حيث إنه لم يباشر القتل بنفسه، وإنما المباشر للقتل هو من وقع عليه التهديد والإكراه، فهو المباشر للقتل حقيقة، وحيث إنه لا يجب

(2) بدائع الصنائع 179/7 وما بعدها، العناية على الهداية 244/9،

الجوهرة النيرة 255/2، المبسوط للمرخسي 73/24 وما بعدها.

القصاص على المكره المتسبب في القتل، فلا يجب على المكره من باب أولى، حيث إنه آله في يده.

2- إن وجوب القصاص يعتمد المساواة، ولما مساواة بين المباشرة والإكراه، فلا يمكن إيجاب القصاص على المكره إلا بطريق المساواة ولما مساواة. (1)

القول الثالث: لزفر: فقد ذهب إلى أن القتل الصادر تحت التهديد والإكراه يوجب القصاص على الواقع عليه التهديد والإكراه، وهو المباشر للقتل دون القائم بعملية التهديد والإكراه، وهو المتسبب في القتل.

واستدل لذلك بما يأتي:

1- إن القتل وجد من الشخص الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للقتل حقيقة وحساً ومشاهدة، وإنكار المحسوس مكابرة، فوجب اعتباره منه دون القائم بالتهديد والإكراه المتسبب في القتل، إذ الأصل اعتبار الحقيقة، ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل.

2- إن الشخص القائم بالتهديد والإكراه متسبب في القتل، والواقع عليه التهديد والإكراه مباشر للقتل، وإذا اجتمع السبب والمباشرة قدم المباشرة. (2)

(2) بدائع الصنائع 179/7، المبسوط للمرخسي 73/24 وما بعدها.

(1) بدائع الصنائع 179/7.

ثانياً: الانتحار الواقع تحت الإكراه: إذا قال الشخص لآخر
اقتلني وإلا قتلتك، فقتله فهو منتحر، وفي وجوب القصاص
على القاتل، فقد ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجب على
القاتل في هذه الحالة قصاص ولا دية.
واستدلوا لذلك بما يأتي:

- 1- إن عصمة النفس تمكنت منها شبهة العدم، لأن الأمر
بالقتل وإن لم يصح حقيقة، فصيغته تورث الشبهة،
والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة، فتسقط الحد.
إن المكره كالألة في يد المكره في الإكراه التام، فينسب الفعل
إلى المكره وهو المقتول، فصار كأنه قتل نفسه.
- 2- إن المقتول أذن له في القتل، وحيث أذن له بذلك فقد أسقط
حقه بالإذن. (3)

وفي رواية: إن الدية تجب على المكره في ماله. (4)

ثالثاً: الزنا تحت الإكراه:

أ- إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو المرأة:
إذا ارتكبت المرأة جريمة الزنا تحت تأثير التهديد والإكراه،
بأن قام شخص باغتصابها وإكراهها واتصل بها اتصالاً
جنسياً محرماً، فإنه لا حد عليها في هذه الحالة.

(3) بدائع الصنائع 236/7، الجوهرة النيرة 126/2.

(4) بدائع الصنائع 236/7، الجوهرة النيرة 126/2.

والدليل على ذلك:

من الكتاب: قول الله - تعالى -: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
(1) أي غفور للفتيات المكرهات على الزنا، رحيم بهن.

وجه الدلالة: بينت هذه الآية الكريمة أن الله - تعالى - قد رفع العقاب عن المرأة التي أتت بجريمة الزنا تحت ضغط التهديد والإكراه، حيث غفر لها رحمة بها.

ومن السنة بما يأتي: -

1- بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". (2)
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن من زنى تحت التهديد والإكراه لا يؤاخذ به.

2- وبما روي عن وائل بن حجر عن أبيه قال: " استكرهت امرأة على عهد رسول الله - ﷺ - فدرأ عنها رسول الله - ﷺ - الحد، وأقامه على الذي أصابها ". (3)

وجه الدلالة: في الحديث دلالة واضحة على عدم إقامة الحد على من زنت تحت التهديد والإكراه.

(1) سورة النور: من الآية 33.

(2) سبق تخريجه.

(3) سنن الترمذي 55/4، وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل.

ومن الأثر بما يأتي:

1- بما روي عن نافع عن ابن عمر: " أن عمراً أتى بإماء من إماء الإمارة، استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان، ولم يضرب الإماء". (4)، فعدم ضرب عمر لهن دليل على سقوط الحد عنهن لإكراههن.

2- وبما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: " أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بامرأة جهدها العطش فمرت على راع، فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تُمكنه من نفسها، ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي -رضي الله عنه-: هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها ففعل ". (5) فتخلي سبيلها دليل على عدم مؤاخذتها بما فعلت تحت التهديد والإكراه، كما أن فيه دلالة على أن الاغتصاب لا يتوقف على الإكراه والتهديد بالسلاح، فقد يكون التهديد والإكراه معنويًا، كاستغلال الفقر والحاجة والضرورة والضعف ونحو ذلك، كما هو في الأثر، حيث قام الراعي باستغلال عطشها وقام باغتصابها، والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة.

(4) مصنف ابن أبي شيبة 505/5.

(5) سنن البيهقي 236/8.

ومن الإجماع: فقد حكي للإجماع على ذلك ولم يعرف
مخالف فيه.⁽¹⁾

ومن المعقول:

1- إن الموجود من المرأة الواقعة تحت التهديد والإكراه ليس
زناً، بل هو مجرد التمكين، ويدراً عنها الحد في نوعي
الإكراه والتهديد، لأنه لم يوجد منها فعل الزنا، بل الموجود هو
التمكين.

2- إن في إثبات جريمة الزنا تحت تأثير التهديد والإكراه
شبهة، ومعروف أن الحدود تدرأ بالشبهات.

ب- إذا كان الواقع عليه التهديد والإكراه هو الرجل:

إذا ارتكب الرجل جريمة الزنا تحت تأثير التهديد والإكراه،
فقد اختلف الفقهاء في عقوبته على النحو الآتي:

القول الأول: لأبي حنيفة:

فقد ذهب: إلى أنه إذا زنى الرجل تحت التهديد والإكراه وجب
عليه الحد.

واستدل لذلك بما يأتي:

1- التهديد والإكراه لا يرخص للشخص أن يرتكب جريمة
الزنا، لأن فيه قتل النفس بالضياح، وينتج عنه ولد غير
شرعي ليس له أب يربيه ويقوم على حاجته، وإفساد الفراش.

(1) بدائع الصنائع 18/7، حاشية ابن عابدين 137/6.

2- إن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة، والتهديد والإكراه لا يؤثر فيه، فكان طائعا في ارتكابه جريمة الزنا، حيث إن الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار، لذا يقام عليه الحد. (2)

القول الثاني: للصاحبين: اللذين ذهبوا: إلى أنه إذا زنى الرجل تحت التهديد والإكراه فلا حد عليه.
واستدلنا لذلك بما يأتي:

1- بعموم قول النبي -ﷺ-: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". (2) في الحديث دلالة على أن التهديد والإكراه يرفع الحكم.

2- إن الحد شرع للزجر عن ارتكاب الجرائم، ولنا حاجة إلى ذلك في حالة التهديد والإكراه، لأنه منزجر إلى أن يتحقق التهديد والإجاء، وخوف التلف على نفسه، فإن الواقع عليه التهديد والإكراه الذي زنى مكرها، إنما قدم على هذا الفعل ليدفع الهلاك عن نفسه، لا لقضاء الشهوة، فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد.

3- إن انتشار الآلة لا يدل على أن الزاني تحت التهديد والإكراه راضٍ به غير خائف، لأن الإنسان قد تنتشر آتته

(2) بدائع الصنائع 180/7، الجوهرة النيرة 256/2.

(2) سبق تخريجه.

طبعاً بالفحولة من غير اختيار له في ذلك، ولما قصد، فكذا هنا. (3)

هذا: والخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه هو اختلاف عصر وزمان، فقد كان السلطان مطاوعاً في عهد أبي حنيفة ولم يكن لغير السلطان من القوة ما يقدر على التهديد والإكراه، فأجاب بناء على ما شاهده في زمانه، ثم تغير حال الناس في عهدهما، وظهر كل متغلب في موضوع، فأجاباً بناء على ما عايناه.

والذي يبدو لي: أن القول بإسقاط الحد عن الشخص الواقع تحت تأثير التهديد والإكراه، سواء أكان الرجل أم المرأة هو الأولى بالقبول بشرط أن لا تكون الأضرار الناتجة عن تنفيذ الشخص الواقع عليه التهديد لما هُدد به أكبر من الأضرار المتوعد بها، فإذا كانت الأضرار الناتجة عن إتيان الشخص الواقع عليه التهديد لما هُدد به أعظم من الأضرار المتوعد بها فإنه لا يجوز له الإقدام على فعل ما هُدد به، ولأن التهديد والإكراه شبهة ومعروف أن الحدود تدرأ بالشبهات.

رابعاً: تناول المواد المسكرة تحت الإكراه:

(3) بدائع الصنائع 180/7 وما بعدها، المبسوط 88/24 وما بعدها، أحكام القرآن للجصاص 382/3، العناية 249/9، الفتاوى الهندية 48/5، الجوهرة النيرة 256/2.

يشترط لإقامة الحد على من تناول المواد المسكرة أن يكون مختاراً في تناوله لها، أي أن يشرب الإنسان المواد المسكرة أو يتعاطاها طائعا بمحض إرادته، لكن إذا حدث وتناول الشخص المواد المسكرة نتيجة وقوعه تحت التهديد والإكراه، فهل يقام عليه الحد أو لا؟:

ذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا حد على من تناول المواد المسكرة تحت تأثير التهديد والإكراه. واستدلوا لذلك بما يأتي:

من الكتاب: قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾. (1) وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (2). والمكره الواقع تحت التهديد مضطر، وقد بينت الآيات أن الإثم والحرَج مرفوع عنه، فيباح التناول للمواد المسكرة، لضرورة التهديد والإكراه.

ومن السنة: قول النبي - ﷺ -: " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". (3) في الحديث دلالة على أن التهديد والإكراه يرفع الإثم عن المكره فيكون فعله كعدمه.

(1) سورة الأنعام / من الآية 119.

(2) سورة البقرة: من الآية 173.

(3) سبق تخريجه.

ومن المعقول:

- 1- إن تناول المواد المسكرة تحت التهديد والإكراه مباح لمن وقع عليه التهديد والإكراه، حيث إن موضع الضرورة مستثنى من الحرمة.
 - 2- إن الحد مشروع للزجر عن ارتكاب الجناية في المستقبل، وقد كان من وقع عليه التهديد والإكراه منزجراً حين لم يقدم على تناول المواد المسكرة مختاراً، فخرج أن يكون الشرب والتعاطي جناية بالتهديد والإكراه.
 - 3- إن الحد عقوبة محضة تستدعي أن تكون الجناية محضة، وتناول المواد المسكرة مع التهديد والإكراه حال، فلا حد ولا إثم عليه. (1)
- هذا ولا يجب الحد إذا كان التهديد والإكراه تاماً، أما إذا كان ناقصاً، فيجب الحد، لأن التهديد والإكراه الناقص لم يوجب تغيير الفعل عما كان عليه قبل التهديد والإكراه بوجه ما، فلا يوجب تغيير حكمه. (2)

خامساً: الجناية على الأموال تحت الإكراه:

إذا وقع الإنسان تحت تأثير التهديد والإكراه، فأكرهه على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من

(1) بدائع الصنائع 178/7، المبسوط للسرخسي 32/24.

(2) بدائع الصنائع 137/2، الجوهرة النيرة 254/2، مجمع الأنهر 432/2.

أعضائه، فأتلفه وجنى عليه، فعلى من يكون الضمان، هل على القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب في التلف، أو على الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للتلف؟. ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن إتلاف مال الغير تحت التهديد والإكراه يوجب الضمان على القائم بعملية التهديد والإكراه وهو المتسبب في الإتلاف، أما الواقع عليه التهديد والإكراه وهو المباشر للإتلاف فلا ضمان عليه، وهذا إذا كان التهديد والإكراه ملجأ.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

إن الإتلاف ينسب إلى الحامل على الفعل القائم بالتهديد والإكراه وهو المكره، لا إلى الفاعل وهو المكره، فإن المكره المباشر للإتلاف بمنزلة الآلة، على معنى أنه مسلوب الاختيار إيثاراً وارتضاء، وهذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكره فيضربه، فأمكن جعله آلة للمكره، فكان الإتلاف حاصلًا بإكراهه، فكان الضمان عليه.

هذا: ولصاحب المال أن يطالب المثلّف وهو المباشر، ويرجع به على المكره القائم بالتهديد والإكراه وهو المتسبب، لأن المكره معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه الضمان. (1)

كما يرى الحنفية: أن التهديد والإكراه إذا كان ناقصاً، فإن الضمان يكون على المكره، لأن التهديد والإكراه الناقص لا يجعل المكره آلة في يد المكره، لأنه لا يسلب الاختيار أصلاً، فكان الإلتاف منسوباً إلى المكره، فكان الضمان عليه.

سادساً: اليمين الصادرة تحت الإكراه:

ذهب أبو حنيفة وتبعه جماعة من الكوفيين: إلى أن اليمين الصادرة تحت التهديد والإكراه تلزم الحالف فيحنث. (4)

واستدلوا لذلك بما يأتي:

من السنة: قول النبي ﷺ: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق، واليمين". (5) ففي الحديث دليل على أن القصد وعدمه لا يؤثر في التصرف وأن اليمين تقع، سواء أكان هازلاً أم جاداً، مكرهاً أم مختاراً.

ومن المعقول:

(1) بدائع الصنائع 179/7، فتح القدير 64/5، درر الحكام شرح غرر الأحكام 271/2، مجمع الأنهر 433/2، شرح التلويح على التوضيح 391/2 وما بعدها.

(4) العناية 108/5، تبين الحقائق 120/3، مجمع الأنهر 553/1.

(5) الدراية 90/2، وقال: لم أجده هكذا، نصب الراية 293/3، وقال: هكذا ذكره المصنف.

1- إن الواقع تحت التهديد والإكراه يمكنه أن يوارى في يمينه كلها، فإذا لم يوار ولا ذهب يمينه إلى خلاف ما أكره عليه، فقد قصد إلى اليمين، فتلزمه، كمن حلف ألا يفعل شيئاً ففعله بنفسه تحت تأثير التهديد والإكراه.

2- إن الأيمان من التصرفات التي لا تحتل الفسخ والنقض، فلا يؤثر فيها الإكراه.

كتاب الحجر

الفصل الأول

تعريف الحجر ، وحكمة مشروعيته، وأدلتة، ومراتبه

أولاً: تعريف الحجر

الحجر لغة: الحجر: بتسكين الجيم معناه: المنع والتضييق،
تقول: حجر القاضي على فلان يحجر حجراً، وحجر فلان
على أهله إذا منعهم من التصرف. (1)

الحجر اصطلاحاً: عرف الحنفية ما عدا ابن عابدين الحجر
بأنه: المنع من نفاذ التصرفات القولية لا الفعلية. (4) فهنا
قصرنا المنع على التصرفات القولية فقط، ولهم في ذلك
وجهة نظر. أما الإمام ابن عابدين فقد

عرف الحجر بأنه: عبارة عن منع مخصوص بشخص
مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه. (2)

لماذا خص الحنفية الحجر بالتصرفات القولية؟

خص أصحاب التعريف السابق الحجر بالتصرفات القولية
دون الفعلية؛ لأن التصرفات القولية هي التي يتصور

(1) المغرب ص103، المصباح المنير ص660، مختار الصحاح
ص111.

(4) الدر المختار 6 / 143، مجمع الأنهر 2 / 437، درر الحكام
273/2.

(2) المصدر السابق.

الحجر فيها بالمنع من نفاذها، أما التصرفات الفعلية فلا يتصور الحجر فيها، لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، فلا يتصور الحجر فيه. (1)

وهنا يلاحظ: أن ابن عابدين أدخل في التعريف المنع من الفعل، فلم يقصره على المنع من القول فقط، كما هو واضح في التعريف السابق، وقال: إن هذا هو التحقيق، فإنه إن جعل الحجر هو: المنع من ثبوت حكم التصرف، فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي، مع أن لكل منهما حكماً؟ ، وما قيل: من أن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، فالمراد به رد حكم الفعل لا ذات الفعل كما هو الشأن في التصرفات القولية، فإنه لا يمكن رد ذات القول بل الممكن هو رد حكمه. (3)

ثانياً: حكمة مشروعية الحجر:

إن الحجر لم يشرع لإهدار كرامة الإنسان، والتعدي على حقوقه، وإنما شرع صيانة للأموال، وحفظاً لها من الضياع، وحماية للمصالح العامة، حيث إن الخلل العقلي أو العته أو التبذير أو غير ذلك مما يبتلى به الإنسان يؤدي إلى سوء التصرف وعدم القدرة على إدارة الأموال، فيجعل المال عرضة للضياع، إما عن طريق السلب بأن يستغل الناس

(1) رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين 6 / 143.

(3) المصدر السابق.

هؤلاء الأشخاص الذين لا عقل لهم ولا رشد، فيستولي الناس على أموالهم بالباطل، أو عن طريق الغش والتدليس.

هذا: ومن محاسن الحجر أن فيه شفقة على خلق الله - تعالى - وهي إحدى طرفي الديانة، والطرف الآخر هو التعظيم لأمر الله - تعالى -، فإن الله - تعالى - خلق الخلق وفرق بينهم، فجعل بعضهم أصحاب رأي وبصيرة، فيحسنون الأمور، وجعل بعضهم مبتلى بسوء التصرف في المعاملات لا يستطيع القيام بأي عمل، ولا التصرف في أدنى شيء حتى أقل الأمور شأنًا، كالمجنون والمعتوه وغيرهما.

هذا: وقد ركب الله في البشر العقل والهوى، وركب في الملائكة العقل دون الهوى، وركب في البهائم الهوى دون العقل، فمن غلب عقله على هواه كان من أفضل الخلق، ومن غلب هواه عقله كان أردى من البهائم، فيكون تصرفه لا يشمل توفير النظر والمصلحة، فلذا يجبر عليه صيانة لأمواله من الضرب والرياح ورعاية للمصلحة العامة والخاصة، فالحجر يحفظ للدائنين حقهم عند من تم إفلاسه، ويحفظ للأطفال والصغار أموالهم إلى أن يكبروا ويحسنوا التصرف، ويحفظ للمجنون والمعتوه والسفيه ماله من الضياع.

من هنا: كان في مشروعية الحجر عناية من الله بخلقه، ورعاية منه - سبحانه - بالضعفاء من عباده، فهو مشروع لحفظ أموالهم عليهم، حتى يحفظ لهم ماء وجوههم، ويعيشوا

كرماء كما أراد لهم خالقهم، فلا يكونوا عالة على الناس والمجتمع. (1)

ثالثاً: أدلة مشروعية الحجر: الحجر مشروع لأسبابه الشرعية، والدليل على ذلك:

من الكتاب: 1- قول الله - تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. (1)

2- وقول الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. (2)

وجه الدلالة من الآيتين: لقد دلت هاتان الآيتان - الكريمتان - على مشروعية الحجر على السفیه والیتیم، حتی لا یضیع مالهما، ففیهما نہی الأولیاء عن أن یؤتوا الذین لا رشد لهم أموالهم فیضیعوها. (3)

(1) تکملة البحر الرائق 8 / 88، تبیین الحقائق 5 / 190 وما بعدها.
وانظر: الحجر والولاية على المال في الشريعة الإسلامية، د / عبد الفتاح النجار ص4.

(1) سورة النساء: آية: 5.

(2) سورة النساء: من الآية: 6.

(3) تفسير البضاوي 2 / 147.

ومن السنة: فيما روي عن كعب بن مالك عن أبيه: (أن رسول الله -ﷺ- حجر على معاذ بن جبل -ﷺ- ماله وباعه بدين كان عليه). (1)

وجه الدلالة من الحديث: دلّ الحديث على مشروعية الحجر على المدين، حيث باع النبي -ﷺ- مال معاذ في دينه، فدل ذلك على الجواز.

ومن المعقول: فإن في الحجر صيانة للأموال وحفظاً لها من الضياع، كما أن فيه من المصلحة العامة للفرد والمجتمع ما لا يخفى، فهو وإن كان لا يخلو من ضرر المحجور عليه إلا أنه في نفس الوقت يحقق مصلحة عامة لا يقتصر نفعها على المحجور عليه وحده وعلى من يتصل به فحسب، بل تعم مصلحته المجتمع الذي يعيش فيه. (5)

رابعاً: مراتب الحجر، وأقسامه:

الحجر على ثلاثة مراتب هي: - حجر أقوى، وحجر متوسط، وحجر ضعيف، وبيانها كالتالي: -

أولاً: الحجر الأقوى: وهو المنع عن أصل التصرف بعد انعقاده، أي بطلانه كتصرف الشخص المجنون، حيث إن الحجر في حقه يمنعه عن أصل التصرف.

(1) المستدرك على الصحيحين 2 / 67، سنن البيهقي الكبرى 6 / 48.

وقال ابن الصلاح في الأحكام: هو حديث ثابت، سبل السلام 2 / 79.

(5) د / عبد الغفار صالح، الإفلاس في الشريعة الإسلامية ص 59.

ثانياً: الحجر المتوسط: وهو المنع عن وصف التصرف، وهو النفاذ⁽²⁾، وذلك كتصرف الصغير المميز⁽³⁾، فإن الحجر عليه يمنع نفاذ تصرفه، حيث يتوقف النفاذ على إجازة من له حق الإجازة.

ثالثاً: الحجر الضعيف: وهو المنع عن وصف التصرف، وهو كون نفاذ التصرف حالاً، مثل: تأخير نفاذ الإقرار من الشخص المحجور عليه بسبب الإفلاس إلى ما بعد فك الحجر عنه. (4)

الفصل الثاني

أقسام الحجر وأسبابه

أولاً: أقسام الحجر: ينقسم الحجر بحسب المصلحة إلى قسمين: -

القسم الأول: وهو الحجر الذي شرع رعاية لمصلحة المحجور عليه في الغالب، وذلك كالحجر على المجنون

(2) النفاذ: هو ترتب أثر التصرف في الحال. ينظر: شرح مجلة الأحكام العدلية 1/ 109.

(3) المميز: هو من يعرف أن البيع سالب والشراء جالب، ويقصد الربح، ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. ينظر: شرح مجلة الأحكام العدلية 2 / 654.

(4) حاشية ابن عابدين 6 / 143.

والصغير والسفيه وغيرهم، فالحجر على هؤلاء وأمثالهم
 شرع رعاية لمصلحتهم، وحفظاً لأموالهم من الضياع.

القسم الثاني: وهو الحجر الذي شرع لمصلحة الغير، وذلك
 كالحجر على المدين المفلس، والمدين الغني المماطل، صيانة
 لحق الغرماء الدائنين، والحجر على المرتد، صيانة لحق
 المسلمين، والحجر على الراهن، صيانة لحق المرتهن في
 العين المرهونة، والحجر على المريض مرض الموت،
 صيانة لحق الورثة فيما زاد على الثلث.

ثانياً: أسباب الحجر: اتفق فقهاء الحنفية على أن
 الصغر والجنون من الأسباب الشرعية الموجبة للحجر. (1)

واختلفوا فيما عدا ذلك على النحو التالي: -

ذهب أبو حنيفة: إلى أن الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة هي:
 الجنون والصبا والرق، وهذه الثلاثة محل اتفاق. هذا: وقد
 ألحق الإمام أبو حنيفة بهؤلاء: المفتي الماجن، والطبيب
 الجاهل، والمكاري المفلس. (4)

وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أنه يضاف إلى السببين
 السابقين السفه، والتبذير، ومطل الغني، وركوب الدين،

(1) العناية على الهداية 253/9 وما بعدها، بدائع الصنائع 7 / 169.

(4) العناية على الهداية 254 / 9، بدائع الصنائع 7 / 169.

وخوف ضياع المال بالتجارة، والتلجئة⁽²⁾، فكل هذه أسباب شرعية موجبة للحجر. (3)

هذا: والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي: هو الحجر على الصغير، والمجنون، والرقيق، والمفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس بالاتفاق بين الحنفية، والحجر على السفیه والمغفل والمدين على قول الصاحبين، وهو ما عليه الفتوى. (1) هذا: وتفصيل القول في أسباب الحجر المتفق عليها بين الحنفية، سوف يكون في المسائل التالية: -

الفصل الثالث

الحجر على الصغير (الطفل)

أولاً: تعريف الصغير:

- 1- الصغير لغة: مأخوذ من صَغُرَ صَغْراً: إذا قل حجمه أو سنّه، فهو صغير، والصغير ضد الكبير، والجمع صغار. (2)
- 2- الصغير اصطلاحاً: هو وصف يلحق بالإنسان من وقت ولادته إلى أن يبلغ الحلم، لعدم تكامل قواه البشرية. (3)

(2) التلجئة: عقد ينشئه العاقد لضرورة أمر فيصير كالمدفع إليه. ينظر الفتاوى الهندية 209/3.

(3) العناية على الهداية 9 / 254، بدائع الصنائع 7 / 169.

(1) تكملة البحر الرائق 8 / 89.

(2) لسان العرب 4 / 458، مختار الصحاح 1 / 152.

ثانياً: حكم الحجر على الصغير: لا خلاف بين فقهاء الحنفية: في أن الصغير الذي لا يعقل يحجر عليه ويمنع من ماله؛ لأن وضع المال في يده إلتاف له. وأيضاً: الصغير العاقل الذي لم يبلغ الحلم، يمنع من ماله، فيظل محجوراً عليه بحكم الشرع حتى يبلغ، ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يؤنس منه الرشد. (4)

ثالثاً: حكم اختبار الصغير وتدريبه على التجارة: لا بأس لولي الأمر أن يدفع إلى الصغير الذي لم يؤنس منه الرشد جزءاً من المال، ليتاجر به، وذلك من باب الاختبار والتدريب للصغير على أعمال التجارة والبيع والشراء.

والدليل على ذلك:

قول الله - تعالى - : ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. (1)

وجه الدلالة من الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - أذن للأولياء الذين يتولون أمور اليتامى أن يقوموا باختبارهم، وذلك بالإذن لهم بالتجارة، فإذا فعلوا ذلك فوجدوا من الصغار رشداً في ضبط المال، وحسن التصرف، ومعرفة التجارة، فلهم أن يقوموا بدفع المال إليهم، لقوله - تعالى - : ﴿فَإِنْ

(3) الحجر والولاية على النفس والمال ص 8، الموسوعة الفقهية الكويتية 20 / 27.

(4) بدائع الصنائع 7 / 170

(1) سورة النساء: من الآية: 6.

أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴿٢﴾ فالرشد هو
الاهتداء والاستقامة في حفظ المال وإصلاحه، وحسن التصرف
في التجارة. (3)

رابعاً: تصرفات الصغير: الصغير نوعان: غير مميز،
ومميز:

أ- الصغير غير المميز: وهو الطفل الذي لا يفهم البيع
والشراء، فإن جميع تصرفاته القولية تقع باطلة بطلاناً مطلقاً،
حيث إنه يكون في حالة لا يستطيع أن يميز بين النافع
والضار بالنسب له.

ب- الصغير المميز: وهو الطفل الذي يفهم البيع والشراء،
ويفهم الخطاب ويرد الجواب، فتصرفاته على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: التصرفات النافعة للصغير المميز نفعا محضاً -
أي نفعا خالصاً -، كقبوله الهبة والصدقة والوقف، فتصرفه
فيها صحيح، حيث تحقق له النفع، فهي تدخل في ملكه، ولم
يلحقه بسببه ضرر.

النوع الثاني: التصرفات الضارة للصغير المميز ضرراً
محضاً - أي ضرراً خالصاً -، كتبرعه، فتصرفه فيها باطل،
لأنه إخراج للشيء عن ملكه، ولا يجوز لوليه إجازته، نظراً
لما يلحقه من الضرر بسبب هذا النوع من التصرفات.

(2) سورة النساء: من الآية: 6.

(3) تفسير البيضاوي 2 / 149، بدائع الصنائع 7 / 170.

النوع الثالث: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية:

فعند الحنفية: تتعقد هذه التصرفات موقوفة على إجازة الولي، فإن أجاز صح، وإن لم يجز بطل. (1)

خامساً: رفع الحجر عن الصغير:

يرفع الحجر عن الصغير بأحد أمرين: - إما بإذن الولي له في التجارة، وإما بالبلوغ.

أولاً: رفع الحجر عن الصغير بالإذن له في التجارة:

إذا أذن ولي الصغير أو القائم عليه بالتجارة للصغير، فأحسن التصرف ولم يُخدع في البيع والشراء وحفظ المال ونمّاه، دفع إليه ماله، وانفك الحجر عنه.

ثانياً: رفع الحجر عن الصغير بالبلوغ: للحنفية في ذلك تفصيل على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن الصغير إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يدفع إليه ماله، ويرفع عنه الحجر.

القول الثاني: وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أنه لا ينفك الحجر عن الصغير إلا ببلوغه رشيداً، فلا بد من وجود البلوغ

(1) العناية 9 / 312، بدائع الصنائع 7 / 171، الفتاوى الهندية 5 /

والرشد، فلا يدفع إليه ماله قبل ذلك، فيصير محجوراً عليه حتى ولو صار شيخاً (6).

الفصل الرابع

الحجر على المجنون والمعتوه

أولاً: تعريف المجنون:- سبق تعريفه-

ثانياً: حكم الحجر على المجنون:

إن الجنون يعتبر من عوارض الأهلية، فهو يزيل أهلية الأداء إن كان الجنون مطبقاً، فلا تترتب على تصرفات المجنون أية آثار شرعية، حيث إن الجنون المطبق يستوجب الحجر على صاحبه إلى أن يتم شفاؤه، وتقع تصرفاته القولية باطلة، شأنه في ذلك شأن الصغير غير المميز. وعليه: فالحنفية على وجوب الحجر على المجنون، سواء أكان الجنون أصلياً أم عارضاً، قوياً أي مطبقاً، أم ضعيفاً أي غير مطبق. (2) هذا: وفي حالة الجنون غير المطبق أي المتقطع لا يمنع الشخص من التكليف في حال الإفاقة، حيث لا ينفي هذا النوع من الجنون أصل الوجوب، فهو في حال إفاقته كالعاقل تعد تصرفاته صحيحة. (3)

(6) المبسوط للرخسي 24 / 61، تبين الحقائق 5 / 195.

(2) العناية على الهداية 9 / 254، تكملة البحر الرائق 8 / 89.

(3) العناية 9 / 254، تبين الحقائق 5 / 191، بدائع الصنائع 7

وعليه: فيجوز الحجر على الشخص الكبير المسن - الشيخ الهرم - إذا ثبت أن في عقله خللاً، لأنه في هذه الحالة يكون أشبه بالشخص المجنون، حيث يعجز عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه، فأشبهه الصبي والسفيه.

ثالثاً: رفع الحجر عن المجنون: المجنون إذا عقل رفع عنه الحجر، ولا حاجة في رفع الحجر عنه إلى قضاء القاضي أو حكم الحاكم، فتعتبر أقواله وتنفذ تصرفاته وذلك، لأن الحجر عليه ثبت بغير قضاء قاض ولا حكم حاكم، فيرتفع عنه كذلك بدون قضاء ولا حكم. (2)

رابعاً الحجر على المعتوه: العته لغة: هو نقص العقل من غير جنون أو دهش، والمعتوه: المدهوش من غير مس أو جنون (1) - العته اصطلاحاً: هو: آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل، فيصير صاحبه مختلط الكلام، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين. (2)

هذا: وقد اختلف الحنفية في تفسير المعتوه، وأحسن ما قيل فيه: أن المعتوه هو من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون.

(2) بدائع الصنائع 7/ 172.

(1) المغرب ص 303، المصباح المنير ص 392.

(2) التقرير والتحبير 2/ 176.

(3) أي أنه يتمتع بالمظهر الهادئ غير العنيف وهو ما يخالف فيه المجنون.

3-حكم الحجر على المعتوه: الإنسان المصاب بالعتة يحجر عليه حفظاً لماله، فهو يأخذ حكم الصبي العاقل في تصرفاته، وفي رفع التكليف عنه، فإن أفاق من عتته رفع عنه الحجر وجازت تصرفاته، فيأخذ حكم البالغ العاقل، تكون جميع تصرفاته صحيحة. (4) ويستدل على ذلك: بالنصوص التي استدل بها سابقاً بالنسبة للصغير، وذلك بطريق التشبيه؛ لأن حال المعتوه دون حال الصبي (5).

(3) حاشية ابن عابدين 3/ 243، البر الرائق 3/ 268، شرح مجلة الأحكام العدلية 2/ 657.

(4) حاشية ابن عابدين 6/ 144، تكملة البحر الرائق 8/ 89.

(5) المبسوط للسرخسي 24/ 156 وما بعدها، غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام 2/ 273، حاشية ابن عابدين 6/ 144.

الفصل الخامس

الحجر على السفية (الغني المبذر):

أولاً: تعريف السفية: السفه لغة: هو: نقص في العقل، وأصله الخفة. (1)

-السفه اصطلاحاً: هو: تبذير المال وتضييعه على خلاف الشرع أو العقل، كالتبذير والإسراف في النفقة. (3)

ثانياً: حكم الحجر على السفية: اختلف فقهاء الحنفية في حكم الحجر بسبب السفه على قولين:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن لا يجوز الحجر على الحر البالغ العاقل السفية، وأن تصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذراً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة. (2)

أدلة هذا القول: من السنة: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلاً ذكر لرسول الله - ﷺ - أنه يُخدع في البيع، فقال النبي ﷺ -: إذا بايعت فقل لا خباية، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خباية ". (3)

(1) المصباح المنير ص 280.

(3) الدر المختار 6/ 147، العناية على الهداية 9/ 259.

(2) العناية 9/ 25 وما بعدها، بدائع الصنائع 7/ 171، المبسوط

للسرخسي 24/ 157، حاشية ابن عابدين 6/ 147.

(3) صحيح مسلم 3/ 1165.

-وما روي أن رجلاً على عهد رسول الله - ﷺ - كان يبتاع وفي عقده (4) ضعف، فأتى به أهله نبي الله، فقالوا: يا نبي الله أحجر على فلان، فإنه يبتاع وفي عقده ضعف، فدعاه النبي - ﷺ - فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال رسول الله - ﷺ - إن كان غير تارك البيع، فقل لها وها (5) ولا خباة (6).

وجه الدلالة: ذكر في الحديثين أن الرجل كان يخدع في البيع، لضعف في عقله أو رأيه ونظره، ومع ذلك لم يمنعه النبي ﷺ من التصرف، ولم يحجر عليه، ولو كان الحجر واجباً، لما تركه النبي ﷺ يبيع وهو مستحق المنع منه. (1) ومن المعقول: فالسفيه مخاطب عاقل، وكل من هو كذلك لا يحجر عليه كالرشيد وذلك؛ لأن في الحجر عليه سلب لولايته، وفي سلب ولايته إهدار لآدميته وإحاقه بالبهايم. (2)

(4) قيل: أي في عقله ضعف. وقيل: أي في رأيه ونظره ضعف. ينظر: عون المعبود 288/9.

(5) أي هات وخذ. ينظر: عون المعبود 288/9.

(6) سنن البيهقي الكبرى 62/6.

(1) أحكام القرآن للجصاص 670/1 وما بعدها، تحفة الأحوذى 380/4، مختصر اختلاف العلماء 220/5.

(2) العناية على الهداية 9 / 261، شرح فتح القدير 9 / 260 وما بعدها..

2- كما أن الضرر الإنساني الذي يلحقه من جراء هذا الإهدار لآدميته بالحجر عليه يزيد كثيراً على الضرر المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في أمواله، وأنه لا يجوز أن يدفع الضرر الأقل بضرر أعظم منه إلا أن يكون في الحجر عليه دفع ضرر عام. (3)

القول الثاني: وذهب أبو يوسف ومحمد في المفتى به: إلى أن السفه من الأسباب الموجبة للحجر، وأنه يجوز الحجر على السفه، فيمنع من التصرف في ماله. (2)

أدلة هذا القول: استدل من قال بجواز الحجر على السفه بالكتاب، والسنة، والأثر، والإجماع، والمعقول، وذلك على النحو التالي: -

أما الكتاب: فيما يلي: -

1- قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ ﴾. (1)

(3) تبين الحقائق 5/ 193، الجوهرة النيرة 1/ 241، وانظر: موقع إسلام أون لاين، حقوق الإنسان في النظرية الإسلامية، د/ إبراهيم البيومي غانم، الأربعاء، 15 من أغسطس 2007م.

(2) العناية على الهداية 9/ 260 وما بعدها، بدائع الصنائع 7/ 171، .

(1) سورة البقرة: من الآية: 282.

وجه الدلالة من الآية: في هذه الآية - الكريمة - تنصيص على إثبات الولاية على السفية، وأنه مؤلّى عليه، ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه. (2)

2- وقول الله - تعالى - : ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۖ ﴾. (3) وجه الدلالة من الآية: في هذه الآية - الكريمة - أيضا ما يفيد إثبات الحجر على السفية؛ لأن النهي عن إتيان المال للسفيه إثبات للحجر عليه بطريق النظر، ورعاية المصلحة. (4)

وأما السنة: فيما روي أن حبان بن منقذ الأنصاري - رضي الله عنه - كان يغبن في البياعات؛ لآمة أصابت رأسه، فسأل أهله رسول الله - ﷺ - أن يحجر عليه، فقال: إني لا أصبر على البيع، فقال: - ﷺ - (إذا بايعت، فقل لا خلافة؛ ولي الخيار ثلاثة أيام). (7)

وجه الدلالة من الحديث: دل هذا الحديث على جواز الحجر على السفية بسبب تبذير المال، فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعا، لما سأل أهل

(2) المبسوط للرخسي 157/ 24، تبين الحقائق 5/ 192، 196.

(3) سورة النساء: من الآية: 5.

(4) المبسوط للرخسي 157/ 24، تبين الحقائق 5/ 192.

(7) سنن البيهقي الكبرى 6/ 62، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2

الرجل في الحديث النبي - ﷺ - أن يحجر عليه، ولما فعله الرسول - ﷺ - . (8)

وأما الأثر: فيما يأتي:

1- ما روي: (أن عبد الله بن جعفر - ﷺ - كان يفني ماله في اتخاذ الضيافات، حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقال: لآتين عثمان ولأسأله أن يحجر عليه، فاهتم لذلك عبد الله - ﷺ - وجاء إلى الزبير - ﷺ - وأخبره بذلك، فقال: أشركني فيها، فأشركه، ثم جاء علي إلى عثمان - ﷺ - وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟) . (1)

وجه الدلالة من الأثر: في هذا الأثر دلالة على أنه لو لم يشاركه الزبير في الدار التي اشتراها لحجر عليه سيدنا عثمان، وقد كان ذلك بمحض من الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد، فدل ذلك على جوازه. (2)

2- وبما روي أن عائشة رضي الله عنها - (بلغها أن الزبير بلغه أنها باعت بعض أرباعها، فقال: لتنتهين أو

(8) المبسوط للسرخسي 158/ 24، تبیین الحقائق 5/ 192 وما بعدها.

(1) سنن الدارقطني 4/ 231، مصنف عبد الرزاق 8/ 267.

(2) معاصر المختصر 2/ 17 وما بعدها.

لأحجرن عليها، فبلغها ذلك، فقالت: لله عليّ أن لا أكلمه أبداً⁽²⁾.

وجه الدلالة من الأثر: فإن هذا الأثر يثبت أن ابن الزبير والسيدة عائشة - رضي الله عنهما - كانا يريان الحجر، إلا أن السيدة عائشة أنكرت على الزبير الحجر، ولولا أنها كانت ترى ذلك جائزاً، لبينت السيدة عائشة للزبير أن الحجر لا يجوز، ولردت عليه قوله⁽³⁾.

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن السفه من الأسباب الموجبة للحجر.

وأما المعقول: فإن السفه مبذر يصرف ماله لا على الوجه الذي يقتضيه العقل، فيحجر عليه، نظراً له وصيانة لماله، قياساً على الصغير، بل هو أولى بالحجر من الصغير؛ لأن الثابت في حق الصغير احتمال التبذير، والثابت في حق السفه هو حقيقة التبذير، فكان أولى بالحجر من الصغير، ولهذا منع عنه المال⁽⁵⁾.

(2) صحيح البخاري 5/ 2255، بلفظ: أن الزبير قال: في بيع أو عطاء أعطته عائشة. .

(3) أحكام القرآن للجصاص 1/ 670، مختصر اختلاف العلماء 5/ 220.

(5) العناية على الهداية 9/ 260 وما بعدها، بدائع الصنائع 7/ 171، .

هذا: والذي يبدو أن القول بأن السفه من الأسباب الموجبة للحجر، وأنه يجوز الحجر على السفه المبذر لماله المسرف له على غير مقتضى الشرع والعقل، هو الأولى بالقبول وهو المفتى به عند الحنفية؛ لأن في الحجر عليه رعاية لمصلحته، وذلك بالمحافظة على ماله وصيانتة له، حتى لا يضيعه، فلا يجد ما ينفق منه، فيصبح عالة على الناس والمجتمع، فكان في الحجر عليه ما يكفل له العيش من ماله، بدلا من أن يضيع فيتكفف الناس.

ثالثاً: الحجر على من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً:

1- المقصود بالرشد: الرشد في اللغة: هو الصلاح، وهو خلاف الغي والضلال. (1)

الرشد عند جمهور الفقهاء: هو الصلاح في المال فقط، وذلك بتمييزه وحسن القيام به في جمعه وإنفاقه. (2)

2- حكم الحجر على من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً:

اختلف فقهاء الحنفية في حكم الحجر على من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً، وذلك على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاً لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا، واستدل أبو حنيفة لقوله بالكتاب، والمعقول:

(1) المصباح المنير ص 227.

(2) أحكام القرآن للجصاص 2 63 وما بعدها، بدائع الصنائع 7 / 170.

أما الكتاب: فقول الله - تعالى - : ﴿وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾. (4) وجه الدلالة من الآية: أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بدفع أموال اليتامى إليهم، والمراد أن يكون الدفع بعد البلوغ، وقد سماهم المولى - عز وجل - يتامى؛ لقربهم من البلوغ، (1) إلا أنه قام الدليل على منع المال منه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد، حيث قال المولى - عز وجل - : ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. (2) وحرف الفاء للوصل والتعقيب، فيكون دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إنباس الرشد، وما يقرب من البلوغ يكون في معنى حالة البلوغ. (3)

وأما المعقول: فيما يأتي: - أن أول مراحل البلوغ قد يعتري الإنسان السفه باعتبار أن أثر الصبا قد يكون باقيا، فكان التقدير بخمس وعشرين سنة؛ لأنه الحال التي يكتمل فيها العقل، فقد روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قال: (ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة) (4)، وقال

(4) سورة النساء: من الآية: 2.

(1) تبين الحقائق 5 / 195.

(2) سورة النساء: من الآية: 6.

(3) المبسوط للسرخسي 24 / 162.

(4) ذكره الزيلعي في تبين الحقائق 5 / 195، ومنلا خسرو في درر

الحكام 274/2 وما بعدها عن عمر - رضي الله عنه -، بينما ذكره الطوري في تكملة

أهل الطبائع — أي الأطباء —: (من بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده).

أن الإنسان إذا بلغ هذا السن، فقد زال عنه أثر الصبا، فلا يعتبر في منع المال عنه مصلحة؛ لأن منع المال عنه يكون على سبيل التأديب عقوبة عليه، والعقوبة بالتأديب تكون عند رجاء التأديب، وهو بعد بلوغه هذا السن انقطع رجاء التأديب، فلا معنى للحجر عليه ومنعه من ماله. (5)

القول الثاني: ذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أنه يحجر على من بلغ رشيدا ثم صار سفيها مبذرا، وأنه لا يجوز دفع المال إليه حتى يؤنس منه الرشد، وأنه لا يجوز تصرفه فيه أبدا، حتى ولو صار شيخا، ما دام سفيها. (1)

واستدل صاحبان لقولهما بما يأتي:

من الكتاب:- قول الله - تعالى -: ﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. (2) وجه الدلالة: أن هذه الآية - الكريمة - محكمة لم ينسخها شيء، فلا يجوز دفع المال

البحر الرائق 8/ 91 عن ابن عمر، ولم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب الأثر.

(5) تبين الحقائق 5/ 195، تكملة البحر الرائق 8/ 91 وما بعدها .

(1) المبسوط للمرخسي 24/ 61، تبين الحقائق 5/ 195.

(2) سورة النساء: من الآية: 6.

إليه قبل إيناس الرشد منه، فأيناس الرشد شرط لدفع المال وزوال الحجر بغض النظر عن السن. (3)

2- وقول الله تعالى -: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ». (4)
وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - نهانا عن دفع المال إلى السفیه ما دام سفيها، وأمرنا بالدفع إليه إن وجد منه الرشد، إذ لا يجوز الدفع إليه قبل إيناس الرشد منه، فدل ذلك على أن إيناس الرشد هو شرط دفع المال ورفع الحجر مهما بلغ من العمر. (5)

وأما المعقول فبما يأتي: إن الإنسان عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال بهذه الآية وهي قول الله - تعالى -: «فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ». (1)، فكذلك الحكم إذا بلغ من العمر خمسا وعشرين سنة سفيها، فإنه لا يدفع إليه المال؛ لأن السفه يستحكم بطول المدة.

القياس على الجنون والعتة، حيث إن السفیه في حكم منع المال منه بمنزلة المجنون والمعتوه، وحيث إن الجنون

(3) المبسوط للسرخسي 161/ 24.

(4) سورة النساء: من الآية: 5.

(5) تبیین الحقائق 5/ 195.

(1) سورة النساء: من الآية: 6.

والعته يمنع من دفع المال إليه حتى ولو بلغ خمسا وعشرين سنة، فكذلك السفه يمنع من ذلك. (2)

هذا: والذي يبدو لي أن القول باستمرار الحجر على الإنسان السفهيه مهما بلغ من العمر حتى يؤنس منه الرشد هو الأولى بالقبول، لما فيه من رعايته، والنظر في مصلحته.

رابعاً: هل يحتاج الحجر على السفهيه إلى قضاء قاض أو حكم حاكم؟. بناء على قول من قال بجواز الحجر على السفهيه حتى يؤنس منه الرشد، حدث خلاف بينهم في هل يتم الحجر على السفهيه بنفس السفه، أو أن الحجر عليه يحتاج إلى قضاء قاض أو حكم حاكم، وذلك على النحو الآتي:

القول الأول: ذهب أبو يوسف: إلى أنه لابد في الحجر على السفهيه من قضاء القاضي أو حكم الحاكم، كما أن رفع الحجر عنه يحتاج إلى قضاء القاضي أو حكم الحاكم، حيث لا يزول الحجر عنه إلا به؛ ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره، فكان كابتداء الحجر عليه، فيتوقف على قضاء القاضي أو حكم الحاكم. (1)

(2) تبين الحقائق 5/ 195، المبسوط للسرخسي 24/ 161 وما بعدها.

(1) المبسوط للسرخسي 24/ 163، بدائع الصنائع 7/ 169، الجوهرة

النيرة 1/ 242.

القول الثاني: وذهب محمد بن الحسن: إلى أن السفية لا يحتاج في الحجر عليه إلى حكم الحاكم أو قضاء القاضي، وإنما يحجر عليه بمجرد السفه وذلك، لأن إفساده وتبذيره لماله هو الذي يوجب الحجر عليه، وإصلاحه لماله وحفظه له هو الذي يطلق يده ليتصرف فيه، حيث إن العلة في الحجر هي السفه، وقد تحققت في حقه في الحال، فيترتب على ذلك الحجر عليه بموجبها بدون حاجة إلى قضاء القاضي أو حكم الحاكم، قياساً على الصبي والمجنون، فإن الصبا والجنون هما السببان الموجبان للحجر عليهما، فكذا هنا يكون السفه هو السبب الموجب للحجر، ولما يتوقف الأمر على حكم الحاكم أو قضاء القاضي. (2)

ثمرة الخلاف في هذه المسألة: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة: فيما لو باع السفية شيئاً قبل الحجر عليه، فعند الجمهور: يقع البيع جائزاً؛ لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر، فلا بد من فعل القاضي، وعند محمد ومن تبعه: يكون غير جائز؛ لأنه يبلغ محجوراً عليه، فلا يتوقف على فعل القاضي. (2)

هذا: والذي يبدو لي أن القول بأن الحجر على السفية يتوقف على قضاء القاضي أو حكم الحاكم، كما أن رفع

(2) المبسوط للرخسي 24/ 163، بدائع الصنائع 7/ 169.

(2) العناية على الهداية 9/ 264، مجمع الأنهر 2/ 440.

الحجر عنه يتوقف على ذلك هو الأولى بالقبول؛ لأنه يسد باب الدعاوى الكيدية، حيث إن القاضي أو الحاكم لا يحكم بالسفه إلا بعد التحري والتقصي وشهادة أهل الخبرة بذلك، فيسد الباب على كل من يحاول أن يتهم غيره بالسفه ليحجر عليه بغير سببه الشرعي.

خامساً: الفرق بين الحجر بالسفه، والحجر بالدين:

يظهر الفرق بين الحجر بالسفه والحجر بالدين من ثلاثة وجوه: -

أحدها: أن الحجر على السفه يكون لمعنى فيه، وهو سوء اختياره وتصرفه، والحجر على المدين يكون لحق الغرماء بسبب الدين، فيفتقر إلى القضاء.

الثاني: أن المحجور عليه بسبب السفه إذا أعتق عبداً وجبت عليه السّعاية⁽¹⁾ وأدى ولا يرجع بما سعى على المولى بعد زوال الحجر، بخلاف المحجور عليه بسبب الإفلاس والدين، فإنه يرجع عليه بذلك.

الثالث: أن المحجور عليه بسبب السفه لا يجوز إقراره لا حال الحجر ولا بعده، ولا في المال القائم، ولا في المال الحادث، أما المحجور عليه بسبب الدين، فإنه لو أقر

(1) السّعاية: اكتساب العبد المال ليتخلص به من الرق، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه : المصباح المنير ص 277 وما بعدها، لسان العرب 14 / 387.

حالة الحجر ينفذ إقراره فيما سيحدث له من المال حالة الحجر. (2)

سادساً: نقض قضاء القاضي بالحجر على السفية:

إذا حجر القاضي على السفية، ثم رُفِعَ حكمه إلى قض آخر، فقام هذا القاضي بإبطال الحكم الذي قضى به القاضي الأول ورفع عنه الحجر، فإن قضاءه جائز؛ لأن الحجر من القاضي فتوى وليس بقضاء، ولأن القضاء يقتضي وجود المقضى له والمقضى عليه، ولا وجود لذلك، وعلى فرض أنه قضاء لا فتوى، فإن نفس القضاء مختلف فيه، فإن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يقل به، فصار محلاً للقضاء يحتاج إلى إمضاء، فلو رفع المحجور عليه تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو غيره فقضى ببطلان تصرفه، ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله؛ لاتصال الإمضاء به، فلا يقبل النقض بعد ذلك. (3)

(2) حاشية ابن عابدين 6/ 148، تكملة البحر الرائق 8/ 90.

(3) العناية على الهداية 9/ 261 وما بعدها، تكملة البحر الرائق 8/ 91.

الفصل السادس

الحجر على ذي الغفلة (1)

أولاً: تعريف الغفلة :

1- الغفلة لغة: هي غيبة الشيء عن بال الإنسان، والرجل المَغْفَل: هو الذي لا فطنة له. (2).

2- الغفلة اصطلاحاً: ضد الفطنة: والمغفل: هو من اختل ضبطه وحفظه، ولا يهتدي إلى التصرفات الراجعة، فيغبن في البياعات، لسلامة قلبه، وعدم استعماله القوة المنبهة مع وجودها. (3) وقيل المغفل: هو الإنسان البسيط الذي يخدع بسهولة ولا يميز بين الرأي السديد والخاطئ، ففيه من الغباء ما يوقعه دوماً في الغبن الفاحش، فهو شخص لا يستطيع تقدير الأمور.

ثانياً: حكم الحجر بسبب الغفلة:

اختلف فقهاء الحنفية في ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أن الغفلة ليست من الأسباب الموجبة للحجر، فلا يجوز الحجر على الغافل

(1) هذه المسألة تحدث عنها فقهاء الحنفية.

(2) المصباح المنير ص 449 وما بعدها، المغرب ص 342.

(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 31 / 260.

بسبب الغفلة. (4) واستدل لذلك: بأن الشخص المصاب بالغفلة ليس بمفسد ولا يقصد الإفساد، غاية الأمر أنه لا يهتدي إلى التصرفات الرباحة، فيغبن في البياعات، لسلامة قلبه. (1)

القول الثاني: للصاحبين من الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن الغفلة من الأسباب الموجبة للحجر، فإنه يحجر علي ذي الغفلة كما يحجر على السفیه، ويكون الحجر عليه من حين قضاء القاضي، وذلك عند أبي يوسف، ومن حين ظهور أمارات الغفلة، وذلك عند محمد، وبناء عليه: فإن الحجر عليه لا يزول عنه إلا بقضاء القاضي عند أبي يوسف، ويزول بزوال الغفلة دون أن يحتاج إلى قضاء القاضي أو حكم الحاكم، وذلك عند محمد بن الحسن. (2)

واستدلنا لذلك بالسنة والمعقول على النحو التالي:

أما السنة: فيما روي: (أن أهل حبان بن منقذ طلبوا من النبي - ﷺ - أن يحجر عليه، فأقرهم النبي - ﷺ - على

(4) العناية على الهداية 9/ 268 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 6/ 147 وما بعدها، تكملة البحر الرائق 8/ 94، تبين الحقائق 5/ 198 وما بعدها.

(1) العناية على الهداية 9/ 269، تبين الحقائق 5/ 198، حاشية ابن عابدين 6/ 147، مجمع الأنهر 2/ 442.

(2) العناية على الهداية 9/ 269، شرح فتح القدير 9/ 269، مجمع الأنهر 2/ 442.

ذلك، ولم ينكر عليهم). (3) وجه الدلالة: دل الحديث أن الحجر لو لم يكن مشروعاً على ذي الغفلة، لأنكر النبي - ﷺ عليهم طلبهم، وحيث لم ينكر عليهم ذلك، فدل على مشروعية الحجر عليه. (4)

وأما المعقول: فإن الحجر على ذي الغفلة شرع صيانة لماله، ونظراً له، فشرع الحجر عليه رعاية لذلك. الفرق بين المعتوه، والمغفل: إن المعتوه أي ناقص العقل والمغفل الذي هو نوع من السفه شبيهان في المذهب الحنفي، من حيث درجة الحجر الواقع عليهما، إذ أنهما كليهما ناقصا الأهلية، وأهليتهما كأهلية الصغير المميز.

ولكن الاثنين يختلفان من وجهين آخرين، هما: -

أولاً: المعتوه أقل عقلاً من المغفل، ولذا اعتبر المعتوه محجوراً عليه لذاته، أما المغفل فالحجر عليه متروك إلى تقدير القاضي.

ثانياً: أن الولاية على المغفل المحجور عليه هي للقاضي دائماً، كما هي لسائر السفهاء، أما المعتوه، فالولاية عليه

(3) سبق تخريجه ص 36 من البحث.

(4) تبين الحقائق 5/ 199.

كالولاية على الصغار، أي أنها لا تعود إلى القاضي إلا عند عدم وجود أحد من أصحاب الولاية، حسب الترتيب. (1)

الفصل السابع

الحجر على المدين

الشخص المدين لا يخلو، إما أن يكون مدينا مفلسا، وإما أن يكون مدينا غنيا إلا أنه مماطل في السداد، وبيان حكم الحجر عليهما يكون على النحو التالي: -

أولاً: الحجر على المدين المفلس:

مفهوم الإفلاس في اللغة والاصطلاح: الإفلاس في اللغة: مصدر أفلس، تقول أفلس الرجل: أي صار إلى حال ليس له فلوس، والفلس: اسم المصدر من الإفلاس. (2)

الإفلاس في الاصطلاح: هو: أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلاً، أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه. (3)

شروط الحجر على المفلس: اشترط القائلون بالحجر على المفلس عدة شروط، لصحة الحجر عليه، وذلك على النحو الآتي:

(1) أ. د/ صبحي محمصاني، الحجر على السفه، موقع شبكة الوطنية

الثقافية. <http://www.alwatanyh.com>

(2) المصباح المنير ص 481.

(3) الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 300.

أن يطلب الغرماء أو من ينوب عنهم الحجر على المفلس.
 أن يكون الدين الذي هو السبب في طلب الحجر ديناً حالاً.
 أن يكون الدين الذي على المفلس هو دين الآدميين.
 أن يكون الدين الذي على المفلس أكثر من ماله.
 أن يكون الدين الذي هو سبب للحجر ديناً لازماً. (2)

رأي الفقهاء في الحجر بسبب الإفلاس: اختلف فقهاء الحنفية في الحجر بسبب الإفلاس، وذلك على النحو الآتي:
 القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يحجر على الإنسان بسبب الدين، حتى لو طلب الغرماء الحجر عليه، ولكن يُحبس، ليتولى هو بنفسه بيع ماله وقضاء ما عليه من الديون. (3) استدل أبو حنيفة لذلك بالمعقول:

- 1- في الحجر على المدين إهدار لأهليته، وهو ضرر عظيم لا يجوز فعله ولا ارتكابه، لدفع ضرر أخف وأخص منه.
- 2- إن في بيع الحاكم ماله جبراً عنه مخالفة للنص القرآني الذي اشترط التراضي، وهو قول الله - تعالى - : ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. (4)، فيكون البيع جبراً باطلاً.

(2) العناية على الهداية 271/ 9، شرح فتح القدير 274/ 9.

(3) العناية على الهداية 271/ 9 وما بعدها، المبسوط للمرخسي 24/ 163.

(4) سورة النساء: من الآية: 29.

3- إن قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم، دفعا لظلمه وإيصالا للحق إلى مستحقه، ولا يكون ذلك إكراها على البيع؛ لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء الدين. (5)

القول الثاني: وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أنه يجوز الحجر على المدين المفلس، وللقاضي أن يبيع ماله إن امتنع هو من بيعه. (1) استدل الصحابان لقولهما بالسنة، والمعقول:

أما السنة: - فيما روي: (أن معاذاً رضي الله عنه - ركب دين، فباع رسول الله ﷺ ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص) (2) وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أنه يجوز الحجر على كل مدين، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين، لقضاء دينه من غير فرق بين ما إذا كان المال مستغرقا بالدين أم لا. (3)

وأما المعقول: فيما يلي: -

(5) شرح فتح القدير 9/ 9/ 271 وما بعدها، المبسوط للسرخسي 24/ 163.

(1) العناية على الهداية 9/ 271، المبسوط للسرخسي 24/ 163، وما بعدها.

(2) سنن البيهقي الكبرى 6/ 49، المعجم الكبير 20/ 31.

(3) نيل الأوطار للشوكاني 5/ 292 وما بعدها.

1- إن في الحجر على المدين رعاية لمصلحة الغير، وهم الدائنون الغرماء، حتى لا يلحقهم الضرر إذا أقر للغير، أو ألجأ ماله وأقر به لشخص يصعب انتزاعه منه.

2- إن البيع واجب عليه لإيفاء ما عليه من الديون، حتى إنه يحبس فيه، فإذا امتنع من البيع ناب القاضي عنه، كما في حالة المجبوب والعنيد إذا امتنعا من التطبيق، فإن القاضي ينوب عنهما، فكذا هنا. (2)

والذي يبدو لي: أن ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز الحجر على المدين المفلس، وأنه يجوز للحاكم أو القاضي أن يبيع ماله، هو الأولى بالقبول، لما فيه من رعاية لمصلحة الغرماء، حتى ترد الحقوق إلى أصحابها.

هذا: والفرق بين المفلس والمعسر: أن المعسر أسوأ حالاً من المفلس، فهو فقير معدم المال أصلاً، كما أن المعسر لا سبيل للدائنين عليه فلا يطالب بالدين وإنما ينظر إلى ميسرة، أما المفلس فهو من كان ماله أقل من ديونه

(2) العناية على الهداية 9/ 271، تبين الحقائق 5/ 199 وما بعدها.

بحيث لا يفي ماله بالتزاماته المالية، فتجري عليه أحكام الإفلاس من الحجر والبيع جبرا عنه لسداد حق الغرماء.⁽¹⁾

حاجة الحجر على المدين ورفعته إلى قضاء القاضي:

أما الحجر عليه: فإنه يتوقف على حكم الحاكم أو قضاء القاضي، فيكون الحجر عليه للحاكم أو للقاضي وحده دون غيره؛ لأن الحجر عليه يحتاج إلى نظر واجتهاد، فيتوقف على قضاء القاضي أو حكم الحاكم.⁽²⁾

وأما فك الحجر عنه: فإنه يرتفع بقسمة المال ولا يتوقف على حكم حاكم أو قضاء قاض، لأنه حُرْج عليه بسبب الدين وبقسمة المال وعدم بقاء الدين زال السبب، وإذا زال السبب، زال الحجر فلا يتوقف على حكم أو قضاء.⁽³⁾

قضاء القاضي بالإفلاس:

عند أبي حنيفة: لا يتحقق القضاء بالإفلاس وذلك، لأن المال غاد ورائح، فلا يحول بينه وبين الغرماء، لأن وقوف الشهود على عدم المال من الأمور التي لا تتحقق إلا ظاهرا،

(1) د / عبد الغفار إبراهيم صالح، الإفلاس في الشريعة الإسلامية ص 20 وما بعدها، عبد المحسن آل شيخ، أحكام الحجر على المفلس ص39.

(2) حاشية ابن عابدين 6 / 148.

(3) شرح مجلة الأحكام العدلية 2 / 716.

فيصالح ذلك للدفع لا لإبطال حق الملازمة، فلا يبطل حق الغرماء بملازمة مَنْ حكم عليه القاضي بالإفلاس.

وعند الصاحبين: إذا قضى القاضي بالإفلاس، فله أن يحول بينه وبين الغرماء، إلا إذا استطاع الغرماء اللّيتان بالبينة التي تشهد بأن له مالا وذلك، لأن القضاء بالإفلاس من الأمور التي تصح عند الصاحبين، وفي هذه الحالة، وهي حالة القضاء بالإفلاس يثبت عسرة المفلس، ويستحق النظرة إلى ميسرة.

هذا: وينبغي أن يلاحظ أن هذه الملازمة تكون بين الرجال، فإذا كان الدائن رجلا والمدين امرأة، فإنه لا يلزمها؛ لأن ذلك يستلزم الخلوة بالمرأة وهو حرام شرعا، وإنما عليه أن يبعث امرأة أمينة تقوم بملازمتها، معنى ذلك أن الرجال يلزمون الرجال والنساء يلازمن النساء، لأن وجود الجنس مع الجنس في الملازمة أخف. (2)

ثانيا: الحجر على المدين الغائب: اختلف فقهاء الحنفية في حكم الحجر على المدين الغائب، وذلك على النحو التالي:

ذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين، سواء أكان غائبا أم حاضرا. (3)

(2) العناية على الهداية 277/9 وما بعدها، الجوهرة النيرة 247/1،

الفتاوى الهندية 63/5 وما بعدها.

(3) الفتاوى الهندية 62/5.

وذهب الصحابان من الحنفية: إلى أنه يصح الحجر على
المدين الغائب، إلا أن لهم في ذلك تفصيل: - (1)
فالصحابان اشترطا لصحة ذلك: أن يعلم المحجور عليه،
ويترتب على ذلك أن كل تصرف يكون قد باشره بعد الحجر
وقبل العلم به صحيحا عندهما.

وعليه: فإذا ثبت الدين بإقرار المدين واعترافه، أو
بشهادة الشهود عليه، إلا أنه غاب عند طلبه أمام مجلس
القضاء قبل الحكم، وامتنع من الحضور:

فعند أبي يوسف: للقاضي أن ينصب وكيلًا عنه، ويحكم عليه
بالمال، إن سأل الخصم ذلك، أما إن سأل الخصم أن يحجر
القاضي على المدين الغائب، فعند أبي حنيفة ومحمد: لا يحكم
ولا يحجر عليه حتى يحضر الغائب، ثم يحكم عليه القاضي،
وللقاضي أن يحجر عليه إذا حضر وذلك عند محمد؛ لأنه إنما
يحجر عليه بعد الحكم لا قبله. (4)

ثالثًا: الحجر على المدين الغني المماطل:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أنه لا يلحق المدين الغني المماطل
بالمدين المفلس، فلا يحجر عليه ولا يباع عنه، بل يجب حبسه
حتى يقضي دينه، وذلك لقول الله - تعالى - : ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ

(1) الفتاوى الهندية 5/ 62.

(4) المصدر السابق.

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» (1)، ولحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه). (2) ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيب من نفسه ولا رضاه.

(1) سورة النساء: من الآية: 29.

(2) سنن البيهقي الكبرى 8/ 182، سنن الدارقطني 3/ 26.

الفصل الثامن

الحجر على الفاسق

مفهوم الفسق في اللغة والاصطلاح:

الفسق في اللغة: هو الخروج عن الطاعة، وعن الدين، وعن الاستقامة، وأصل الفسق: خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد. (1) والفسق في الاصطلاح: هو الخروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية. (2)

حكم الحجر على الفاسق: ذهب فقهاء الحنفية: إلى أنه لا يحجر على الإنسان الفاسق إذا كان مصلحاً لماله، أي محافظاً عليه يصرفه على الوجه الذي يقتضيه الشرع والعقل، لا فرق في ذلك بين الفسق الأصلي، وهو ما إذا بلغ الإنسان فاسقاً، وبين الفسق الطارئ. واستدلوا لذلك بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب: فقول الله - تعالى - : ﴿ فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ﴾. (3)

وجه الدلالة من الآية: إن الله - سبحانه وتعالى - ذكر لفظ «رُشْدًا» نكرة، والنكرة بإطلاقها تتناول القليل والكثير، وهو قد أونس منه نوع رشد، فتتناوله النكرة، حيث أصلح في ماله،

(1) المصباح المنير ص 473، المغرب ص 361.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم 2/ 54، تحفة الأحوذى 7/ 324.

(3) سورة النساء: من الآية: 6.

ومن أصلح في ماله، فقد أونس منه رشداً فلما يحجر عليه. (4)
وبمعنى آخر: أن قوله - تعالى - : ﴿رُشْدًا﴾ نكرة في موضع
الاثبات، والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم، فإذا وجد
منه رشداً ما فقد وجد الشرط، فيجب دفع المال إليه. (1)
وأما المعقول: فبما يأتي:

- 1- إن الفاسق من أهل الولاية لإسلامه، وطالما أنه من أهل
الولاية، فيكون والياً للتصرف في ماله.
- 2- إن مجرد الفسق فقط لا يوجب الحجر، لأن الفسق لا
يتحقق به إلتاف المال ولا عدم إلتافه. (2)

الفصل التاسع

الحجر على مريض مرض الموت والمرتب

مفهوم المرض في اللغة والاصطلاح:

المرض لغة: حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل.

(1)

واصطلاحاً: ما يعرض للبدن، فيخرجه عن الاعتدال. (2) أو
هو: هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال
الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير سليمة. (3)

(4) العناية على الهداية 9 / 268.

(1) المبسوط للسرخسي 24 / 162.

(2) الهداية، وعليها العناية 9 / 268.

(1) المصباح المنير ص 568.

من هو مريض الموت؟: مريض الموت هو: من لا يستطيع الخروج لحوائجه خارج البيت، ولا تستطيع المرأة القيام بعملها داخل البيت. (5)

حكم الحجر على المريض مرض الموت:

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أن مرض الموت من الأسباب الموجبة للحجر على المريض في تبرعاته فيما زاد على الثلث، وذلك للحفاظ على حق الورثة، حتى لا يضيع حقهم في التركة التي تؤول إليهم بعد موته، ولما فيه من صيانة حق الغرماء عن الضياع إذا ما كان مدينا بمال لغيره. (1)

هذا: مع العلم بأن المرض يكون سببا من الأسباب الموجبة للحجر إذا اتصل به الموت، وذلك لأن المرض المميت للإنسان هو السبب في الحجر وليس نفس المرض، حتى لا يكون في ذلك دعوى إلى الحجر على كل إنسان يتعرض للمرض حتى ولو كان مرضا عاديا يتعرض له أي إنسان، ولا يكون من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة في الغالب، وذلك من باب سد الذرائع على الذين يريدون الاستيلاء على أموال الناس عن

(2) التقرير والتحبير 2/ 186.

(3) المصدر السابق.

(5) حاشية ابن عابدين 3/ 383.

(1) العناية على الهداية 9/ 266.

طريق الحجر بدون أن توجد الأسباب الشرعية الداعية إلى ذلك.

الحجر على مال المرتد: اختلف الحنفية في حكم الحجر على مال المرتد:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة: إلى أنه يحجر على مال المرتد بسبب الردة، ويمنع من التصرف، وأنه لو تصرف بعد رده تكون تصرفاته موقوفة، فإن أسلم وتاب انفك الحجر عنه، وجاز تصرفه فيه، كما كان يتصرف فيه قبل رده، وإن قُتل أو مات على رده بطل تصرفه. (5)

واستدل لذلك بما يأتي: إن المرتد قد وجد منه سبب زوال الملك وهو الردة التي تستوجب الحجر عليه في ملكه، حيث إن الردة سبب لوجوب القتل، والقتل سبب لحصول الموت، فكان زوال الملك عن المرتد عند الموت مضافاً إلى السبب وهو الردة. (1)

إن المرتد لا يمكنه اللحاق بدار الحرب بأمواله التي اكتسبها حال إسلامه، حيث إنه لا يمكن من ذلك، بل يُقتل لردته، فيبقى ماله فاضلاً عن حاجته، فكان ينبغي أن يحكم بزوال ملكه عنه للحال، إلا أن التوقف فيه لاحتمال عودته إلى الإسلام. (2)

(5) بدائع الصنائع 7/ 136، تبين الحقائق 285/3 وما بعدها.

(1) بدائع الصنائع 7/ 136 وما بعدها.

(2) المصدر السابق.

وبمعنى آخر أن المرتد مقهور تحت أيدي المسلمين، حتى إنه يقتل، إلا أنه لا قتل إلا بالحرب، وهذا يوجب زوال ملكه، ولأنه هالك حكماً، فصار كالهالك حقيقة، إلا أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عودته إليه، فيتوقف في أمره. (3)

القول الثاني: وذهب أبو يوسف ومحمد: إلى أن المرتد لا يحجر عليه وأن تصرفه جائز. (1)

واستدلوا لذلك بما يأتي:

إن الملك كان ثابتاً للمرتد قبل رده، أي حال إسلامه، وذلك لوجود سبب الملك وأهليته وهي الحرية، وتأثير الردة إنما يظهر في إباحة دم المرتد لا في زوال ملكه، حيث إن الردة لا تؤثر في زوال الملك، فلا يزول ملكه ويصح تصرفه في ماله. (2)

إن المرتد مكلف محتاج، وكل من هو كذلك يجب عدم زوال ملكه عنه، حيث لا يمكنه القيام بما كلف به إلا ببقاء ملكه، فيبقى ملكه ضرورة التمكين. (3)

(3) العناية على الهداية 6/ 73 وما بعدها، تبين الحقائق 3/ 285 وما بعدها، البحر الرائق 5/ 140، حاشية ابن عابدين 4/ 247.

(1) العناية 6/ 74، بدائع الصنائع 7/ 136، تبين الحقائق 3/ 285.

(2) بدائع الصنائع 7/ 136، تبين الحقائق 3/ 285.

(3) تبين الحقائق 3/ 285.

قياس المرتد على المحكوم عليه بالإعدام بجامع أن كلا منهما مكلف مباح الدم. (4)

هذا: وبعد اتفاق أبو يوسف ومحمد: على صحة تصرف المرتد وعدم الحجر عليه، اختلفا في صفة هذا التصرف، هل يأخذ حكم تصرف الصحيح، أو المريض، وذلك على النحو الآتي:

ذهب أبو يوسف: إلى أن تصرف المرتد يأخذ حكم تصرف الصحيح. واستدل لذلك: بأن المرتد بيده أن يختار الإسلام، فهو متمكن من دفع الهلاك عن نفسه، وذلك بالرجوع إلى الإسلام، والمريض لا يمكنه دفع المرض عن نفسه، فلا تشابه بين المرتد والمريض.

وذهب محمد: إلى أن تصرف المرتد يأخذ حكم تصرف المريض مرض الموت. واستدل لذلك: بأن المرتد أشرف على الهلاك بردته، حيث إنه يقتل لردته، فأشبهه المريض مرض الموت، بل هو أسوأ حالا من مريض مرض الموت. (1)

أما بالنسبة للمرأة المرتدة: فإنه لا يحجر على تصرفاتها، فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف، فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع، حيث إنها لا تُقتل بردتها عن الإسلام، وبالتالي لم تكن

(4) العناية على الهداية 6/ 74.

(1) بدائع الصنائع 7/ 136، شرح فتح القدير 6/ 75.

ردتها سببا لزوال ملكها عن أموالها، فتجوز تصرفاتها ولا يحجر عليها فيها. (4)

الفصل العاشر

الحجر على تصرفات الزوجة

ذهب فقهاء الحنفية: إلى أنه لا حجر على المرأة في تصرفها في أموالها بالتبرع أو المعاوضة، ولا تحتاج في ذلك إلى إذن زوجها. (1) واستدلوا لذلك بالكتاب: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ (2) وجه الدلالة من الآية: أن هذا النص ظاهر في فك الحجر وإطلاق التصرف لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

والسنة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) (6) وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ أمر النساء بالصدقة، ولم يسأل ولم يستفصل، فلو كان تصرفهن لا ينفذ إلا بإذن أزواجهن لما أمرهن بالصدقة، كما أنه ﷺ لم يشترط التصرف في مقدار معين، فهو دليل على جواز

(4) بدائع الصنائع 137/7، تبين الحقائق 5/ 440 وما بعدها.

(1) الحجة، لمحمد بن الحسن الشيباني 5/ 169.

(2) سورة النساء: من الآية: 6.

(6) صحيح البخاري 2/ 533، صحيح مسلم 2/ 694.

تصدق الزوجة بدون إذن زوجها وعلى صحة تبرعها بدون تحديد مقدار معين في ذلك.

والمعقول: فإن من وجب دفع ماله إليه لرشده، جاز تصرفه فيه من غير إذن من أحد، فهي كالغلام الذكر إذا رشد، فإن تصرفه لا يتوقف على إذن من أحد، والمرأة من أهل التصرف، ولا حق للزوج في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف في جميعه.

فهرس الموضوعات

م	الموضوع	ص
	كتاب أدب القاضي	4
	فصل في الحبس	48
	كتاب الدعوى	84
	كتاب الصلح	124
	كتاب الجنایات	145
	كتاب الشهادات	185
	كتاب الإقرار	291
	كتاب الرهن.	304
	كتاب الإكراه.	326
	كتاب الحجر.	386
	فهرس الموضوعات	424